

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-1]인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음1) 甲이 제기하고자 하는 `예방적 금지소송`이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 관련하여 우리 판례의 입장을 서술하고, 만약 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명하라.》

<문제1.2의 물음1> 인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 자신의 주거지 인근에 화장장 건립계획이 확정·발령되기 전에 그 시행을 금지하여 달라는 소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지> 여부와 <허용되지 않는 경우 甲이 취할 수 있는 다른 권리구제수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명한다.

II. 예방적 금지소송의 허용 여부

1. 예방적 금지소송의 의의

- 예방적 금지소송이란 행정청이 장래 일정한 처분을 할 것이 예상되는 경우에 미리 법원에 그 처분을 하여서는 안 된다는 명령을 구하는 소송을 말한다. 이는 행정권의 남용으로 인한 회복하기 어려운 손해를 미연에 방지하고자 하는 취지에서 논의된다.

2. 학설의 태도

(1) 긍정설

- "행정소송법 제4조"의 항고소송 열거를 예시적인 것으로 보아, 국민의 재판청구권을 실질적으로 보장하고, 실효성 있는 권리구제를 위해 명문의 규정이 없더라도 예방적 금지소송을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 부정설

- "행정소송법 제4조"는 항고소송의 종류를 한정적으로 규정한 것이며, 예방적 금지소송을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하여 권력분립 원칙에 반하게 된다는 견해이다.

3. 판례의 입장

- 우리 "대법원"은 예방적 금지소송에 대하여 매우 엄격한 부정적 입장을 견지하고 있다. "판례"는 행정소송법상 항고소송의 종류는 법에 명시된 것에 한정된다고 보며, 행정청의 처분이 내려지기 전에 미리 그 처분의 금지를 구하는 소송은 현행법상 허용되지 않는다고 판시한다.

(1) 판결의 주요 논거

- "대법원"은 행정처분에 대한 사법심사는 행정청이 처분을 발령한 이후에 그 적법성을 판단하는 것이 원칙이라고 본다. 만약, 처분이 발령되기도 전에 법원이 이를 금지한다면 행정권의 고유한 권한을 사전에 제약하게 되어 권력분립의 원칙상 부당하다는 점을 강조한다.

(2) 구체적인 사례

- "판례"는 화장장 건립 반대나 건축 허가 금지 청구 등과 같이 장래의 처분을 미리 저지하려는 청구에 대하여 소의 부적법을 이유로 각하판결을 내리고 있다. 즉, 주관적 권리구제의 필요성보다 행정의 자율성과 사법부의 사후 심사 원칙을 우선시키고 있다.

III. 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형 및 구제 수단

1. 처분 발령 이후의 항고소송

- 예방적 금지소송이 허용되지 않으므로 甲은 행정청의 화장장 건립 계획이 대외적으로 확정되어 처분의 형태로 발령될 때까지 기다려야 한다.

(1) 취소소송

- A시장의 화장장 건립 결정이 처분성을 갖추어 발령되면, 甲은 해당 처분이 자신의 법률상 이익을 침해함을 근거로 처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다. 이는 "행정소송법 제4조 제1호"에 따른 가장 전형적인 항고소송이다.

(2) 무효확인소송

- 만약, 해당 건립 계획 처분에 중대하고 명백한 하자가 존재하여 그 효력이 처음부터 발생하지 않았다고 판단되는 경우에는 무효확인소송을 제기하여 그 효력 유무를 다툴 수 있다.

2. 가구제 수단의 활용(집행정지)

- 사후적 소송만으로는 이미 진행된 공사 등으로 인해 甲의 권익이 침해될 위험이 크다. 따라서 본안 소송 제기과 동시에 집행정지를 신청하여 실효성을 확보할 수 있다.

(1) 집행정지의 요건

- 甲은 취소소송 또는 무효확인소송을 제기한 상태에서, 처분의 집행이나 효력의 정지가 없으면 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고, 긴급한 필요가 있다는 점을 소명해야 한다.

(2) 집행정지의 효과

- 법원이 甲의 신청을 인용하여 집행정지 결정을 내리면, 본안 판결 시까지 화장장 건립 계획의 효력이나 그에 따른 공사 집행이 일시적으로 정지된다. 이는 예방적 금지소송의 실질적인 대안 역할을 한다.

IV. 사안의 적용

- 사안에서 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 "판례"에 따르면 현행 행정소송법상 허용되지 않는다. 따라서 甲이 계획 단계에서 제기하는 금지소송은 각하될 가능성이 크다.

1. 소송의 부적법성

- 甲의 청구는 행정청의 1차적 판단권을 침해하고, 법적 근거가 없는 소송 유형이므로 “판례”상 부적법하다.

2. 대안적 권리구제

- 甲은 화장장 건립 계획이 처분으로서 발령된 직후에 취소소송을 제기해야 한다. 또한, 처분의 효력을 즉시 멈추기 위해 집행정지를 신청함으로써 건립 중단이라는 실질적인 목적을 달성할 수 있다.

3. 관련 이익의 검토

- 甲은 인근 주민으로서 환경상 이익 등 법률상 이익을 가지는 제3자에 해당하므로 원고적격을 인정받는 데 어려움이 없을 것이며, 처분 발령 후 적법한 기간 내에 소를 제기해야 한다.

V. 결론

- 결론적으로 甲이 제기하고자 하는 예방적 금지소송은 우리 “판례”상 허용되지 않는다. 甲은 향후 행정청이 건립 계획을 처분으로 발령하면 그에 대하여 취소소송을 제기하고, 이와 병행하여 집행정지 신청을 함으로써 권리를 구제받아야 한다. 이러한 “판례”의 태도는 행정의 능동적 수행을 보장하기 위한 것이나, 국민의 권익 보호를 위해 향후 행정소송법 개정 등을 통해 예방적 금지소송의 도입을 검토할 필요가 있다는 점이 중요하게 다루어진다.

<제01장 행정소송의 일반론.제02절 행정소송의 유형>

[예상][1.02-2]공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

《【문제1.2】

<사례>

A시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형(항고소송 vs 당사자소송)을 판례의 입장에 근거하여 구분하고, 그 이유를 기술하라.》

<문제1.2의 물음2> 공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

I. 문제의 제기

- 사안에서 공무원 乙은 자신에게 내려진 정직 처분이 무효임을 전제로 하여, 이미 발생하였으나 지급되지 않은 보수의 지급을 청구하는 소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <乙이 제기해야 하는 소송이 처분등의 취소나 무효확인을 구하는 항고소송인지, 아니면 공법상 법률관계에 관한 다툼을 다루는 당사자소송인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 공무원의 보수청구권의 법적 성질과 관련한 판례의 입장을 토대로 소송 유형을 구분하고 그 이유를 구체적으로 기술한다.

II. 보수 청구 소송의 유형 검토

1. 항고소송과 당사자소송의 구분

(1) 항고소송

- 행정청의 처분등 공법적 권력 행사의 취소나 무효확인을 구하는 소송이다. 행정청의 처분이 있어야만 비로소 구체적인 권리가 발생하는 경우라면, 해당 처분을 다루는 항고소송의 형태를 띠게 된다.

(2) 당사자소송

- 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 공법상 신분이나 계약, 또는 법령의 규정에 의하여 당연히 발생하는 권리라면 당사자소송의 대상이 된다.

2. 판례의 입장

(1) 보수청구권 발생 근거에 따른 구분

- 우리 “판례”는 공무원의 보수청구권이 법령의 규정에 의하여 직접 그 존부나 범위가 확정되는 경우에는 행정청의 별도 처분을 거칠 필요 없이 직접 당사자소송으로 그 지급을 구할 수 있다는 입장이다. 즉, 보수 지급 여부가 행정청의 재량이나 처분에 달린 것이 아니라 법령에 의해 일률적으로 정해져 있다면 이는 처분에 대한 다툼이 아닌 법률관계 자체에 대한 다툼으로 본다.

(2) 징계처분 무효와 보수청구권

- “판례”에 의하면 정직 처분과 같은 징계처분이 무효인 경우, 그 처분은 처음부터 효력이 없었던 것이 되므로 공무원의 신분 및 법령상 보수청구권은 중단 없이 유지된다. 따라서 무효인 처분을 원인으로 하여 이미 발생한 미지급 보수를 청구하는 것은 공법상 법률관계에 관한 다툼으로서 당사자소송의 영역에 속한다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형의 결정 : 당사자소송

- 乙은 정직 처분의 무효를 전제로 보수 지급을 청구하고 있다. 공무원의 보수는 공무원보수규정 등 관련 법령에 의해 지급 조건과 범위가 확정되어 있다. 정직 처분이 당연무효라면 乙은 법령상 당연히 해당 기간의 보수청구권을 보유하게 되므로, 이는 행정청의 새로운 보수 지급 처분을 기다릴 필요 없이 국가나 지방자치단체를 상대로 한 당사자소송으로 제기해야 한다.

2. 항고소송이 부적절한 이유

- 乙이 정직 처분 자체의 효력을 없애고자 한다면 무효확인소송(항고소송)을 제기할 수 있으나, 본 사안의 직접적인 목적은 미지급된 보수의 지급이라는 구체적인 금전적 청구권의 행사이다. 보수 지급 행위는 행정청의 공권력 행사인 처분이 아니라 법령상 의무 이행인 공법상 법률관계의 이행에 해당하므로 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송의 대상이 될 수 없다.

3. 소송의 구조 및 선결문제

- 乙은 보수 지급 의무가 있는 주체를 피고로 설정하여 당사자소송을 제기하여야 한다. 이 경우 수소법원은 해당 당사자소송의 선결문제로서 정직 처분의 무효 여부를 스스로 판단할 수 있으며, 무효라고 판단될 경우 피고에게 보수 지급을 명하는 판결을 내리게 된다.

IV. 결론

- 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송 유형은 당사자소송이다. “판례”는 법령상 당연히 발생하는 공무원의 보수청구권을 공법상 법률관계에 관한 권리로 판시하고 있다. 따라서 행정청의 별도 처분 없이도 당사자소송을 통해 직접 지급 청구가 가능하다. 이는 행정소송의 효율적인 분류와 국민의 실질적인 금전적 권리 구제를 도모하는 “판례”의 확립된 태도에 부합한다.

<제01장 행정소송의 일반론.제03절 행정소송의 한계>

[기출][2022-1-2]관할행정청의 처분 전에 제3자가 예방적으로 처분 금지를 구하는 소송의 허용 여부

《[문제1] 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 '이 사건 처분'이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 위 사안에서 丙이 토석채취허가신청을 하였으나, 乙이 이 사건 처분을 하기 전이라면, 甲은 乙이 이 사건 처분을 하여서는 안 된다는 소의 제기가 허용되는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 관할행정청의 처분 전에 제3자가 예방적으로 처분 금지를 구하는 소송의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 토석채취허가를 신청하였으나 아직 허가처분이 이루어지지 않은 상태에서, 과수원을 운영하는 甲이 장차 이루어질 토석채취허가처분을 하여서는 안 된다는 취지의 소를 제기하고자 한다. 쟁점으로 <행정청이 아직 처분을 하지 않은 단계에서 장래의 처분을 금지하는 예방적 금지소송의 제기가 현행 행정소송법상 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 위 사안에서 丙이 토석채취허가신청을 하였으나, 乙이 이 사건 처분을 하기 전이라면, 甲은 乙이 이 사건 처분을 하여서는 안 된다는 소의 제기가 허용되는가를 설명한다.

II. 소의 대상적격

1. 취소소송의 대상

- "행정소송법 제4조"는 취소소송을 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송으로 규정하고 있다. 따라서 취소소송의 전제가 되는 소송대상은 반드시 행정청의 처분등이 존재하여야 한다.

2. 처분 개념

- "대법원"은 처분을 행정청의 공권력 행사 또는 그 거부, 기타 이에 준하는 행위로서 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행위라고 정의한다. 따라서 단순한 신청이나 행정청 내부의 검토는 처분이 아니며, 외부에 대해 직접적 법률효과를 미치지 않는다.

III. 예방적 금지 소송의 허용 여부

1. 예방적 금지 소송의 의의

- 예방적 금지 소송이란 장래 행정청이 행할지도 모르는 처분을 미리 금지해 달라고 청구하는 소송을 말한다. 이는 아직 구체화되지 않은 행정작용을 대상으로 한다는 점에서, 행정쟁송의 기본 구조인 사후적 구제구조와 대비된다.

2. 예방적 금지 소송의 원칙적 부정

- "판례"와 다수설은 예방적 금지 소송을 인정하지 않는다. 그 근거는 다음과 같다. ❶ 행정소송법상 취소소송은 이미 존재하는 처분을 대상으로 한다는 점에서 법문상 근거가 없다. ❷ 행정청의 장래 행위를 미리 법원이 통제하는 것은 행정재량을 과도하게 제약하여 권력분립원리에 반한다. ❸ 실제 처분이 발령되지 않을 수도 있음에도 미리 소송을 허용하는 것은 사법자원의 낭비를 초래한다.

3. 예외적 허용 필요성 논의

- 그러나 환경권·건강권과 같은 기본권 침해는 일단 발생하면 회복이 극히 곤란하다. 따라서 사후적 구제만으로는 실효적 권리보호가 곤란한 경우 예방적 구제의 필요성이 인정될 수 있다. 일부 학설은 헌법상 권리보호 요청을 근거로 금지소송을 예외적으로 허용해야 한다고 주장한다.

4. 판례의 태도

- "대법원"은 행정소송으로서 금지소송을 인정한 사례는 없다. 다만, "헌법재판소"는 원자력발전소 부지사건 등에서 예방적 구제 필요성을 부분적으로 긍정하였다. 그러나 이는 행정소송이 아니라 헌법소원심판의 영역에서이다. 따라서 현행 행정소송법 해석상 금지소송의 허용은 극히 제한적이다.

5. 대체적 구제수단

- 금지소송이 인정되지 않는 대신, ❶ 행정절차법상 의견제출·청문 참여, ❷ 처분 발령 후 집행정지 신청, ❸ 헌법소원 등 다른 제도적 장치가 존재한다. 따라서 법제는 금지소송을 부정하면서도 다른 경로를 통해 예방적 구제의 기능을 보완하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송 형태 검토

- 甲은 '군수 乙이 허가처분을 하여서는 아니 된다'는 취지로 소송을 제기하고자 한다. 그러나 이는 허가처분이 발령되기 전 단계의 예방적 금지소송에 해당한다. 행정소송법상 소송의 대상으로서 처분이 존재하지 않으므로, 원칙적으로 부적법하다.

2. 예외적 허용 가능성

- 토석채취로 인한 비산먼지 발생은 과수원 농작물의 오염, 잼 제품의 품질 저하, 영농법인의 영업상 신뢰 손상 등 회복하기 어려운 피해를 초래할 수 있다. 따라서 甲의 입장에서 예방적 구제의 필요성이 강력하다고 주장할 수 있다. 그러나 현행 행정소송 구조와 "판례"의 태도에 비추어 볼 때, 금지소송을 허용할 법적 근거는 부족하다.

3. 가능한 구제수단

- 甲은 허가처분이 실제 발령되면 즉시 취소소송을 제기하고, 동시에 집행정지를 신청하여 허가의 효력을 정지시키는 방식으로 권리보호를 도모할 수 있다. 또한, 허가절차 진행 중에는 행정절차법에 따른 의견제출·청문을 통해 적극적으로 자신의 이해관계를 주장할 수 있다.

V. 결론

- 본 사안에서 甲이 제기하고자 하는 乙은 토석채취허가처분을 하여서는 안 된다는 소송은, 허가처분이 발령되기 이전 단계에서 제기되는 예방적 금지소송에 해당한다. 그러나, 행정소송법상 취소소송은 이미 존재하는 처분을 대상으로 함을 전제로 하므로, 이러한 예방적 금지소송은 원칙적으로 허용되지 않는다. 따라서 甲은 허가처분이 실제로 발령된 이후 취소소송을 제기해야 하며, 처분 전 단계에서는 행정절차 참여, 처분 후에는 집행정지 신청 등을 통해 실질적인 권리구제를 도모해야 한다. 결국 본 사안에서 甲의 소송은 허용되지 않는다고 보아야 한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-1]취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 `폐기물 관리법` 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술하라.》

<문제2.1의 물음1> 취소소송 소송요건의 법적 성질 및 법원의 직권조사 원칙과 예외

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사업장 폐쇄명령의 취소를 구하는 취소소송을 제기하고자 하고, 법원은 소송을 심리하는 과정에서 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지 등 소송요건의 구비 여부를 문제 삼고 있다. 쟁점으로 <취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질과 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위하여 직권으로 조사할 수 있는 사항의 원칙 및 예외>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송의 소송요건이 갖는 법적 성질에 대해 설명하고, 법원이 소송요건의 구비 여부를 확인하기 위해 취하는 직권조사 사항의 원칙과 예외에 대해 서술한다.

II. 취소소송 소송요건의 법적 성질

1. 소송의 적법요건

- 취소소송의 소송요건은 법원이 본안 심리에 들어가기 위해 반드시 갖추어야 할 전제조건이다. 이러한 소송요건을 갖추지 못한 소 제기는 부적법한 것이 되어 본안 판결(인용 또는 기각)을 내릴 수 없으며, 법원은 판결으로써 소를 각하해야 한다.

2. 재판상의 요건

- 소송요건은 소 제기 당시는 물론 변론 종결 시까지 계속해서 존재해야 한다. 만약, 소 제기 당시에는 요건을 갖추었더라도 소송 도중에 요건이 흠결되게 되면 법원은 소를 각하해야 한다. 반대로 소 제기 당시에는 흠결이 있었으나 각하되지 않고, 본안 심리가 진행되었다면 변론 종결 전까지 흠결이 치유되면 적법한 소가 된다.

3. 강행규정성

- 행정소송법상의 소송요건은 공익적 견지에서 정해진 강행규정이다. 따라서 당사자 사이의 합의로 소송요건의 흠결을 정당화하거나 면제할 수 없으며, 법원은 당사자의 주장 여부와 상관없이 이를 엄격히 심사해야 한다.

III. 직권조사 사항의 원칙과 예외

1. 직권조사의 원칙

(1) 의의

- 소송요건의 존부는 법원의 직권조사 사항에 해당한다. 이는 소송의 개시와 범위는 당사자의 의사에 맡기지만, 일단 개시된 소송이 적법한지 여부에 대한 판단은 사법 정의의 실현과 공익 보호를 위해 법원의 고유한 권한이자 의무로 보는 것이다.

(2) 법원의 의무

- 법원은 당사자가 소송요건의 흠결을 주장하지 않더라도 스스로 이를 조사하여 확인해야 할 의무가 있다. 만약, 피고인 행정청이 소송요건에 대해 아무런 이의를 제기하지 않더라도 법원은 대상적격이나 제소기간 등의 준수 여부를 독립적으로 심사해야 한다.

(3) 증명책임의 소재

- 소송요건의 구비 사실에 대한 증명책임은 원칙적으로 소를 제기한 원고에게 있다. 원고는 자신이 제기한 소가 적법함을 소명해야 하며, 법원이 직권으로 조사함에 있어 필요한 자료를 제출할 협조 의무를 진다.

2. 직권탐지주의의 예외적 적용

(1) 행정소송법 제26조와의 관계

- "행정소송법 제26조"는 법원이 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대해서도 판단할 수 있다"고 규정하고 있다. 이는 "민사소송법"상의 변론주의를 보완하여 행정처분의 적법성 확보라는 공익을 달성하기 위함이다.

(2) 직권조사와 직권탐지의 차이

- 직권조사는 판단의 기초가 되는 자료가 제출되어 있을 때 법원이 이를 스스로 검토하는 것을 의미하며, 직권탐지는 법원이 직접 증거를 수집하고 당사자가 주장하지 않은 사실까지 찾아내는 적극적인 행위를 포함한다. "판례"는 소송요건에 관하여 사실관계의 존부가 불분명한 경우 법원이 적극적으로 이를 탐지하여 확인할 수 있다는 태도를 취한다.

(3) 보정 명령

- 법원은 소송요건의 흠결이 발견되었으나 그것이 보정 가능한 성질의 것인 경우, 즉시 각하하기보다는 원고에게 보정을 명하여 국민의 재판청구권을 실효적으로 보장해야 한다. 예를 들어 피고를 잘못 지정한 경우 피고경정 등을 유도하는 것이 이에 해당한다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송요건 검토

- 법원은 甲이 제기한 취소소송에서 A시장의 사업장 폐쇄 명령이 행정소송법상 처분에 해당하는지(대상적격), 甲이 해당 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지(원고적격), 그리고 제소기간 내에 소를 제기했는지 등을 직권으로 조사해야 한다.

2. 법원의 직권조사 수행

- 본 사안에서 법원은 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 가졌으므로, 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 관련 법령과 사실관계를 조사하여 대상적격 유무를 판단해야 한다. 만약, 사업장 폐쇄 명령이 폐기물 관리법에 근거한 구체적 사실에 대한 법집행으로서 공권력의 행사임이 확인된다면 처분성이 인정될 것이다.

V. 결론

- 취소소송의 소송요건은 소의 적법 여부를 결정하는 강행규정적 성격을 가지며, 법원의 직권조사 사항이다. 법원은 당사자의 항변 유무와 관계없이 소송요건의 구비 여부를 확인해야 하며, 필요시 직권으로 자료를 탐지할 수 있다. 甲의 소송에서 법원은 사업장 폐쇄 명령의 처분성을 직권으로 심사하여 소의 적법성을 먼저 가려낸 후 본안 심리에 임해야 한다. 이러한 법리는 행정소송이 단순히 개인의 이익 보호를 넘어 행정의 적법성 통제라는 공익적 기능을 수행하고 있음을 뒷받침한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제01절 소송요건의 일반론>

[예상][2.01-2]권고조치를 대상으로 한 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

《【문제2.1】

<사례>

A시장은 인근 주민들의 민원을 이유로 관내에서 폐기물 처리업을 운영하는 甲에게 `폐기물 관리법` 위반을 사유로 사업장 폐쇄 명령을 내렸다. 甲은 이 처분이 재량권의 범위를 일탈·남용하여 위법하다고 주장하며 A시장을 상대로 취소소송을 제기하고자 한다. 한편, A시 관내 다른 구역에서 영업하는 乙은 행정청의 처분은 아니나 사실상의 행정지도에 불과한 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 또한 법원은 甲이 제기한 소송을 심리하던 중 해당 사건이 행정소송의 대상이 되는지에 대한 의문을 갖게 되었다.

(물음2) 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 소송요건으로서 어떠한 의미를 갖는지 기술하고, 만약 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 내려야 하는 판결의 종류와 그 사유를 설명하라.》

<문제2.1의 물음2> 권고조치 대상 취소소송에서 대상적격의 의미 및 소송요건 결여 시 판결의 종류와 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청의 처분이 아닌 사실상의 행정지도인 권고 조치로 인해 영업상 손실이 발생하였다고 주장하며 이에 대한 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이때 <乙이 제기하려는 소송에서 대상적격의 존부가 어떠한 법적 의미를 갖는지> 검토가 필요하다. 또한 <취소소송의 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우 법원이 어떠한 판결을 내려야 하는지>와 그 사유를 명확히 규명해야 한다. 이하에서는 대상적격의 의의와 소송요건 흠결 시의 판결인 각하판결에 대해 설명한다.

II. 대상적격의 의미와 乙의 소송에서의 중요성

1. 대상적격의 의의

- 대상적격이란 행정소송의 대상이 될 수 있는 적절한 자격을 의미한다. "행정소송법 제2조 제1항 제1호" 및 "제19조"에 따라 취소소송의 대상은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용인 처분등이어야 한다.

2. 乙의 소송에서 대상적격의 의미

(1) 소송의 적법성 판단 기준

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 원칙적으로 행정지도에 해당한다. 행정지도는 상대방의 임의적 협력을 전제로 하는 비권력적 사실행위로서, 국민의 권리와 의무에 직접적인 법적 변화를 일으키지 않으므로 처분성이 부정되는 것이 원칙이다. 따라서 乙의 소송에서 대상적격의 존부는 해당 소송이 본안 심리로 나아갈 수 있는지 여부를 결정하는 핵심적인 관문이 된다.

(2) 항고소송의 범위 확정

- 대상적격은 사법권에 의한 행정통제의 범위를 확정하는 기능을 한다. 권고 조치가 예외적으로 처분성을 인정받지 못한다면, 이는 행정소송의 대상이 될 수 없음을 의미하며 사법부가 개입할 수 없는 영역으로 남게 된다.

III. 소송요건 결여 시의 판결 유형 : 각하판결

1. 각하판결의 의의

- 각하판결이란 소송요건이 흠결되어 소송이 부적법한 경우, 본안(처분의 위법성 여부)에 대하여 판단하지 않고 소송을 종결시키는 판결을 말한다. 이는 소송의 개시를 거절하는 소송판결의 일종이다.

2. 각하판결의 사유

(1) 소송요건의 불비

- 취소소송이 적법하기 위해 갖추어야 할 대상적격, 원고적격, 협의의 소의, 피고적격, 제소기간, 행정심판 전치주의 등의 요건 중 어느 하나라도 결여된 경우이다. 사안의 乙처럼 처분성이 없는 행정지도를 대상으로 소를 제기한 경우 대상적격 흠결이 각하 사유가 된다.

(2) 보정의 불가능 또는 불이행

- 흠결된 소송요건이 보정할 수 없는 것이거나, 법원의 보정 명령에도 불구하고 원고가 이를 보정하지 않은 경우 법원은 각하판결을 내린다. 행정지도를 대상으로 한 소송은 처분성이라는 본질적 요건의 흠결로 보정이 불가능한 경우가 많다.

IV. 사안의 적용

1. 乙이 제기하려는 소송의 대상적격 검토

- 乙이 다투고자 하는 권고 조치는 사례에서 사실상의 행정지도에 불과한 것으로 명시되어 있다. "판례"에 따르면 행정지도는 공권력의 행사가 아니므로 취소소송의 대상인 처분에 해당하지 않는다. 따라서 乙의 소송은 대상적격이라는 소송요건을 결여하고 있다.

2. 법원이 내려야 하는 판결 : 각하판결

- 법원은 乙이 제기한 소송을 심리함에 있어 직권조사 사항인 대상적격 유무를 먼저 확인해야 한다. 조사 결과 권고 조치의 처분성이 부정되므로, 법원은 본안 심리인 영업상 손실의 위법성 여부를 판단할 필요 없이 소송법적 판단만으로 소를 각하해야 한다.

3. 각하판결의 사유

- 乙의 소송은 "행정소송법 제2조" 및 "제19조"가 정한 처분을 대상으로 하지 않았으므로 대상적격을 갖추지 못하였다. 이러한 소송요건의 흠결은 강행규정 위반으로 부적법한 소 제기해 해당하며, 사법 자원의 효율적 배분과 행정권의 독립성 존중을 위해 법원은 각하판결로써 소송을 종결시켜야 한다.

V. 결론

- 乙이 제기하려는 소송에서 대상적격은 소의 적법성을 결정짓는 필수적인 소송요건이다. 행정지도에 불과한 권고 조치는 처분성이 부정되므로 乙의 소송은 대상적격을 결여한 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이러한 소송요건의 흠결을 이유로 본안 판단을 거절하는 각하판결을 내려야 한다. 이러한 법리는 국민의 권리구제와 행정작용의 처분성 사이의 한계를 명확히 함으로써 행정소송의 적법한 범위를 확정하는 데 기여한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협약의 소의 이익)>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제01절 행정심판전치주의>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제03절 관할법원>

[기출][2009-1]취소소송의 제기요건(소송요건)(대상적격, 원고적격, 피고적격, 소의 이익, 제소기간, 행정심판전치주의, 관할법원)

《【문제1】 취소소송의 제기요건(소송요건)에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 취소소송의 제기요건(소송요건)(대상적격, 원고적격, 피고적격, 소의 이익, 제소기간, 행정심판전치주의, 관할법원)

I. 문제 제기

- 본 문제는 행정소송법상 가장 전형적인 항고소송인 <취소소송의 적법성 요건(소송요건)>에 대하여 상세히 논하는 데 있다. 취소소송이 적법하게 제기되어 본안 심리로 나아가기 위해서는 법이 정한 일정한 요건들을 모두 충족해야 하며, 이러한 소송요건의 구비 여부는 법원의 직권조사 사항으로, 흠결 시에는 소가 부적법 각하된다. 이하에서는 취소소송의 주요 소송요건들을 법적 근거와 학설 및 판례의 태도를 중심으로 구체적으로 논한다.

II. 소송요건의 종류 및 내용

1. 대상적격

(1) 의의

- 대상적격은 취소소송의 대상이 되는 행정작용의 자격에 관한 요건으로, "행정소송법 제19조 본문"에 따라 처분등만이 취소소송의 대상이 될 수 있다. 처분등의 정의는 "동법 제2조 제1항 제1호"에 규정되어 있다.

(2) 판단 기준

- 취소소송의 대상이 되는 처분이 되기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

① 행정청의 행위

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청은 국가나 공공단체의 의사를 결정하여 외부에 표시하는 기관을 의미한다.

② 구체적 사실의 법집행으로서 공권력 행사 또는 거부

- 처분은 구체적인 사건에 대하여 법률을 집행하는 행위여야 하며, 그 성격은 공권력의 행사이거나 이에 준하는 행정작용이어야 한다. 거부행위의 처분성을 인정하기 위해서는 신청인에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되어야 한다. 신청권이 없는 단순한 요청에 대한 거부는 원칙적으로 처분성이 부정된다.

③ 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래

- 가장 중요한 기준으로서, 그 행위가 국민의 법률상 지위(권리 또는 의무)에 직접적으로 변동을 초래해야 한다. 이 요건을 충족하지 못하는 내부 행위, 사실 행위 등은 원칙적으로 처분성이 부정된다.

(3) 판례의 경향

- "판례"는 국민의 권리구제 확대를 위해 처분 개념을 탄력적으로 해석한다. 법규명령 형식의 행정규칙이나 행정계획의 경우에도 별도의 집행 행위 없이 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 때에는 처분성을 인정하는 경향을 보인다(예 : 고시나 공고). 또한, 거부행위의 처분성 인정 요건인 신청권의 인정 범위도 확대하는 추세이다.

2. 원고적격

(1) 의의

- 원고적격은 소송을 제기하여 판결을 받을 수 있는 자격, 즉 소송을 통해 침해된 자신의 권리 또는 법률상 이익의 구제를 받을 자격을 의미하며, "행정소송법 제12조"에 규정되어 있다.

(2) 법률상 이익의 의미

- 원고적격이 인정되는 법률상 이익이란 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의해 보호되는 개별적, 구체적, 직접적인 이익을 의미한다. 단순한 사실상의 이익이나 경제적인 이해관계는 포함되지 않는다.

① 처분의 직접 상대방

- 처분의 직접 상대방은 해당 처분에 의해 권리 또는 의무에 직접적인 변동을 받으므로, 그 처분의 위법성을 다룰 법률상 이익이 추정되어 원고적격이 인정되는 것이 일반적이다.

② 제3자 (인인소송, 경원자소송 등)

- 처분의 직접 상대방이 아닌 제3자의 경우에도 그 처분으로 인해 법률상 이익을 침해당한 경우 원고적격이 인정될 수 있다. (i) 경원자소송 : 복수 신청인 중 한 사람에게만 면허 등 수익적 처분을 발령함으로써 탈락한 다른 신청인의 이익을 침해한 경우, 탈락한 신청인은 인용처분을 받은 자의 처분의 취소를 구할 원고적격이 있다(특허의 대립관계). (ii) 인인소송 : 처분이 제3자에게 미치는 영향이 당해 처분의 근거 법령이 보호하는 이익에 해당할 경우 원고적격이 인정된다(예 : 환경영향평가 대상 지역 주민의 환경상 이익).

(3) 판례의 경향

- "판례"는 원고적격 인정 범위를 점차 확대하여, 환경영향평가법 등 공익 관련 법규에서 규정하는 공익 속의 개인적 이익이나 법률상 보호할 가치가 있는 이익까지 법률상 이익에 포함시키는 적극적인 추세를 보인다.

3. 피고적격

(1) 의의

- 피고적격은 소송에서 피고가 될 수 있는 자격에 관한 요건으로, "행정소송법 제13조"에 규정되어 있다. 취소소송은 해당 처분을 행한 행정청을 피고로 한다.

(2) 판단 기준

① 대외적으로 처분 명의를 표시한 행정청

- 처분을 행한 행정주체(국가나 공공단체)가 아닌, 대외적으로 자신의 명의를 표시하여 처분을 행한 행정청이 피고가 된다. 이는 소송 수행의 편의와 재처분 의무의 이행 확보를 위한 것이다.

② 소속 기관의 장

- 국가나 공공단체의 기관이 아닌 소속 기관의 장이 처분 명의를 표시한 경우에도, 그 처분을 한 행정청을 피고로 한다.

4. 협의의 소익 (권리보호의 필요)

(1) 의의

- 협의의 소익은 소송을 통해 원고가 주장하는 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 실익이 있는냐에 관한 요건이다. 설령 처분이 위법하더라도, 소송을 통해 처분을 취소할 필요가 없거나 취소할 실익이 없는 경우 소익이 부정된다. ("행정소송법 제12조")

(2) 판단 기준

① 처분의 효력 소멸

- 취소소송 중 해당 처분의 효력이 소멸하여 처분 취소의 목적이 달성된 경우 원칙적으로 소익이 부정된다. 다만, 취소판결을 통해 회복될 수 있는 법률상 이익이 남아 있는 경우에는 예외적으로 소익이 인정된다(예 : 가중 요건으로서의 전과가 남아 있는 경우).

② 동일한 처분의 반복 가능성 (반복 위험성)

- 처분의 효력이 소멸했더라도, 그 처분이 반복될 위험이 있고, 법적 견해의 통일을 얻는 것이 중요한 경우 ("행정소송법 제12조 단서"의 예시적 규정), 소익이 인정될 수 있다. 이는 반복 위험성이 있거나, 처분 취소로 인해 침해되는 공익보다 개인의 권리 구제 필요성이 큰 경우에 한정하여 엄격하게 적용된다.

5. 제소기간

(1) 의의

- 제소기간은 취소소송을 제기할 수 있는 법정 기간이며, 소송의 남용을 방지하고 행정법 관계의 조속한 확정을 위한 소송 요건이다. ("행정소송법 제20조")

(2) 기간

① 안 날부터 90일 이내

- 처분이 있음을 안 날(현실적으로 안 날)부터 90일 이내에 제기하여야 한다. 이때 안 날의 판단 기준은 행정처분서의 도달 여부뿐만 아니라, 일반인의 주의력으로 처분의 존재를 인식할 수 있었던 시점까지 포함하여 해석된다.

② 있는 날부터 1년 이내

- 처분이 있는 날(불특정 다수인을 위한 고시 등은 효력 발생일)부터 1년 이내에 제기하여야 한다. 이는 안 날 여부와 관계없이 적용되는 최장 제소기간이다.

③ 불변기간

- 위 기간은 법원이 그 기간을 연장하거나 단축할 수 없는 불변기간이며, 천재지변 등 당사자가 책임질 수 없는 사유가 있는 때에 한하여 추후 보완이 허용될 수 있다.

6. 행정심판 전치주의

(1) 의의

- 행정심판 전치주의란 행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거치도록 하는 제도이다. 이는 사법 구제 이전에 행정부 스스로 문제를 해결할 기회를 주어 행정의 자율성을 보장하려는 취지이다.

(2) 현행법상 원칙

- 현행 "행정소송법 제18조 제1항 본문"에 따라, 행정심판을 거치지 아니하고도 취소소송을 제기할 수 있는 임의적 전치주의가 원칙이다.

(3) 예외 (필요적 전치주의)

- "행정소송법 제18조 제1항 단서"에 따라 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 명시적인 규정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 필요적 전치주의가 적용된다. 이 경우 행정심판을 거치지 않고 제기된 소송은 부적법 각하된다.

7. 관할 법원

(1) 의의

- 관할 법원은 소송을 제기해야 할 법원의 종류와 위치에 관한 요건으로, 전속 관할의 성격을 가진다. ("행정소송법 제9조")

(2) 판단 기준

① 피고의 소재지

- 취소소송의 피고가 되는 행정청의 소재지를 관할하는 행정법원이 관할 법원이 된다.

② 고등법원 관할

- 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 제기할 수 있다.

III. 소송요건의 심리 및 효과

1. 소송요건의 심리

(1) 법원의 직권조사 사항

- 소송요건은 소송의 적법성 여부를 판단하는 요건으로서, 당사자의 주장에 구애받지 않고 법원이 직권으로 조사하여야 할 사항이다.

(2) 변론주의와 직권탐지주의

- 소송요건의 존부에 관한 사실 인정은 원칙적으로 당사자의 주장과 증거에 의존하는 변론주의가 적용된다. 그러나 법원은 소송요건에 대해서는 직권으로 사실을 조사할 수 있는 직권탐지주의를 보충적으로 적용할 수 있다.

2. 소송요건 흠결의 효과

(1) 각하판결

- 취소소송의 소송요건 중 어느 하나라도 결여된 경우에는 본안 심리로 나아가지 않고, 법원은 판결의 형식으로 소를 부적법하다고 하여 각하판결을 내린다.

(2) 재소금지 효력 없음

- 각하판결은 본안 판단을 포함하지 않으므로, 확정되어도 위법한 처분이 적법하게 되는 기판력이 발생하지 않는다. 또한, 소송 요건을 보완하여 다시 소송을 제기할 수 있으며, 재소금지 효력은 발생하지 않는다.

IV 결론

- 취소소송은 행정소송의 핵심적인 유형으로서, 그 적법성을 확보하고 국민의 권리 구제를 실효적으로 달성하기 위해서는 행정소송법이 정한 엄격한 소송요건을 충족해야 한다. 대상적격, 원고적격, 피고적격, 협의의 소익, 제소기간, 관할 등의 소송요건은 모두 법원의 직권조사 사항이며, 이들 요건을 정확히 파악하고 충족시키는 것이 소송 승패를 가르는 중요한 출발점이 된다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[기출][2011-1]면적축소 관련 법령에 대한 취소소송 및 환원처분을 구하는 소송의 적법성 여부

《【문제1】 관할 행정청은甲의 어업면허의 유효기간이 만료됨에 따라 동 어업면허의 연장을 허가하여 새로이 어업면허를 함에 있어서 관련법령에 따라 면허면적을 종전의 어업면허보다 축소하였다.甲이 자신의 재산권을 침해하는 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하거나, 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송을 제기하는 것이 적법하게 인정될 수 있는가? (50점)》

<문제1> 면적축소 관련 법령에 대한 취소소송 및 환원처분을 구하는 소송의 적법성 여부

I. 문제 제기

-사안에서 관할 행정청은甲의 어업면허 갱신 시 관련 법령에 따라 종전보다 축소된 면적으로 어업면허를 하였고, 이에甲은 면허면적 축소의 근거가 된 법령의 취소 또는 종전 면적으로의 환원을 구하는 행정소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <법령의 취소를 구하는 행정소송과 종전 면적으로의 환원을 구하는 행정소송이 현행 행정소송법상 허용되는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송 또는 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송이 적법하게 인정될 수 있는가를 설명한다.

II. 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송의 적법성

1. 취소소송의 대상 (처분등)

(1) 행정행위의 처분성

-“행정소송법 제19조”는 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하며, “행정소송법 제2조 제1항 제1호”에서는 처분등을 행정청이 행하는 구체적인 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용으로 규정한다.

(2) 법규명령의 처분성

① 원칙

-법규명령(법령)은 일반적·추상적 규율로서 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 초래하는 것이 아니므로, 원칙적으로 행정소송의 대상인 처분등에 해당하지 않는다. 법규명령은 그 자체로서는 행정소송의 대상이 되지 않고, 그 법규명령에 근거하여 행정청이 한 구체적인 처분이 비로소 소송의 대상이 된다.

② 예외 (집행행위 없이 직접 국민의 권리·의무를 규율하는 경우)

-일부 법규명령은 그 내용이 개별적이고 구체적이어서, 별도의 집행행위를 기다릴 필요 없이 그 자체로 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 경우가 있다. 이러한 법규명령은 예외적으로 처분성을 인정하여 항고소송의 대상이 될 수 있다는 것이 “판례”의 입장이다. (예 : 구 병역법시행령 조항의 특정 조항, 또는 고시·계획 등의 처분성 인정 등).

2. 법령에 대한 위헌·위법 심사 방식

-법령 자체에 위헌·위법이 있다고 주장하는 경우, 직접 법령의 취소를 구하는 소송이 아니라 다음과 같은 방법으로 다투어야 한다.

(1) 구체적 규범 통제

-해당 법령에 근거한 구체적인 처분(어업면허처분)에 대한 취소소송을 제기하면서, 그 소송에서 선결문제로서 해당 법령의 위헌·위법 여부를 다투는 방식이다. 법원은 처분의 위법성 판단을 위해 법령의 위헌·위법 여부를 심사할 수 있고, 법령이 위헌·위법하다고 판단되면 그 법령에 근거한 처분을 취소할 수 있다. 이것이 간접적으로 법령의 효력을 부인하는 방법이다.

(2) 헌법소원

-법령 자체로 인해 직접적으로 기본권이 침해되는 경우, 헌법재판소에 헌법소원(“헌법재판소법 제68조 제1항”)을 청구할 수 있다. 다만, 이 경우에도 원칙적으로 법령 자체에 대한 공권력 행사성이 인정되어야 하고, 다른 법률에 구제절차가 없는 경우에만 보충적으로 허용된다.

3. 사안의 적용

-甲이 취소를 청구하는 대상은 면허면적축소와 관련된 법령이다. 어업면허면적을 축소하도록 규정한 관련 법령은 일반적·추상적인 규범으로서, 그 자체로甲의 어업면허면적을 축소시키는 것이 아니라, 그 법령에 근거하여 이루어진 어업면허(갱신) 처분이甲의 면허면적을 축소시키는 직접적인 행위이다. 따라서 이 법령은 별도의 집행행위(어업면허처분)를 매개로 하여甲의 권리·의무에 영향을 미치므로, 그 자체로 처분성을 가진다고 보기 어렵다. 법령 자체에 대한 취소소송은 대상적격을 갖추지 못한다.

4. 검토

-甲이 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 직접 청구하는 행정소송은 적법하게 인정될 수 없다. 해당 법령은 그 자체로甲의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 처분에 해당하지 않으므로, 취소소송의 대상적격을 결여하기 때문이다.甲은 해당 법령에 근거한 어업면허 처분(면허면적축소가 포함된 처분)에 대한 취소소송을 제기하면서, 그 소송에서 법령의 위법성을 다투는 구체적 규범 통제 방식을 취해야 한다.

III. 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송의 적법성

1. 소의 종류 선택(취소소송인가, 의무이행소송인가?)

(1) 어업면허의 연장(갱신)과 법적 성격

-어업면허는 특정인에게 독점적으로 어업권을 부여하는 특허에 해당한다. 어업면허의 연장(갱신)은 기존 면허의 유효기간 만료와 함께 새로운 면허를 부여하는 것으로 해석하는 것이 “판례”의 일반적인 태도이다. 이는 기존 면허의 효력을 그대로 연장하는 것이 아니라, 새로운 면허 부여의 재량행위로 본다. 따라서 재량권이 행사될 여지가 있다.

(2) 면허면적축소의 법적 성격

-어업면허의 축소는 종전의 어업면허에 비해 불이익을 주는 처분이므로 수익적 행정행위의 변경(불이익 변경) 또는 재량권 행사의 문제로 볼 수 있다. 사안은 면허연장 과정에서 면허면적을 축소한 경우이므로, 기존의 어업면허가 만료되고 축소된 면적으로 새로운 어업면허를 발급한 재량행위에 해당한다.

(3)甲의 청구의 의미

-甲은 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하고 있다. 이는 특정 내용의 적극적 처분(종전 면적으로의 연장 또는 새로운 면허)을 해달라는 요구에 해당한다.

(4) 취소소송의 한계

- 취소소송은 위법한 처분을 취소하는 소극적인 성격을 가진다. 즉, 면허면적축소가 포함된 어업면허 처분이 위법하다고 판단되어 취소된다 하더라도, 법원이 직접 종전 면적으로 환원하는 새로운 어업면허 처분을 하도록 명할 수는 없다. 취소판결은 행정청에게 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 발생시키지만, 그 재처분의 내용이 반드시 甲이 원하는 종전 면적 환원이 되어야 하는 것은 아니다(행정청이 재량권을 다시 행사할 수 있다).

(5) 의무이행소송의 필요성 (현행법상 부인)

- 甲이 원하는 것은 특정 내용의 처분(종전 면적으로의 환원)을 해달라는 것이므로, 이는 법원이 행정청에게 특정 처분을 명해줄 것을 구하는 의무이행소송의 성격을 가진다. 그러나 우리 행정소송법은 의무이행소송을 명시적으로 인정하고 있지 않다. 현행법 해석상 거부처분에 대한 취소소송이 인용되어도 행정청은 판결의 기속력에 따라 재처분 의무를 지지만, 다른 사유로 다시 거부처분을 할 수 있다. 결국 취소소송만으로는 甲의 목적 달성이 어렵다. 그러나 의무이행소송은 우리 행정소송법이 예정하고 있지 않으므로, 이러한 소송을 제기하더라도 법원은 각하할 것이다.

2. 현행법상 적법하게 인정될 수 있는 소송의 형태

(1) 어업면허(연장 또는 갱신) 처분에 대한 취소소송

- 甲의 재산권을 침해하는 면허면적축소가 포함된 새로운 어업면허 처분 자체가 위법하다고 판단될 경우, 그 처분 전체 또는 면적 축소 부분에 대한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원은 해당 처분이 재량권의 일탈·남용으로 위법한지 여부를 심리하게 된다. 만약 위법하다면 취소판결을 내릴 것이고, 행정청은 기속력에 따라 재처분을 해야 한다. 그러나 재처분의 내용이 반드시 종전 면적으로의 환원이 될 것이라고 단정하기 어렵다. 만약 법령 자체의 위법성이 선결문제로 인정되어 처분이 위법하다고 판단된다면, 그 법령에 근거한 처분(면적 축소 포함)을 취소할 수 있다.

(2) 거부처분 취소소송 (간접적 구제)

- 만약 甲이 면적 축소에 대해 별도로 이의를 제기하며 종전 면적으로 연장해 달라는 신청을 했고, 행정청이 이를 거부하는 처분을 했다면, 甲은 그 거부처분에 대한 취소소송을 제기할 수 있다. 이 경우 법원이 거부처분을 취소하면 행정청은 다시 신청에 대해 처분을 해야 할 의무를 지지만, 역시 반드시 종전 면적으로 환원하는 처분을 해야 하는 것은 아니다.

3. 사안의 적용

- 甲이 원하는 종전 면적으로의 환원 처분을 직접적으로 명하는 소송은 의무이행소송에 해당하며, 이는 현행법상 인정되지 않아 부적법하다. 따라서 甲이 취할 수 있는 유일하고 적법한 소송 형태는 행정청이 발급한 축소 면허 처분 전체를 대상으로 하는 취소소송이며, 이 소송의 승소 판결을 통해 재처분 의무를 발생시켜 간접적인 구제를 받아야 한다.

4. 검토

- 甲이 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 직접 청구하는 형태의 행정소송은, 우리 행정소송법이 특정 처분을 명하는 의무이행소송을 인정하고 있지 않으므로, 적법하게 인정될 수 없다. 따라서 甲은 다음과 같은 방법을 취하여 간접적인 구제를 시도해야 한다. ❶ 새로이 발급된 어업면허(축소된 면적의) 처분에 대해 그 면적 축소 부분이 재량권 일탈·남용 등으로 위법하다고 주장하며 취소소송을 제기하여 승소한 후, 행정청이 재량권을 다시 행사하도록 유도하는 방법. ❷ 만약 종전 면적으로의 환원을 별도로 신청하였으나 행정청이 이를 거부하는 처분을 했다면, 그 거부처분에 대한 취소소송을 제기하는 방법. 이 두 가지 경우 모두 법원이 직접 행정청에게 종전 면적으로 환원하는 처분을 하라고 명할 수는 없다.

Ⅳ. 종합 결론

- 甲이 제기하고자 하는 두 가지 유형의 행정소송의 적법성에 대한 결론은 다음과 같다. ❶ 면허면적축소와 관련된 법령의 취소를 청구하는 행정소송은 법규명령으로서 취소소송의 대상인 처분에 해당하지 않아 대상적격이 없으므로 적법하게 인정될 수 없다. ❷ 어업면허면적을 종전으로 환원하여 주는 처분을 청구하는 행정소송은 현행 행정소송법상 인정되지 않는 의무이행소송의 형태이므로 적법하게 인정될 수 없다. 따라서 甲은 현행법상 축소된 어업면허 처분 전체를 대상으로 하는 취소소송을 제기하고, 그 소송에서 법령의 위법성을 다투어 승소함으로써, 행정청의 재처분을 통해 종전 면적으로의 면허를 간접적으로 확보하는 것이 유일하고 적법한 구제 경로이다.

《【문제1】 다음 질문에 답하시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50점)

(물음1) 근로자 A는 甲노동조합을 조직해서 그 설립신고를 하였으나 乙시장은 `설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중에 있는 자의 가입을 허용하고 있다.(`노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 라목)는 사유로 설립신고서를 반려하였다. 이에 甲노동조합은 취소소송을 제기하고자 하는바, 乙시장의 설립신고서 반려는 취소소송의 대상이 될 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음1> 구직자의 노동조합 가입을 이유로 한 설립신고서 반려처분의 취소소송 대상적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲노동조합은 설립신고를 하였으나 乙시장은 설립신고서에서 근로자가 아닌 구직 중인 자의 가입을 허용하고 있다는 이유로 설립신고서를 반려하였고, 이에 甲노동조합은 그 반려처분에 대하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <乙시장의 노동조합 설립신고서 반려가 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙시장의 설립신고서 반려가 취소소송의 대상이 될 수 있는가를 설명한다.

II. 취소소송의 대상

1. 대상적격의 의의

- 취소소송은 행정청의 위법한 처분등을 취소하는 소송으로서, "행정소송법 제19조"에 따라 소송의 대상이 되는 행정작용을 대상적격이라고 한다. "행정소송법 제2조 제1항 제1호"는 처분등을 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라고 정의한다.

2. 거부처분의 처분성 인정 요건

- 乙시장의 설립신고서 반려 행위는 신청에 대한 거부 행위이므로, 거부처분으로서의 처분성 인정 여부가 핵심이다. "판례"는 거부 행위가 처분성을 갖기 위한 요건으로 다음과 같은 네 가지를 요구한다.

(1) 공권력의 행사일 것

- 거부 행위가 행정청의 지위에서 행해지는 공법적 행위여야 한다.

(2) 신청에 대한 거부일 것

- 거부의 대상이 되는 신청이 있어야 한다.

(3) 법규상 또는 조리상 신청권이 있을 것

- 거부 행위의 대상이 된 행정작용에 대하여 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 인정되어야 한다. "판례"는 국민이 행정청에 대하여 신청에 따른 행정행위를 해 줄 것을 요구할 수 있는 법적 지위에 있을 때 신청권이 인정된다고 본다.

① 법규상 신청권

- 관련 법규가 신청인에게 일정한 행정작용을 요청할 수 있는 권리를 부여하고 있는 경우이다.

② 조리상 신청권

- 관련 법규에 명문 규정이 없더라도, 행정작용의 성질상 국민에게 신청을 할 수 있도록 해주는 것이 행정의 합목적성에 부합하거나, 신청권이 없다고 보는 것이 실질적 법치주의에 반하는 경우에 인정된다.

(4) 거부로 인해 신청인의 권리 또는 이익에 영향을 미칠 것

- 신청의 거부로 신청인의 법률상 지위에 직접적인 영향을 미쳐야 한다. 단순히 사실상의 불이익이나 반사적 이익의 침해에 그치는 경우에는 처분성이 부정된다.

III. 사안의 적용

1. 노동조합 설립신고의 법적 성격

- 노동조합 설립신고는 "노동조합법 제10조"에 근거하여 행정청에 제출하는 신고로서, 신고가 수리되면 노동조합으로서 법적 지위를 취득하게 된다. 따라서 설립신고는 단순한 통지행위가 아니라, 신고 수리 여부에 따라 노동조합의 법적 지위가 결정되는 행정행위로 평가된다.

2. 설립신고 반려의 처분성 인정 여부

- 乙시장이 설립신고서를 반려한 행위는 다음과 같은 점에서 처분성을 가진다. ① A 또는 甲노동조합의 권리 행사를 제한한다는 점, ② 법률에 따른 설립신고권을 행사하려는 신청에 대한 거부라는 점, ③ 구체적·직접적 법률상 이익(설립된 노동조합의 법적 지위 확보)을 침해한다는 점, 따라서 설립신고 반려행위는 행정소송법상 취소소송의 대상인 처분으로 볼 수 있다. 다만, 반려 사유가 "노동조합법 제2조 제4호 라목"에 해당하여, 실제로 노조법상 설립요건을 결여한 경우라면, 소송은 행정청의 재량권 행사 적법성 여부를 중심으로 심리될 것이다.

IV. 결론

- 乙시장이 甲노동조합의 설립신고서를 반려한 행위는 노조법에 따른 법규상 신청권에 근거한 신청을 거부한 행위이다. 또한, 그 거부로 인하여 甲노동조합은 노조법상의 법적 지위를 획득하지 못하고 각종 법적 보호를 받지 못하게 되는 구체적이고 직접적인 법률상 불이익을 입는다. 따라서 乙시장의 설립신고서 반려 행위는 "행정소송법 제2조 제1호" 및 "제19조"에서 규정하는 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당한다. 甲노동조합은 乙시장의 반려행위가 "노동조합법 제2조 제4호 라목"의 요건을 잘못 해석하거나 판단한 위법한 처분임을 주장하며 취소소송을 제기할 수 있다.

《[문제1] A회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제2조 제4호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 무자격 노동조합 설립신고 수리에 대한 사용자의 취소심판 청구의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 관할 행정청은 노동조합으로 볼 수 없는 무자격조합에 해당함에도 甲의 노동조합 설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 그 신고수리를 대상으로 취소심판을 제기하였다. 쟁점으로 <A회사가 제기한 취소심판청구가 행정심판의 대상적격 및 청구인적격 등 적법요건을 충족하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 제기한 심판청구의 적법성에 관한 법적 쟁점을 설명한다.

II. 설립신고 수리의 처분성 및 사용자의 청구인적격 법리

1. 노동조합 설립신고 수리의 대상적격(처분성)

- “행정심판법 제2조 제1호”의 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 등을 의미한다. 노동조합 설립신고는 단순히 정보를 제공하는 신고가 아니라, 행정청이 법령상 요건을 심사하여 수리함으로써 비로소 법정 노동조합으로서의 지위를 부여하는 수리를 요하는 신고이다. 따라서 행정청의 설립신고 수리행위는 신청인의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치는 공권력의 행사로서 취소심판의 대상이 되는 처분성이 인정된다.

2. 제3자인 사용자의 청구인적격(법률상 이익)

- “행정심판법 제13조 제1항”에 따른 청구인적격은 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자에게 인정된다.

(1) 판례의 태도(부정설)

- “대법원”은 노동조합법이 설립신고주의를 취하는 것은 노동조합이 자주성과 민주성을 갖춘 조직으로 존속할 수 있도록 관리·감독하기 위한 노동정책적 고려에서 마련된 것이라고 본다. 따라서 사용자는 무자격 노동조합이 설립되지 않음으로써 사실상의 이익을 향유할 수 있을지라도, 그러한 이익이 노동조합법 규정에 의해 직접적이고 구체적으로 보호되는 이익이라 볼 수 없다고 판단한다. 또한, 설립신고 수리 자체로 사용자에게 어떤 공적의 무가 직접 부과되는 것은 아니며, 사용자는 향후 당해 노동조합이 단체교섭 요구나 부당노동행위 구제신청 등 구체적인 법적 절차를 개시할 때 비로소 그 절차 내에서 노동조합의 무자격성을 주장하여 다룰 수 있을 뿐이므로 수리처분 자체를 다룰 청구인적격이 없다는 입장이다.

(2) 학설의 태도(긍정설 및 비판론)

- 상당수의 노동법 및 행정법 학자들은 “판례”의 태도를 비판한다. 행정청이 노동조합 설립신고를 수리하면 사용자는 노동조합법상 단체교섭에 성실히 응해야 할 공법상 의무(정당한 이유 없이 거부 시 부당노동행위로 형사처벌 및 구제명령의 대상이 됨)를 강제적으로 부담하게 된다. 따라서 설립신고 수리처분은 사용자의 법적 지위에 직접적이고 중대한 불이익을 초래하므로, 실질적인 권리구제와 소송경제 측면에서 사용자의 법률상 이익을 긍정하여 청구인적격을 인정해야 한다는 견해이다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- 관할 행정청이 甲의 설립신고를 수리한 행위는 수리를 요하는 신고의 수리로서 처분성이 인정된다. 따라서 행정심판의 대상적격 요건은 충족한다.

2. 청구인적격의 충족 여부

- 사안의 노동조합은 사용자로부터 경비 원조를 받는 무자격 조합이므로 행정청의 수리처분에는 실체법상 하자가 존재한다. 사용자의 청구인적격에 관하여, 학설의 대립 중 긍정설에 따르면 수리처분으로 인하여 A회사에 법적 단체교섭의무 등이 부과되므로 청구인적격이 인정될 수 있다. 그러나 “대법원 판례”의 엄격한 태도에 의하면, 이러한 수리처분으로 인하여 사용자인 A회사가 입게 되는 경영상·경제상의 불이익이나 무자격 조합의 배제 이익은 간접적·사실적 이해관계에 불과하다. 따라서 현행 “판례”에 따를 때 A회사는 해당 수리처분의 취소를 청구할 직접적이고 구체적인 법률상 이익을 가지지 않으므로 청구인적격이 결여된다.

IV. 결론

- 관할 행정청의 설립신고 수리행위는 행정심판의 대상이 되는 처분에 해당하나, 제3자인 사용자는 해당 수리처분의 취소를 청구할 법률상 이익이 없다. 따라서 “판례”의 입장을 엄격히 관철할 때 A회사가 제기한 취소심판청구는 청구인적격을 결여한 부적법한 청구에 해당하므로 행정심판위원회는 본안심리를 하지 않고 각하결정을 내려야 한다. 다만, 사용자의 단체교섭의무 부과 등 실질적인 법적 지위의 변동을 중시하는 학설의 비판론을 수용한다면 적법한 청구로 보아 본안 심리로 나아갈 여지도 존재한다.

<관련판례>

“대법원 1997. 10. 14. 선고 96누9829 판결 [노동조합설립신고증교부(수리)처분취소] [공1997.11.15.(46),3489]”

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오. (50점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음1) A회사에 근무하는 근로자 甲은 사용자와의 임금인상에 관한 문제를 해결하고 근로조건 개선에 도모하고자 A회사에 노동조합을 조직하고 관찰시장 乙에게 설립신고서를 제출하였다. 이에 관찰시장 乙은 A회사 노동조합 설립신고서에는 'A회사로부터 해고되어 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 하고 중앙노동위원회의 재심판정이 있기 전의 자'를 조합원으로 가입시킬 수 있다고 명시되어 있고, 이는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 라목의 '근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우'에 해당한다는 이유로 甲의 설립신고서를 반려하였다. 관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여, 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논하십시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 노동조합 설립신고 반려처분에 대한 취소소송상 소송요건과 가구제 및 본안 인용 시 권리구제 방안

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 노동조합 설립신고를 하였으나 관찰시장 乙은 설립신고서가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 근로자가 아닌 자의 가입을 허용한다는 이유로 설립신고서를 반려하였고, 甲은 이에 대하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위가 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지 및 이를 통한 권리구제가 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논한다.

II. 설립신고 반려의 처분성 및 구제수단 법리

1. 소송요건의 충족 여부

(1) 대상적격 (반려행위의 처분성)

- 노동조합 설립신고는 수리를 요하는 신고이다. "판례"는 설립신고 반려가 노동3권의 실질적 행사를 가로막고, 법적 지위 획득을 저지하는 직접적인 불이익을 초래하므로, 행정소송법상 처분성이 인정된다고 본다.

(2) 원고적격 및 소송당사자능력

- 설립등기 전 노동조합은 비법인사단으로서 소송당사자능력이 인정된다. 또한, 반려처분의 직접 상대방인 노동조합(또는 대표자 甲)은 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되어 원고적격을 구비한다.

2. 임시적 구제수단 (가구제)

(1) 집행정지 [행정소송법 제23조]

- "판례"는 거부처분에 대하여 집행정지를 결정하더라도 행정청에게 재처분의무가 직접 발생하지 않으므로 신청의 이익이 없어 부적법하다고 본다. 따라서 반려처분에 대한 집행정지는 허용되지 않는다.

(2) 민사상 가처분의 준용 여부

- 행정소송법상 임시의 지위를 정하는 민사상 가처분의 준용 여부에 대하여, "판례"는 행정소송의 특수성을 고려할 때 집행정지 외에 가처분 제도는 준용될 수 없다는 입장이다.

3. 본안판단 및 인용판결의 효력

(1) 반려처분의 실체법적 위법성

- "노조법 제2조 제4호 라목 단서"는 해고된 자가 부당노동행위 구제신청을 하여 중노위 재심판정이 있기 전까지는 근로자 아닌 자로 해석해서는 안 된다고 규정한다. 이에 부합하는 규약을 이유로 한 반려는 위법하다.

(2) 취소판결의 기속력에 따른 의무

- 취소판결이 확정되면 "행정소송법 제30조 제2항"에 따라 피고 행정청은 판결의 취지에 맞게 이전 신청에 대해 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 부담한다.

III. 사안의 적용

1. 소송요건 및 가구제의 적용

(1) 대상적격과 원고적격

- 乙의 반려행위는 甲이 조직한 노동조합의 법적 지위 획득을 배제하므로 처분성이 인정된다. 소송당사자는 비법인사단인 노동조합 또는 대표자 甲이 되며 원고적격 역시 충족한다.

(2) 가구제 신청의 기각

- 반려처분은 거부처분에 해당하므로 행정소송법상 집행정지는 소의 이익이 없어 허용되지 않으며, 민사상 가처분의 준용 역시 부정되므로 가구제를 통한 임시 구제는 불가능하다.

2. 본안 및 확정판결 효력의 적용

(1) 반려처분의 위법성

- A사 노동조합의 규약은 "노조법 제2조 제4호 라목 단서"에 부합하므로 조합원 자격에 흠결이 없다. 따라서 이를 이유로 행해진 乙의 반려처분은 실체상 위법하므로 법원은 반려처분 취소판결을 내려야 한다.

(2) 乙의 재처분의무 이행

- 취소소송에서 인용판결이 확정되면 피고인 乙은 판결의 기속력에 따라 지체 없이 설립신고서를 수리하고 설립신고증을 교부해야 하는 재처분의무를 이행하여야 한다.

IV. 결론

- 甲이 제기하는 설립신고 반려처분 취소소송은 대상적격과 원고적격을 충족하여 적법하며, 본안심리 결과 乙의 반려처분은 실체법상 위법하므로 법원은 취소판결을 선고해야 한다. 취소판결이 확정되면 乙은 기속력에 따른 재처분의무를 부담하므로 지체 없이 설립신고증을 교부해야 하며, 불이행 시 간접강제를 통해 이행을 강제할 수 있으므로 취소소송은 甲에게 실효성 있는 구제수단이 된다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2023-1-1]행정청의 이주대책 대상자 제외 재결정에 대한 취소소송의 대상적격과 제소기간 기산점

《[문제1] A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구에서 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 '택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자'로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 '기준일 이후 주택 취득'을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 '1차 결정'이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 '2차 결정'이라 함). 다음 각 물음에 답하십시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50점)

(물음1) 甲이 자신을 이주대책 대상에서 제외한 A시의 결정에 대해 취소소송으로 다투려는 경우, 소의 대상 및 제소기간의 기산점에 대해 설명하십시오. (25점)

<문제1의 물음1> 행정청의 이주대책 대상자 제외 재결정에 대한 취소소송의 대상적격과 제소기간 기산점

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시는 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 1차 결정을 하였고, 이후 甲의 이의신청에 대하여도 추가 증빙자료만으로는 선정요건을 충족하지 못한다는 이유로 이를 기각하는 2차 결정을 하였다. 쟁점으로 <甲이 취소소송을 제기하는 경우 어느 결정을 소의 대상으로 삼아야 하는지와 제소기간의 기산점을 언제로 보아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 자신을 이주대책 대상에서 제외한 A시의 결정에 대해 취소소송으로 다투려는 경우, 소의 대상 및 제소기간의 기산점에 대해 설명한다.

II. 거부처분과 이의신청에 대한 재결정의 법리

1. 거부처분의 성립과 소의 대상

(1) 거부처분의 성립 요건

- 행정청의 거부행위가 취소소송의 대상인 처분이 되기 위해서는 신청인에게 신청권이 존재해야 하며, 거부로 인하여 신청인의 권리나 법적 지위에 직접적인 영향을 미쳐야 한다.

(2) 취소소송의 대상적격

- "행정소송법 제19조"에 의하면 취소소송은 행정청의 처분을 대상으로 하므로, 행정청의 처분성 있는 거부행위가 대외적으로 존재할 때 비로소 소송을 제기할 수 있다.

2. 이의신청 기각결정의 새로운 처분성 인정 여부

(1) 단순한 이의신청에 대한 통지

- 처분청에 대한 임의적 이의신청에 대하여 행정청이 종전 처분을 그대로 유지하는 기각 통지를 한 경우, 이는 기존 처분을 재확인하는 것에 불과하여 독자적인 처분성이 부정된다.

(2) 새로운 사실이나 증빙 제출에 따른 재결정

- "대법원"은 이의신청을 하면서 당초 거부처분의 사유를 해소할 수 있는 새로운 사실관계나 증빙서류를 추가로 제출하는 등 실질적으로 재신청을 하였고, 행정청이 이를 재심사하여 다시 거부결정을 내렸다면 이는 새로운 거부처분에 해당한다고 판시한다.

3. 제소기간의 기산점

(1) 제소기간의 원칙적 제한

- "행정소송법 제20조 제1항"에 의하면 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는 엄격한 불변기간의 제한을 받는다.

(2) 새로운 거부처분 시 기산점

- 재신청에 대한 거부가 새로운 거부처분으로 성립하는 경우, 제소기간은 당초의 거부처분일이 아니라 새로운 거부처분이 있음을 안 날부터 독자적으로 새롭게 기산한다.

III. 사안의 적용

1. 소의 대상 확정

(1) 새로운 사실과 증빙서류의 제출

- 甲은 1차 결정을 통보받은 후 마을주민확인서, 수도개설 사용 및 전력 개통사용자 확인서 등 당초 선정요건을 충족함을 증명하는 실질적인 증빙서류를 새롭게 추가하여 제출하였다. 이는 단순한 처분의 재고 요청이 아닌 실질적인 재신청이다.

(2) A시의 실질적 심사와 2차 결정의 처분성

- A시는 甲이 새로 제출한 자료를 바탕으로 요건 충족 여부를 실질적으로 재심사하여 기각하는 2차 결정을 하였다. 따라서 2차 결정은 1차 결정의 반복이 아니라 독자적인 새로운 거부처분이 되므로 소의 대상은 2차 결정이 된다.

2. 제소기간 기산점 산정

(1) 1차 결정 통보일의 배제

- 1차 결정이 통보된 2023. 6. 28.은 새로운 거부처분인 2차 결정의 제소기간 기산일이 될 수 없다.

(2) 2차 결정 통보일의 기준 의제

- 소의 대상인 2차 결정이 甲에게 통보되어 도달한 날은 2023. 8. 31.이다. 따라서 취소소송의 제소기간은 甲이 2차 결정이 있음을 현실적으로 안 날인 2023. 8. 31.부터 새롭게 기산한다.

IV. 결론

1. 소의 대상의 확정

- 甲이 추가 증빙자료를 제출하여 재심사를 유도하였고 이에 따라 내려진 2차 결정은 독립적인 새로운 거부처분이므로, 취소소송의 대상은 2차 결정이 된다.

2. 제소기간 기산점의 산정

- 소의 대상이 2차 결정이 되므로, 제소기간의 기산점 역시 2차 결정의 통보를 받아 처분이 있음을 안 날인 2023. 8. 31.이 된다.

<보충>

I. 구별의 필요

- 원처분주의(행정심판 재결과의 관계)와 본 사안의 이의신청 기각 후 재결은 구별이 필요하다.

II 원처분주의의 적용 범위

- "행정소송법 제18조 제1항"은 취소소송은 처분 등을 대상으로 한다고 규정하고, "제18조 제3항"은 행정심판을 거친 경우에도 재결에 고유한 위법이 없는 한 원처분을 대상으로 하여야 한다고 규정한다. 즉, 행정심판 재결과의 관계에서는 원처분주의가 원칙이고, 재결을 대상으로 하는 것은 예외적으로 재결에 고유한 위법이 있는 경우뿐이다.

III 본 사안의 이의신청 기각 결정의 법적 성질

- 사안에서 甲은 1차 결정(이주대책 제외 통보)에 대하여 행정심판이 아니라, 행정청 내부적 이의신청을 하였을 뿐이다. 이의신청은 행정심판법상 법정 구제절차가 아니고, 단지 행정청 내부 절차로 종전 처분을 재검토하는 과정일 뿐이다. 따라서 본 사안의 2차 결정은 행정심판 재결이 아니라, 행정청이 새로운 자료를 심사하여 다시 내린 실질적 처분에 불과하다. 즉, 원처분주의 vs 재결주의 문제로 볼 수 없고, 단순히 최종 처분이 무엇인가의 문제로 정리된다.

IV 1차 결정과 2차 결정의 관계

- 단순히 종전 처분을 재확인하는 것이라면, 다툼의 대상은 여전히 1차 결정(원처분)이다. 그러나 이의신청 과정에서 새로운 증빙자료가 제출되고, 행정청이 이를 실질적으로 심사한 뒤 별도의 판단을 내렸다면, 그 결과는 새로운 처분으로 평가할 수 있다. 본 사안에서는 甲이 새로운 증빙자료(마을주민확인서, 수도·전력 사용내역 등)를 제출했고, A시는 이를 근거로 별도로 판단하여 다시 제외 결정을 했다. 이는 단순한 재확인인 아니라 새로운 처분이라고 봄이 타당하다. 따라서 소송의 대상은 2차 결정이다.

V. 결론

- 본 사안은 행정심판의 재결이 아니라 내부적 이의신청이므로 원처분주의의 문제는 적용되지 않는다. 따라서 甲의 소송은 최종 처분인 2차 제외 결정을 대상으로 해야 하고, 제소기간도 2차 결정 통보일(2023. 8. 31.)을 기준으로 기산된다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2024-3]일부 변경된 집합금지명령의 대상적격성 및 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간 준수 여부

《[문제3] A시장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거한 집합금지명령을 2024. 5. 1. 공고하면서 관내 다중이용시설을 대상으로 2024. 5. 6.부터 매일 22시에서 다음날 06시 사이의 영업을 제한하였는 바, 그에 대하여 유흥주점 업주 甲은 2024. 5. 27. 취소소송을 제기하였고, 2024. 9. 5. 현재 소송 계속 중이다. 한편, 예방조치에도 불구하고 감염병 확산세가 급등하자 A시장은 2024. 5. 31.부터 관내 다중이용시설의 영업제한 시간을 매일 20시에 다음날 07시까지로 늘리는 내용의 집합금지명령을 2024. 5. 29. 공고하였다. 음식점 업주 乙은 해외에 체류하다가 귀국하여 2024. 6. 8. 자신의 업소에 부착된 공고문 및 안내문을 보고 비로소 그 명령을 알게 되었고, 2024. 8. 30. 그에 대하여 취소소송을 제기하였다. 甲의 소송이 대상적격을 갖춘 것인지와 乙의 소송이 적법한 기간 내 제소된 것인지를 검토하시오. (25점)》

<문제3> 일부 변경된 집합금지명령의 대상적격성 및 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 집합금지명령에 대하여 취소소송을 제기한 후 소송 계속 중 명령의 내용이 변경되었고, 乙은 변경된 집합금지명령을 뒤늦게 알게 된 후 이에 대한 취소소송을 제기하였다. 쟁점으로 <甲의 소송이 대상적격을 갖추었는지>와 <乙의 소송이 제소기간을 준수하여 적법하게 제기되었는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 소송이 대상적격을 갖춘 것인지와 乙의 소송이 적법한 기간 내 제소된 것인지를 검토한다.

II. 집합금지명령의 대상적격 (甲의 소송)

1. 일반처분의 처분성 및 대상적격

(1) 처분의 개념과 일반처분

- 「행정소송법 제2조 제1항 제1호」의 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서 공권력의 행사 등을 의미한다. 이 중 일반처분은 불특정 다수인을 상대로 특정한 구체적 사건을 규율하는 행정행위로서 처분성이 인정된다.

(2) 사안의 판단

- A시장의 2024. 5. 1.자 집합금지명령은 관내 다중이용시설 업주라는 불특정 다수인을 상대로 영업시간을 제한하여 의무를 부과하는 일반처분으로 대상적격이 인정된다.

2. 소송 계속 중 변경처분과 대상적격의 존속

(1) 판례의 태도

- 「판례」는 소송 계속 중 당초처분의 유효를 전제로 그 내용 중 일부만을 추가하거나 변경하는 일부 변경처분이 있는 경우, 당초처분은 소멸하지 않고 그 성질이 허용하는 한 변경된 내용의 범위 내에서 여전히 존속한다고 판시한다. 따라서 원고는 당초처분을 대상으로 소송을 계속할 수 있다.

(2) 사안의 판단

- A시장의 2024. 5. 29.자 집합금지명령은 당초 영업제한 시간(22시~06시)을 매일 20시~07시로 늘리는 내용으로서, 당초처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·확장하는 변경처분이다. 따라서 당초 2024. 5. 1.자 처분은 여전히 효력을 유지하므로 甲의 소송은 대상적격을 상실하지 않는다.

III. 고시·공고에 의한 처분의 제소기간 (乙의 소송)

1. 제소기간 기산점에 관한 판례의 태도

(1) 일반적 원칙

- 「행정소송법 제20조 제1항」에 따라 취소소송은 처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다.

(2) 고시·공고에 의한 일반처분의 특징

- 「판례」는 불특정 다수인을 상대로 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우, 그 처분에 이해관계를 갖는 사람은 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날에 그 처분이 있음을 알았다고 보아야 한다고 판시한다.

2. 사안의 판단 및 제소기간 산정

(1) 기산일의 확정

- A시장의 2024. 5. 29.자 집합금지명령은 2024. 5. 31.부터 효력이 발생하도록 공고되었다. 따라서 불특정 다수인에 대한 일반처분으로서 乙이 실제로 안 날(2024. 6. 8.)과 무관하게 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분이 있음을 안 것으로 의제된다.

(2) 제소기간 도과 여부 검토

- 초일불산입 원칙에 따라 2024. 6. 1.부터 기산하여 90일이 되는 날은 2024. 8. 29.이다. 乙은 이보다 하루 늦은 2024. 8. 30.에 취소소송을 제기하였으므로, 제소기간을 경과하였다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 소송에 대한 적용

- A시장의 집합금지명령은 일반처분으로서 처분성이 인정되고, 후속 변경처분이 당초처분을 소멸시키는 대체적 변경처분이 아니라 일부 확장·변경하는 처분이므로 甲이 제기한 취소소송의 대상은 여전히 존속하여 대상적격을 갖춘다.

2. 乙의 소송에 대한 적용

- 乙은 일반처분의 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분이 있음을 안 것으로 의제되므로 제소기간의 종기는 2024. 8. 29.이 된다. 乙이 해외 체류 등의 사정으로 실제로 2024. 6. 8.에 알았다 하더라도 기산일이 변경되지 않으므로 2024. 8. 30.에 제기한 소는 부적법하다.

V. 결론

1. 甲의 소송

- 甲의 소송은 처분성이 인정되는 일반처분을 대상으로 하고, 소송 계속 중의 변경처분에도 불구하고 대상적격이 유지되므로 적법하다.

2. 乙의 소송

- 乙의 소송은 실제 안 날이 아닌 효력 발생일을 기준으로 제소기간이 기산되므로 90일을 경과하여 제기된 부적법한 소로서 법원에 의해 각하되어야 한다.

<보충 - 乙의 경우 제소기간 도과 판단에 대한 부가 설명>

I. 문제의 제기

- "행정소송법 제20조"는 취소소송의 제소기간을 처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있는 날부터 1년으로 제한하고 있다. 사안의 乙은 해외 체류라는 불가피한 사정으로 일반처분의 공고 및 효력 발생 사실을 뒤늦게 알았음에도, 법원이 효력 발생일을 기산점으로 삼아 90일의 제소기간 도과를 이유로 소를 각하하는 것은 가혹하다는 지적이 존재한다. 이하에서는 국민의 실질적 권리 구제라는 관점에서 처분이 있는 날부터 1년의 규정을 적용할 수 없는 법적 한계를 규명하고, 구체적 타당성과 법적 안정성의 조화 방안 및 대안적 소송법상 구제 수단을 고찰한다.

II. 행정소송법 제20조 제1항과 제2항의 법적 관계

1. 주관적 제소기간과 객관적 제소기간의 누적적 적용

- "행정소송법 제20조 제1항"의 안 날부터 90일(주관적 제소기간)과 "제2항"의 있는 날부터 1년(객관적 제소기간)은 선택적 관계가 아니다. 두 기간은 병립적으로 적용되며, 둘 중 어느 하나의 기간이라도 먼저 경과하면 소송을 제기할 수 없게 되는 누적적(제한적) 관계에 있다.

2. 일반처분에서 안 날의 의제(간주) 효과

- "대법원 판례"에 따르면 고시·공고에 의한 일반처분의 경우, 처분의 이해관계인은 현실적으로 고시 사실을 알았는지 여부와 무관하게 고시가 효력을 발생하는 날에 처분이 있음을 안 것으로 의제된다.

(1) 90일 기간의 즉시 작동

- 乙의 경우, 실제 귀국하여 안 날인 2024. 6. 8.과 상관없이 법적으로는 효력 발생일인 2024. 5. 31.에 처분을 안 것으로 취급된다. 이로써 안 날부터 90일이라는 주관적 제소기간이 2024. 6. 1.부터 즉시 가동된다.

(2) 1년 기간 적용의 불가능성

- 처분이 있는 날부터 1년의 규정은 처분이 있었으나 이를 현실적으로 알지 못한 경우에 한하여 보충적으로 적용되는 객관적 제소기간이다. 그러나 일반처분의 법리에 의해 乙은 이미 2024. 5. 31.에 처분을 안 것으로 법적 평가를 받으므로, 안 날부터 90일의 제한을 우선적으로 적용받게 된다. 따라서 1년의 기간이 남아있다 하더라도 이미 90일의 불변기간이 도과하였다면 소는 부적법해진다.

III. 법적 안정성과 구체적 타당성의 충돌

1. 가혹성 인정 (구체적 타당성의 침해)

- 개인의 과실이 없음에도 불구하고 단지 해외에 체류했다는 이유로 소송 기회를 원천 차단당하는 것은 자기책임 원칙 및 헌법상 재판청구권(제27조)의 실질적 보장 측면에서 매우 가혹한 처사임이 분명하다.

2. 행정의 법적 안정성 및 통일성 확보의 필요성

- 그럼에도 불구하고 대법원이 이를 엄격히 관철하는 이유는 일반처분의 특수성 때문이다. 일반처분은 불특정 다수인을 대상으로 하는 규율이므로, 만약 개개인이 실제로 안 날을 기준으로 제소기간을 개별 산정한다면 동일한 행정명령(예 : 감염병 집합금지명령)의 효력이 수개월 혹은 1년이 지난 후에도 개별 소송에 의해 흔들릴 수 있다. 이는 행정법 관계의 조속한 안정을 해치고 행정의 통일적 집행을 불가능하게 만드는 치명적인 결과를 초래한다.

IV. 소송법상 대안적 구제 수단의 검토

1. 소송행위의 추후보완 (추완) 가능성 검토

(1) 규정 및 요건

- "행정소송법 제8조 제2항"에 의해 "민사소송법 제173조"가 준용된다. 처분이 있음을 안 날부터 90일은 불변기간이므로, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 이를 준수하지 못한 경우 그 사유가 없어진 날부터 2주일(외국에 있던 자는 30일) 이내에 게을리한 소송행위를 보완(소 제기)할 수 있다.

(2) 판례의 엄격한 태도

- 해외 체류로 인해 공고 사실을 알 수 없었다는 사정이 과연 책임질 수 없는 사유에 해당하는지가 관건이다. "판례"는 고시·공고에 의한 일반처분의 제소기간에 대해서는 천재지변이나 이에 준하는 극단적인 사정이 없는 한 단순히 해외 체류 등의 사정만으로는 소송행위의 추완을 인정하지 않는 매우 보수적인 태도를 견지한다. 이는 고시·공고의 대외적 공정력과 객관적 가치를 중시한 결과이다.

2. 국가배상청구소송을 통한 우회적 구제

- 만약 집합금지명령 자체의 위법성으로 인해 乙에게 심각한 재산상 손실이 발생했고 취소소송의 기한을 놓쳤다면, 乙은 처분의 위법성을 이유로 한 국가배상청구소송(민사소송)을 제기할 수 있다. 소멸시효는 손해 및 가해자를 안 날부터 3년이므로 제소기간보다 훨씬 여유가 있으며, 법원은 이 소송에서 처분의 위법 여부를 선결문제로 판단할 수 있다.

V. 결론 및 입법론적 제언

- 현행법과 "판례" 체계하에서 乙의 소송을 적법한 제소기간 내의 소로 유효하게 다루는 것은 불가능하다. 있는 날부터 1년의 독자적 적용을 허용할 경우 일반처분의 존속력이 장기간 불안정한 상태에 놓이게 되며, 이는 전체 행정법 관계의 혼란으로 이어지기 때문이다. 결국 법원은 구체적 타당성을 희생하더라도 법적 안정성을 수호하는 방향을 선택할 수밖에 없다. 다만, 이러한 사법적 한계를 극복하기 위해서는 입법론적인 보완이 필요하다. 해외 체류자 등 정당한 사유로 고시를 인지하지 못한 것이 객관적으로 증명된 경우에 한하여 예외적으로 소송행위의 추완 요건을 완화해 주는 명문의 규정을 두거나, 국가가 중대한 영업 제한 처분을 내릴 때는 공고 외에도 행정절차법상 가능한 범위 내에서 업종별 대표자나 등록된 업주들에게 문자 송신 등의 보완적 통지 제도를 강화함으로써 국민의 실질적 구제와 행정의 안정성을 조화롭게 달성해야 할 것이다.

<관련판례>

- "대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결"

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

[기출][2025-3]국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등 확인소송

《【문제3】 A지방고용노동청장(이하 'A청장')은 민원인의 이용 편의를 위하여 청사 지하 1층에 편의점을 위탁운영하기로 결정하고, '청사 내 편의시설(편의점) 운영자 선정 입찰 공고'를 하였다. 입찰 결과 甲이 낙찰자로 결정되었고, A청장은 2022. 12. 20. 甲과 계약기간은 2023. 1. 1. 부터 2024. 12. 31.까지(2년간), 연 사용료 1억 원 등을 내용으로 하는 '청사 편의점 운영권 위탁계약(이하 '위탁운영계약')'을 체결하여 편의점 운영자 선정 절차가 완료되었다. 그 후 甲은 편의점을 1년 이상 운영하면서 납부기한까지 사용료를 납부하지 않았고, 이에 A청장은 2024. 2. 29. 「국유재산법」의 규정을 근거로 위탁운영계약을 해지하였다. 甲은 위탁운영계약 해지에 무효사유에 해당하는 하자가 있음을 발견하여, 이를 소송상 다투고자 한다. 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명하시오. (단, 위탁운영계약 체결 관련 사항은 A청장에게 위임되어 있음) (25점)》

<문제3> 국유재산 사용·수익허가 해지에 대한 구제수단으로서의 무효등 확인소송

I. 문제의 제기

- 사안에서 A청장은 甲과 청사 편의점 위탁운영계약을 체결하였으나, 甲의 사용료 연체를 이유로 국유재산법에 근거하여 위탁운영계약을 해지하였고, 甲은 그 해지에 무효사유가 있음을 이유로 이를 다투고자 한다. 쟁점으로 <위탁운영계약의 법적 성질과 이에 대한 해지행위의 성격을 기초로 甲이 어떠한 소송으로 권리구제를 받아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하여야 하는 소송을 설명한다.

II. 위탁운영계약 및 해지의 법적 성질

1. 행정재산 사용·수익허가의 성질

(1) 판례의 태도

- "대법원"은 국유재산법상 행정재산의 사용·수익허가는 순전히 사법상의 행위가 아니라 공법상의 행정처분(강학상 특허)에 해당한다고 일관되게 판시하고 있다.

(2) 법적 성질의 검토

- A청장 청사의 지하 1층은 국유재산법상 행정재산에 해당하므로, 편의점 위탁운영계약은 실질적으로 행정재산의 사용·수익허가에 해당하며 공법상 행정처분의 성격을 가진다.

2. 위탁운영계약 해지의 성질

(1) 행정처분성 인정 여부

- 행정재산 사용·수익허가를 받은 자가 사용료를 납부하지 않아 이를 해지하는 행위는 행정청의 일방적인 공권력 행사로서 허가의 효력을 소멸시키는 행정처분(강학상 철회처분)이다.

(2) 사법상 계약 해지와 구별

- 이는 단순한 사법상 계약의 해지나 공법상 계약의 해지가 아니므로, 민사소송이나 당사자소송이 아닌 항고소송의 대상이 된다.

III. 甲이 제기하여야 하는 소송 형태

1. 무효등 확인소송의 의의 및 성격

(1) 개념 및 취지

- "행정소송법 제4조"에 따른 무효등 확인소송은 행정청의 처분 등의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 항고소송이다.

(2) 무효 주장과의 관계

- 사안의 甲은 해지 행위에 무효사유의 하자가 있다고 주장하므로, 처분의 무효를 법원에 구하는 무효등 확인소송을 제기하는 것이 타당하다.

2. 소송 요건의 검토

(1) 피고 및 대상적격

- 피고는 처분을 행한 행정청인 A청장이 되며, 소송의 대상은 위탁운영계약 해지처분이 된다.

(2) 제소기간 및 전치주의의 예외

- 무효등 확인소송은 취소소송과 달리 "행정소송법 제20조"의 제소기간 제한을 받지 않으며, 행정심판전치주의도 적용되지 않아 언제든지 제기할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 처분성 인정 여부의 판단

- A청장의 청사는 행정재산이며, 甲과 체결한 위탁운영계약은 행정처분인 사용·수익허가이다. 따라서 국유재산법에 근거한 A청장의 위탁운영계약 해지는 행정처분에 해당한다.

2. 구체적 소송 형태의 적용

- 甲은 A청장을 피고로 하여 서울행정법원 등 관할 행정법원에 위탁운영계약 해지처분 무효확인소송을 제기하여야 한다. 이 소송은 제소기간의 제한을 받지 않으므로 절차상 유리하다.

V. 결론

- 국유재산법상 행정재산의 사용·수익허가 및 그 취소(해지)는 행정처분이다. 따라서 甲은 A청장의 해지 조치를 사법상 계약 해지로 다투어서는 안 되며, 행정소송법상 항고소송인 무효등 확인소송을 제기하여야 한다. 피고는 A청장으로 지정하고 해지처분의 무효확인을 청구함으로써 실질적인 권리 구제를 도모할 수 있다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2012-3]지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 특별행정쟁송절차의 흐름과 요건

《[문제3] 지방노동위원회의 처분(「근로기준법」 제30조에 따른 구제명령과 그에 준하는 것)에 대한 행정쟁송절차를 설명하시오(다툼이 있을 경우 판례에 따름). (25점)》

<문제3> 지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 특별행정쟁송절차의 흐름과 요건

I. 문제의 제기

- 지방노동위원회의 구제명령이나 기각결정은 공권력의 행사로서 행정소송법상 처분에 해당하지만, 근로기준법 및 노동위원회법에 의해 일반적인 행정쟁송과는 다른 특별한 절차적 제한을 받는다. 특히, 행정심판 전치주의(임의적 전치주의)의 예외(필요적 전치주의)로서 중앙노동위원회의 재심 절차를 반드시 거치도록 의무화하고 있으며, 제소기간 역시 매우 단기로 규정하고 있다. 이하에서는 <지방노동위원회의 처분에 대한 행정심판에 해당하는 중앙노동위원회 재심신청 절차와 이에 불복하여 제기하는 재심판정 취소소송의 요건>을 구체적으로 설명한다.

II. 노동위원회 처분에 대한 행정쟁송의 특별법리

1. 재결주의와 필요적 재심절차

(1) 재결주의의 채택

- 우리 법제는 지방노동위원회의 처분에 대하여 "노동위원회법 제27조 제1항" 및 "근로기준법 제31조 제2항"을 통해 명백한 재결주의를 채택하고 있다. 이에 따라 원처분인 지방노동위원회의 구제명령 등은 직접 행정소송의 대상이 될 수 없으며, 오직 중앙노동위원회의 재심판정만이 취소소송의 대상이 된다.

(2) 필요적 전치주의

- 재결주의의 당연한 논리적 결과로서, 지방노동위원회의 처분에 불복하여 법원의 사법심사를 받기 위해서는 반드시 중앙노동위원회에 재심을 신청하는 행정심판 절차를 거쳐야만 한다. 이를 거치지 않고 직접 제기한 행정소송은 소송요건을 결여한 것으로서 부적법 각하된다.

2. 중앙노동위원회 재심절차의 특징

(1) 재심청구의 당사자와 기간

- 지방노동위원회의 구제명령이나 기각결정에 불복하는 근로자 또는 사용자는 처분서를 송달받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청해야 한다. 이는 행정심판법상의 일반적인 심판청구기간인 90일에 비해 매우 단기로 규정된 특별 규정이다.

(2) 재심판정의 유형

- 중앙노동위원회는 심리 결과 지방노동위원회의 처분이 적법·타당하다고 판단하면 재심신청을 기각하고, 위법·부당하다고 판단하면 당초의 처분을 취소하거나 변경하는 인용 판정을 내린다. 이러한 재심판정은 행정심판의 재결에 해당한다.

3. 재심판정에 대한 행정소송 요건

(1) 소송의 대상과 피고적격

- 재심판정에 불복하여 제기하는 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정이다. 이때 피고는 합의제 행정청인 중앙노동위원회가 아니라, "노동위원회법 제27조 제2항"의 특별 규정에 의하여 행정청의 대표자인 중앙노동위원회 위원장이 된다.

(2) 제소기간의 제한

- 소송은 재심판정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 제기하여야 한다. 이는 행정소송법상의 일반적인 제소기간인 90일을 배제하고 우선 적용되는 특별불변기간에 해당하므로, 하루라도 경과하면 소송은 부적법 각하된다.

III. 구체적 양태

1. 지방노동위원회 처분에 대한 재심신청 단계

(1) 10일의 신청기간 준수

- 지방노동위원회의 구제명령이나 그에 준하는 처분을 받은 사용자와 근로자는 권리를 구제받기 위해 구제명령서 등을 송달받은 날부터 10일 이내에 반드시 중앙노동위원회에 재심을 신청해야 한다. 이는 사법심사로 나아가기 위한 필수적 전제 요건이다.

(2) 특별행정심판으로서의 의무이행적 성격

- 중앙노동위원회에 대한 재심청구는 성질상 특별행정심판에 해당하며, 특히 부당해고 등의 구제사안에서는 사용자에게 대하여 원직복직 및 임금상당액 지급을 구체적으로 명하는 의무이행적 성격을 내포하게 된다.

2. 중앙노동위원회 재심판정에 대한 행정소송 단계

(1) 제소기간 15일의 준수

- 중앙노동위원회의 재심판정에도 불복하는 당사자는 재심판정서를 송달받은 날부터 15일이라는 매우 제한된 불변기간 내에 취소소송을 제기하여야 한다. 15일의 특별제소기간은 노사관계의 신속한 안정을 도모하기 위한 헌법적 합리성을 지닌다.

(2) 중앙노동위원회 위원장 피고 지정

- 당사자가 행정소송을 제기할 때는 피고를 오인하지 않도록 유의해야 한다. 피고는 처분을 행한 지방노동위원회나 재결청인 중앙노동위원회가 아니라, 법령에 특별히 지정된 중앙노동위원회 위원장을 피고로 삼아야 적법하다.

IV. 결론

- 지방노동위원회의 구제명령 등 처분에 대한 행정쟁송절차는 행정심판과 행정소송의 유기적 결합 속에서 고도의 신속성을 요구하는 특별한 구조를 지닌다. 당사자는 처분 송달 후 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청하여 필요적 행정심판 절차를 거쳐야 하며, 그 재심판정서 송달 후 15일 이내에 중앙노동위원회 위원장을 피고로 하여 행정소송을 제기하여야 한다. 또한, "근로기준법 제32조"에 따라 재심신청이나 소송 제기가 구제명령의 효력을 정지시키지 않는 집행행정지의 원칙이 적용되므로, 구제의 실효성이 초기에 담보된다. 이러한 특별절차는 노사분쟁의 전문적 해결과 신속한 지위 확정을 조화롭게 달성하기 위한 법적 장치로서 실무상 엄격하게 관철된다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제02절 행정심판의 당사자적격>

[기출][2014-1-2]제3자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

《[문제1] A회사의 근로자 甲은 노동조합을 설립하고자 「노동조합 및 노동관계조정법」 제10조에 따라 설립신고를 하였으나, 甲이 설립하려는 노동조합은 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 조직으로, 동법 제2조 제4호에 의해 노동조합으로 보지 아니하는 것이다. 그럼에도 불구하고 관할 행정청은 甲의 조합설립신고를 수리하였고, 이에 A회사는 甲의 조합은 무자격조합임을 이유로 신고수리에 의해 취소심판을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음2) 만약 A회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 제3자의 청구에 따른 인용재결로 인하여 불이익을 입게 된 원처분 상대방의 소송제기 가능성 및 소송의 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사의 취소심판이 인용되어 노동조합 설립신고 수리를 취소하는 취소명령재결이 이루어졌고, 甲은 이에 대하여 소송으로 다투고자 한다. 쟁점으로 <취소명령재결이 취소소송의 대상이 되는지>와 <甲이 그 인용재결을 직접 취소소송으로 다툴 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 취소심판이 인용되어 취소명령재결이 행해지면, 甲은 이러한 인용재결에 대해 취소소송으로 다툴 수 있는가를 설명한다.

II. 재결취소소송과 제3자요 행정행위의 인용재결 범위

1. 원처분주의와 재결 자체에 고유한 위법의 의미

(1) 행정소송법 제19조의 규정

- 「행정소송법 제19조」는 원칙적으로 원처분을 취소소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결에 대한 취소소송을 제기할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 고유한 위법의 학설 및 판례

- 재결 자체에 고유한 위법이란 원처분에는 없고 재결에만 있는 재결청의 권한 또는 구성과 같은 주체의 위법, 재결 절차나 형식의 위법, 그리고 재결 내용의 위법을 의미한다. “판례”는 주체, 절차, 형식뿐만 아니라 내용상의 위법(사실오인, 법리오해 등)도 고유한 위법에 포함된다는 태도를 취하고 있다.

2. 제3자요 행정행위의 인용재결과 대상적격

(1) 제3자요 행정행위와 인용재결의 특수성

- 제3자요를 수반하는 복효적 행정행위에 대하여 제3자가 행정심판을 제기하여 그 청구를 인용하는 재결(취소재결)이 내려지면, 원처분의 상대방은 이 인용재결로 인하여 비로소 권리나 이익을 침해받게 된다. 원처분 자체는 자신에게 유리한 수익적 처분이었으므로 상대방은 원래의 원처분을 다툴 소의 이익이 없다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 복효적 행정행위, 특히 제3자요를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다툴 필요가 있다고 본다. 또한 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로, 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 소의 대상과 재결 고유의 위법 충족 여부

(1) 제3자요 행정행위의 성격

- 관할 행정청의 노동조합 설립신고 수리처분은 신청인인 甲에게는 노동조합으로서의 법적 지위를 부여하는 수익적 행정행위인 동시에, 사용자인 A회사에게는 단체교섭 의무 등을 부담시키는 제3자요 행정행위의 성격을 가진다.

(2) 인용재결로 인한 불이익의 발생

- A회사가 제기한 취소심판이 인용되어 수리처분을 취소하는 재결이 내려지면, 수익적 처분의 상대방이었던 甲은 이 인용재결로 인해 비로소 법정 노동조합의 지위를 박탈당하는 직접적인 권리 침해를 입게 된다. 甲에게는 당초의 수리처분이 유리한 처분이었으므로 이를 스스로 다툴 수 없었고, 오직 해당 인용재결을 통해서만 자신의 불이익을 시정할 수 있다. 따라서 “판례”의 확고한 법리에 따를 때, 甲이 해당 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 위법을 다투는 것이 되므로 “행정소송법 제19조 단서”의 대상적격을 충족한다.

2. 원고적격 및 피고적격의 검토

(1) 원고적격의 구비

- 甲은 비록 행정심판의 청구인은 아니었으나, 제3자의 청구를 인용하는 재결로 인하여 자신의 법률상 이익(노동조합 설립등록 지위)을 직접 침해받은 원처분의 상대방이므로 “행정소송법 제12조”의 원고적격을 구비한다.

(2) 피고적격의 확정

- 재결취소소송의 대상이 재결 자체이므로, 소송의 피고는 원처분청이 아니라 해당 인용재결을 내린 행정청인 행정심판위원회가 되어야 한다.

IV. 결론

- 사안에서 A회사의 취소심판이 인용되어 甲의 노동조합 설립신고 수리처분을 취소하는 재결이 내려진 경우, 원처분의 상대방인 甲은 이 인용재결로 인해 비로소 자신의 권리와 법률상 이익을 직접 침해받게 된다. 이 인용재결은 원처분과 내용을 완전히 달리하는 새로운 처분의 성격을 가지는데, 원처분에는 없는 재결 자체에 고유한 하자가 존재하는 셈이므로 “행정소송법 제19조 단서”에 따라 당연히 취소소송의 대상이 된다. 결론적으로 甲은 해당 인용재결을 소송의 대상으로 삼고 인용재결을 행한 행정심판위원회를 피고로 하여 적법하게 취소소송을 제기함으로써 권리를 구제받을 수 있다.

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오. (50점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음2) 취소소송의 인용판결 확정으로 A회사 노동조합은 적법하게 설립신고를 완료하였다. 이후 A회사 사용자는 임금인상을 요구하는 근로자 丙에 대하여 업무정지를 명하고, 수일 후에 해고를 명하였다. A회사 노동조합은 이에 대해 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 A회사에게 `丙을 원직에 복직시키고 업무정지 및 해고기간 동안 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라`는 구제명령을 내렸다. A회사는 丙에 대한 업무정지 및 해고는 정당하고 임금상당액도 지급할 의무가 없다는 취지로 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 이에 대해 중앙노동위원회는 `해고는 부당노동행위에 해당하나 업무정지는 부당노동행위에 해당하지 않으며, A회사는 해고기간 동안의 임금상당액만을 지급하라`는 재심판정을 하였다. 이 때 A회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상은? (15점)》

<문제1의 물음2> 중앙노동위원회의 일부인용 재심판정에 대하여 사용자가 제기하는 취소소송의 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 지방노동위원회의 구제명령에 불복하여 중앙노동위원회에 재심을 신청하였고, 중앙노동위원회는 업무정지 부분은 취소하고 해고 부분에 대해서만 부당노동행위를 인정하여 임금상당액 지급을 명하는 재심판정을 하였다. 쟁점으로 <A회사가 재심판정에 대하여 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분 또는 재심판정을 소송의 대상으로 삼아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상을 설명한다.

II. 노동위원회법상 재결주의와 일부인용 재심판정

1. 노동위원회법상 재결주의

(1) 재결주의의 의의

- 재결주의란 법률에 특별한 규정이 있는 경우 예외적으로 행정심판의 재결만을 취소소송의 대상으로 삼도록 제한하는 제도이다. 이 경우 원처분의 대상성은 배제되며 재결에 대해서만 소를 제기해야 한다.

(2) 노동위원회법의 명문 규정

- "노동위원회법 제27조 제1항" 및 "근로기준법 제31조 제2항"은 지방노동위원회의 구제명령 등에 불복 시 중앙노동위원회에 재심을 신청하고 그 재심판정에 대해 취소소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 명시하고 있다.

2. 일부인용 재심판정과 소의 이익

(1) 소의 이익의 의의

- 소의 이익이란 원고가 청구하는 판결을 통해 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 필요성을 말한다. 원고에게 유리하여 불이익이 없는 처분은 소의 이익이 흠결된다.

(2) 일부인용 시 소송 대상의 범위

- 일부인용 재결에 대해 청구인은 자신에게 불리하게 작용한 기각 부분에 대해서만 불복할 소의 이익을 가진다. 유리하게 취소·변경되어 불이익이 해소된 인용 부분은 다룰 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 재결주의에 따른 소송 대상

(1) 지방노동위원회 구제명령의 대상성 배제

- 지방노동위원회의 구제명령은 원처분에 해당하나, 노동위원회법상 재결주의가 적용되므로 취소소송의 대상이 될 수 없다.

(2) 중앙노동위원회 재심판정의 대상성 인정

- 재결주의에 따라 소송의 대상은 행정심판의 재결에 해당하는 중앙노동위원회의 재심판정으로 제한된다.

2. 일부인용 재심판정 중 소의 대상 확정

(1) 인용 부분의 소의 이익 결여

- 중앙노동위원회는 업무정지 처분이 정당하다고 보아 지방노동위원회의 구제명령을 취소하였다. 이는 A회사에게 유리한 인용 부분이므로 다룰 소의 이익이 없다.

(2) 기각 부분의 소의 이익 구비

- 중앙노동위원회는 해고를 부당노동행위로 보아 A회사의 재심신청을 기각하고 임금지급을 명하였다. 이는 A회사에게 불리한 기각 부분이므로 소의 이익이 인정된다.

IV. 결론

- 노동위원회법상 재결주의가 적용되므로 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정이 된다. 또한, 일부인용 재심판정의 특성상 사용자는 자신에게 불리한 기각 부분에 한하여 소의 이익을 가진다. 결론적으로 A회사가 제기할 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정 중 A회사의 재심신청을 기각한 부분(즉, 해고를 부당노동행위로 인정하여 해고기간 동안의 임금상당액 지급을 명한 부분)으로 확정된다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2017-1-1]감액변경처분에 대한 취소소송의 대상적격과 부적법한 행정심판을 거친 경우의 제소기간 준수 여부

《【문제1】 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 '의의가 있는 경우 행정심판법 제27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.'라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직직강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 감액처분에 불복하여 행정심판을 청구하였고 각하재결을 받은 후 재결서를 송달받은 즉시 2017년 5월 경 근로복지공단을 상대로 위 감액처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였다. 이 경우 당해 취소소송의 적법 여부를 검토하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 감액변경처분에 대한 취소소송의 대상적격과 부적법한 행정심판을 거친 경우의 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로복지공단은 甲의 이중보상을 이유로 이미 지급된 급여에 대하여 당초 징수결정(원처분)을 하였으나, 甲의 민원에 의해 그 세액의 일부를 감액하는 변경처분을 하였다. 이에 甲이 행정심판 각하재결을 거쳐 감액처분의 취소를 구하는 소송을 제기한 상황이다. 쟁점으로 <일부 감액처분이 있는 경우 취소소송의 대상(대상적격)이 무엇인지>, <부적법한 행정심판을 거친 경우 재결서 정본 송달일을 제소기간의 기산점으로 삼을 수 있는지>, <처분 고지서상 소송 제기 기간에 대한 잘못된 고지(오고지)가 제소기간 계산에 영향을 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲이 제기한 취소소송의 적법성을 검토한다.

II. 감액변경처분과 취소소송의 대상적격

1. 원처분주의와 감액변경처분의 대상적격

(1) 대상적격의 원칙

- "행정소송법 제19조"에 의하면 취소소송은 행정청의 처분을 대상으로 한다. 행정심판을 거친 경우에도 재결에 고유한 하자가 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 감액변경처분의 경우

- "대법원"은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액된 경우, 그 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 독립된 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가질 뿐이라고 판시한다. 따라서 취소소송의 대상은 감액변경처분이 아니라 감액되고 남은 내용의 당초처분이 된다.

2. 소구 대상의 해석

(1) 형식적 기재와 실질적 취지

- 원고가 소송에서 소의 대상을 감액변경처분으로 기재하였더라도, 이는 실질적으로 감액되고 남은 당초처분의 취소를 구하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

(2) 법원의 석명 의무

- 법원은 원고가 대상을 오인하여 청구취지를 잘못 기재한 경우, 석명권을 행사하여 청구취지를 감액되고 남은 당초처분으로 적절히 변경하도록 유도하여야 한다.

III. 행정심판을 거친 경우의 제소기간과 오고지의 효력

1. 제소기간과 행정심판의 적법성

(1) 원칙적인 제소기간의 제한

- "행정소송법 제20조 제1항"에 의하면 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 행정심판을 거친 경우에는 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있다.

(2) 부적법한 행정심판의 효과

- "판례"에 의하면 행정심판을 거쳐 제소기간이 연장되기 위해서는 그 행정심판 청구가 적법하여야 한다. 행정심판 청구기간을 도과하는 등 부적법하여 심판청구가 각하된 경우에는 재결서 송달일을 기준으로 제소기간을 기산할 수 없으며, 당초처분이 있음을 안 날부터 제소기간을 계산하여야 한다.

2. 행정처분 고지서상 오고지의 효력

(1) 행정심판법상 오고지 규정의 준용 여부

- "행정심판법 제27조 제5항"은 오고지 시 더 긴 기간 내에 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나, "대법원"은 이 규정이 행정소송에 그대로 준용되지 않는다고 판시한다. 즉, 행정소송법에는 오고지에 관한 명문 규정이 없으므로 잘못된 고지가 있었다 하더라도 행정소송의 제소기간이 연장되지 않는다.

(2) 신뢰보호의 원칙 적용 한계

- 행정청의 오고지를 신뢰한 당사자 보호의 필요성이 있으나, 제소기간은 법적 안정성을 위한 불변기간이므로 신뢰보호원칙을 적용하여 법정 제소기간을 연장할 수는 없다는 것이 "판례"의 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

(1) 원처분의 확정

- 근로복지공단이 2016년 11월에 행한 감액처분은 2016년 3월의 당초 징수결정의 일부를 감액·취소한 것에 불과하므로 소송의 대상은 감액되고 남은 당초의 징수결정이다.

(2) 甲의 소송 대상 오인

- 甲은 감액처분 자체의 취소를 구하고 있어 소송 대상을 오지정하였으나, 법원의 석명권 행사를 통해 청구취지를 감액되고 남은 당초 징수결정으로 변경하면 대상적격의 흠결은 치유될 수 있다.

2. 제소기간의 준수 여부

(1) 각하재결에 따른 제소기간 기산일

- 甲은 당초 징수결정(2016년 3월) 또는 늦어도 감액처분(2016년 11월)이 있은 후 적법한 심판청구기간 내에 행정심판을 제기하지 않아 각하재결을 받았다. 이처럼 부적법한 행정심판에 해당하므로 재결서 송달일인 2017년 5월경은 기산일이 될 수 없다.

(2) 제소기간 도과에 따른 부적법

- 제소기간의 기산일은 처분이 있음을 안 날인 2016년 3월(혹은 감액처분일인 2016년 11월)이 되며, 이로부터 90일이 모두 경과한 2017년 5월에 제기된 소송은 제소기간을 도과하여 부적법하다. 고지서상의 오고지가 있었다 하더라도 제소기간 연장 등의 효력이 없으므로 제소기간 도과의 흠결은 치유되지 않는다.

V. 결론

- 甲이 제기한 취소소송은 대상적격의 경우 청구취지 해석 및 석명을 통해 감액되고 남은 당초 징수결정으로 다룰 수 있어 충족될 여지가 있다. 그러나 제소기간의 경우, 선행한 행정심판이 부적법하여 각하되었으므로 재결서 송달일을 기산점으로 삼을 수 없고, 고지서의 오고지 구제 규정 또한 행정소송에 준용되지 않는다. 결국 처분이 있음을 안 날부터 90일의 불변기간이 도과한 후인 2017년 5월에 소를 제기하였으므로, 당해 취소소송은 제소기간을 준수하지 못해 부적법하며 법원에 의해 각하되어야 한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2017-3]행정심판의 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

《【문제3】 행정심판 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우를 설명하시오. (25점)》

<문제3> 행정심판의 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

I. 문제의 제기

- "행정소송법 제19조"는 행정심판의 재결에 대하여 원처분주의를 선언하여 원칙적으로 원처분을 소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결을 취소소송의 대상으로 규정하고 있다. 또한 개별 법령에서 원처분 소송을 배제하고 재결만을 다투도록 하는 재결주의를 채택하고 있는 경우도 존재한다. 이하에서는 재결이 취소소송의 대상이 되는 구체적 요건과 유형을 살펴보고, 실제 사례에 대입하여 소송법상 구제방안에 대하여 설명한다.

II. 원처분주의와 재결 고유의 위법

1. 원처분주의의 원칙

- 취소소송은 원칙적으로 행정청의 처분을 대상으로 하며, 행정심판의 재결은 처분의 위법 여부를 확인한 선언에 불과하므로 소송의 대상이 될 수 없다.

2. 재결 자체에 고유한 위법의 범위

(1) 주체·절차·형식의 위법

- 재결권한이 없는 기관이 재결을 내린 경우(주체), 심의나 의결 등 필요한 절차를 거치지 않은 경우(절차), 재결서의 형식을 결여한 경우(형식)가 이에 속한다.

(2) 내용상의 위법

- 처분청에는 없는 위법이 재결에만 특유하게 발생한 경우로서, 사실오인이나 법리오해 등이 포함되며 "판례"는 내용상의 위법 역시 재결 고유의 하자로 인정한다.

III. 재결소송이 허용되는 예외적 유형

1. 제3자효 행정행위의 인용재결 및 사정재결

(1) 제3자의 청구에 따른 수익적 처분의 취소

- 영업자 등 제3자가 행정심판을 청구하여 인용재결이 내려지면 원처분의 상대방은 해당 인용재결로 인하여 비로소 권리 침해를 받게 되므로 재결을 다투어야 한다.

(2) 사정재결의 예외적 대상성

- 청구인의 청구가 이유 있음에도 공공복리를 이유로 기각하는 사정재결은 재결 자체의 공공복리 형량에 하자가 있음을 주장하여 재결소송을 제기할 수 있다.

2. 개별법상 재결주의가 채택된 경우

(1) 감사원의 변상판정처분

- 감사원의 재심의판정에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 규정하여 원처분의 소송 대상성을 전면 배제한다.

(2) 노동위원회의 재심판정

- 지방노동위원회의 구제명령 등에 불복 시 중앙노동위원회에 재심을 신청하여 그 재심판정만을 취소소송의 대상으로 삼도록 제한한다.

IV. 구체적 양태

1. 제3자의 인용재결로 불이익을 입은 수혜자

(1) 소송 대상의 지정

- 원처분은 자신에게 유리하였으므로 소의 이익이 없고, 수혜자는 자신에게 침익적 처분인 인용재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 피고적격의 확정

- 소송의 대상이 재결 자체이므로 피고는 원처분청이 아닌 인용재결을 내린 행정청인 행정심판위원회가 되어야 적법하다.

2. 부당해고 구제명령에 불복하는 사용자

(1) 재결주의의 관철

- 사용자는 지방노동위원회의 구제명령을 대상으로 소송을 제기할 수 없으며, 반드시 중앙노동위원회의 재심판정을 대상으로 소송을 제기하여야 한다.

(2) 피고의 특정

- "노동위원회법 제27조 제2항"에 따라 피고는 중앙노동위원회가 아닌 중앙노동위원회 위원장을 피고로 지정하여 소송을 진행하여야 한다.

V. 결론

1. 예외적 대상성의 성립

- 행정심판 재결은 원칙적으로 소송의 대상이 되지 못하나, 재결 자체에 고유한 위법이 존재하는 경우와 개별법상 재결주의가 규정된 특수 영역에 한하여 예외적으로 취소소송의 대상이 된다.

2. 구체적 구제방안의 확정

- 당사자는 제3자효 인용재결 시 행정심판위원회를 피고로 재결소송을 제기하고, 노동위원회 사건 시 중앙노동위원회 위원장을 피고로 재심판정취소소송을 제기하여 실효성 있게 권리를 구제받아야 한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2020-1-1]일부인용재결 및 감경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

《【문제1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A시 소재의 3층 건물의 1층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3월의 영업정지처분을 1월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲이 제기하는 취소소송의 대상적격, 피고적격, 제소기간에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 일부인용재결 및 감경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 3월의 영업정지처분에 대하여 행정심판을 청구하였고, 일부인용재결에 따라 1월의 영업정지처분으로 변경되었으나 이에 불복하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <甲이 제기하는 취소소송에서 소의 대상, 피고 및 제소기간이 적법하게 갖추어졌는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기하는 취소소송의 대상적격, 피고적격, 제소기간에 대하여 논한다.

II. 감경 변경재결 및 후속 변경처분이 있는 경우의 법리

1. 대상적격의 판단 기준

(1) 원처분주의의 원칙

- "행정소송법 제19조 본문"에 따라 취소소송은 원칙적으로 행정청의 처분을 대상으로 한다. 행정심판을 거친 경우라 하더라도 재결 자체에 고유한 하자가 없는 한 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 감경 변경처분의 경우

- "대법원"은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액되거나 감경된 경우, 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 독립된 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가진다고 판시한다. 따라서 취소소송의 대상은 감경 변경처분이 아니라 감경되고 남은 내용의 당초처분이 된다.

2. 피고적격의 판단 기준

(1) 처분청 피고의 원칙

- "행정소송법 제13조 제1항"에 따라 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분을 행한 행정청(처분청)을 피고로 삼아야 한다.

(2) 피고 지정의 법리

- 일부인용재결에 따라 당초처분의 효력이 일부 감경된 경우라 하더라도, 소송의 대상이 원처분(감경되고 남은 당초처분)인 이상, 피고는 재결을 내린 행정심판위원회가 아니라 원래의 원처분을 행한 처분청이 되어야 한다.

3. 제소기간의 기산점과 계산

(1) 행정심판을 거친 경우의 특징

- "행정소송법 제20조 제1항 단서"에 의하면 행정심판을 거쳐 취소소송을 제기하는 경우, 제소기간은 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내로 규정되어 있다. 이는 불변기간에 해당한다.

(2) 기간 계산의 원칙

- "민법 제157조" 및 "행정소송법 제8조 제2항"에 따라 기간을 계산할 때는 초일을 산입하지 아니한다(초일불산입 원칙). 따라서 재결서 정본을 송달받은 다음 날부터 기산하여 90일이 되는 날을 만료일로 산정한다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- 사안에서 A시장 乙이 행한 2020. 3. 17.자 후속 변경처분은 당초의 3월 영업정지처분을 1월로 감경한 것에 불과하다. 따라서 甲이 제기해야 할 취소소송의 대상은 2020. 3. 17.자 변경처분이 아니라 1월의 영업정지처분으로 변경되고 남은 당초 2019. 12. 26.자 영업정지처분이 되어야 한다. 그러므로 변경처분 자체를 소송의 대상으로 삼고자 하는 甲의 계획은 대상적격을 오지정한 것으로서 부적법하다.

2. 피고적격의 충족 여부

- 취소소송의 대상이 1월로 변경되고 남은 당초의 영업정지처분이므로, 피고는 해당 원처분을 행한 행정청인 A시장 乙이 되어야 한다. 만약 甲이 행정심판을 거쳤다는 이유로 재결청인 행정심판위원회를 피고로 지정하여 소를 제기한다면 피고적격을 결여한 것으로서 부적법하다. 다만, 이는 법원의 피고경정("행정소송법 제14조") 절차를 통해 구제받을 여지가 있다.

3. 제소기간의 준수 여부

(1) 기산일의 확정

- 甲은 2020. 3. 10.에 행정심판 재결서 정본을 송달받았다. 초일불산입 원칙에 따라 제소기간의 기산일은 다음 날인 2020. 3. 11.이 된다.

(2) 90일 만료일 산정

- 2020. 3. 11.부터 90일이 되는 날을 계산하면 다음과 같다. 3월은 총 31일까지 있으므로 기산일인 11일부터 31일까지 남은 일수는 21일이다. 4월은 30일, 5월은 31일이므로 여기까지의 누적 일수는 82일(21+30+31)이다. 따라서 90일이 만료되는 날은 6월의 8번째 날인 2020. 6. 8.(월)이 된다.

(3) 준수 여부 판단

- 甲은 2020. 6. 15.에 취소소송을 제기하고자 한다. 이는 적법한 제소기간의 만료일인 2020. 6. 8.을 이미 초과한 시점이므로, 甲의 소송은 제소기간을 준수하지 못하여 부적법하다.

N. 결론

- 사안에서 甲이 제기하고자 하는 취소소송은 소송요건을 결여하여 부적법하므로 법원에 의해 각하되어야 한다. ❶ 소송의 대상은 감경되고 남은 당초 처분이어야 하므로 후속 변경처분을 대상으로 삼은 것은 대상적격을 결여한 것이다. ❷ 피고는 행정심판위원회가 아닌 원처분청인 A시장 乙이 되어야 한다. ❸ 가장 결정적으로 재결서 정본 송달일인 2020. 3. 10.로부터 90일이 되는 날은 2020. 6. 8.이므로, 2020. 6. 15.에 제기하는 소송은 불변기간인 제소기간을 경과하여 구제받을 수 없는 부적법한 소에 해당한다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2021-2]행정청의 환지예정지지정처분에 대한 사정재결 후 취소소송 대상

《【문제2】 X시장의 환지예정지지정처분(이하 '이 사건 처분'이라 함)으로 불이익을 입은 甲은 이 사건 처분이 위법하다는 이유로 취소심판을 청구하였고 행정심판위원회는 처분의 위법을 인정하였다. 다만 행정심판위원회는 이 사건 처분이 취소될 경우 다수의 이해관계인에 대한 환지예정지지정처분까지도 변경됨으로써 기존의 사실관계가 뒤집어지고 새로운 사실관계가 형성되는 혼란이 발생될 수 있다는 이유로 이 사건 처분을 취소하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하여 위 심판청구를 기각하는 재결을 하였다. 甲이 이에 불복하여 취소소송을 제기할 경우 그 대상에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 행정청의 환지예정지지정처분에 대한 사정재결 후 취소소송 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 환지예정지지정처분에 대하여 취소심판을 청구하였고, 행정심판위원회는 처분의 위법성을 인정하면서도 처분을 취소하는 것이 공공복리에 크게 위배된다는 이유로 기각재결(사정재결)을 하였다. 쟁점으로 <행정심판위원회의 사정재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분 또는 재결을 소송의 대상으로 삼아야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 이에 불복하여 취소소송을 제기할 경우 그 대상에 대하여 설명한다.

II. 사정재결과 소의 대상에 관한 법리

1. 사정재결의 의의 및 성격

(1) 사정재결의 의의

- "행정심판법 제44조 제1항"에 의하면 행정심판위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하면 그 심판청구를 기각하는 재결(사정재결)을 할 수 있다.

(2) 사정재결의 성격

- 사정재결은 본안심리 결과 원처분이 위법·부당함에도 불구하고 예외적으로 공익상 필요에 의해 청구를 기각하는 것이므로 실질은 인용에 가깝지만 형식은 기각재결이다. 위원회는 재결 주문에서 당해 처분이 위법하거나 부당하다는 것을 명시하여야 한다.

2. 원처분주의와 재결 자체에 고유한 위법

(1) 행정소송법 제19조의 규정

- 우리 행정소송법은 원칙적으로 원처분을 취소소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결에 대한 취소소송을 제기하도록 규정하고 있는데, 이를 원처분주의라고 한다.

(2) 재결 자체에 고유한 위법의 범위

- 재결 고유의 위법이란 원처분에는 존재하지 않고 재결에만 특유하게 존재하는 주체, 절차, 형식 또는 내용상의 하자를 의미한다.

3. 사정재결 시 취소소송의 대상 범위

(1) 이 사건 처분(원처분)이 소의 대상이 되는 이유

- 사정재결은 형식적으로 청구를 물리치는 기각재결에 불과하므로 위법한 당초 처분의 효력은 소멸하지 않고 그대로 유효하게 존속한다. 따라서 청구인이 당초 처분인 환지예정지지정처분의 위법을 구체적으로 다투고자 하는 경우에는 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 사정재결(재결) 자체가 소의 대상이 되는 이유

- "대법원"은 사정재결을 함에 있어서 공공복리에 대한 판단을 잘못하여 기각재결을 한 사안과 관련하여 사정재결의 요건이 충족되지 않았다는 사정은 재결 자체에 고유한 위법에 해당한다고 본다. 따라서 청구인이 행정위의 공공복리 형량 오류 및 재결 자체의 부당함을 공격하고자 하는 경우에는 사정재결 자체를 소송의 대상으로 삼을 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 원처분인 환지예정지지정처분을 다투는 경우

- X시장의 처분은 행정위의 심리 결과 위법함이 선언되었으나, 사정재결로 인하여 효력이 유효하게 존속하는 가공의 상태에 놓여 있다. 따라서 甲이 당해 환지예정지지정처분에 존재하는 본래의 하자를 이유로 처분의 효력 자체를 부인하고자 취소소송을 제기할 때에는 원처분인 환지예정지지정처분을 소의 대상으로 설정하여야 한다.

2. 사정재결 자체의 위법성을 다투는 경우

- 행정위는 다수의 이해관계인 처분의 변동과 사실관계의 반복에 따른 혼란을 공공복리 위해 사유로 지적하여 사정재결을 하였다. 그러나 甲이 행정위의 이러한 사정재결 요건 구비 여부에 이의를 제기하여 공공복리 형량 판단에 중대한 하자가 존재함을 주장하는 경우에는 원처분에는 없는 재결 자체의 고유한 하자를 다투는 것이 되므로 사정재결 자체를 소의 대상으로 삼을 수 있다.

IV. 결론

1. 원처분을 다투는 구체 방안

- 甲이 환지예정지지정처분에 존재하는 실체상의 위법 사유를 규명하여 처분의 취소를 쟁취하고자 하는 경우에는 원처분주의 원칙에 따라 원처분인 환지예정지지정처분을 소의 대상으로 삼아야 한다.

2. 재결 고유의 위법을 다투는 구체 방안

- 甲이 사정재결의 전제 요건인 공공복리의 현저한 침해 우려가 사실상 부존재하거나 형량 판단에 오인이 있음을 집중 공격하고자 하는 경우에는 재결 특유의 하자를 주장하는 셈이므로 사정재결(기각재결) 자체를 소의 대상으로 삼아 제소할 수 있다.

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

[기출][2025-2]감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

《【문제2】개업노무사로 업무를 수행하고 있는 甲은 2024. 3. 한 달 동안 3차례에 걸쳐 노동 관계 법령에 위반되는 행위에 관한 지도·상담을 하다가 관할 지방고용노동청에 적발되었다. 이에 고용노동부장관 A는 공인노무사자격심의·징계위원회의 징계의결에 따라 2024. 8. 26. 甲에게 6월의 직무정지처분을 하였고, 甲은 다음 날 그 처분서를 수령하였다. 甲은 2024. 9. 30. 6월의 직무정지처분이 재량권을 일탈·남용하였다는 관할 행정심판위원회에 6월의 직무정지처분의 취소심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 2024. 11. 4. 'A가 甲에 대하여 한 6월의 직무정지처분을 3월의 직무정지처분으로 변경하라'는 일부인용의 이행재결을 하였으며, 2024. 11. 18. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. A는 재결의 취지에 따라 2024. 11. 25. 甲에게 '6월의 직무정지처분을 3월의 직무정지처분으로 변경한다'는 취지의 후속 변경처분을 하였으나, 甲은 이 또한 과도한 제재처분이라면서 2024. 11. 25.자 3월의 직무정지처분을 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 2024. 12. 10. 취소소송을 제기하였다. 이 경우 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토하시오. (25점)》

<문제2> 감경 변경재결 및 후속 변경처분에 따른 취소소송의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간 준수 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 6월의 직무정지처분에 대하여 취소심판을 청구하여 일부인용재결을 받았고, 이에 따라 A가 3월의 직무정지처분으로 변경하는 후속처분을 하자 이를 대상으로 관할 행정심판위원회를 피고로 하여 취소소송을 제기하였다. 쟁점으로 <甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격이 인정되는지 및 제소기간을 준수하였는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 제기한 취소소송의 대상적격과 피고적격 그리고 제소기간의 준수 여부에 관하여 각각 검토한다.

II. 감경 변경처분의 대상적격 · 피고적격 · 제소기간의 법리

1. 대상적격의 판단 기준

(1) 변경명령재결과 변경처분의 관계

- 행정심판위원회의 변경명령재결에 따라 처분청이 후속 변경처분을 한 경우, 변경처분은 당초처분을 완전히 대체하여 소멸시키는 처분이 아니라 당초처분의 일부를 취소·감경하는 성격을 가진다.

(2) 판례의 태도

- "대법원"은 행정처분이 변경처분에 의하여 감액된 경우, 소송의 대상은 감액 변경처분이 아니라 감액되고 남은 감액된 내용의 당초처분이라고 일관되게 판시하고 있다. 따라서 소송의 대상은 3월로 감경되고 남은 당초의 직무정지처분이 된다.

2. 피고적격의 판단 기준

(1) 처분청 피고의 원칙

- "행정소송법 제13조 제1항"에 따라 취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분을 행한 행정청(처분청)을 피고로 하여야 한다.

(2) 재결소송과의 구별

- 원처분주의를 취하는 현행법상 재결 자체에 고유한 하자가 없는 한 재결의 피고인 행정심판위원회가 아니라 원처분청을 피고로 해야 한다.

3. 제소기간의 기산점과 계산 법리

(1) 행정심판을 거친 경우의 특징

- "행정소송법 제20조 제1항 단서"에 따라 행정심판을 거친 경우의 제소기간은 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다.

(2) 불변기간의 적용

- 이 기간은 불변기간이며, 초일불산입 원칙에 따라 초일은 산입하지 아니한다.

III. 사안의 적용

1. 대상적격의 충족 여부

- A의 2024. 11. 25.자 후속 변경처분은 6월의 직무정지처분을 3월로 감경한 것에 불과하므로, 소송의 대상은 후속 변경처분이 아니라 3월의 직무정지처분으로 변경된 당초 2024. 8. 26.자 처분이다. 따라서 2024. 11. 25.자 변경처분 자체를 대상으로 한 甲의 소송은 대상적격을 결여하여 위법하다.

2. 피고적격의 충족 여부

- 취소소송의 피고는 처분을 행한 행정청인 고용노동부장관 A가 되어야 한다. 그럼에도 불구하고 甲은 재결을 내린 행정심판위원회를 피고로 지정하였으므로 피고적격을 결여하여 부적법하다. 다만, 이는 법원의 피고경정("행정소송법 제14조")을 통해 구제받을 여지가 있다.

3. 제소기간의 준수 여부

- 甲은 2024. 11. 18. 재결서 정본을 송달받았으므로 제소기간의 기산일은 2024. 11. 19.이다. 이로부터 90일이 되는 날은 2025. 2. 16.이 된다. 甲은 2024. 12. 10.에 소를 제기하였으므로, 90일의 제소기간을 적법하게 준수하였다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 제기한 취소소송은 제소기간은 준수하였으나, 대상적격과 피고적격을 잘못 지정하여 부적법하다. 소송의 대상은 변경처분이 아니라 3월로 변경된 당초처분이어야 하고, 피고는 행정심판위원회가 아니라 고용노동부장관 A이어야 한다. 따라서 법원은 피고경정 절차를 거치지 않는 한 소각하 판결을 내려야 한다. 다만, 제소기간 내에 소가 제기되었으므로 피고경정 및 청구취지 변경을 통해 소송의 하자를 치유할 수 있다.

<사실관계 정리>

순서	일방	타방	내용	일자	비고
1	고노동장관 A	노무사 甲	6월 직무정지처분	2024.08.26.	2024.08.27. 甲은 처분서 수령
2	노무사 甲	행정심판위원회	취소심판	2024.09.30.	
3	행정심판위원회	고노동장관 A	이행재결(일부인용(3월))	2024.11.04.	2024.11.18. 甲은 재결서 정본 수령
4	고노동장관 A	노무사 甲	3월 직무정지처분	2024.11.25.	
5	노무사 甲	행정심판위원회	취소소송(순서4의 처분)	2024.12.10.	

<제03장 취소소송의 당사자자격.제01절 원고적격>

[기출][2013-1-1]법인인 회사를 대상으로 한 처분에 대한 대표이사 개인과 경제적 불이익을 받는 근로자의 원고적격 여부

《[문제1] 甲은 乙이 대표이사로 있는 A운수주식회사에서 운전기사로 근무하고 있는데, A회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲의 법령위반행위로 인하여 A회사에 과징금이 부과된 경우, A회사에 갈음하여 대표이사인 乙이 스스로 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? 또한 乙이 甲의 법령위반행위로 인한 과징금의 액수가 과다하지만 그 액수만큼 甲에 대한 상여금에서 공제할 수 있어 회사에 실질적인 손해가 없다고 생각하여 과징금부과처분에 대한 취소소송의 제기에 적극적인 태도를 보이지 않는 경우, 甲이 당해 과징금부과처분에 대한 취소소송을 제기한다면 이 소송은 적법한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 법인인 회사를 대상으로 한 처분에 대한 대표이사 개인과 경제적 불이익을 받는 근로자의 원고적격 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 운전기사 甲의 법령위반행위로 A회사에 과징금이 부과된 상황이다. 쟁점으로 <A회사에 부과된 과징금부과처분에 대해 대표이사 乙이 회사를 대신하여 자신의 이름으로 제기한 취소소송이 원고적격 요건을 충족하여 적법한지>, <회사가 소송에 적극적이지 않자 운전기사인 근로자 甲이 제기한 취소소송과 관련하여, 노사 임금협정에 기한 상여금 공제라는 불이익이 행정소송법 제12조의 법률상 이익에 해당하여 원고적격이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련한 구체적인 행정소송법상 법리를 검토하고 사안에 적용하여 각 소송의 적법 여부를 검토한다.

II. 대표이사 乙의 취소소송의 적법 여부

1. 법인격 독립의 원칙과 처분의 상대방

(1) 법인과 자연인의 법적 분리

- 법인은 자연인과 별개의 독립된 법적 주체이므로, 법인에 귀속되는 권리·의무 관계는 대표자 개인의 권리·의무 관계와 엄격히 구별된다. 행정처분의 효과가 법인에게 귀속되는 경우, 그 처분의 직접 상대방은 법인이지 대표이사 개인이 아니다.

(2) 소송당사자 자격의 법인 귀속

- 따라서 처분의 취소를 구할 수 있는 원칙적인 권리구제의 주체는 처분의 직접 상대방이자 법적 권리·의무의 주체인 법인 자체가 된다.

2. 대표이사 개인의 원고적격 인정 여부

(1) 제3자 소송담당의 한계

- 대표이사는 법인의 대외적 대표 기관에 불과하므로, 법률에 명시적인 규정이 없는 한 법인의 권리관계를 구제하기 위해 대표자 개인의 이름으로 제3자 소송담당을 할 수 없다.

(2) 대표이사 개인의 이익의 성질

- 법인에 대한 처분으로 대표이사 개인이 간접적인 타격을 입더라도, 이는 사실상·경제적 이해관계에 불과하다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 대표이사 개인은 법률상 이익이 없으므로 법인에 대한 처분을 다룰 원고적격이 없다.

III. 근로자 甲의 취소소송의 적법 여부

1. 행정소송법 제12조의 원고적격과 법률상 이익

(1) 법률상 보호되는 이익의 의미

- “대법원”은 “행정소송법 제12조”의 법률상 이익이 있는 자를 당해 처분의 근거 법률 및 관련 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 가진 자로 제한하여 해석한다.

(2) 반사적·경제적 이익의 배제

- 공익 보호의 결과로 제3자가 간접적으로 누리는 반사적 이익이나 단순한 사실상·경제적 이해관계는 법률상 이익에 포함되지 않으므로 원고적격이 부정된다.

2. 사적 약정에 기한 불이익과 법률상 이익

(1) 사법상 인과관계에 따른 불이익

- 행정처분의 직접적 효과가 아니라, 당사자 간에 체결된 사적인 계약이나 단체협약·임금협정 등의 사법상 약정에 기해 비로소 제3자에게 불이익이 전가되는 경우이다.

(2) 공법상 보호이익과의 단절성

- 과징금 부과 근거 법령은 근로자 개인의 사법상 임금이나 상여금 보호를 목적으로 설계된 것이 아니므로, 사적 계약에 기한 경제적 손실은 법률상 보호되는 이익이 될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 대표이사 乙의 소송제기에 대한 적용

(1) 처분의 상대방과 제기 주체의 불일치

- 사안에서 과징금부과처분의 상대방은 대표자 개인이 아니라 A운수주식회사라는 법인이다. 대표이사 乙은 법인의 기관으로서 법인의 이름으로 소송을 제기해야 할 뿐이다.

(2) 원고적격의 흠결

- 乙이 법인에 갈음하여 스스로(대표이사 개인의 이름으로) 소송을 제기한 것은 소송수행권 내지 원고적격이 없는 자가 제기한 소송에 해당하여 부적법하다.

2. 근로자 甲의 소송제기에 대한 적용

(1) 임금협정에 따른 불이익의 법적 성질

- 甲이 입게 되는 상여금 공제 불이익은 과징금부과처분 자체에 의해 직접 발생하는 법적 효과가 아니다. 이는 A회사 노사간에 체결된 임금협정이라는 사법상 계약을 매개로 발생하는 간접적·경제적 불이익에 불과하다.

(2) 법률상 이익의 부정에 따른 부적법성

- 과징금 부과에 근거 법령이 운전기사 개인의 상여금 확보 등 경제적 이익을 보호하는 것을 목적으로 하지 않으므로, 甲에게는 취소소송을 제기할 법률상 이익이 인정되지 않아 소송이 부적법하다.

V. 결론

1. 乙이 제기한 취소소송의 적법 여부

- 대표이사 乙은 과징금부과처분의 직접 상대방이 아니며 이를 자신의 이름으로 다룰 원고적격이 없으므로, 乙이 제기한 소송은 부적법하여 법원은 각하 판결을 내려야 한다.

2. 甲이 제기한 취소소송의 적법 여부

- 과징금 부과로 인한 甲의 상여금 감액 불이익은 임금협정이라는 사적 약정에 기한 간접적·경제적 불이익에 불과해 법률상 이익이 인정되지 않는다. 따라서 甲은 원고적격이 없으며, 甲이 제기한 소송 역시 부적법하여 법원은 각하 판결을 내려야 한다.

《[문제3] 취소소송에서 원고적격의 확대와 관련하여 이른바 제3자요 행정행위의 원고적격에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제3> 제3자요 행정행위의 취소소송에서 제3자의 원고적격 인정 범위와 유형별 판단 기준

I. 문제의 제기

- <행정청의 처분이 당사자에게는 이익을 주지만 제3자에게는 불이익을 주는 제3자요(이중효과적) 행정행위의 경우, 불이익을 입은 제3자가 소송을 제기할 수 있는지>가 원고적격의 핵심 쟁점이 된다. 전통적으로 행정소송은 처분의 직접 상대방에게만 원고적격을 인정하는 경향이 있었으나, 현대 복효적 행정관계의 다양화에 따라 국민의 실질적인 재판청구권 보장 및 권리구제를 위해 제3자의 원고적격 확대가 강력히 요구된다. 이하에서는 제3자요 행정행위에서 "행정소송법 제12조"의 법률상 이익의 의미를 고찰하고, 경업자·경원자·이웃소송 등 구체적 유형별 판례의 태도를 통해 원고적격 인정 범위에 대해 설명한다.

II. 제3자요 행정행위의 의의와 법률상 이익의 범위

1. 제3자요 행정행위의 의의

- 제3자요 행정행위란 하나의 행정처분이 어느 사람에게는 권리나 이익을 부여하는 수익적 효과를 발생시키는 동시에, 다른 사람에게에는 권리나 이익을 침해하는 침익적 효과를 발생시키는 행정행위를 의미한다.

2. 법률상 이익의 범위

(1) 학설의 대립

- 처분등으로 인하여 권리가 침해된 자만이 항고소송을 제기할 수 있는 원고적격을 가진다는 권리구제설, 보호규범이론에 근거하여 위법한 처분에 의하여 침해되고 있는 이익이 근거 법률에 의하여 보호되고 있는 이익인 경우에는 그러한 이익이 침해된 자에게도 처분의 취소를 구할 원고적격이 인정된다고 보는 법적 이익구제설, 항고소송의 주된 기능을 행정통제에서 찾고, 처분의 위법성을 다룰 적합한 이익을 가지는 자에게 원고적격을 인정하는 적법성 보장설 등이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- "대법원"은 근거 법령 및 관계 법령에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 의미하며, 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계에 불과한 경우에는 원고적격을 부정하는 법적 이익구제설의 입장을 취하고 있다.

III. 제3자 원고적격의 구체적 유형별 검토

1. 경업자 소송

(1) 의의

- 동일한 영업구역 내의 기존 업자가 신규 업자에 대한 면허나 허가 처분으로 인해 경영상 타격을 입게 됨을 이유로 그 처분의 취소를 구하는 소송이다.

(2) "판례"의 태도

- 당해 사업이 특정인에게 독점적 권리를 설정하는 특허(면허)인 경우에는 기존 업자의 경영상 이익을 법률상 이익으로 보아 원고적격을 인정한다. 반면, 일반적 금지를 해제하는 허가 사업인 경우에는 기존 업자의 이익을 단순한 반사적 이익으로 보아 원고적격을 부정한다.

2. 경원자 소송

(1) 의의

- 인허가 등의 처분을 신청한 여러 사람 중 일방에 대한 면허 처분이 타방에 대한 거부처분으로 귀결될 수밖에 없는 상호 배타적 관계에서의 소송이다.

(2) "판례"의 태도

- 허가 정수가 정해져 있어 일방의 인허가로 타방의 탈락이 확정되므로, 탈락한 경원자는 자신의 거부처분뿐만 아니라 타방에 대한 인허가 처분의 취소를 구할 원고적격이 인정된다.

3. 이웃 소송(인근 주민 소송)

(1) 의의

- 공장 건립이나 토석채취허가 등 환경오염을 유발할 우려가 있는 처분에 대하여 인근 주민들이 환경상 이익 침해를 이유로 제기하는 소송이다.

(2) "판례"의 태도

- 환경영향평가 대상 구역 내 주민들은 환경상 이익 침해가 사실상 추정되어 원고적격이 인정된다. 반면 구역 외 주민들은 당해 처분으로 수인한도를 넘는 피해를 입거나 입을 우려가 있음을 스스로 입증하여야 원고적격이 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. 관계 법령의 확대를 통한 법률상 보호 이익의 도출

- 이른바 제3자요 행정행위에서 제3자의 원고적격은 당해 처분의 직접 근거 법률뿐만 아니라 관련법 및 조례 등 관계 법령까지 종합 해석하여 도출된다. 사법부는 법령의 목적이 공익뿐만 아니라 사익도 개별적·구체적으로 보호하고 있는지를 면밀히 판단하여 제3자의 소송 참여를 확대 적용하고 있다.

2. 기본권 규정과의 조화로운 해석 적용

- "판례"는 기본권 규정으로부터 직접 법률상 이익을 인정하는 것에는 신중하지만, 근거 법령이 불확정 개념을 포함하고 있는 경우 환경권이나 직업의 자유 등 헌법상 기본권 가치를 고려하여 법령의 사익 보호성을 긍정하는 방식으로 원고적격 범위를 실질적으로 넓히고 있다.

V. 결론

- 제3자요 행정행위에서 제3자의 원고적격은 사법통제의 실질화와 행정의 적법성 확보를 위해 지속적으로 확대되는 추세에 있다. 판례는 법률상 보호되는 이익설의 틀을 유지하면서도 관계 법령의 범위를 넓히고 경업자·경원자·이웃소송 등의 유형별 법리를 체계화하여 제3자의 재판청구권을 충실히 보장하고 있다. 결론적으로 제3자요 행정행위에 대한 원고적격의 합리적 확대는 행정의 일방적 집행에 견제 장치를 마련하고, 다면적 법률관계에서 이해관계인들의 권리를 조화롭게 보호하는 실질적 법치주의 구현의 핵심적 교두보 역할을 수행한다.

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

[기출][2022-1-1]토석채취허가에 대하여 비산먼지 피해를 우려하는 인근 영농법인의 취소소송 원고적격 인정 여부

《【문제1】 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 '이 사건 처분'이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 위 취소소송에서 甲의 원고적격은 인정될 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 토석채취허가에 대하여 비산먼지 피해를 우려하는 인근 영농법인의 취소소송 원고적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 관할행정청은 丙에게 P산지에 대한 토석채취허가를 하였고, 인근에서 과수원을 운영하는 영농법인 甲은 비산먼지 등으로 과수원과 영업에 피해를 입게 된다고 주장하며 그 허가처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 쟁점으로 <토석채취허가처분으로 영향을 받는 인근 영농법인 甲에게 취소소송을 제기할 원고적격이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 원고적격이 인정될 수 있는가를 설명한다.

II. 제3자의 원고적격과 환경상 이익 보호 법리

1. 행정소송법 제12조의 법률상 이익의 범위

(1) 법률상 보호되는 이익설의 내용

- “대법원”은 “행정소송법 제12조”의 법률상 이익이 있는 자에 대하여 법률상 보호되는 이익설의 입장을 취하고 있다. 즉, 당해 처분의 근거 법률 및 관계 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 의미하며, 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계를 가지는 데 불과한 경우에는 법률상 이익에 해당하지 않아 원고적격이 부정된다.

(2) 관련 법률의 범위 확대

- 이때 법률상 이익을 판단하는 기준이 되는 법률은 당해 처분의 직접적인 근거 법률뿐만 아니라, 그 처분과 밀접하게 연계된 관계 법률 및 관련 규정까지 포함하여 종합적으로 해석하여야 한다는 것이 “판례”의 일관된 태도이다.

2. 인근 주민의 원고적격 및 입증책임

(1) 영향권 기준에 따른 인용 여부

- 환경상 위해를 유발하는 처분에 대하여 인근 주민이 소를 제기하는 경우, “판례”는 법령상 환경영향평가 구역 등 환경상 이익이 보호되는 구역이 설정되어 있다면 그 구역 내 주민들의 환경상 이익 침해는 사실상 추정된다고 본다. 반면, 그러한 구역 밖의 주민이거나 별도의 규정이 없는 사안이라면, 당해 처분으로 인하여 자신의 생활환경이나 건강 등에 미치는 위해가 사회통념상 참을 수 있는 한도(수인한도)를 넘는다는 점을 원고가 스스로 입증하여야 원고적격이 인정된다.

(2) 환경상 침해와 재산상 이익의 보호

- “판례”는 인근 주민의 원고적격을 판단할 때 단순한 정신적·환경적 생활환경의 향유뿐만 아니라, 환경 오염으로 인하여 농작물이 훼손되거나 토지가 오염되는 등 직접적인 재산적 불이익을 입게 되는 경우 역시 법률상 보호되는 구체적 이익의 범주에 포함하여 파악하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 토석채취허가의 법적 성격과 보호규정

(1) 근거 법령의 입법 목적과 주민 보호

- 이 사건 처분인 토석채취허가의 근거가 되는 산지관리법 및 관련 환경 규정들은 산지 개발로 인하여 인근 주민들의 주거 생활환경이 파괴되거나 소음, 비산먼지, 진동 등으로 인해 인근 농경지 및 과수원 등 생업 기반이 훼손되는 피해를 방지하도록 행정청에 의무를 부과하고 있다. 이는 인근 주민들이 가지는 개별적·구체적 이익을 법적으로 보호하고자 하는 취지로 평가할 수 있다.

(2) 법인의 환경적·재산적 이익 보호 가능성

- 비록 甲이 자연인이 아닌 영농법인(법인)이라 하더라도, 실제로 처분 예정지 인근 산지 내에서 과수원을 소유·운영하며 경제 활동을 영위하고 있는 주체이다. 따라서 토석채취로 발생하는 비산먼지가 과수원 농작물에 직접적인 피해를 주어 잼 제조·판매업이라는 법인의 실질적 재산권을 침해한다면, 甲은 자연인 주민과 마찬가지로 법률상 이익을 가지는 주체로서 소송을 제기할 자격을 가질 수 있다.

2. 甲의 구체적 피해 및 원고적격 충족 판단

(1) 비산먼지로 인한 과수원 피해의 구체성

- 사안에서 甲이 재배하는 과일은 청정지역의 브랜드 가치를 지니고 있어 인기리에 판매되고 있으나, 과수원 바로 인근에서 석재가 채취되면 대량의 비산먼지가 발생하여 과일의 생육을 방해하고 상품 가치를 극도로 저하시킬 것이 명백하다. 이는 사실적·경제적 불이익을 넘어 법령이 보호하는 농업 생산 환경 및 재산권에 대한 직접적이고 구체적인 위해에 해당한다.

(2) 소송요건상 원고적격 인정 여부

- 따라서 甲은 과수원의 위치와 이 사건 처분이 행해지는 P산지와의 거리, 지형적 특성 등을 고려할 때 비산먼지의 직접적인 피해 범위 내에 존재한다는 사실과, 그 피해가 수인한도를 초과할 우려가 있음을 소송 과정에서 소명하여야 한다. 사안의 정황상 인근 과수원에 미치는 환경상 불이익이 직접적이고 중대하므로, 甲이 이러한 인과관계와 피해 우려를 소명한다면 “행정소송법 제12조”의 원고적격은 명백히 인정된다.

IV. 결론

- 사안에서 영농법인 甲이 乙시장의 이 사건 처분에 대해 제기하는 취소소송은 적법한 원고적격을 충족할 수 있다. 토석채취허가의 근거 법령이 인근 주거 및 농경지의 위해 방지를 목적으로 하고 있으므로, 과수원을 운영하는 甲의 재산적·환경적 이익은 단순한 반사적 이익이 아니라 법령에 의해 구체적으로 보호되는 이익에 해당한다. 결론적으로 甲이 토석채취로 인한 비산먼지 피해가 자신의 과수원에 수인한도를 초과하는 실질적인 불이익을 초래함을 구체적으로 소명한다면, 법원으로부터 “행정소송법 제12조”의 원고적격을 인정받아 본안 심리를 받을 수 있다.

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

[기출][2023-2]여객자동차운송사업 양도·양수 인가처분에 대한 제3자 경업자의 원고적격 인정 여부

《[문제2] A사에서 여객자동차운송사업을 하고 있는 甲은 운송사업 중 일부 노선을 같은 지역 여객자동차운송사업자인 乙에게 양도하였고, A시의 시장 X는 위 양도·양수를 인가하였다. 이 노선에는 甲이외에도 여객자동차운송사업자 丙이 일부 중복된 구간을 운영하고 있으며, 위 인가처분으로 해당 구간의 사업자는 甲, 乙, 丙으로 증가한다. 이에 丙은 기존의 경쟁 사업자 외에 乙이 동일한 운행경로를 포함한 운행계통을 가지게 되어 그 중복운행 구간의 연고 있는 사업자 수가 증가하고, 그 결과 향후 운행횟수 증회, 운행계통 신설 및 변경 등에 있어 장래 기대이익이 줄어들 것을 우려한다. 그런데 위 인가처분으로 인해 甲이 운행하던 일부 노선에 관한 운행계통, 차량 및 부대시설 등이 일체로 乙에게 양도된 것이어서, 이로 인하여 종전노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 변동이 있는 것은 아니다. 丙이 위 인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 경우, 원고적격이 인정되는가? (25점)》

<문제2> 여객자동차운송사업 양도·양수 인가처분에 대한 제3자 경업자의 원고적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시의 시장 X는 甲과 乙 사이의 일부 노선 양도·양수를 인가하였고, 동일한 중복구간을 운영하는 경쟁사업자인 丙은 장래의 영업상 기대이익이 침해될 것을 이유로 그 인가처분의 취소를 구하고자 한다. 쟁점으로 <기존 경쟁사업자인 丙에게 노선 양도·양수 인가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되어 원고적격이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 丙이 위 인가처분의 취소를 구하는 소송을 제기할 경우 원고적격이 인정되는가를 설명한다.

II. 경업자 소송과 원고적격의 법리

1. 원고적격의 판단 기준 및 경업자 소송

(1) 법률상 보호되는 이익

- "행정소송법 제12조 제1항"의 법률상 이익이 있는 자란 처분의 근거 법률 및 관계 법률에 의하여 보호되는 구체적이고 직접적인 이익을 가진 자를 의미하며, 단순히 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계를 가지는 데 불과한 자는 제외된다(법률상 보호되는 이익설).

(2) 경업자 소송의 의의와 판단 기준

- 경업자 소송이란 동일한 영업구역 내의 기존 업자가 신규 업자에 대한 허가나 면허 등 특허 처분으로 인하여 경영상 이익이 침해될 것을 주장하며 그 처분의 취소를 구하는 소송이다. 면허제도와 같이 특정인에게 독점적 권리를 부여하는 특허 사업인 경우에는 기존 업자의 이익이 법률상 보호되는 이익에 해당하므로 신규 면허 처분을 다룰 원고적격이 인정된다. 반면 일반적 금지를 해제하는 데 불과한 허가 사업인 경우에는 기존 업자의 이익이 단순한 반사적 이익에 불과하여 원고적격이 부정된다.

2. 단순 양도·양수 인가처분에서의 원고적격 한계

(1) 인가처분의 법적 성격

- 여객자동차운송사업의 양도·양수 인가처분은 양수인이 양도인의 사업자로서의 법적 지위를 그대로 승계하는 설관적 처분의 성격을 가진다.

(2) 실질적 변동이 없는 경우의 판례 태도

- "대법원"은 양도·양수 인가처분으로 인하여 양수인이 양도인의 지위를 승계하는 것에 불과하고, 종전의 노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 아무런 변동이 없는 경우라면 기존 업자의 이익 침해를 긍정하지 않는다. 이 경우 다른 경쟁 업자가 입게 되는 불이익은 단순한 사실상의 경쟁에 지나지 않으므로, 양도·양수 인가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없어 원고적격이 부정된다고 일관되게 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 여객자동차운송사업의 성격 및 경업자 관계의 성립 여부

- 여객자동차운송사업은 특정인에게 독점적 권리를 설정해 주는 강화상 특허에 해당한다. 사안의 중복 구간에 노선 면허가 신설되거나 증차 등의 처분이 직접 행해진 경우라면 丙에게 기존 업자로서 원고적격이 당연히 인정될 수 있다.

2. 단순 양도·양수 인가에 따른 법률상 이익 침해 여부

(1) 공급량 및 운행 밀도의 불변

- X시장의 인가처분은 기존 사업자인 甲의 노선과 차량 지위를 乙이 그대로 이전받는 지위 승계에 불과하다. 문제의 사실관계에서 '종전노선 및 운행계통이나 그에 따른 차량수 및 운행횟수 등에 변동이 있는 것은 아니다'라고 구체적으로 명시하고 있다. 즉, 시장 전체의 운송 공급량이나 중복 구간 내의 실질적인 경쟁 밀도는 처분 전후로 동일하다.

(2) 丙의 불이익의 법적 성질

- 乙이 새롭게 경쟁자로 진입함에 따라 丙이 우려하는 장래 기대이익의 감소 등은 새로운 면허 처분이나 운행 횟수 증회 처분 등에 의해 발생하는 직접적인 불이익이 아니다. 이는 사업 주체가 甲에서 乙로 교체됨에 따른 사실상의 경제적 반사이익의 감소에 불과하므로 법령에 의해 구체적으로 보호되는 법률상 이익이라 볼 수 없다. 따라서 丙의 원고적격은 인정될 수 없다.

IV. 결론

- X시장의 양도·양수 인가처분은 乙이 甲의 기존 사업 지위를 그대로 승계하는 것에 불과하며 실질적인 노선, 차량 수, 운행 횟수 등의 물리적 변동을 수반하지 않는다. 따라서 제3자 경업자인 丙이 주장하는 불이익은 법률상 구체적으로 보호되는 이익이 아니라 단순한 사실상의 경쟁 심화에 따른 경제적 반사이익 침해에 불과하다. 결론적으로 丙은 이 사건 인가처분의 취소를 구할 "행정소송법 제12조"의 원고적격을 결여하였으므로, 丙이 제기한 취소소송은 소송요건 흠결로 법원에 의해 부적법 각하되어야 한다.

<제03장 취소소송의 당사자자격.제02절 피고적격>

<제09장 무효등 확인소송.제02절 무효등 확인소송의 요건>

[기출][2025-1-2]내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

《[문제1] 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50점)》

<사례1>

근로자 甲은 A지방고용노동청장(이하 'A청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하였다. A청장은 '甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 <처분사유1>)'는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유1> 이외에 '甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 <처분사유2>)'라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유2>는 기존 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례2>

근로자 乙은 B지방고용노동청장(이하 'B청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음2) 乙은 환수처분의 발령 주체 상의 하자를 이유로, 환수처분에 대한 항고소송을 제기하여 담당부서장이 환수한 지원금을 다시 반환받고자 한다. i) 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고, ii) 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

I. 문제의 제기

- 사건에서 乙은 담당부서장 명의의 환수처분에 따라 지원금을 반환하였으나, 이후 그 환수처분에 발령 주체상의 하자가 있음을 이유로 이를 다투며 이미 환수한 지원금을 돌려받고자 한다. 쟁점으로 <발령 주체상의 하자가 있는 환수처분에 대하여 乙이 제기할 수 있는 항고소송의 유형과 피고 및 인용판결을 통하여 이미 환수한 지원금을 반환받을 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고 및 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명한다.

II. 항고소송의 구체적 유형과 피고적격

1. 환수처분의 하자의 정도와 성격

(1) 내부위임과 권한 귀속의 법리

- 내부위임은 행정청 내부의 업무 편의를 위한 권한 분담에 불과하므로 대외적인 권한은 여전히 위임청인 B청장에게 귀속된다. 따라서 수임청인 담당부서장은 위임청의 명의로 처분을 해야 하며, 자신의 명의로 처분을 할 수 없다.

(2) 주체상 하자의 정도와 효력

- 내부위임의 한계를 일탈하여 수임청인 담당부서장이 자신의 명의로 한 처분은 권한 없는 자에 의해 행해진 처분으로서 주체상의 하자가 존재한다. "대법원"은 이러한 권한 없는 자의 처분은 하자가 중대하고 명백하여 당연무효에 해당한다는 확고한 입장을 견지하고 있다.

2. 구체적 소송유형과 피고적격의 확정

(1) 구체적 소송유형의 선택

- 乙은 환수처분의 당연무효를 구하는 무효등 확인소송을 제기할 수 있다. 또한, 처분일로부터 제소기간인 안 날부터 90일 또는 있는 날부터 1년을 경과하지 않았다면 무효사유의 하자를 취소소송의 형태로 다투는 무효선언을 구하는 취소소송도 청구할 수 있다.

(2) 피고적격의 지정

- "행정소송법 제13조 제1항"에 따라 항고소송의 피고는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 처분을 행한 행정청이 된다. 비록 담당부서장이 실제법상 처분 권한이 없는 자라 하더라도 대외적으로 자신의 명의로 처분을 한 이상, 피고는 처분 명의자인 담당부서장이 되어야 한다.

III. 인용판결을 통한 지원금 반환의 논거

1. 법률상 원인의 소급적 소멸과 부당이득

(1) 처분 효력의 소급적 박탈

- 법원이 환수처분의 무효를 확인하거나 이를 취소하는 판결을 내리면, 해당 처분의 효력은 처분 시로 소급하여 소멸한다. 따라서 乙이 지원금을 국가에 반환한 법적 근거가 소급적으로 상실된다.

(2) 국가의 부당이득 반환 의무

- 처분의 효력이 상실됨에 따라 국가가 영수한 지원금은 법률상 원인 없이 보유하는 부당이득이 된다. 乙은 이를 근거로 국가를 상대로 민사상 부당이득반환청구소송을 제기하여 이미 반환한 지원금을 다시 돌려받을 수 있다.

2. 판결의 기속력과 결과제거의무

(1) 행정소송법 제30조의 기속력

- "행정소송법 제30조 제1항"에 따라 처분을 취소하거나 무효를 확인하는 판결은 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 기속력이 발생한다.

(2) 결과제거의무의 발생

- 판결의 기속력 중 소극적 의무로서 행정청은 위법한 처분으로 인해 발생한 가공의 상태를 제거해야 할 결과제거의무(원상회복의무)를 부담한다. 따라서 담당부서장 또는 B청장은 판결의 취지에 따라 위법한 환수처분으로 수령한 지원금을 乙에게 반환해야 할 공법상의 의무를 지게 된다.

N. 결론

- 乙은 권한 없는 자인 담당부서장이 행한 환수처분에 대하여 담당부서장을 피고로 삼아 무효등 확인소송 또는 무효선언을 구하는 취소소송을 제기하여야 한다. 乙이 승소할 경우 판결의 효력에 의해 환수처분의 법적 근거가 소급적으로 소멸하여 국가에 대한 부당이득반환청구권이 성립하게 되며, 판결의 기속력에 따라 행정청은 乙에게 지원금을 돌려주어야 하는 결과제거의무를 부담하게 되므로, 乙은 지원금을 실질적으로 반환받을 수 있다.

《[문제1] 건설회사에 근무하는 甲은 건설현장 불법행위 단속을 나온 공무원 乙의 중과실로 인하여 공사현장에서 업무 중 골절 등 산재사고로 인한 상해를 입었고, 이를 이유로 2014년 2월 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등을 지급받았다. 그런데 이후 甲이 회사가 가입하고 있던 보험회사로부터 별도로 장해보상금을 지급받자 근로복지공단은 甲이 이중으로 보상받았음을 이유로 2016년 3월경 이미 지급된 급여의 일부에 대한 징수결정을 하고 이를 甲에게 고지하였다. 그러나 甲이 이 같은 징수결정에 대해서 민원을 제기하자 2016년 11월경 당초의 징수결정 금액의 일부를 감액하는 처분을 하였는데, 그 처분 고지서에는 `이의가 있는 경우 행정심판법 제27조의 규정에 의한 기간 내에 행정심판을 청구하거나 행정소송법 제20조의 규정에 의한 기간 내에 행정소송을 제기할 수 있습니다.`라고 기재되어 있었다.

한편 공무원 乙은 공직기강확립 감찰기간 중 중과실로 甲에 대한 산재사고를 야기하였음을 이유로 해임처분을 받자 이에 대해서 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 해임처분취소소송의 계속 중 乙이 정년에 이르게 된 경우, 乙에게 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지 여부를 검토하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 해임처분취소소송 계속 중 정년에 도달한 공무원의 협의의 소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 공무원 乙은 해임처분에 대하여 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였으나, 소송 계속 중 정년에 이르게 되었다. 쟁점으로 <乙이 정년에 도달한 이후에도 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 해임처분취소소송의 계속 중 乙이 정년에 이르게 된 경우, 乙에게 해임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되는지 여부를 검토한다.

II. 공무원의 신분 상실 및 정년 도달과 협의의 소의 이익에 관한 법리

1. 협의의 소의 이익과 행정소송법 제12조 제2문

(1) 협의의 소의 이익의 의미

- 원고가 청구하는 판결을 통하여 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 필요성을 의미하며, 소송계속 중 사정변경으로 목적 달성이 불가능해진 경우 원칙적으로 소의 이익은 소멸한다.

(2) 제12조 제2문의 보충적 구제

- 처분의 효력이 소멸한 뒤에도 처분의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자는 소를 제기할 수 있다고 규정하여, 사실상 원직복직이 불가능하더라도 부수적인 법률상 이익이 있다면 소의 이익을 예외적으로 인정하고 있다.

2. 정년 도달 시 소의 이익에 관한 판례의 태도

(1) 소급 급여 및 퇴직급여 등 재산상 이익의 회복

- “대법원”은 공무원이 위법한 면직(해임 등)처분으로 인하여 신분상·재산상 불이익을 입은 경우, 처분 당시로 소급하여 법적 상태를 회복할 필요가 있다면 단순히 신분이 상실되었다는 사유만으로 소의 이익이 없다고 할 수 없다고 판시한다. 따라서 정년 도과로 원직복직은 불가능하더라도 처분이 취소되면 해임 시부터 정년까지의 기간 동안 받지 못한 급여 상당액(보수)을 청구할 수 있고, 공무원연금법상 퇴직급여 등의 감액 불이익을 방지할 수 있으므로 취소를 구할 법률상 이익이 인정된다.

(2) 행정처분의 공정력과 민사소송과의 관계

- 공무원의 해임은 행정처분이므로 공정력(구성요건적 효력)이 발생한다. 따라서 乙이 국가를 상대로 미지급 급여를 청구하는 당사자소송이나 민사소송을 제기하더라도, 선행 해임처분이 취소소송을 통해 취소되지 않는 한 수소법원은 처분의 위법성을 스스로 판단하여 급여 지급 판결을 내릴 수 없다. 그러므로 乙은 급여 청구의 전제로서 반드시 취소소송을 제기하여 해임처분의 공정력을 제거하여야 하므로 소의 이익이 명백히 인정된다.

III. 사안의 적용

1. 원직복직 불능과 급여 청구권의 회복 가능성

(1) 원직복직의 불가능성

- 乙은 소송 계속 중 정년에 도달하였으므로 법원이 해임처분을 취소하는 판결을 내리더라도 다시 공직으로 복귀하는 원직복직의 목적은 달성할 수 없다.

(2) 소급 급여 상당액 청구권의 확보

- 해임처분이 취소되면 해임 시로 소급하여 공무원의 신분이 회복된다. 따라서 乙은 해임일인 2014년 2월경부터 자신의 정년 도달일까지의 기간 동안 정상적으로 근무하였다면 지급받을 수 있었던 급여 상당액(보수) 및 퇴직급여 감액분 등의 재산적 이익을 확보할 수 있는 법적 지위를 얻게 된다.

2. 해임처분의 공정력 제거의 필요성

(1) 공정력의 작용

- 乙에게 가해진 해임처분은 유효한 행정처분이므로 공정력이 존재한다. 이 처분이 취소되지 않는 한, 다른 소송 절차에서 해임처분의 효력을 스스로 부정하여 급여 청구를 인용할 수 없다.

(2) 선결문제 해결을 위한 취소소송의 필요성

- 乙이 미지급 보수 등을 국가로부터 정상적으로 지급받기 위해서는 이 법원에 제기된 취소소송에서 해임처분의 공정력을 깨뜨려야만 한다. 따라서 乙에게는 해임처분 취소소송의 본안판결을 받아낼 실질적인 구제의 필요성이 인정된다.

IV. 결론

- 사안에서 공무원 乙이 소송 계속 중 정년에 이르게 되어 원래의 공무원 신분으로 원직복직하는 것은 물리적으로 불가능해졌다. 그러나 해임처분이 취소됨으로써 해임일부터 정년 도달일까지의 소급 보수(급여)를 청구할 수 있고 공무원연금법상의 불이익을 배제할 수 있는 구체적인 법률상 이익이 엄연히 존재한다. 더욱이 해임처분의 공정력 때문에 乙은 취소소송을 거치지 않고서는 미지급 급여를 실질적으로 반환받을 수 없다. 따라서 乙에게는 해임처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익(법률상 이익)이 명백히 인정되므로, 법원은 소를 각하해서는 안 되며 본안 심리를 통해 해임처분의 위법성 여부를 규명하여야 한다.

《【문제1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A시 소재의 3층 건물의 1층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3월의 영업정지처분을 1월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲은 乙의 영업정지처분 1월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 영업정지기간 도과 후 가중적 제재 우려가 있는 경우의 협의의 소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 행정심판의 일부인용재결에 따라 1월의 영업정지처분을 받았고, 그 영업정지기간이 모두 경과한 이후에 그 처분의 취소를 구하고자 한다. 쟁점으로 <영업정지기간이 이미 경과하여 처분의 효력이 소멸한 경우에도 甲에게 영업정지처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲에게 乙의 영업정지처분 1월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논한다.

II. 기간 도과와 가중제재 규정에 관한 법리

1. 협의의 소의 이익과 제12조 제2문

(1) 협의의 소의 이익의 개념

- 소송을 제기하여 본안판결을 구하는 데 적합한 실질적 가치나 필요성을 의미하는 소송요건이다.

(2) 행정소송법 제12조 제2문

- 처분의 효력이 기간의 경과 등으로 소멸한 후에도 처분의 취소를 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 경우 소를 제기할 수 있다고 규정하여 예외적 구제 가능성을 열어두고 있다.

2. 가중제재 규정의 형식에 따른 판례의 태도

(1) 과거 판례의 태도

- “과거 대법원”은 가중처벌 규정의 성격에 따라 구별하는 태도를 취하였다. 가중처벌 규정이 대통령령(시행령) 형식으로 규정된 경우에는 법규성을 인정하여 소의 이익을 긍정하였으나, 부령(시행규칙) 형식의 행정처분기준인 경우에는 행정규칙에 불과하여 가중처벌의 불이익은 사실상·경제상 불이익에 불과하다고 보아 소의 이익을 부정하였다.

(2) 변경된 전원합의체 판례의 태도

- “대법원”은 전원합의체 판결을 통해 종전의 견해를 폐기하였다. 가중제재 규정이 대통령령인지 부령인지 여부와 상관없이, 행정청이 해당 기준을 준수하여 가중처벌을 과할 가능성이 실질적으로 명백한 이상 원고가 입게 될 불이익은 구체적이고 현실적인 불이익에 해당한다고 판단하였다. 따라서 제재기간이 도과한 후에도 선행 제재처분의 취소를 구할 구체적인 법률상 이익이 인정된다고 일관되게 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 영업정지기간 도과에 따른 상황 분석

- 사안에서 甲에게 가해진 1월의 영업정지기간은 이미 경과하였다. 따라서 단순히 영업정지처분의 효력 정지나 원래 지위로의 단순 복귀만을 목적으로 한다면 원칙적으로 소의 이익은 소멸한 것으로 평가할 수 있다.

2. 가중 제재 위험성과 소의 이익 유무

- 그러나 식품위생법 시행규칙 별표에 가중적 제재처분 기준이 마련되어 있고, 시장 乙 또한 향후 동일 위반 시 가중처벌이 내려진다는 점을 명확히 안내하였다. 변경된 “대법원 전원합의체 판결”의 법리에 의할 때, 이 제재처분 기준이 비록 부령 형식인 식품위생법 시행규칙에 규정되어 있더라도 행정청인 乙이 향후 처분 시 이를 준수하여 가중처벌을 내릴 실질적 위험은 현실적이고 구체적이다. 따라서 甲은 1월의 영업정지기간이 경과하였더라도 가중적 제재의 위험이라는 장래의 확실한 불이익을 제거하기 위하여 선행 영업정지처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익을 명백히 가진다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 乙의 1월 영업정지처분이 완전히 경과한 후 소송을 제기하였더라도, 당해 처분의 취소를 구할 협의의 소의 이익은 인정된다. 식품위생법 시행규칙상 가중처벌 기준이 존재하여 장래에 불이익을 입을 구체적이고 실질적인 위험이 현존하기 때문이다. 따라서 법원은 제재기간이 경과하였다는 이유로 소를 각하해서는 안 되며, 甲의 소송에 대하여 본안 심리를 개시하여 청구의 당부를 판단하여야 한다.

<제03장 취소소송의 당사자자격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

[기출][2022-2]소송 계속 중 정년 도과와 금전보상명령의 협의의 소의 이익 인정 여부

《【문제2】 甲은 교육사업을 영위하는 회사 乙과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 乙로부터 해고를 통보받았다. 이에 대해 甲은 서울지방노동위원회에 부당해고 구제를 신청하였고, 이후 원직에 복직하는 대신 금전보상명령을 구하는 것으로 신청취지를 변경하였다. 그러나 서울지방노동위원회에의 구제신청과 이어진 중앙노동위원회에의 재심신청이 각각 기각됨에 따라, 甲은 2022. 7. 22. 서울행정법원에 재심판정의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 한편, 乙은 2022. 7. 19. 정당한 절차에 의해 취업규칙을 개정하였고, 이 규칙은 이 사건 소가 계속 중이던 2022. 8. 1.부터 시행되었다. 종전 취업규칙에는 정년에 관한 규정이 없었으나 `개정 취업규칙`에는 근로자가 만 60세에 도달하는 날을 정년으로 정하고 있으며, 甲은 이미 2022. 4. 15. 만 60세에 도달하였다.

甲이 중앙노동위원회의 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송 계속 중 정년 도과와 금전보상명령의 협의의 소의 이익 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 甲은 해고에 대하여 부당해고 구제신청 후 금전보상명령을 구하도록 신청취지를 변경하였으나 중앙노동위원회의 재심판정이 기각된 상태에서 취소소송을 제기하였고, 소송 계속 중 취업규칙이 개정되어 甲이 이미 정년에 도달한 사실이 발생하였다. 쟁점으로 <정년 도달이라는 사정 변경에도 불구하고 중앙노동위원회 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 중앙노동위원회의 재심판정을 다툰 협의의 소의 이익이 인정되는지를 설명한다.

II. 정년 도과와 협의의 소의 이익에 관한 법리

1. 협의의 소의 이익의 의의

(1) 개념 및 취지

- 협의의 소의 이익이란 원고가 청구하는 판결을 통해 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 이익을 의미한다.

(2) 사정 변경에 따른 각하

- 소송 계속 중 사정 변경으로 인하여 원고가 구하는 목적 달성이 불가능해진 경우에는 원칙적으로 소의 이익이 부정되어 소가 각하된다.

2. 정년 도과 시 구제이익 인정 여부에 대한 판례의 태도

(1) 과거 판례의 태도 (소극설)

- “과거 대법원”은 근로자가 구제절차 도중 정년에 도달하거나 근로계약기간이 만료된 경우, 해고처분이 취소되더라도 원직복직이 불가능하므로 소의 이익이 소멸한다고 보았다. 해고기간 중의 임금 상당액을 지급받는 것은 민사소송을 통해 해결해야 할 사실상·경제적 이익에 불과하다고 판단한 것이다.

(2) 변경된 전원합의체 판결의 태도 (적극설)

- “대법원”은 전원합의체 판결을 통해 종전 견해를 폐기하였다. 부당해고 구제명령 제도는 근로자의 원직복직만을 목적으로 하는 것이 아니라, 해고기간 중 지급받지 못한 임금 상당액의 신속한 구제도 중요한 목적으로 삼고 있다. 따라서 근로자가 정년에 도달하여 원직복직이 불가능해지더라도, 구제명령을 얻을 경우 임금 상당액을 지급받을 수 있는 법적 지위가 확보되므로 여전히 구제이익(소의 이익)이 인정된다고 판시하였다.

3. 금전보상명령 신청의 특수성

(1) 제도의 의의

- “근로기준법 제30조 제3항”은 근로자가 원직복직을 원하지 아니하는 경우 금전보상명령을 신청할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 원직복직 불능과의 관계

- 금전보상명령은 원직복직을 전제로 하지 않고 정당한 이유 없는 해고에 대한 금전적 보상 자체를 목적으로 하므로, 정년 도과로 인해 원직복직이 불가능해지더라도 금전적 보상을 받을 실질적 권리는 소송 결과에 따라 직접적인 법적 영향을 받는다.

III. 사안의 적용

1. 취업규칙 개정에 따른 정년 도과의 효력

(1) 개정 취업규칙의 적용

- 사안에서 乙 회사는 2022. 7. 19. 적법한 절차에 의해 취업규칙을 개정하였고, 이는 2022. 8. 1.부터 시행되었다. 개정 취업규칙상 정년은 만 60세이다.

(2) 정년 도과의 시점

- 甲은 이미 2022. 4. 15.에 만 60세에 도달하였으므로 개정 취업규칙의 시행일인 2022. 8. 1.에 정년에 도달하여 더 이상 乙 회사의 근로자 지위를 유지할 수 없게 된다.

2. 甲의 협의의 소의 이익 인정 여부

(1) 소급 임금 청구권의 유효성

- 변경된 “대법원 전원합의체 판결”의 법리에 의할 때, 甲이 비록 정년 도과로 인해 乙 회사로의 원직복직은 불가능해졌더라도 해고일부터 정년 도과일(취업규칙 시행일인 2022. 8. 1.)까지의 해고기간 동안 정상적으로 근무했다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 구제받을 실효성 있는 법률상 이익이 존재한다.

(2) 금전보상명령의 목적 달성 가능성

- 특히 甲은 최초 구제신청 이후 원직복직 대신 금전보상명령을 구하는 것으로 신청취지를 변경하였다. 금전보상명령은 정년 도과 여부와 상관없이 부당해고기간 동안의 임금과 위로금 성격의 금전을 보상받기 위한 제도이므로, 甲이 청구한 금전보상의 당부를 심리하여 구제받도록 하는 것은 협의의 소의 이익을 충족하기에 충분하다.

IV. 결론

- 사안에서 근로자 甲이 소송 계속 중 개정 취업규칙의 정년 도과로 인해 원직복직을 할 수 없는 상태가 되었다 하더라도, 해고기간 중의 임금 상당액을 보상받거나 당초 신청한 금전보상명령의 정당성을 확인받을 법률상 이익은 여전히 존속한다. “대법원 전원합의체 판결”의 취지에 비추어 볼 때 정년 도과만을 이유로 소를 각하해서는 안 되며, 따라서 甲이 제기한 재심판정 취소소송의 협의의 소의 이익은 명백히 인정되므로 법원은 본안 심리를 개시하여야 한다.

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 행정소송법상의 소송참가 (25점)》

<문제2의 물음2> 소송참가의 의의, 제3자의 소송참가, 행정청의 소송참가

I. 소송참가의 의의

1. 개념

- 소송참가란 행정소송 계속 중에 제3자 또는 다른 행정기관이 그 소송 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가질 때, 소송의 당사자가 아닌 자가 소송에 관여하여 자기의 이익을 옹호하거나 타방 당사자를 돕는 행위를 말한다. 이는 당사자 이외의 이해관계인을 소송에 참여시켜 소송 경제를 도모하고 판결의 실효성을 확보하려는 목적을 가진다.

2. 소송참가의 종류

- 행정소송법상 소송참가는 크게 제3자의 소송참가와 행정청의 소송참가로 구분된다. 이외에도 행정소송법이 준용하는 민사소송법상 보조참가 등이 있다.

II. 제3자의 소송참가

1. 의의

- 제3자의 소송참가란 취소소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 스스로 원고나 피고 측에 참가하여 소송을 수행하는 것을 말한다. ("행정소송법 제16조") 이는 주로 취소판결의 제3자효(기속력)로 인해 권리 침해를 받을 제3자를 구제하기 위한 제도이다.

2. 요건

(1) 소송 계속 중일 것

- 취소소송이 법원에 적법하게 계류되어 있어야 한다.

(2) 제3자일 것

- 소송의 당사자(원고 또는 피고)가 아닌 자여야 한다.

(3) 참가 이익이 있을 것

- 판결의 결과에 따라 권리 또는 법률상 이익의 침해를 받을 제3자이어야 한다. 단순한 사실상 또는 경제적 이익의 침해는 참가 이익으로 인정되지 않는다.

(4) 신청 또는 직권 결정에 의할 것

- 참가하고자 하는 제3자의 신청이 있거나, 법원이 직권으로 제3자에게 소송참가를 명하는 경우에 참가할 수 있다.

3. 참가 형태 및 효과

- 제3자는 원고 또는 피고 중 어느 일방을 돕는 보조참가 형태가 일반적이다. 참가한 제3자는 다음의 효과를 가진다.

(1) 독자적인 소송 수행

- 참가인은 공동소송적 보조참가인으로서, 피참가인(원고 또는 피고)의 행위와 관계없이 독자적으로 공격방어 방법이나 상소 등 소송 행위를 할 수 있다.

(2) 기판력 확장

- 제3자의 소송참가가 있는 경우, 확정된 판결의 기판력은 참가인에게도 미치게 되어 법률관계의 통일적 확정이 가능하다.

III. 행정청의 소송참가

1. 의의

- 행정청의 소송참가란 소송의 결과에 따라 권한 또는 법률상 이익의 침해를 받을 다른 행정청이 해당 소송에 참가하는 것을 말한다. ("행정소송법 제17조") 이는 행정청 상호 간의 권한 유무나 범위에 관한 다툼을 일거에 해결함으로써 행정 조직 내부의 질서를 유지하려는 목적을 가진다.

2. 요건

(1) 소송 계속 중일 것

- 취소소송이 법원에 적법하게 계류되어 있어야 한다.

(2) 다른 행정청일 것

- 소송의 당사자인 행정청 이외의 행정청이어야 한다.

(3) 참가 이익이 있을 것

- 소송의 결과에 따라 권한 또는 법률상 이익의 침해를 받을 다른 행정청이어야 한다.

(4) 신청 또는 직권 결정에 의할 것

- 참가하고자 하는 행정청의 신청이 있거나, 법원이 직권으로 소송참가를 명하는 경우에 참가할 수 있다.

3. 참가 형태 및 효과

- 참가한 행정청은 원고 또는 피고 중 어느 일방을 보조하여 소송을 수행하며, 그 효과는 다음과 같다.

(1) 소송 행위 가능

- 참가 행정청은 피참가 행정청과 독립하여 소송 행위를 할 수 있다.

(2) 판결의 기속력

- 확정된 판결의 기속력은 참가한 행정청에게도 미치게 된다. ("행정소송법 제30조")

IV. 결론

- 행정소송법상의 소송참가 제도는 취소소송의 결과에 법률상 이해관계를 갖는 제3자 및 다른 행정청을 소송에 참여시켜 판결의 실효성과 소송 경제를 동시에 달성하는 데 그 목적이 있다. 특히 제3자의 소송참가는 취소소송 판결의 제3자 효로 인해 불이익을 받을 수 있는 자를 보호하고, 행정청의 소송참가는 행정 조직 내부의 권한 질서를 유지하는 데 중요한 역할을 수행한다.

《【문제3.4】

<사례>

A시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음1) 사업 시행자 甲이 소송 계속 중 자신의 이익을 보호하기 위해 취할 수 있는 행정소송법상 조치와 그 요건에 대하여 서술하시오.》

<문제3.4의 물음1> 폐기물 처리시설 설치 승인 처분의 수익자인 회사가 취소소송에 참가하기 위한 요건과 절차

I. 문제의 제기

- 사안에서 사업 시행자인 甲 주식회사는 폐기물 처리시설 설치 승인처분에 대한 취소소송이 계속 중 그 소송 결과로 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 쟁점으로 <사업 시행자인 甲이 자신의 이익을 보호하기 위하여 행정소송법상 어떠한 소송참가를 할 수 있는지와 그 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사업 시행자 甲이 소송 계속 중 자신의 이익을 보호하기 위해 취할 수 있는 행정소송법상 조치와 그 요건에 대하여 서술한다.

II. 제3자의 소송참가

1. 소송참가의 의의

- 소송참가란 소송 계속 중 당사자 이외의 제3자가 자기의 법률상 이익을 보호하기 위하여 또는 당사자 일방을 보조하기 위하여 해당 소송 절차에 가입하는 것을 말한다. 이는 소송의 결과에 의하여 영향을 받는 제3자에게 소송참여의 기회를 부여함으로써 그 권익을 보호하고 판결의 모순을 방지하여 분쟁을 일거에 해결하는 데 목적이 있다.

2. 소송참가의 요건

(1) 소송의 계속

- 소송참가는 사실심의 변론종결 전까지 소송이 계속되어 있어야 한다. 상고심에서의 소송참가 가능성에 대해서는 견해가 대립하나 “판례”는 상고심에서도 소송참가가 가능하다고 보고 있다.

(2) 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자

- “판례”에 의하면 여기서 소송의 결과란 판결의 주문뿐만 아니라 판결 이유 중의 판단까지 포함하며 권리 또는 이익의 침해란 당해 처분의 취소 판결로 인하여 자신의 법률상 이익이 침해되는 경우를 의미한다. 사안의 甲은 처분의 상대방으로서 처분이 취소될 경우 직접적으로 법률적 불이익을 입게 되므로 이에 해당함이 명백하다.

(3) 참가의 필요성

- 제3자가 자신의 권익을 보호하기 위하여 소송 절차에 가입하여 자기의 의견을 진술하고 증거를 제출할 필요가 있어야 한다.

3. 참가의 절차 및 방법

(1) 신청 또는 직권에 의한 결정

- 소송참가는 당사자나 제3자의 신청 또는 법원의 직권에 의한 결정으로 이루어진다. 제3자가 신청하는 경우 참가의 이유를 명시하여 서면으로 제출해야 한다. 법원은 결정을 내리기 전에 당사자와 제3자의 의견을 들어야 한다.

(2) 참가인의 지위

- 참가인은 독립하여 소송행위를 할 수 있는 지위를 갖는다. 다만 피참가인인 행정청의 소송행위와 저촉되는 행위는 할 수 없으나 참가인의 이익이 피참가인과 반드시 일치하는 것은 아니므로 독자적인 증거 제출이나 주장 제기가 가능하다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 지위 및 참가 가능성

- 사안에서 甲 주식회사는 A시 시장으로부터 폐기물 처리시설 설치 승인을 받은 처분의 직접 상대방이다. 주민 乙이 제기한 취소소송에서 乙이 승소할 경우 甲의 설치 승인 처분은 효력을 상실하게 되어 사업 수행이 불가능해진다. 이는 소송의 결과에 따라 법률상 이익의 침해를 받는 제3자에 해당하므로 “행정소송법 제16조”에 따른 소송참가 요건을 충족한다.

2. 구체적 조치

- 甲은 현재 소송이 계속 중인 법원에 소송참가신청서를 제출하여야 한다. 신청서에는 취소소송의 결과로 인해 자신이 입게 될 불이익과 참가의 필요성을 상세히 기재하여야 한다. 법원이 참가를 허가하는 결정을 내리면 甲은 소송당사자에 준하는 지위에서 해당 처분의 적법성을 옹호하는 주장을 펼치고 관련 증거를 제출함으로써 자신의 이익을 방어할 수 있다.

3. 소송 행위의 범위

- 참가인으로 확정된 甲은 독자적으로 상소하거나 재심청구를 할 수 있는 권한을 가지며 원고 乙의 주장에 대항하여 처분의 절차적 정당성(환경영향평가법 준수 여부 등)을 적극적으로 변론할 수 있다. 특히 피참가인인 행정청이 소홀히 할 수 있는 수익적 처분의 신뢰보호 필요성 등을 주장함으로써 재판부의 판단에 영향을 미칠 수 있다.

IV. 결론

- 사안의 사업 시행자 甲은 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 직접적으로 침해될 우려가 있는 제3자이다. 따라서 “행정소송법 제16조”에 의거하여 해당 취소소송이 계속 중인 법원에 소송참가를 신청할 수 있다. 법원의 참가 결정이 내려지면 甲은 참가인으로서 독자적인 소송수행권을 행사하며 판결의 결과에 따른 불이익을 방지할 수 있는 법적 기회를 보장받게 된다. 이러한 소송참가는 절차적 권리 보장을 넘어 판결의 실효성을 높이고 관련 분쟁의 일회적 해결을 가능케 하는 중요한 수단이 된다.

《【문제3.4】

<사례>

A시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음2) 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토하시오.》

<문제3.4의 물음2> 인근 주민의 취소소송 참가 가능성 및 행정소송법 제16조상 참가인의 법적 지위

I 문제의 제기

- 사안에서 인접 지자체 주민인 丙은 폐기물 처리시설 설치 승인처분의 취소를 구하는 乙의 소송에서 환경상 피해를 우려하여 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참가하고자 한다. 쟁점으로 <주민 丙에게 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 인정되는지>와 <참가가 인정될 경우 참가인의 지위를 어떻게 보는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 "행정소송법 제16조"의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토한다.

II 제3자 소송참가의 요건과 丙의 참가 가능성

1. 제3자의 법률상 이익

(1) 법률상 이익의 의미

- "행정소송법 제16조"의 법률상 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하며, 단순히 간접적이거나 사실적·경제적 이해관계를 가지는 경우에는 포함되지 않는다.

(2) 환경권과 법률상 이익

- "판례"는 환경영향평가 대상 지역 내의 주민들에 대해서는 환경상 이익의 침해를 법률상 이익으로 추정한다. 그러나 대상 지역 밖의 주민이라 하더라도 당해 처분으로 인하여 환경상 이익을 침해받거나 침해받을 우려가 있음을 입증하는 경우에는 법률상 이익을 인정한다.

2. 소송의 결과와의 관련성

- 소송의 결과란 판결의 주문뿐만 아니라 그 전제가 되는 이유 중의 판단까지 포함한다. 제3자의 권리나 이익이 당해 소송의 판결에 의해 직접 영향을 받는 관계에 있어야 한다.

3. 사안의 경우

- 丙은 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 주민이다. 丙이 환경영향평가 대상 지역 내에 거주한다면 법률상 이익이 당연히 인정되나, 지역 밖에 거주한다면 수인한도를 넘는 환경상 피해를 구체적으로 입증해야 한다. 만약 丙에게 이러한 법률상 이익이 인정된다면 乙이 승소할 경우 처분이 취소되어 丙의 환경상 이익이 보호되므로 소송의 결과에 이해관계를 가진 제3자로서 참가 요건을 충족할 수 있다.

III 소송참가인의 법적 지위

1. 독립적 지위의 인정 여부

- "행정소송법 제16조"에 의해 참가한 제3자는 단순한 보조참가인과 달리 당사자에 준하는 독립된 지위를 갖는다. 이는 판결의 효력이 제3자에게도 미치는 제3자효(형성력)가 있기 때문이다.

2. 소송행위의 범위

(1) 독자적인 소송행위

- 참가인은 자기의 이름으로 소송행위를 할 수 있다. 기일의 통지를 받고 변론에 참여하여 독자적인 증거를 제출하거나 공격·방어 방법을 제시할 수 있다.

(2) 피참가인과의 관계

- 참가인은 피참가인(원고 乙)의 소송행위와 저촉되는 행위를 할 수 있다. 즉, 원고가 주장하지 않는 사유를 주장하거나 원고가 제출하지 않은 증거를 제출할 수 있다. 다만, 소의 취하나 포기 등 소송물 자체를 처분하는 행위는 허용되지 않는다.

(3) 상소 및 재심청구

- 참가인은 소송 결과에 대하여 독자적으로 상소할 수 있으며, 확정판결에 대하여 "행정소송법 제31조"에 따른 제3자의 재심청구권을 행사할 수 있는 주체가 된다.

3. 민사소송법상 공동소송적 보조참가와와의 비교

- 행정소송법상의 제3자 소송참가는 판결의 효력이 참가인에게 미친다는 점에서 민사소송법상의 공동소송적 보조참가와 유사한 지위를 갖는다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

IV 사안의 적용

1. 丙의 참가 유형 검토

- 丙은 원고 乙의 승소를 보조하기 위해 참가하고자 하므로, 실질적으로는 원고 측 제3자 소송참가인이 된다. 丙의 거주지가 환경영향평가법령에 의해 보호되는 범위 내에 있거나, 범위를 벗어나더라도 수인한도를 넘는 피해를 입증할 수 있다면 丙은 "행정소송법 제16조"의 제3자로서 소송참가가 가능하다.

2. 丙의 지위와 권한

- 丙이 소송에 참가하면 乙의 소송수행 능력과 관계없이 독자적으로 환경 오염의 위험성을 입증할 자료를 법원에 제출할 수 있다. 설령 원고 乙이 소송에 소극적으로 임하더라도 丙은 자신의 환경상 이익을 지키기 위해 적극적으로 변론할 수 있으며, 1심 판결에서 乙이 패소한 경우 乙이 항소하지 않더라도 丙은 독자적으로 항소하여 소송을 계속할 수 있는 지위를 보장받는다.

V. 결론

- 주민 丙이 환경상 피해 우려를 구체적으로 입증하여 법률상 이익을 인정받는다면 "행정소송법 제16조"에 따른 제3자의 소송참가가 가능하다. 이때 丙은 단순한 보조자가 아니라 당사자에 준하는 공동소송적 보조참가인의 지위를 갖게 된다. 이를 통해 丙은 원고 乙의 소송행위에 구애받지 않고 자신의 독립된 이익을 보호하기 위한 모든 소송행위를 수행할 수 있으며, 이는 행정소송의 적정성과 실효적 권리 구제를 보장하는 중요한 장치가 된다.

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 행정심판전치주의 (25점)》

<문제2의 물음1> 행정심판전치주의의 의의, 요건, 적용범위, 예외, 이행여부

I. 행정심판전치주의의 의의

1. 개념

- 행정심판전치주의란 행정소송법상 취소소송을 제기하기 이전에 당해 처분에 대하여 행정심판을 먼저 제기하고 그 재결을 거치도록 요구하는 제도를 말한다. 이는 사법적 구제 이전에 행정 내부에서 문제를 자체적으로 해결할 기회를 제공하는 행정쟁송의 한 원칙이다.

2. 목적

- 행정심판전치주의는 다음과 같은 목적을 가진다. ❶ 행정의 자율적 통제 및 시정 기회 제공을 통해 행정의 능률성을 향상시키고 권리 구제 비용을 절감한다. ❷ 사법(司法)의 부담 경감을 통해 법원의 업무 과중을 덜고 신속한 사법 심사를 보장한다. ❸ 행정심판 단계에서 사실 관계를 확정하고 전문적인 판단을 거침으로써 사법 심사의 적정성을 제고한다.

II. 행정심판전치주의의 요건

1. 대상이 되는 행정작용

- 행정심판전치주의는 원칙적으로 취소소송의 대상인 처분에 적용된다. 무효등확인소송이나 부작위위법확인소송은 그 성격상 행정심판을 거칠 필요가 없어 원칙적으로 적용이 배제된다.

2. 적법한 행정심판의 제기

- 취소소송을 제기하기 전에 당해 처분에 대하여 적법한 행정심판을 제기해야 한다. 행정심판의 청구 기간, 청구인 적격 등 요건을 갖추어야 한다.

3. 재결의 존재 또는 일정 기간 경과

- 취소소송을 제기하기 위해서는 원칙적으로 행정심판의 재결이 있어야 한다. 다만, 재결이 없더라도 행정심판 청구 후 60일이 경과하거나 기타 법정된 사유가 있는 경우에는 재결 없이도 소송을 제기할 수 있다.("행정소송법 제18조 제2항")

III. 행정심판전치주의의 적용범위

1. 원칙 (임의적 전치주의)

- 현행 행정소송법은 임의적 전치주의를 원칙으로 채택하고 있다.("행정소송법 제18조 제1항 본문") 따라서 국민은 행정심판을 거치지 아니하고도 취소소송을 제기할 수 있다.

2. 예외 (필요적 전치주의)

(1) 다른 법률의 명시적 규정

- 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 명시적인 규정이 있는 경우에 필요적 전치주의가 적용된다.("행정소송법 제18조 제1항 단서") 대표적으로 국세 관련 처분이나 노동위원회 재심판정 등이 이에 해당한다.

(2) 필요적 전치주의 위반의 효과

- 필요적 전치주의가 적용되는 경우 행정심판을 거치지 않고 제기된 취소소송은 소송 요건을 결여한 것으로 보아 법원은 부적법 각하 판결을 내린다.

IV. 행정심판전치주의의 적용제외

1. 행정소송법상 적용제외 사유 [행정소송법 제18조 제2항]

(1) 심판 청구 후 60일 경과

- 심판 청구가 있는 날부터 60일이 지나도 재결이 없는 때.

(2) 재결을 거칠 수 없는 정당한 사유

- 그 밖에 법률에 의한 행정심판기관이 의결 또는 재결을 하지 못할 사유가 있을 때.

(3) 사실심 변론종결 후 처분 변경

- 처분의 집행 또는 절차의 속행으로 생길 중대한 손해를 예방할 긴급한 필요가 있을 때.

(4) 기타 사유

- 원고에게 책임을 돌릴 수 없는 사유로 재결을 거칠 수 없는 때 등이다.

2. 무효등 확인소송 및 부작위위법확인소송의 원칙적 제외

- 무효등 확인소송은 처분의 무효를 다투는 것이므로 행정심판을 거치는 실익이 적어 "행정소송법 제38조 제1항"에 따라 행정심판 전치에 관한 규정이 준용되지 않는다. 부작위위법확인소송 역시 부작위 상태가 계속되는 한 위법 상태로 계속되므로 전치주의 적용은 부적절하다는 것이 일반적 견해이다.

V. 행정심판전치주의의 이행 여부의 판단

1. 판단 시점

- 행정심판 전치주의의 이행 여부는 법원의 직권조사 사항으로서, 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 소송 제기 당시 행정심판을 거치지 않았더라도 사실심 변론종결 전에 재결이 있다면 전치주의 요건을 충족한 것으로 본다.

2. 판단 내용

- 행정심판을 거친 것으로 볼 수 있는가의 판단에 있어서는 관련 처분 간의 동일성이 요구된다. 즉, 행정심판을 거친 처분과 취소소송의 대상이 되는 처분이 동일해야 한다. 다만, 관련 처분 이론에 따라 행정심판의 대상이 된 처분과 내용상 밀접한 관련이 있는 후속 처분의 경우에도 예외적으로 전치주의를 충족한 것으로 볼 수 있다.

VI. 결론

- 행정심판전치주의는 행정청의 자율적인 시정 기회를 부여하고 사법적 부담을 경감하는 데 기여하는 제도로써, 현행법상 임의적 전치주의가 원칙이다. 다만, 다른 법률의 명시적 규정이 있는 경우에 한하여 필요적 전치주의가 적용되며, 이 경우 법정된 예외 사유가 없는 한 행정심판을 거치지 않은 소송은 부적법 각하된다.

《【문제1】 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무수당에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명시오. (30점)

(2) 乙은 2024. 8. 1. Y광역시를 피고로 하여 시간외근무수당에 미치지 못하는 시간외근무수당의 지급을 구하는 행정소송의 소장을 Y지방법원에 제출하여 접수되었다. 乙은 제소에 앞서 「지방공무원법」 제20조의2에 따른 소청절차를 거치지 않았다. Y광역시장 C는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직 등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음1-2> 소청절차를 거치지 않고 제기한 지방공무원의 시간외근무수당 청구소송의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 지방공무원인 乙은 시간외근무수당의 차액 지급을 구하는 행정소송을 제기하면서 지방공무원법상 소청절차를 거치지 않았고, 피고인 Y광역시는 소청전치주의 위반을 이유로 소가 부적법하다고 항변하고 있다. 쟁점으로 <시간외근무수당 지급청구에 관한 행정소송에서 소청절차를 거쳐야 하는지>와 <이를 거치지 않은 소송의 적법 여부 및 법원의 판단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소청절차를 거치지 않은 乙의 행정소송에 대한 법원의 판단에 관하여 설명한다.

II. 공무원의 시간외근무수당 청구와 당사자소송의 법리

1. 시간외근무수당 청구권의 법적 성질

(1) 법령에 의해 직접 발생하는 권리

- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 등 관련 법령에 의하면 공무원의 시간외근무수당 청구권은 근무의 제공이라는 사실관계와 법령의 규정에 의해 직접 확정되는 권리이다. 이는 행정청의 처분이나 급여 결정과 같은 구체적인 행정처분에 의해 비로소 발생하는 권리가 아니다.

(2) 공법상 당사자소송의 대상

- "대법원 판례"는 공무원의 시간외근무수당 청구권처럼 법령에 의해 직접 발생하는 공법상 금전지급 청구권의 경우, 행정청의 처분을 다투는 항고소송이 아니라 "행정소송법 제3조 제2호"에 따른 공법상 당사자소송의 형태로 제기되어야 한다고 판단한다.

2. 당사자소송과 필요적 행정심판전치주의의 관계

(1) 필요적 전치주의의 적용 범위

- "지방공무원법 제20조의2"는 처분에 대한 행정소송을 제기할 때 소청심사위원회의 재결을 반드시 거치도록 하는 필요적 행정심판전치주의를 규정하고 있다. 그러나 이러한 전치주의는 행정청의 거부나 불이익 처분 등을 다투는 항고소송을 제기할 때 적용되는 원칙이다.

(2) 당사자소송에서의 전치주의 배제

- 공법상 당사자소송은 행정청의 처분을 전제로 하지 않는 대등한 당사자 간의 법률관계에 관한 소송이므로, 개별 법령에 특별한 규정이 없는 한 행정심판전치주의가 적용되지 않는다. 지방공무원법상 시간외근무수당 청구소송에 대해 소청심사를 거치도록 하는 특별한 제한 규정은 존재하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형 및 피고적격의 정당성

(1) 공법상 당사자소송의 적법성

- 乙이 청구하는 시간외근무수당은 지방공무원 수당 규정에 의해 직접 인정되는 권리이므로, 이를 청구하는 소송은 공법상 당사자소송에 해당한다. 따라서 乙이 행정청의 거부처분을 전제로 한 항고소송이 아닌 직접 지급을 구하는 소송을 제기한 것은 적법하다.

(2) 피고 지정의 정당성

- 공법상 당사자소송의 피고는 "행정소송법 제39조"에 따라 권리 의무의 귀속주체인 국가 또는 공공단체가 된다. 사안에서 乙은 권리 의무의 귀속주체인 Y광역시를 피고로 지정하여 소를 제기하였으므로 피고적격을 적법하게 갖추었다.

2. 소청절차 흠결 항변의 부당성

(1) 소청심사 대상의 불포함

- 乙의 청구는 행정청의 일반적인 불이익 처분이나 징계 처분을 대상으로 하지 않으므로 지방공무원법상 소청심사의 대상이 될 수 없다. 소청심사위원회는 법령에 의해 직접 발생하는 공법상 금전채권의 존부를 판단할 권한이 없다.

(2) Y광역시장의 항변에 대한 판단

- Y광역시장 C는 乙이 소청절차를 거치지 않았음을 이유로 소송이 각하되어야 한다고 주장하나, 공법상 당사자소송에는 소청전치주의가 적용되지 않는다. 따라서 소청을 거치지 않았다는 C의 주장은 법리적으로 이유가 없으며 적법한 항변이 될 수 없다.

IV. 결론

- 사안에서 공무원 乙이 Y광역시를 피고로 하여 제기한 시간외근무수당 지급 청구 소송은 법령에 의해 권리가 직접 발생하는 공법상 당사자소송에 해당하므로 매우 적법하다. 이러한 당사자소송에는 지방공무원법상의 필요적 소청심사 전치주의가 적용되지 않으므로, 소청 절차를 거치지 않은 흠결이 존재하지 않는다. 따라서 법원은 소송이 부적법하다는 Y광역시장 C의 항변을 배척하고, 乙이 실제로 제공한 시간외근무수당에 부합하는 수당 청구권이 존재하는지 여부에 관하여 본안 심리를 진행하여야 한다.

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `식품위생법` 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 `미성년자에게 주류를 제공하였다`는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 `영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다`는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음1) 행정청 A가 소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 사유를 추가하거나 변경하는 `처분사유의 추가·변경`의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술하라.》

<문제5.1의 물음1> 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대한 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 영업정지처분의 취소소송 계속 중 처분서에 기재되지 않았던 새로운 위반사실을 처분사유로 추가하여 처분의 적법성을 주장하고자 한다. 쟁점으로 <소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 처분사유의 추가·변경이 허용되는지와 그 허용범위 및 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 인정 여부

1. 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분 당시에 적시한 사유 외에 소송 계속 중에 새로운 사유를 추가하거나 당초의 사유를 다른 사유로 변경하여 처분의 적법성을 주장하는 것을 말한다.

2. 인정 여부에 관한 판례의 입장

- 명문의 규정이 없음에도 불구하고 “판례”는 소송경제와 행정의 적법성 확보라는 측면에서 일정한 한계 내에 처분사유의 추가·변경을 허용하고 있다. 다만, 무제한적으로 허용할 경우 원고의 방어권을 침해할 수 있으므로 엄격한 요건을 요구한다.

III. 처분사유 추가·변경의 요건과 한계

1. 시간적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시 이미 존재하고 있었던 사유여야 한다. 처분 이후에 발생한 새로운 사실이나 법령의 변경을 근거로 당초 처분의 적법성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 처분 시를 기준으로 사유의 존부를 판단해야 한다.

2. 객관적 한계 : 기본적 사실관계의 동일성

(1) 동일성 판단 기준

- “대법원”은 당초의 처분사유와 추가·변경하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 경우에만 처분사유의 추가·변경을 허용한다. 여기서 동일성이란 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실관계에 비추어 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 의미한다.

(2) 판례의 구체적 경향

- “판례”는 사실관계의 동일성 여부를 엄격하게 해석한다. 예를 들어 `미성년자 주류 제공`과 `영업소 면적 변경 미신고`는 그 기초가 되는 사실관계가 전혀 다르므로 동일성을 인정하기 어렵다. 반면, 법적 근거 규정만을 변경하거나, 사실관계의 세부적인 부분만을 수정하는 경우에는 동일성을 인정하여 추가·변경을 허용하는 경향이 있다.

3. 절차적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 원고의 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 따라서 사실심 변론종결 전까지 이루어져야 하며, 당사자에게 충분한 반박 기회가 주어져야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 기본적 사실관계의 동일성 검토

- 행정청 A가 당초 내세운 사유인 `미성년자 주류 제공`은 영업 행위 상의 의무 위반에 해당하며, 새로 발견한 `영업소 면적 변경 미신고`는 영업 신고사항의 변경이라는 형식적 의무 위반에 해당한다. 이 두 사실은 사회적 사실관계의 기초가 완전히 상이하므로 “판례”의 기준에 따라 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다.

2. 추가·변경의 허용 여부 판단

- 사안의 경우 시간적 요건은 갖추었을지라도 객관적 요건인 동일성이 흠결되어 있다. 따라서 행정청 A가 소송에서 `영업소 면적 변경 미신고` 사유를 추가하거나 변경하여 처분의 정당성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 만약 행정청이 해당 사유를 근거로 처분을 유지하고자 한다면, 현재 진행 중인 소송과 별개로 새로운 처분 절차를 밟아야 한다.

V. 결론

- “대법원 판례”에 따르면 처분사유의 추가·변경은 당초 사유와 추가 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 예외적으로 허용된다. 사안의 `미성년자 주류 제공`과 `면적 변경 미신고`는 그 동일성이 인정되지 않으므로 행정청 A의 주장은 소송에서 받아들여질 수 없다. 이러한 “판례” 태도는 행정처분의 상대방인 원고가 소송에서 예측하지 못한 불이익을 당하는 것을 방지하고 재판받을 권리를 실질적으로 보호하기 위한 취지에서 확립된 법리라 할 수 있다.

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `식품위생법` 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 `미성년자에게 주류를 제공하였다`는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 `영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다`는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음2) 甲이 행정심판 단계의 기록을 법원이 제출받도록 하기 위해 활용할 수 있는 `행정심판기록 제출명령`의 의의와 그 효과에 대하여 설명하라.》

<문제5.1의 물음2> 행정심판기록 제출명령의 의의와 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 취소소송에서 자신에게 유리한 증거를 확보하기 위하여 행정청 A가 보관하고 있는 행정심판 단계의 기록을 법원에 제출받고자 한다. 쟁점으로 <행정심판기록 제출명령의 의의와 요건 및 그에 따른 법적 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판기록 제출명령의 의의와 그 효과에 대하여 설명한다.

II. 행정심판기록 제출명령의 의의 및 성질

1. 의의

- 행정심판기록 제출명령이란 행정소송의 제기가 있는 경우 법원이 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 행정심판을 행한 행정청에 대하여 행정심판에 관한 기록을 제출할 것을 명하는 제도를 말한다. 이는 행정청이 독점하고 있는 정보를 법원이 제출받게 함으로써 무기대응의 원칙을 실현하기 위한 장치이다.

2. 법적 성질

(1) 증거조사의 특례

- 민사소송법상의 문서제출명령이나 문서송부촉탁 등 일반적인 증거조사 방법이 행정소송에도 준용되지만, 행정심판기록 제출명령은 행정소송의 특수성을 고려하여 "행정소송법 제25조"가 별도로 마련한 특례 규정이다.

(2) 신청에 의한 결정

- 법원이 직권으로 명할 수는 없으며 반드시 당사자의 신청이 있어야 한다. 법원은 당사자의 신청이 이유 있다고 인정할 때 결정으로 제출을 명하게 된다.

III. 행정심판기록 제출명령의 요건 및 절차

1. 신청의 요건

(1) 행정심판을 거친 사건일 것

- 당해 처분에 대하여 행정심판을 거친 경우에만 신청이 가능하다. 사안의 甲은 행정심판 단계를 거쳤으므로 이 요건을 충족한다.

(2) 소송이 계속 중일 것

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 제기되어 소송이 계속되고 있는 상태여야 한다.

2. 제출의 대상

- 행정심판 기록에는 청구서, 답변서, 심리조서, 증거서류 및 의결서 등이 포함된다. 행정청은 법원의 명령이 있으면 해당 기록 전부 또는 일부를 지체 없이 법원에 제출하여야 한다.

IV. 행정심판기록 제출명령의 효과

1. 증거자료의 확보와 심리의 충실화

(1) 정보 비대칭의 해소

- 행정처분의 근거가 되는 조사 자료나 심판 과정의 진술은 주로 행정청이 보관하고 있어 원고가 접근하기 어렵다. 제출명령을 통해 이러한 자료가 법원에 제출됨으로써 원고인 甲은 자신에게 유리한 증거를 확보할 수 있고, 법원은 처분의 위법성 여부를 더욱 정확하게 판단할 수 있다.

(2) 사실관계의 명확화

- 행정심판 단계에서 다투어졌던 사실관계와 행정청의 판단 근거가 소송에서 그대로 드러나게 되므로, 쟁점을 조기에 확정하고 심리를 신속하고 충실하게 진행할 수 있는 효과가 있다.

2. 불이행 시의 효과

(1) 증거법적 불이익

- 행정청이 법원의 제출명령에 정당한 사유 없이 응하지 않는 경우, 법원은 민사소송법을 준용하여 원고인 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정하거나 행정청에게 불리한 사실인정을 할 수 있는 자유심증권의 행사가 가능해진다.

(2) 심리의 방해에 대한 판단

- 공법상 의무를 지는 행정청이 사법부의 명령을 거부하는 것은 행정의 적법성 원칙에 반하는 행위로 간주되어 소송 결과에 간접적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 甲의 권리구제 수단으로서의 효용성

- 甲은 행정심판 기록 중 조사 자료를 통해 `미성년자 주류 제공` 사실이 없었음을 증명하거나, 행정청 A의 적법절차 위반 등을 입증할 수 있다. 특히 행정청 A가 주장하려는 새로운 사유인 `면적 변경 미신고`가 처분 당시에 전혀 고려되지 않았음을 심판 기록을 통해 확인하여 처분사유의 추가·변경의 부당성을 논증하는 데 활용할 수 있다.

2. 법원의 판단 근거 제공

- 법원은 제출된 기록을 바탕으로 행정청 A의 처분이 식품위생법상 적법한 절차와 근거를 갖추었는지 심리하게 된다. 甲이 주장하는 유리한 증거들이 기록에 포함되어 있다면 이는 甲의 승소 가능성을 높이는 결정적인 역할을 할 것이다.

Ⅵ. 결론

- 행정심판기록 제출명령은 행정소송에서 원고와 피고 사이의 정보 불균형을 시정하고 실질적인 법치주의를 구현하기 위한 필수적인 제도이다. 甲은 법원에 행정심판기록 제출명령을 신청함으로써 행정청이 독점하고 있는 증거 자료를 법정에 현출시킬 수 있으며, 이를 통해 처분의 위법성을 효과적으로 공격하고 자신의 권익을 보호받을 수 있다.

《[문제3] 甲은 산업입지 및 개발에 관한 법령 등에 따라 관할 행정청 도지사 乙에 의해 지정된 산업단지 내에서 산업단지개발계획상 녹지용지로 되어있던 토지의 소유자이다. 甲은 해당 토지에서 폐기물처리사업을 하기 위하여 乙에게 사업부지에 관한 개발계획을 당초 녹지용지에서 폐기물처리시설용지로 변경해 달라는 내용의 신청을 하였다. 당시 위 법령에 따르면 폐기물처리시설용지로의 변경이 불가능하게 되어 있었다. 이에 따라 乙은 위 변경신청을 거부하는 처분을 하였고, 甲은 이에 대하여 취소소송을 제기하였다. 그런데 거부처분 이후 폐기물처리시설용지로의 변경이 가능하도록 법령의 개정이 있었다고 할 때, 법원이 어느 시점을 기준으로 위법성을 판단하여야 하는지에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 거부처분 후 법령이 개정된 경우 취소소송에서 위법성 판단의 기준시점

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 산업단지개발계획상 녹지용지를 폐기물처리시설용지로 변경해 달라는 신청을 하였으나 당시 법령상 변경이 허용되지 않아 거부처분을 받았고, 이후 관련 법령이 개정되어 변경이 가능하게 되었다. 쟁점으로 <거부처분 취소소송에서 처분 이후 법령이 개정된 경우 법원이 처분의 위법성을 어느 시점을 기준으로 판단하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분의 위법성 판단의 기준시점에 관하여 설명한다.

II. 위법성 판단의 기준시점에 관한 법리

1. 학설의 대립

(1) 처분시설

- 행정처분의 위법 여부는 처분이 행해진 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단해야 한다는 견해이다. 행정처분의 효력은 처분 시에 확정되므로 사법부는 처분 당시 행정청의 판단이 적법했는지만을 사후적으로 심사해야 한다는 논거에 기초한다.

(2) 판결시설

- 법원의 판결(사실심 변론종결) 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 위법성을 판단해야 한다는 견해이다. 특히 거부처분의 경우, 당사자의 권리구제를 실질화하기 위해서는 처분 이후의 사정변경이나 법령 개정까지 고려하여 판결 시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다는 논거를 제시한다.

2. 판례의 태도

(1) 처분시 기준의 원칙

- “대법원”은 취소소송에서 행정처분의 위법 여부는 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 한다고 일관되게 판시하며 처분시설의 입장을 취하고 있다.

(2) 거부처분의 위법성 판단 기준시점

- “대법원”은 거부처분에 대한 취소소송에서도 마찬가지로 처분시를 기준으로 위법 여부를 판단해야 한다고 본다. 따라서 처분 이후에 법령이 개정되거나 허가 기준이 변경되었다 하더라도, 그러한 사정만으로 처분 당시에는 적법하게 내려진 거부처분이 사후적으로 위법하게 된다고 볼 수 없다고 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 위법성 판단 기준시점의 적용

- “대법원”의 확립된 “판례”인 처분시 기준원칙에 의할 때, 乙이 행한 개발계획 변경신청 거부처분의 위법 여부는 처분이 행해진 당시의 법령을 기준으로 심사하여야 한다. 처분 이후에 폐기물처리시설용지로의 변경이 가능하도록 법령이 개정되었다 하더라도, 판결 시의 신법을 소급하여 처분의 위법성 판단 기준으로 삼을 수는 없다.

2. 구체적 위법 여부의 판단

- 처분 당시의 법령에 따르면 녹지용지를 폐기물처리시설용지로 변경하는 행위는 법적으로 불가능하게 규정되어 있었다. 따라서 乙이 당시 법령을 엄격히 준수하여 甲의 변경신청을 거부한 처분은 처분 당시의 법령에 부합하는 적법한 처분이다. 비록 사후적인 법령 개정으로 변경이 가능해졌다고 하더라도, 처분 당시 적법했던 거부처분이 사후적으로 위법한 처분으로 소급하여 변할 수는 없다.

IV. 결론

- 취소소송에서 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준시점은 행정청이 처분을 행한 당시인 처분시이다. 따라서 법원은 거부처분 이후에 행해진 법령 개정(신법)이 아닌 처분 당시의 법령(구법)을 기준으로 乙의 거부처분의 위법 여부를 판단하여야 한다. 결과적으로 乙의 거부처분은 처분 당시의 법령에 따라 행해진 적법한 처분이므로, 법원은 甲의 청구를 기각하는 판결을 내려야 한다. 다만 甲은 개정된 법령에 기하여 다시 乙에게 개발계획 변경을 신청하여 새로운 행정절차를 통해 권리를 구체받을 수 있을 뿐이다.

<보충>

I. 법리 원칙(원처분주의·처분시 기준설)

- 법원은 처분 당시 기준으로 적법 여부를 판단하고, 이후 사정 변경은 새로운 신청을 통해 다투게 하는 것이 타당.

II. 판례 입장(권리구제 중시)

- 거부처분은 권리구제 성격상 계속적 효과가 있으므로, 변론종결시의 법령·사실 상태를 반영하여 판단해야 함. 따라서 이 경우에는 법원 스스로 개정된 법령을 기준으로 위법성을 판단할 수 있음.

《【문제2】 甲은 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않았음을 이유로 입찰참가자격 제한처분을 받았다. 이에 대해 甲이 취소소송으로 다투던 중 처분청은 당초 처분사유 외에 위 계약 당시 관계 공무원에게 뇌물을 준 사실을 처분사유로 추가하였다. 처분청의 행위는 소송상 허용되는가? (25점)》

<문제2> 입찰참가자격 제한 처분의 취소소송 중 뇌물수수 사유 추가의 허용 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲은 입찰참가자격 제한처분의 취소를 구하는 소송 계속 중 처분청이 당초의 계약 불이행 사유 외에 계약 당시 공무원에게 뇌물을 제공한 사실을 새로운 처분사유로 추가하였다. 쟁점으로 <소송 계속 중 당초 처분사유와 다른 새로운 처분사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분청의 처분사유 추가가 소송상 허용되는지 설명한다.

II. 처분사유 추가·변경의 의의 및 허용 기준

1. 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 행한 처분의 적법성을 소송에서 방어하기 위해 당초 처분 단계에서 제시하지 않았던 사유를 새로이 제출하거나, 이미 제시된 사유를 다른 형태로 바꾸어 주장하는 것을 의미한다. 이는 처분의 근거를 확장 또는 전환하는 것이므로 원칙적으로 엄격한 제한이 필요하다.

2. 허용 기준 (판례의 입장)

(1) 원칙적 불허

- “대법원”은 처분사유는 처분 당시 행정청이 처분의 근거로 삼은 사실과 이유에 한정되므로, 새로운 사유를 추가·변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 본다. 이는 처분의 사후 보안을 금지하는 행정행위 하자의 보안 금지 원칙에 기초한다.

(2) 예외적 허용

- 다만, “판례”는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서는 당초 처분사유를 보충·구체화하는 정도의 추가·변경은 허용된다고 본다. 이 경우에도 원고의 방어권 행사에 불이익을 주어서는 안 된다.

① 기본적 사실관계의 동일성 인정

- 당초 사유와 추가된 사유가 동일한 사회적 사실관계에 기초하여 하나의 법률효과를 발생시키는 경우 동일성이 인정된다.

② 원고의 방어권 침해 여부

- 새로운 사유로 인해 원고가 전혀 예상하지 못한 사실관계를 방어해야 하는 경우라면 허용되지 않는다.

(3) 기본적 사실관계의 동일성 판단 기준

① 사회적 사실 관계의 동일성

- 처분의 기초가 되는 사실적 상황이 사회통념상 동일한 생활관계에 속하는가.

② 주된 내용의 동일성

- 처분의 요지를 규정하는 핵심적 사실관계가 일치하는가.

③ 판례의 엄격한 해석

- “판례”는 동일성 범위를 좁게 보아 새로운 사유의 제시는 제한적으로만 인정한다.

III. 사안의 적용

1. 당초 처분사유와 추가 사유

(1) 당초 처분사유

- 甲이 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않았다는 사유이다. 이는 계약 불이행이라는 행정상 의무 위반을 이유로 입찰참가자격 제한을 부과한 것이다.

(2) 추가 처분사유

- 소송 과정에서 새롭게 제시된 사유는 계약 당시 관계 공무원에게 뇌물을 제공했다는 것이다. 이는 뇌물수수라는 범죄적 행위로, 공정한 입찰 질서와 공무원 직무의 공정성을 침해한 전혀 다른 성격의 위법행위이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 판단

(1) 내용의 차이

- 당초 사유는 계약의 불이행이라는 사후적 채무불이행에 관한 것이고, 추가 사유는 계약 체결 과정에서의 뇌물 제공이라는 범죄행위이다. 두 사실은 발생 시점, 위법성의 본질, 법적 평가에서 명확히 구별된다.

(2) 법률적 평가의 차이

- 계약 불이행은 행정상의 계약 관계를 위반한 것이며, 뇌물 제공은 형법상 범죄로서 사회적 비난 가능성이 훨씬 중하다. 따라서 동일한 법률관계에 속한다고 보기 어렵다.

(3) 방어권 침해 여부

- 만약 뇌물 제공 사실을 추가 사유로 인정한다면, 甲은 전혀 다른 범죄 사실에 대한 방어를 준비해야 하므로 방어권이 중대하게 침해된다. 이는 예측 불가능한 새로운 공격 방어방법 제시에 해당한다.

(4) 검토

- 따라서 계약 불이행과 뇌물 제공은 기본적 사실관계의 동일성을 인정하기 어렵다. 추가 사유를 허용한다면 사실상 새로운 처분사유를 소송 과정에서 뒤늦게 보완하는 것이 되어 허용될 수 없다.

IV. 결론

- 처분사유 추가·변경은 원칙적으로 허용되지 않으며, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 예외적으로 허용된다. 본 사안에서 당초 처분사유인 계약 불이행과 추가된 사유인 뇌물 제공은 발생 시점과 위법성의 성질, 법률적 평가에서 전혀 다른 사실관계에 해당하므로 동일성을 인정할 수 없다. 따라서 처분청이 소송 도중 뇌물 제공 사실을 추가 사유로 내세운 행위는 소송상 허용되지 않는다.

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

[기출][2015-1-2]개발행위 불허가 처분 취소소송 중 기반시설 설치계획 부적절 사유 외 환경 부조화 사유 추가 가능 여부

《【문제1】 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 `해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다`라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 취소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50점)

(물음2) 乙은 취소소송의 계속 중 `국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요가 있고 주변 환경이나 경관과 조화를 이루지 못 한다`라는 처분사유를 새로이 추가할 수 있는가? (30점)》

<문제1의 물음2> 개발행위 불허가 처분 취소소송 중 기반시설 설치계획 부적절 사유 외 환경 부조화 사유 추가 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 개발행위 불허가처분의 취소를 구하는 소송 계속 중 처분청 乙은 당초의 기반시설 확보계획 부적절이라는 처분사유 외에 국토 및 자연의 유지와 환경보전 등 중대한 공익상의 필요와 주변 환경·경관과의 부조화라는 새로운 처분사유를 추가하려고 한다. 쟁점으로 <취소소송 계속 중 당초 처분사유와 다른 새로운 처분사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 취소소송의 계속 중 새로운 처분사유를 추가할 수 있는지 설명한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 법리

1. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 성격

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 처분 당시 제시했던 사유 외에 다른 사유를 추가하거나 변경하여 주장하는 소송법상 행위를 말한다.

(2) 인정의 필요성

- 행정소송법상 명문 규정은 없으나 법원은 분쟁의 일회적 해결을 통한 소송경제 도모와 반복 소송의 방지를 위해 제한적인 범위 내에서 처분사유의 추가·변경을 인정하고 있다.

2. 처분사유의 추가·변경의 허용 한계

(1) 기본적 사실관계의 동일성 요건

- 추가되는 사유는 당초 처분사유와 기본적 사실관계에서 동일성이 유지되어야 한다. 동일성 여부는 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해 법익 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지에 따라 판단한다.

(2) 시간적 및 절차적 요건

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시에 이미 존재했던 객관적 사실에 한하여 허용되며(시간적 한계), 원고의 실질적 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 허용되어야 한다(절차적 한계).

III. 사안의 적용

1. 당초 처분사유와 추가 처분사유의 사실관계 비교

(1) 당초 처분사유의 성격

- 당초의 사유인 `기반시설의 설치 및 용지확보계획 부적절`은 개발행위 자체의 기술적·물리적 계획상의 미비점을 지적한 것이다.

(2) 추가 처분사유의 성격

- 추가하려는 사유인 `국토 및 자연의 유지, 환경보전 등 공익적 필요 및 경관과의 부조화`는 개발행위가 주변 환경에 미치는 생태적·공익적 영향을 판단한 것이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 여부 판단

(1) 구체적 판단 및 판례의 태도

- “대법원 판례”에 의할 때, 개발행위허가신청 거부처분의 당초 사유인 `기반시설 설치나 그에 필요한 용지확보계획 부적절`과 소송 과정에서 추가하려는 사유인 `인근 토지의 환경·경관 저해 및 환경보전 등 공익상 필요`는 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 객관적으로 동일하다고 보기 어렵다.

(2) 피고 乙의 주장에 대한 법원의 조치

- 두 사유 사이에는 기본적 사실관계의 동일성이 부정되므로, 법원은 피고 乙의 처분사유 추가 주장을 허용해서는 안 된다.

IV. 결론

- 취소소송 중 피고 행정청의 처분사유의 추가·변경 주장은 당초의 사유와 추가하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 존재해야만 허용된다. 사안에서 乙이 추가로 주장하는 환경보전 및 경관조화의 사유는 당초 사유인 기반시설 및 용지확보계획 부적절과 객관적 사실 내용이 완전히 다른 별개의 사유에 해당한다. 따라서 양 사유 간에는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로, 법원은 피고 乙의 추가 주장을 허용해서는 안 되며 당초의 기반시설 관련 사유만을 기준으로 불허가처분의 적법 여부를 심리하여야 한다.

《[문제1] 사용자인乙주식회사는 소속 근로자인甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한乙주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 갑을 3월의 징계처분을 하였다. 甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다. 甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에 甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50점)

(물음2) 중앙노동위원회는 이 소송의 계속 중에 甲과 A노동조합의 유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당하여 징계사유에 해당한다고 추가적으로 주장한다. 이러한 중앙노동위원회의 주장이 타당한지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 취소소송 계속 중 피고인 중앙노동위원회가 징계사유를 추가적으로 주장하는 것의 허용 여부 및 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 중앙노동위원회의 재심판정에 대한 취소소송 계속 중 중앙노동위원회가 기존 재심판정의 사유 외에 유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당하여 징계사유가 된다는 새로운 사유를 추가하여 주장하고 있다. 쟁점으로 <취소소송 계속 중 중앙노동위원회가 새로운 사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 중앙노동위원회의 새로운 주장 추가가 소송상 허용되는지 논한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 법리

1. 의의 및 인정 근거

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분 당시에 제시했던 구체적 근거 사유를 소송 계속 중에 새로운 사유로 교체하거나 보충하는 것을 말한다. 행정소송법에는 이에 관한 명문의 규정이 없으나, “판례”와 학설은 행정의 능률성과 소송경제 및 분쟁의 일회적 해결을 근거로 일정한 범위 내에서 이를 인정하고 있다.

2. 허용 한계 : 기본적 사실관계의 동일성

(1) 동일성의 의미

- “판례”는 처분사유의 추가·변경이 허용되기 위해서는 추가 또는 변경되는 사유가 당초의 처분사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되어야 한다고 판시하고 있다. 여기서 동일성 여부는 서구적·추상적으로 판단할 것이 아니라, 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 피해 대상 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지 여부에 따라 판단한다.

(2) 시간적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 시(재심판정 시)를 기준으로 그 이전에 이미 존재했던 사유에 한하여 가능하다. 처분 이후에 발생한 새로운 사실을 근거로 사유를 추가하는 것은 허용되지 않는다.

(3) 절차적 한계

- 추가하려는 사유가 당초 사유와 동일성이 인정되더라도, 법원은 당사자의 방어권 행사에 지장을 주지 않는 범위 내에서 이를 허용해야 한다.

III. 사안의 적용

1. 추가 사유와 당초 사유의 동일성 검토

(1) 당초의 사유

- 중앙노동위원회가 재심판정을 내릴 때 근거로 삼은 사유는 甲의 ‘유인물 배포 등 행위’ 및 ‘성명서 발표 및 기사 게재로 인한 명예훼손행위’이다.

(2) 추가된 사유

- 소송 계속 중 중앙노동위원회가 새롭게 주장하는 사유는 ‘유인물 배포행위가 정당하지 않은 노동조합행위에 해당한다’는 것이다.

(3) 판단

- 중앙노동위원회의 추가 주장은 당초 징계사유로 삼았던 ‘유인물 배포행위’라는 객관적 사실을 바탕으로, 그 행위의 법적 성격이나 평가를 정당성 없는 노동조합행위로 구체화하거나 보충하는 것에 해당한다. 이는 동일한 행위(유인물 배포)에 대한 법적 평가의 관점을 달리하는 것이거나 구체적 사실을 보완하는 것으로서, 사회적 사실관계의 객관적 측면에서 시간적·장소적 동일성이 인정된다고 볼 수 있다.

2. 소송경제 및 방어권 보호 측면

- 중앙노동위원회의 이러한 주장은 새로운 징계사유를 창설하는 것이 아니라, 이미 징계대상으로 삼았던 행위의 부당성을 논증하는 과정에서 나온 것이다. 따라서 원고인 甲의 입장에서 전혀 예상치 못한 새로운 사실관계에 대한 방어를 강요받는 것으로 보기 어려우며, 이를 소송 절차 내에서 판단하는 것이 분쟁의 일회적 해결이라는 취지에도 부합한다.

IV. 결론

- 중앙노동위원회가 소송 계속 중 추가로 주장한 사유는 당초의 재심판정 사유인 유인물 배포 등 행위와 기본적 사실관계의 동일성이 인정된다. 이는 새로운 처분사유를 내세우는 것이 아니라 당초 사유를 구체화하거나 그 법적 근거를 명확히 하는 범위 내에 있다고 판단된다. 따라서 “판례”의 처분사유 추가·변경 법리에 비추어 볼 때 중앙노동위원회의 주장은 허용될 수 있으며, 해당 주장이 사실로 밝혀질 경우 징계사유의 적정성을 뒷받침하는 근거로 활용될 수 있으므로 타당하다고 할 것이다.

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

[기출][2021-3]취소소송 계속 중 피고 행정청이 당초 징계사유 외에 다른 징계사유를 추가적으로 주장할 수 있는지 여부

《[문제3] 국가공무원 甲은 업무시간 중 민원인으로부터 골프접대 등의 뇌물을 수수하였다는 이유로 징계권자로부터 해임의 징계처분을 받고, 그 징계처분에 대하여 소청심사를 거쳐 취소소송을 제기하였다. 피고 행정청은 취소소송의 계속 중 甲이 뇌물수수뿐만 아니라 업무시간 중 골프접대를 받는 등 직무를 태만히 한 것도 징계사유의 하나라고 소송절차에서 주장하였다. 이러한 피고의 주장이 허용되는지 설명하시오. (25점)》

「국가공무원법 제78조(징계 사유)」

❶ 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 징계 의결을 요구하여야 하고 그 징계 의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.

1. 이 법 및 이 법에 따른 명령을 위반한 경우
2. 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무를 포함한다)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3. 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

<문제3> 취소소송 계속 중 피고 행정청이 당초 징계사유 외에 다른 징계사유를 추가적으로 주장할 수 있는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 국가공무원 甲은 뇌물수수를 이유로 해임처분을 받고 취소소송을 제기하였는데, 소송 계속 중 피고 행정청은 당초 처분사유 외에 업무시간 중 골프접대를 받는 등 직무태만 행위도 징계사유에 해당한다고 추가 주장하고 있다. 쟁점으로 <취소소송에서 처분청이 당초 처분 당시 제시하지 않은 새로운 징계사유를 추가하여 주장하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 피고 행정청의 새로운 징계사유 주장 허용 여부에 대하여 설명한다.

II. 처분사유의 추가·변경과 재량행위의 법리

1. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 필요성

(1) 개념 및 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 소송 계속 중에 처분의 적법성을 유지하기 위해 처분 당시 제시했던 사유 외에 다른 사유를 추가하거나 변경하여 주장하는 소송법상 행위를 말한다.

(2) 인정의 필요성

- 행정소송법상 명문 규정은 없으나 법원은 분쟁의 일회적 해결을 통한 소송경제 도모와 반복 소송의 방지를 위해 제한적인 범위 내에서 처분사유의 추가·변경을 인정하고 있다.

2. 처분사유의 추가·변경의 허용 한계

(1) 기본적 사실관계의 동일성

- 추가되는 사유는 당초 처분사유와 기본적 사실관계에서 동일성이 유지되어야 한다. 동일성 여부는 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해 법익 등을 종합하여 사회적 사실관계가 객관적으로 동일한지에 따라 판단한다.

(2) 시간적 및 절차적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시에 이미 존재했던 객관적 사실에 한하여 허용되며(시간적 한계), 원고의 실질적 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 허용되어야 한다(절차적 한계).

3. 재량행위와 처분사유의 추가·변경

(1) 허용 여부에 관한 학설

- 재량행위의 경우 처분사유를 변경하면 재량권 행사의 기초가 바뀌어 법원의 재량심사 구도가 변하므로 허용할 수 없다는 부정설과, 기속행위와 마찬가지로 일정한 범위 내에서 인정해야 한다는 제한적 긍정설이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 처분의 성격이 기속행위인지 재량행위인지 여부를 불문하고, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서는 처분사유의 추가·변경을 허용한다는 일관된 입장을 취하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 재량행위인 징계처분에서의 적용 가능성

(1) 징계처분의 성격

- 공무원에 대한 해임처분 등 징계처분은 관계 법령상 행정청의 광범위한 재량이 인정되는 재량행위에 해당한다.

(2) 판례에 따른 처분사유의 추가·변경의 허용

- 재량행위인 공무원 징계처분이라 하더라도 “판례”에 의할 때 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 한 처분사유의 추가·변경 자체는 가능하다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 여부 판단

(1) 당초 사유와 추가 사유의 성격 분석

- 당초의 징계사유는 뇌물수수로 국가공무원법상 청렴의무 위반에 해당하며, 추가하려는 사유는 직무태만으로 성실의무 위반에 해당한다.

(2) 동일성 부정에 따른 불허

- 두 사유는 근무시간 중에 발생한 골프행위라는 점에서 시간적·장소적 밀접성이 있어 보이나, 의무 위반의 구체적 내용과 침해 법익이 상이하다. 뇌물수수는 직무의 청렴성을 해치는 비위이고, 직무태만은 직무 수행의 성실성을 저해하는 행위로 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 객관적으로 동일하다고 보기 어렵다. 따라서 두 사유 간의 기본적 사실관계의 동일성은 부정된다.

IV. 결론

- 취소소송 중 피고 행정청의 처분사유의 추가·변경 주장은 당초의 사유와 추가하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 존재해야만 허용된다. 사안의 해임처분은 재량행위이므로 처분사유의 추가·변경을 허용함에 있어 원고의 방어권 보장이 더욱 엄격하게 요구된다. 피고 행정청이 추가로 주장하는 직무태만의 사유는 당초 징계사유인 뇌물수수와 의무 위반의 취지 및 객관적 사실 내용이 완전히 다른 별개의 징계사유에 해당한다. 따라서 양 사유 간에는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로, 법원은 피고 행정청의 추가 주장을 허용해서는 안 되며 당초의 뇌물수수 사유만을 기준으로 해임처분의 적법 여부를 심리하여야 한다.

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2013-1-2]과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

《【문제1】 甲은 乙이 대표이사로서 있는 A운수주식회사에서 운전기사로서 근무하고 있는데, A회사의 노사간에 체결된 임금협정에는 운전기사의 법령위반행위로 회사에 과징금이 부과되면 추후 당해 운전기사에 대한 상여금 지급시 그 과징금 상당액을 공제하기로 하는 내용이 포함되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 과징금부과처분에 대한 취소소송에서 법원이 A회사에 대한 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단할 경우, 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내에서 과징금부과처분의 일부를 취소할 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음2> 과징금부과처분이 과다할 경우 법원의 일부취소판결 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A운수주식회사는 운전기사 甲의 법령위반행위로 부과된 과징금처분의 취소소송을 제기하였고, 법원은 해당 과징금의 금액이 지나치게 과다하다고 판단하는 경우이다. 쟁점으로 <재량행위인 과징금부과처분에 대하여 법원이 적정하다고 판단하는 한도 내에서 일부 취소판결을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 과징금부과처분에 대한 법원의 일부 취소 가능 여부에 대하여 논한다.

II. 일부취소판결의 요건 및 재량행위에 대한 한계

1. 행정소송법상 변경의 의미와 일부취소의 요건

(1) 소극적 변경으로서의 일부취소

- "행정소송법 제4조 제1호"는 취소소송의 목적을 처분의 취소 또는 변경으로 규정한다. "판례"는 "대법원 전원합의체 판결"을 통해 여기서의 변경을 소극적 변경인 일부취소로 이해한다. 법원이 스스로 처분을 변경하는 적극적 변경은 권력분립 원칙상 허용되지 않는다.

(2) 일부취소의 실체법적 요건

- 하나의 행정처분이라 하더라도 처분의 대상이나 액수가 객관적으로 가분적이거나 특정할 수 있어야 일부취소가 가능하다. 가분성이 없거나 구체적 수액을 산정할 수 없는 경우에는 일부취소가 원천적으로 불가능하다.

2. 기속행위와 재량행위에 따른 일부취소의 범위

(1) 기속행위와 일부취소

- 기속행위의 경우 처분의 가분성이 인정되고 법원이 제출된 자료에 의하여 적법하게 부과될 구체적인 금액을 명확히 산출할 수 있다면, 법원은 위법한 부분만을 특정하여 일부취소판결을 내릴 수 있다.

(2) 재량행위와 일부취소의 제한

- 재량행위의 경우에는 처분청에 공익과 사익을 이익형량할 수 있는 독자적인 재량권이 유보되어 있다. 따라서 법원이 적정한 한도액을 직접 산출하여 초과 부분만을 일부취소하는 것은 처분청의 재량권을 박탈하고 사법부가 제1차적 판단권을 행사하는 결과가 되어 권력분립 원칙에 반한다. 이에 따라 재량행위의 경우 예외적인 경우를 제외하고는 처분 전부를 취소하여 행정청이 적법하게 재량을 다시 행사하도록 하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 과징금부과처분의 법적 성질

(1) 재량행위성 검토

- 여행자동차운수사업법상 과징금부과처분은 영업정지처분에 갈음하여 부과되는 제재적 금전부과처분으로서, 행정청에 부과 여부 및 수액 산정에 관한 광범위한 재량권이 부여된 재량행위에 해당한다.

(2) 독자적 한도액 산정의 불가능성

- 과징금 부과는 일련의 위반행위에 대하여 하나의 제재로서 총액으로 부과되는 것이므로, 이를 임의로 나누어 취소할 수 있는 구체적 기준이 소송과정에서 당연히 도출되는 것은 아니다.

2. 일부취소판결의 가능성 판단

(1) 일탈·남용에 따른 전부취소의 원칙

- 법원이 보기에 이 사건 과징금 액수가 지나치게 과다하여 이익형량의 한계를 벗어난 위법이 있다고 판단하는 경우, 해당 처분은 재량권의 일탈·남용으로 처분 전부가 위법하게 된다.

(2) 사법심사의 한계와 일부취소 부정

- 법원이 스스로 적정한 과징금 액수를 결정하여 이를 초과하는 부분만을 일부취소하는 것은 행정청의 권한인 재량의 영역에 침범하는 것이다. 따라서 법원은 적정하다고 판단하는 한도 내로 과징금부과처분의 일부만을 취소할 수 없으며, 과징금부과처분 전부를 취소하여야 한다.

IV. 결론

- 행정소송법상 일부취소판결은 대상 처분이 가분적이고 기속행위이거나 구체적 적법 수액을 명확히 특정할 수 있는 경우에 한하여 허용된다. 사안의 과징금부과처분은 전형적인 재량행위에 해당하므로 법원이 독자적인 이익형량을 통해 적정 한도액을 산정하여 일부취소판결을 내리는 것은 행정청의 재량권을 침해하여 권력분립 원칙에 반한다. 결론적으로 법원은 과징금 액수가 지나치게 과다하여 위법하다고 판단하더라도 이를 일부취소할 수 없으며, 과징금부과처분 전체를 취소하는 판결을 내려야 한다.

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2015-3]항고소송의 사정판결의 의의, 취지, 요건, 효과

《【문제3】 항고소송에 있어서의 사정판결에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 항고소송의 사정판결의 의의, 취지, 요건, 효과

I. 문제의 제기

- 항고소송은 행정청의 위법한 처분이나 부작위를 대상으로 하여 그 취소 또는 무효확인을 구하는 소송으로, 원칙적으로 위법한 행정행위는 사법심사를 통하여 제거되어야 한다. 그러나 경우에 따라 행정처분이 위법하더라도 이를 취소하는 것이 오히려 현저히 공공복리에 반하는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 상황에서 법원은 원고의 청구가 이유 있다고 인정하면서도 예외적으로 취소를 기각하는 판결, 즉 사정판결을 선고할 수 있다. 이하에서는 사정판결의 의의, 제도적 취지, 요건, 효과를 중심으로 검토한다.

II. 사정판결의 의의

- 사정판결이란 행정처분이 위법하여 취소되어야 함에도 불구하고, 그 취소로 인하여 발생할 공공복리에 반하는 결과가 현저히 크다고 인정되는 경우 법원이 예외적으로 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. ("행정소송법 제28조") 즉, 위법성을 인정하면서도 공익과 사익의 비교형량을 통해 공익적 요소를 우선하는 판결형태이다.

III. 사정판결의 제도적 취지

- 사정판결은 행정소송의 목적이 단순히 위법한 처분의 제거에만 있지 않고, 법질서 전체의 조화와 사회적 타당성 확보에 있다는 점에서 제도화되었다. 행정처분의 취소가 사회 전체에 심각한 혼란을 야기하거나 이미 형성된 공익적 법률관계를 무너뜨리는 경우, 법원이 사정판결을 통해 법치주의와 공익적 안정성을 조화롭게 조정할 수 있다. 이는 행정의 안정성과 법적 정의를 동시에 고려하는 장치라 할 수 있다.

IV. 사정판결의 요건

1. 본안 소송이 적법할 것

- 사정판결은 본안심리에 들어가 위법 여부를 판단한 이후에만 선고될 수 있다. 따라서 소 제기가 부적법하거나 본안 심리 자체가 불가능한 경우에는 사정판결이 허용되지 않는다.

2. 원고의 청구가 이유 있을 것 (대상 처분의 위법성)

- 사정판결은 전제가 되는 처분이 위법하여 원고의 청구가 인용되어야 함에도 불구하고, 예외적으로 기각하는 판결이므로, 반드시 처분의 위법성이 인정되어야 한다.

3. 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아닐 것

- 이는 사정판결의 핵심 요건이다.

(1) 판단 기준

① 공익과 사익의 비교형량

- 취소판결로 인해 침해되는 공익과 원고가 얻을 사익을 비교하여 공익의 침해가 현저히 큰 경우 사정판결이 가능하다.

② 판단 시점

- 처분 당시가 아니라 변론종결시를 기준으로 판단한다는 것이 "판례"의 입장이다.

③ 구체적 사정 고려

- 단순히 추상적 공익을 이유로 할 수 없고, 구체적 사정을 고려하여 현저히 공공복리에 반하는지를 살펴야 한다.

(2) 판례상 인정 사례

① 대규모 공공사업

- 도로, 댐, 철도 등 이미 상당 부분 진행되어 취소 시 사회적 비용이 막대한 경우.

② 교육 제도

- 학교 설립인가 취소 시 이미 입학한 학생들의 교육권 보호 필요성이 큰 경우.

③ 기타

- 사회복지시설이나 대규모 기반시설의 설치 등 공익적 요소가 현저한 경우.

4. 법원의 사정조사 의무

- 행정소송법은 법원에 대해 사정판결을 할 경우 공공복리에 적합하지 아니함을 조사할 의무를 명시하고 있다. 따라서 법원은 단순히 공익을 추정할 것이 아니라 변론 전체의 취지와 증거조사를 통해 실질적으로 판단해야 한다.

V. 사정판결의 효과

1. 주문에서의 위법성 명시

- 사정판결은 단순 기각판결과 달리, 처분이 위법함을 전제로 기각한다. 따라서 주문에서 그 취지를 반드시 밝혀야 하며, 원고의 청구가 이유 있음을 인정한 기록이 남는다.

2. 기판력

- 사정판결도 기판력을 가진다. 즉, 해당 처분의 위법 여부에 관한 판단은 확정되어 다시 다툴 수 없다. 다만, 위법성을 인정하고도 취소하지 않았다는 점에서 원고에게 일정한 불이익이 남는다.

3. 기속력

- 사정판결에는 일반 취소판결과 마찬가지로 기속력이 인정된다. 따라서 행정청은 그 판결에서 인정된 위법사유를 시정할 필요가 있으며, 동일한 위법을 반복해서는 안 된다.

VI. 결론

- 사정판결은 행정처분이 위법함에도 불구하고 공익과 사익의 비교형량 결과, 취소가 현저히 공공복리에 반한다고 판단되는 경우에 예외적으로 허용되는 제도이다. 이는 법치주의적 요청과 공익적 안정성 확보라는 두 가치를 조화시키기 위한 장치로서 기능한다. 다만 남용될 경우 국민의 권리구제가 위

측될 수 있으므로, 법원은 사정판결을 엄격하게 제한하여 적용해야 한다. 결국 사정판결은 행정소송에서 공익과 사익의 긴장을 조정하는 예외적 제도로서 의의가 크다.

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

[기출][2024-1-2]추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

《[문제1] 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아휴직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음2) 甲은 소송의 계속 중에 조정이 성립하여 소를 취하하고 육아휴직급여의 전액을 지급받았다. 이후 甲이 육아휴직기간 중 8개월 동안 해외에서 체류하여 해당 영유아와 동거하지 아니한 사실(이는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제14조에서 정하는 육아휴직 종료 사유이다)이 적발되었다. A는 甲에게 8개월에 해당하는 육아휴직급여의 반환명령 및 그 100/100에 해당하는 추가징수를 처분하였다. 甲이 추가징수 처분이 생계를 현저히 곤란하게 하므로 위법하다는 이유로 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우 법원이 처분의 일부를 취소할 수 있는지를 설명하시오. (20점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직 등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음2> 추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 육아휴직급여를 지급받은 후 육아휴직기간 중 해외 체류로 육아휴직 종료 사유가 발생하였다는 이유로 육아휴직급여 반환명령 및 추가징수처분을 받았고, 이에 추가징수처분의 위법을 이유로 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <추가징수처분이 재량행위에 해당하는 경우 법원이 생계곤란 등의 사정을 고려하여 처분의 일부를 취소할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 추가징수 처분에 대한 법원의 일부 취소 가능 여부에 대하여 설명한다.

II. 반환명령과 추가징수의 법적 성질

1. 반환명령

- 육아휴직급여는 고용보험법에 따른 사회보험급여로, 수급요건을 충족하지 않은 상태에서 지급받은 급여는 부당이득에 해당한다. 이에 대한 반환명령은 기속행위의 성격을 가지며, 위법한 급여수급 사실이 확인되면 반드시 발령되어야 한다.

2. 추가징수

- "고용보험법 제116조 제2항"은 부정수급액의 100/100에 해당하는 추가징수를 규정하고 있는데, 이는 제재적 성격을 가지는 재량행위이다. 따라서 반환명령과 추가징수는 법적 성질상 구분되며, 각각 독립한 처분으로 볼 수 있다.

III. 재량행위와 사법심사의 한계

1. 재량행위의 통제 범위

- 법원은 재량행위의 적법성을 심사할 때, 행정청이 재량을 행사함에 있어 비례·평등 원칙 등 일반원칙을 위반하거나, 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 경우에 한하여 재량권 일탈·남용으로 위법성을 판단할 수 있다.

2. 대법원 판례

- "대법원"은 법원은 재량행위에 대하여 그 일탈·남용 여부만을 심사할 수 있을 뿐, 제재수준이 적정한지 여부를 독자적으로 판단하여 감경 내지 변경하는 것은 허용되지 않는다고 하였다. 즉, 법원은 재량판단의 당부 자체를 대체할 권한이 없고, 오직 그 재량행위가 사회통념상 현저히 불합리하여 위법한지 여부만 심사할 수 있다.

3. 가분성 문제

- 행정처분이 가분성을 갖는 경우에는 일부 취소도 가능하지만, 재량행위의 경우 법원이 일부 취소를 통해 제재수준을 실질적으로 변경하는 것은 곧바로 재량권의 대체행사로 이어질 수 있으므로 허용되지 않는다. 따라서 반환명령과 추가징수가 법적으로 구분된다 하더라도, 법원이 추가지급분만 취소하는 것은 자칫 제재의 경중을 조절하는 결과가 될 수 있어 제한된다.

IV. 사안의 적용

1. 반환명령 부분

- 甲이 8개월 동안 영유아와 동거하지 않은 사실은 법령상 육아휴직급여 수급자격 상실 사유에 해당한다. 이에 따라 해당 기간 지급된 급여는 부정수급으로 보아 반환명령을 내린 A의 처분은 기속행위로 정당하다. 법원은 이를 취소할 수 없다.

2. 추가징수 부분

- 추가징수는 재량행위이므로, 법원은 A가 생계 곤란 사정을 고려하지 않고 기계적으로 전액을 부과한 것이 사회통념상 현저히 불합리한지 여부를 심사한다. 만약 생계 유지가 사실상 불가능할 정도의 과도한 제재로 평가될 경우, 이는 재량권 일탈·남용으로 위법하다. 그러나 법원은 그 위법성을 인정할 경우 추가징수처분 전부를 취소할 수 있을 뿐, 일부만 감액하는 방식으로 적정 수준을 새로 설정할 수는 없다. 이는 "판례"("2007두18062")가 확인한 바와 같이 법원이 재량권을 대체할 권한이 없기 때문이다.

3. 결론적 판단

- 따라서 법원은 반환명령 부분은 그대로 두되, 추가징수 전액이 사회통념상 과도하다고 인정된다면 추가징수처분 전체를 취소할 수 있다. 그러나 추가징수처분을 일부만 취소하여 추가징수액을 감경하는 방식의 판결은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 육아휴직급여 반환명령은 기속행위로서 정당하며 취소될 수 없다. 추가징수처분은 재량행위로서, 그 전액 부과가 甲의 생계 곤란 등 구체적 사정을 전혀 고려하지 않아 비례원칙에 반해 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 경우 재량권 일탈·남용으로 위법하게 된다. 다만 법원은 "판례"("2007두18062")가 확인한 바와 같이 법원이 재량권을 대체할 권한이 없기 때문이다.

2")가 설시한 바와 같이 재량권 일탈 여부만 심사할 수 있을 뿐, 제재수준을 적정하게 감경·변경하는 권한은 없다. 따라서 법원은 반환명령은 존속시키
되, 추가징수처분 전부를 취소할 수 있을 뿐, 일부만 취소하는 것은 허용되지 않는다.

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2010-1]거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

《【문제1】 수익적 처분의 발령을 신청한 甲에 대하여 관할 행정청 A는 이를 거부하였다. 甲은 거부처분취소소송을 제기하여 인용판결을 받았고, A의 항소 포기로 동 판결은 확정되었다. 위 확정판결에도 불구하고 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우들을 논하시오. (50점)》

<문제1> 거부처분 취소소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재차 거부처분이 허용되는 구체적 예외 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 수익적 처분의 거부처분취소소송에서 인용판결이 확정되었음에도 불구하고 행정청 A가 다시 거부처분을 할 수 있는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <거부처분취소판결의 기속력에도 불구하고 행정청이 재차 거부처분을 할 수 있는 예외적인 경우와 그 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분취소판결의 기속력에 반하지 아니하여 행정청 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우를 논한다.

II. 확정판결의 기속력

1. 기속력의 의미 및 특성

- 취소판결의 기속력은 확정된 취소판결의 실효성을 확보하기 위하여, 판결의 내용과 모순되는 행위를 반복할 수 없도록 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 효력이다. ("행정소송법 제30조 제1항") 이는 소송 당사자 및 법원을 구속하는 일반적인 기판력(既判力)과 구별되는 행정소송 특유의 효력이다. 기속력은 행정청의 자의적인 행정 작용을 방지하고 행정의 합법성을 확보함으로써 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 기속력의 내용(재처분 의무와 반복 금지 의무)

- 거부처분 취소판결이 확정된 경우, 기속력은 행정청에게 다음과 같은 의무를 부과한다.

(1) 재처분 의무 (적극적 의무)

- 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 적극적인 의무를 부담한다. ("행정소송법 제30조 제2항") 판결이 거부사유를 위법하다고 판단했으므로, 원칙적으로 행정청은 위법 사유를 제거하고 신청된 수익적 처분을 발령해야 할 의무를 진다.

(2) 반복 금지 의무 (소극적 의무)

- 행정청은 법원이 위법하다고 판단한 사유와 동일한 사유를 근거로 동일한 내용의 처분을 다시 해서는 안 된다. 이 의무는 기속력의 객관적 범위가 미치는 핵심 영역이며, 행정청이 패소한 동일한 쟁점을 반복적으로 제기하여 신청인을 괴롭히는 것을 방지한다.

3. 기속력의 범위

(1) 객관적 범위

- 기속력은 단순히 판결의 주문(예 : 거부처분을 취소한다)에만 미치는 것이 아니라, 판결의 주문 도출의 전제가 된 구체적인 위법 사유에 관한 판단에 미친다. 즉, 법원이 해당 거부처분이 왜 위법한지 판단한 처분 사유의 존부 및 당부(當否)에 대한 판단에 기속력이 발생한다.

(2) 시간적 범위

- 기속력은 원칙적으로 종전 거부처분 시에 존재했던 사실관계와 법령을 기준으로 판단된 위법성에 한하여 미친다. 따라서 판결 확정 후에 새로이 발생한 사유나 법령의 변화는 기속력의 시간적 범위 밖에 놓이게 될 가능성이 있다.

III. 확정판결에도 재차 거부처분을 할 수 있는 경우

- 행정청이 확정된 취소판결에도 불구하고 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는, 그 재차 거부처분이 종전 판결의 기속력에 저촉되지 않는 새로운 사유에 근거할 때에 한정된다. 이는 실질적인 법치 행정의 요청과 국민의 실효적 권리 구제라는 두 가치 사이의 조정을 통해 도출된 것이다.

1. 새로운 법적·사실적 사유에 근거하여 거부하는 경우

- 이는 거부 사유가 종전 처분 시 이미 존재했던 사유이기는 하나, 종전 거부처분의 위법성 판단에 전제가 된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는 경우이다.

(1) 새로운 사유의 허용 원칙

- 거부처분 취소판결의 기속력은 판결에서 위법하다고 판단된 사유에 한정되므로, 행정청은 그 기속력에 저촉되지 않는 한 종전 처분 시 이미 존재하고 있던 다른 독립적인 사유를 들어 다시 거부처분을 할 수 있다.

(2) 기본적 사실관계의 동일성의 판단

- 새로운 거부 사유가 되기 위해서는 종전 거부 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않아야 한다.

① 동일성 부정의 의미

- 두 사유가 법적 쟁점이 다르고, 각 사유를 뒷받침하는 구체적인 사실관계가 상호 독립적이어서, 행정청이 종전 처분 시 하나의 사유만 주장했다 하더라도 다른 사유를 주장하지 않은 데 상당한 이유가 있는 것으로 볼 수 있는 경우를 의미한다. 예를 들어, 신청서류 미비와 공익 목적상 거부는 그 근거가 되는 사실관계와 법적 판단의 관점이 완전히 다르므로 동일성이 부정된다.

② 판례의 입장

- “대법원”은 거부처분 취소판결 확정 후 재처분을 하면서 종전 거부처분의 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 볼 수 없는 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 저촉되지 않는다고 본다. 이 경우 행정청은 새로운 사유를 근거로 적법하게 재차 거부처분을 할 수 있다.

(3) 법적 근거

- 만약 행정청이 모든 거부 사유에 대해 기속력을 받게 된다면, 행정청은 소송에서 모든 사유를 한꺼번에 주장할 것이고, 이는 소송의 복잡화와 소송경제의 저해를 초래할 수 있다. 따라서 법원은 기본적 사실관계의 동일성이 없는 독립된 새로운 사유에 대해서는 기속력의 적용을 배제한다.

2. 판결 확정 후에 새로운 법령이 제정·개정된 경우

- 거부처분 취소판결이 확정된 후, 행정청이 재처분 의무를 이행하기 전에 새로운 법령이 제정 또는 개정되어 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 법적으로 발생한 경우이다.

(1) 법적 근거

- 취소판결의 기속력은 처분 시의 법령에 근거하여 발생한 위법성에 한하여 미치지만, 행정청의 재처분은 재처분 시의 유효한 법령을 적용해야 한다. 이는 법치주의 원칙상 재처분 시의 적법한 법령을 적용해야 할 행정청의 의무가 종전 판결의 기속력보다 우선하기 때문이다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 확정판결 이후 법령이 변경되어 그 변경된 법령을 적용함으로써 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 발생하였다면, 행정청은 변경된 법령을 근거로 재차 거부처분을 할 수 있다고 명시하였다.

(3) 예시

- 행정청의 유해 물질 배출 시설 설치 허가 거부처분이 법원에 의해 취소판결 확정 후, 관련 환경법이 개정되어 배출 기준이 대폭 강화되었고, 이 새로운 기준에 따라 유해 물질 배출 시설 설치가 불가능하게 된 경우가 이에 해당한다.

3. 판결 확정 후에 새로운 사실이 발생하여 거부하는 경우

- 거부처분 취소판결이 확정된 후, 행정청이 재처분 의무를 이행하기 전에 새로운 사실이 발생하여 그 새로운 사실을 근거로 신청자의 신청이 거부되어야 할 사유가 발생한 경우이다.

(1) 법적 근거

- 기속력은 종전 처분 시에 존재했던 사실관계에 대한 판단에 미치므로, 판결 확정 후에 새로 발생한 사실에 근거한 거부처분은 기속력의 시간적 범위 밖에 있다. 행정청은 항상 최신의 정확한 사실관계를 바탕으로 적법하고 합목적적인 처분을 해야 할 의무가 있다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 확정판결이 있는 후 새로 발생한 사실을 근거로 하는 거부처분은 종전 판결의 기속력에 반하지 않는 새로운 처분으로 보아 허용된다고 본다.

(3) 예시

- 행정청의 건축 허가 거부처분이 법원에 의한 취소 판결로 확정된 후, 해당 건축 부지에 대형 싱크홀이 발생하여 안전상 이유로 건축이 불가능한 위험 구역으로 지정된 경우, 이 새로운 사실을 근거로 행정청은 재차 거부처분을 할 수 있다.

IV. 사안의 적용

- 법원의 거부처분 취소소송 인용판결 확정에도 불구하고 행정청 A가 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는 다음과 같이 요약하여 적용할 수 있다.

1. 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유

- 종전 거부 사유가 법원이 위법하다고 판단한 a 요건 미비였다면, A는 재처분 시 종전 처분 시 이미 존재했던 b 요건 미비를 이유로 거부할 수 있다. 단, b 요건은 a 요건과 법적 쟁점 및 사실관계가 완전히 달라 기본적 사실관계의 동일성이 부정되어야 한다.

2. 판결 확정 후 법령 변경

- 판결 확정 이후 관련 법령이 개정되어 甲의 신청 요건이 강화되었고, 그 강화된 요건을 적용할 경우 甲이 요건을 충족하지 못하게 된 경우, A는 변경된 법령을 근거로 거부처분을 할 수 있다.

3. 판결 확정 후 사실관계 변화

- 판결 확정 후, 신청 대상 목적물의 멸실이나, 신청인의 자격 상실, 또는 신청 대상 지역의 공익적 위험 발생 등 새로운 사실관계가 발생하여 이를 근거로 甲의 신청을 거부해야 할 사유가 생긴 경우, A는 이 새로운 사실을 근거로 거부처분을 할 수 있다.

V. 결론

- 행정청 A가 거부처분 취소소송의 인용판결 확정에도 불구하고 재차 거부처분을 할 수 있는 경우는, 그 재차 거부처분의 근거가 확정판결의 기속력에 저촉되지 않는 새로운 사유에 한정된다. 이는 ❶ 종전 판결이 인정한 위법 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유에 근거하거나, ❷ 판결 확정 후에 새로운 법령이 제정·개정되었거나, ❸ 판결 확정 후에 새로운 사실이 발생하여 거부 사유가 생긴 경우에 한하여 적법하게 인정될 수 있다. 이외의 사유로 재차 거부하는 것은 판결의 기속력 중 반복 금지 의무에 위반되어 위법하게 된다.

《【문제3】 공법상 결과제거청구권을 행정소송상 관철할 수 있는 방법에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 결과제거청구권(원상회복청구권)의 행정소송상 관철 방법

I. 문제 제기

- 행정작용이 위법하게 이루어진 경우, 단순히 그 행위를 취소하거나 무효로 돌리는 것만으로는 국민의 권리가 충분히 회복되지 않는 경우가 있다. 예컨대, 위법한 건축허가에 따라 건물이 건축된 상태, 또는 위법한 행정처분으로 인한 기재·등기 상태가 존재할 경우, 신청인은 단순한 취소판결로는 구제받을 수 없다. 이때 위법한 상태 자체를 제거하여 원래의 권리 상태를 회복하려는 권리가 문제되는데, 이를 공법상 결과제거청구권이라 한다. 이하에서는 그 의의와 성질을 검토한 후, 행정소송상 관철할 수 있는 구체적 방법을 설명한다.

II. 결과제거청구권의 의의

1. 개념

- 공법상 결과제거청구권이란 위법한 행정행위나 공권력 작용으로 인해 발생한 상태를 제거하고 원래의 권리 상태로 회복시켜 달라고 행정주체에 요구할 수 있는 권리를 말한다. 이는 단순히 위법 행위의 무효확인이나 취소를 넘어 위법상태를 적극적으로 제거한다는 점에 특징이 있다.

2. 성질

(1) 불법행위 성질

- 일부 학설은 위법한 행정작용을 원인으로 하는 불법상태 제거라는 점에서 민법상 불법행위 책임과 유사하다고 본다.

(2) 위법상태의 제거

- 다른 견해는 손해배상적 성격이 아니라, 단순히 위법상태 자체를 제거하는 것이므로 행정법상 독자적 권리로 본다.

(3) 손해배상청구와의 구별

- 손해배상청구가 이미 발생한 손해에 대한 전보적 구제라면, 결과제거청구권은 현재 진행 중인 위법상태를 종국적으로 제거한다는 점에서 구별된다. 따라서 양자는 상호 보완적 관계에 있다.

III. 행정소송상 관철 방법

1. 항고소송에 병합하여 제기하는 방법

(1) 취소소송과 병합

① 원칙

- 위법한 처분을 취소하는 동시에 그 처분으로 인한 상태 제거를 함께 청구할 수 있다.

② 적용

- 예컨대, 건축허가처분 취소소송에서 허가가 취소되면, 기재된 건축물대장 정정을 병합하여 청구할 수 있다.

③ 한계

- 다만 행정소송법은 주된 청구의 적법성을 전제로 하므로, 취소청구가 기각될 경우 결과제거청구도 함께 배척된다.

(2) 무효등 확인소송과 병합

- 무효확인소송과 병합하는 경우에도 무효확인의 결과로 발생한 위법상태 제거를 청구할 수 있다. 다만 이 경우 역시 주된 소송의 인용 여부에 종속되는 점에서 한계가 있다.

2. 당사자소송으로 제기하는 방법

(1) 의의

- 당사자소송은 공법상 권리·의무의 존부에 관한 분쟁을 다투는 소송이다. 결과제거청구권이 독립된 공법상 권리라면, 이를 기초로 당사자소송을 제기할 수 있다.

(2) 학설

- 긍정설과 다수설은 결과제거청구권을 독자적 공법상 권리로 보고, 당사자소송으로 제기 가능하다고 본다. 부정설은 행정소송법에 명문 규정이 없고, 간접적으로 취소소송이나 손해배상청구로 해결 가능하므로 부인한다.

(3) 판례

- “대법원”은 결과제거청구권을 독자적 공권리로는 보지 않고, 행정청의 작위의무가 명문으로 인정되는 경우에만 구제 가능하다고 하여 소극적 태도를 취하고 있다. 따라서 현실적으로는 당사자소송을 통한 관철은 쉽지 않다.

3. 의무이행소송 도입 시의 가능성 (현행법상 불인정)

(1) 의미

- 의무이행소송은 행정청에게 일정한 행위를 하도록 청구하는 소송이다. 만약 우리 법체계에 의무이행소송이 인정된다면, 결과제거청구권은 직접적으로 이 소송을 통해 실현될 수 있다.

(2) 현행법상 한계

- 그러나 행정소송법은 의무이행소송을 명문으로 인정하지 않고 있어, 결과제거청구권을 직접적으로 행사할 제도적 통로는 제한적이다.

4. 간접강제 또는 손해배상청구 (간접적 구제)

(1) 간접강제

- 법원이 취소판결이나 무효확인판결을 선고하였음에도 행정청이 그 결과를 이행하지 않을 경우, 간접강제 제도를 통해 실질적 권리구제를 확보할 수 있다.

(2) 손해배상청구

- 위법한 상태로 인해 손해가 발생하였다면, 결과제거가 불가능한 경우라도 국가배상청구를 통해 전보적 구제를 받을 수 있다.

IV. 결론

- 공법상 결과제거청구권은 위법한 행정작용으로 발생한 상태를 제거하여 원래의 권리 상태를 회복하고자 하는 권리로서, 손해배상청구와는 구별되는 독자적 기능을 가진다. 그러나 현행 행정소송법상 이를 직접적으로 관철할 수 있는 수단은 제한적이다. 현실적으로는 취소소송이나 무효등 확인소송에

병합하여 간접적으로 실현하는 방법이 주로 활용되고 있으며, 당사자소송을 통한 직접적 관철은 “판례”가 소극적 입장을 취하고 있어 인정되기 어렵다. 장기적으로는 의무이행소송 제도의 도입과 같은 입법적 보완이 필요하다. 현재로서는 간접강제나 손해배상청구를 통해 보완적 구제가 이루어지고 있다. 따라서 결과제거청구권은 제도적 한계에도 불구하고, 국민의 권리구제를 위한 중요한 법리적 기초로 기능하고 있음을 확인할 수 있다.

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50점)

(물음2) 위 취소소송의 관할법원은 `구직 중에 있는 자도 「노동조합 및 노동관계조정법」상 근로자의 지위를 가지고 노동조합에 가입할 수 있다.`는 이유로 乙시장의 설립신고서 반려를 취소하였고 그 판결은 확정되었다. 그러나 乙시장은 또다시 설립신고서를 반려하면서, 甲노동조합이 `주로 정치운동을 목적으로 하는 경우`(`노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 마목)에 해당함을 그 사유로 제시하였다. 이에 甲노동조합은 다시 취소소송을 제기하고자 하는바, 그 청구는 본안에서 인용될 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음2> 설립신고서 반려 취소 판결 후 새로운 사유를 근거로 한 재반려처분의 기속력 위반 여부 및 본안 인용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲노동조합은 설립신고서 반려처분에 대한 취소소송에서 승소하여 판결이 확정되었으나, 乙시장이 다시 주로 정치운동을 목적으로 한다는 새로운 사유를 들어 설립신고서를 반려하자 이에 대한 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <확정판결의 기속력에 의하여 행정청이 새로운 처분사유를 들어 다시 동일한 처분을 할 수 있는지와 그 처분의 위법 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙시장의 재차 설립신고서 반려처분에 대한 甲노동조합의 청구가 본안에서 인용될 수 있는지 답한다.

II. 기판력과 기속력의 일반 법리

1. 기판력의 의의 및 범위

(1) 개념

- 기판력이란 확정판결을 내린 법원과 당사자가 후행 소송에서 전소 판결과 모순·저촉되는 주장이나 판단을 할 수 없도록 구속하는 소송법상 효력을 말한다.

(2) 범위

- 취소소송의 소송물은 당해 처분의 위법성 존부이다. 전소와 후소의 소송물이 동일하거나 선결관계 또는 모순관계에 있어야 기판력이 작용하며, 처분의 내용상 하자로 취소판결이 확정된 경우 기판력의 객관적 범위는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 한도 내로 제한된다.

2. 기속력의 의의 및 범위

(1) 개념 및 재처분의무

- 「행정소송법 제30조 제1항」에 규정된 기속력은 취소판결이 확정되었을 때 피고 행정청과 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 구속하는 실체법상 효력이다. 특히 거부처분이 취소된 경우 행정청은 동조 제2항에 따라 이전 신청에 대하여 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 부담한다.

(2) 객관적 범위

- 기속력의 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다. 따라서 당초 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 위배되지 않는다.

3. 기본적 사실관계의 동일성 판단 기준

- 기본적 사실관계의 동일성 여부는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실관계에 착안하여 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해법익 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

III. 사안의 적용

1. 기판력 및 기속력의 위배 여부

(1) 당초 사유와 새로운 사유의 비교

- 전소의 반려사유는 구직 중인 자의 가입 허용(「노동법 제2조 제4호 라목」)이며, 후속 재반려처분의 사유는 주로 정치운동을 목적으로 하는 경우(「동조 동호 마목」)이다.

(2) 기본적 사실관계의 동일성 검토

- 라목의 사유는 조합원 자격 유무라는 인적 구성원에 관한 구체적 사실에 기초하는 반면, 마목의 사유는 노동조합의 목적 및 활동의 성격이라는 단체의 설립 지향점에 관한 구체적 사실에 기초한다. 이 두 사유는 구체적 사실관계의 기초가 완전히 다르고 행위 태양 및 침해법익이 상이하므로 기본적 사실관계의 동일성이 부정된다.

(3) 저촉 여부에 대한 판단

- 기본적 사실관계의 동일성이 부정되므로, 乙시장의 새로운 반려처분은 전소 판결의 기판력에 저촉되지 않으며 기속력(재처분의무)에 위배되지 않는 적법한 재처분의 형식을 갖추었다.

2. 후행 소송의 본안 인용 여부

(1) 입증책임의 분배

- 처분의 적법성 및 처분사유의 구체적 존재 여부에 대한 입증책임은 처분을 행한 피고 행정청(乙시장)에 있다.

(2) 구체적 판단 및 인용 가능성

① 乙시장이 사유를 입증하지 못하는 경우

- 만약 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 조직된 단체가 아니거나 乙시장이 이를 입증하지 못한다면, 해당 처분은 실체법상 처분사유의 부존재로 위법하다. 이 경우 법원은 반려처분을 취소하는 인용판결을 내려야 한다.

② 乙시장이 사유를 입증하는 경우

- 만약 실제로 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 설립되었다는 사실이 객관적으로 존재하고 乙시장이 이를 입증한다면, 새로운 반려처분은 실체법상 적법하므로 법원은 甲노동조합의 청구를 기각하여야 한다.

IV. 결론

- 乙시장이 새로운 사유를 들어 재차 반려처분을 한 것은 당초 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로 전소 판결의 기판력 및 기속력에 위배되지 않는다. 그러나, 후속 취소소송에서 당해 처분이 본안 인용될 수 있는지 여부는 실체법상 처분사유인 `주로 정치운동을 목적으로 하는지`에 대

한 실제 존재 여부 및 피고의 입증 여부에 달려 있다. 결론적으로, 피고 乙시장이 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 하는 단체라는 사실을 증명하지 못한다면 새로운 반력처분은 실체상 처분사유 부존재로 위법하므로 법원은 甲노동조합의 취소 청구를 인용하여야 한다.

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

[기출][2013-2]의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상), 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

《[문제2] 거부처분에 대한 의무이행재결 또는 취소판결이 확정되었음에도 불구하고 행정청이 그 재결 또는 판결의 취지에 따른 처분을 하지 아니 하는 경우, 당해 재결 또는 판결의 실효성 확보 방안에 관하여 서술하시오. (25점)》

<문제2> 의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상), 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

I. 문제 제기

- 행정청이 국민의 권리구제를 위한 의무이행재결이나 법원의 취소판결에 기속되어 있음에도 불구하고, 그 재결 또는 판결의 취지에 따른 처분을 하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 사태가 방지된다면 권리구제의 실효성이 상실되고, 행정의 법치주의 및 신뢰보호 원칙이 심각하게 침해된다. 따라서 현행 법제는 행정심판 단계와 행정소송 단계에서 각각의 강제 수단을 마련하여 실효성을 담보하고 있으며, 부수적으로 손해배상 청구나 형사책임 추궁 등도 고려할 수 있다. 이하에서는 의무이행재결 및 취소판결 불이행 상황별로 실효성 확보 방안을 검토하고, 공통적 보완수단에 대해 서술한다.

II. 의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상)

1. 직접처분 [행정심판법 제50조]

(1) 의의

- 의무이행재결이 확정되었음에도 행정청이 이를 이행하지 않을 경우, 행정심판위원회가 직접 해당 처분을 대신하여 행하는 제도이다.

(2) 요건

- ❶ 의무이행재결의 존재, ❷ 피청구인의 재결 불이행, ❸ 청구인의 신청, ❹ 행정심판위원회의 시정명령에도 불구하고 불이행, ❺ 직접처분이 가능한 성질의 처분일 것(사실행위나 고도의 전문적 재량행위 등은 제한됨).

(3) 효과

- 행정심판위원회의 직접처분은 원처분청의 처분과 동일한 효력을 가지며, 국민의 권리를 실질적으로 구제할 수 있다.

2. 간접강제 [행정심판법 제50조의2]

(1) 의의

- 행정청이 재결을 이행하지 않을 경우, 금전적 제재를 통하여 간접적으로 재결의 실효성을 확보하는 제도이다.

(2) 요건

- ❶ 재처분의무의 존재, ❷ 피청구인의 불이행, ❸ 청구인의 신청, ❹ 상당한 기간 경과.

(3) 효과

- 행정심판위원회는 피청구인에게 일정 기간 내에 재처분을 하도록 명령하고, 불이행 시 일정 금액을 배상하도록 명할 수 있다. 이를 통해 행정청의 재결 불이행을 억제하는 기능을 한다.

III. 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

1. 간접강제 [행정소송법 제34조]

(1) 의의

- 행정청이 취소판결이나 부작위위법확인판결 확정에도 불구하고 재처분을 하지 않을 때, 금전적 제재로 이행을 강제하는 제도이다.

(2) 요건

- ❶ 거부처분 취소판결 또는 부작위위법확인판결의 확정, ❷ 처분청의 재처분 불이행, ❸ 청구인의 신청, ❹ 상당한 기간 경과.

(3) 효과

- 법원은 행정청에 대하여 판결의 취지에 따른 처분을 할 때까지 일정 금액의 배상을 명할 수 있다. 이는 간접적 압박을 통해 판결의 실효성을 보장한다.

2. 재심청구 [행정소송법 제31조 준용]

(1) 의의

- 행정청이 판결에 불복하거나 새로운 사정이 발생했을 때 재심을 청구할 수 있는 제도이다.

(2) 한계

- 재심은 판결 확정 후의 절차적 구제수단일 뿐, 판결 불이행 자체를 강제하는 수단은 아니므로 실효성 확보 방안으로는 제한적 기능만을 가진다.

IV. 공통적인 실효성 확보 방안

1. 손해배상청구 소송

- 재결이나 판결 불이행으로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 국가배상법에 근거하여 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 권리구제의 직접성 측면에서는 한계가 있다.

2. 관련 형사처벌 규정 검토

- 행정청 공무원이 판결이나 재결을 의도적으로 불이행한 경우, 직무유기죄가 문제될 수 있다. 그러나 이는 고의성 및 위법성 입증에 어려워 실효적 수단으로 활용되기는 제한적이다.

3. 직무유기죄 고발 (제한적 적용)

- “판례”는 행정청의 불이행을 직무유기로 보는데 소극적이나, 중대한 권리침해가 발생한 경우 예외적으로 적용 가능성이 논의될 수 있다.

V. 결론

- 행정심판 단계에서는 직접처분과 간접강제 제도를 통해 재결 불이행에 대응할 수 있으며, 이는 국민의 권리구제 실효성을 강화한다. 행정소송 단계에서는 간접강제 제도가 중심적 역할을 하며, 나아가 손해배상청구나 직무유기 고발 등을 보조적 수단으로 활용할 수 있다. 실효성 확보 제도의 발전은 권리구제의 실질화를 위한 필수적 장치로, 행정청의 불이행을 제재하고 법치행정을 실현하는 데 중요한 의미를 가진다.

<보충 - 거부처분에 대한 의무이행재결 또는 취소판결 확정 후 불이행 시 실효성 확보 방안>

I. 문제의 제기

- 행정심판의 인용재결이나 행정소송의 인용판결이 확정되면 "행정소송법 제30조" 및 "행정심판법 제49조"에 따라 피청구인(피고)인 행정청을 구속하는 기속력이 발생한다. 특히 거부처분에 대한 의무이행재결이나 거부처분취소판결이 확정되면 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 하는 실체법상 재처분의무를 부담하게 된다. 그러나 행정청이 이러한 재처분의무를 이행하지 않고 방치하는 경우, 확정된 재결 및 판결은 유명무실해지므로 이를 강제하기 위한 실효성 확보 수단이 강구되어야 한다. 이하에서는 거부처분에 대한 의무이행재결 및 거부처분취소판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분의무를 불이행할 때, 행정심판법과 행정소송법상 인정되는 구체적인 실효성 확보 수단을 비교하여 서술한다.

II. 행정심판법상 실효성 확보 방안

1. 행정심판위원회의 직접처분 [행정심판법 제50조]

(1) 의의 및 성격

- 피청구인이 인용재결에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 청구인의 신청에 따라 행정심판위원회가 직접 처분을 할 수 있는 제도이다. 이는 행정심판이 행정권 내부의 자가통제 절차이기에 인정되는 행정심판법 고유의 강력한 실효성 확보 수단이다.

(2) 요건 및 적용 범위

- 행정심판위원회는 당사자의 신청이 있으면 기한을 정하여 서면으로 시정을 명하고, 그 기간 내에 이행하지 아니하면 직접 처분을 할 수 있다. 단, 직접처분은 의무이행재결("행정심판법 제49조 제2항")의 불이행에 한하여 적용되며, 거부처분취소재결의 불이행 시에는 준용 규정이 없어 적용되지 않는다.

2. 행정심판위원회의 간접강제 [행정심판법 제50조의2]

(1) 의의 및 성격

- 피청구인이 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 행정심판위원회가 결정으로 상당한 기간을 정하고 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나 즉시 배상할 것을 명함으로써 의무 이행을 간접적으로 강제하는 수단이다.

(2) 적용 범위의 특수성

- 간접강제는 의무이행재결의 불이행뿐만 아니라, "행정심판법 제50조의2 제1항"의 명문 규정에 따라 거부처분 취소재결 및 변경재결("행정심판법 제49조 제4항"에서 "제2항"을 준용하는 경우)의 불이행 시에도 전면적으로 허용된다.

III. 행정소송법상 실효성 확보 방안

1. 법원의 간접강제 [행정소송법 제34조]

(1) 의의 및 성격

- 행정청이 거부처분취소판결에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 법원이 제1심 수소법원의 결정으로 상당한 기간을 정하고 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하는 제도이다. 민사집행법상 채무불이행에 대한 간접강제와 유사한 성질을 지닌다.

(2) 요건 및 결정 시기

- ❶ 거부처분 취소소송의 인용판결이 확정되었을 것, ❷ 행정청이 판결의 취지에 따른 재처분을 하지 아니하였을 것, ❸ 청구인의 신청이 있을 것을 요한다. 간접강제 결정은 취소판결과 동시에 내릴 수도 있고, 판결 확정 후 별도의 신청에 의하여 내릴 수도 있다.

2. 직접처분의 허용 여부

(1) 소송법상 한계

- 현행 행정소송법상으로는 행정청의 재처분의무 불이행 시 사법부가 직접 처분을 발령할 수 있는 직접처분권 규정이 존재하지 않는다.

(2) 권력분립 원칙과의 관계

- 사법부인 법원이 처분청을 대신하여 직접 행정처분을 발령하는 것은 헌법상의 권력분립 원칙에 반하며 행정권의 제1차적 판단권을 본질적으로 침해할 우려가 있으므로, 소송법상 직접처분은 인정될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 행정심판 재결의 불이행 시 적용

(1) 의무이행재결의 불이행인 경우

- 甲의 신청에 대한 거부처분에 대하여 행정심판위원회가 의무이행재결을 내렸음에도 행정청이 불이행한다면, 甲은 "행정심판법 제50조"에 따른 행정심판위원회의 직접처분을 신청하거나 "동법 제50조의2"에 따른 간접강제를 선택적으로 신청하여 실효성을 확보할 수 있다.

(2) 거부처분 취소재결의 불이행인 경우

- 인용재결의 형태가 거부처분 취소재결인 경우라면 직접처분은 청구할 수 없으나, "행정심판법 제50조의2"에 따른 간접강제 신청을 통해 행정청의 접수 공개 등 처분 이행을 강제할 수 있다.

2. 행정소송 판결의 불이행 시 적용

(1) 간접강제 신청을 통한 구제

- 甲이 거부처분 취소소송에서 확정판결을 얻었음에도 행정청이 처분을 하지 않는 경우, 甲은 "행정소송법 제34조"에 따라 제1심 법원에 간접강제를 신청하여 지연배상 결정을 유도할 수 있다.

(2) 직접처분 청구의 불가능성

- 甲은 사법부에 대하여 행정청을 대신하여 직접 수익적 처분을 내려달라는 청구를 할 수 없으며, 오직 배상금 부과라는 간접적 압박 수단만을 활용할 수 있을 뿐이다.

V. 결론

- 거부처분에 대한 인용재결 및 인용판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분의무를 불이행하는 경우, 행정심판법과 행정소송법은 사법통제의 성격에 따라 실효성 확보 방안을 달리 규정하고 있다. 행정심판 단계에서는 행정 내부적 통제 수단으로서의 성격을 살려 의무이행재결에 대해 직접처분("제50조")과 간접강제("제50조의2")라는 강력한 이원적 구제수단을 제공한다. 반면, 행정소송 단계에서는 헌법상 권력분립의 원칙을 존중하여 법원의 직접처분을 전면 부정하는 대신, 배상금 제재를 통한 간접강제("제34조")만을 일원적으로 인정함으로써 사법권의 소극적 한계 속에서 권리구제의 실효성을 조화롭게 도모하고 있다.

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2018-1-2]기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

《【문제1】 甲은 A국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009년 4월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010년 4월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015년 12월 귀화하였으나, 2016년 10월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017년 7월 乙과 혼인신고를 하고, 2017년 8월 관할행정청인 X에게 대한민국 국민의 배우자(F-6-1)자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7년여의 '불법체류'를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 '지침 등'이라 함)상 허가요건 중 하나인 '국내합법체류자'요건을 결여하게 되어 X는 2017년 8월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50점)

(물음2) 위 반려처분에 대하여 甲이 취소소송을 제기하여 승소판결이 확정되었다. 그러나 X는 위 '지침 등'에 따른 체류자격 변경허가를 위한 또 다른 요건 중의 하나인 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'을 충족하지 못한다는 것을 이유로 다시 체류자격 변경허가를 거부하고자 한다. 이 거부처분이 적법한지에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 기속력의 객관적 범위와 다른 사유를 근거로 한 재거부처분의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 체류자격 변경허가 거부처분에 대한 취소소송에서 승소판결을 받아 확정되었으나, X가 동일한 신청에 대하여 새로운 거부사유를 들어 다시 거부처분을 하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 취소판결의 기속력과 재처분의무가 새로운 처분사유를 근거로 한 재거부처분을 제한하는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 확정된 취소판결의 효력이 미치는 범위와 그에 따른 재거부처분의 적법성에 대해 논한다.

II. 확정판결의 기속력

1. 의의

- 취소소송의 승소판결이 확정되면 그 판결의 내용이 관계 행정청에 대하여 가지는 법적 구속력을 기속력이라고 한다. 이는 행정소송의 실효성을 확보하고, 판결의 권위를 보장하기 위해 행정소송법이 인정한 특별한 효력이다. 기속력은 판결의 내용에 따라 행정청이 재량의 여지없이 일정한 조치를 취하도록 의무를 부과하는 공법상 효력이다.

2. 관련 법규정 및 내용

- "행정소송법 제30조 제1항"은 처분 등을 취소하는 판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다고 규정하고 있다. 이러한 기속력은 행정청에 다음과 같은 세 가지 의무를 부과한다.

(1) 반복금지 의무

- 반복금지 의무는 판결에서 위법하다고 판단된 처분의 동일한 사유를 들어 동일한 처분을 반복할 수 없다는 소극적 의무를 의미한다. 이는 동일한 위법이 재발하는 것을 방지함으로써 행정의 적법성을 확보하고자 하는 취지이다. "판례"는 처분 당시와 동일한 사실관계와 동일한 법적 판단 하에서 동일한 행정청이 동일한 내용의 처분을 할 수 없다는 원칙을 확립하고 있다.

(2) 재처분 의무

- 재처분 의무는 판결의 취지에 따라 다시 처분하여야 할 적극적 의무를 의미한다. 특히 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우, 행정청은 판결의 취지에 따라 신청에 대한 처분을 다시 하여야 한다. 이 경우, 행정청은 판결에서 위법하다고 판단된 사유 외의 다른 사유로 다시 거부할 수 있는지 여부를 재검토해야 하며, 원칙적으로는 신청을 인용하는 방향으로 처분할 의무가 발생한다. 이는 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위한 핵심적인 의무이다.

(3) 결과제거 의무

- 결과제거 의무는 위법한 처분으로 인해 발생한 위법상태를 제거하거나, 그로 인해 발생한 부당한 결과를 시정할 의무이다. 예를 들어 위법한 영업정지 처분이 취소된 경우, 영업정지 기간을 단축하거나 정지기간 중의 손해에 대한 보상을 검토하는 등의 조치가 포함될 수 있다.

3. 기속력의 범위

- 기속력은 그 효력이 미치는 범위에 따라 인적, 시적, 주관적 범위로 나뉜다.

(1) 인적 범위

- 기속력은 당해 사건의 피고인 행정청 및 그 밖의 관계 행정청에 미친다.

(2) 시적 범위

- 기속력은 판결이 확정된 이후에 이루어진 행정청의 행위에 미친다. 따라서 판결 확정 이전의 행위에는 기속력이 미치지 않는다.

(3) 주관적 범위

- 기속력은 판결의 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에 미친다. 이는 판결에서 위법하다고 판단된 처분 사유에만 기속력이 발생함을 의미하며, 판결에서 다루어지지 않은 새로운 사유에는 기속력이 미치지 않는다는 것을 뜻한다. 이 원칙은 행정청이 판결에 의해 판단받지 않은 다른 적법한 사유를 근거로 다시 처분을 할 수 있는 가능성을 열어준다. 이는 행정청의 적법한 재량권 행사를 보장하고, 법원의 판단 범위를 넘어서지 않기 위함이다.

III. 사안의 적용

1. 취소판결의 기속력 발생 및 내용 검토

- 甲의 승소판결이 확정되었으므로, "행정소송법 제30조"에 따른 기속력이 발생하였다. 이에 따라 X는 판결의 취지에 따라 다시 처분하여야 하는 재처분 의무를 부담한다. 이 재처분 의무는 X가 甲의 신청을 다시 심사하여 그 결과에 따라 적법한 처분을 내릴 것을 요구한다.

2. 새로운 거부처분 사유의 적법성 검토

- X가 甲의 신청에 대해 다시 거부하고자 하는 사유는 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'이라는 또 다른 허가요건을 충족하지 못한다는 것이다. 이 새로운 거부 사유는 甲이 승소한 취소소송의 대상이 된 '국내합법체류자 요건 결여 사유'와는 전혀 다른 별개의 사유이다. 취소판결의 기속력은 오직 판결에서 위법하다고 판단된 '국내합법체류자 요건 결여 사유'에 대해서만 미친다. 따라서 X는 동일한 사유(불법체류)를 들어 甲의 신청을 다시 거부할 수 없다(반복금지 의무). 그러나 새로운 사유는 이전 소송에서 법원의 판단을 받지 않았으므로, 취소판결의 기속력은 새로운 거부처분에 미치지 않는다. 따라서 X는 판결의 취지에 따라 甲의 신청에 대해 다시 심사하여 이 새로운 요건을 이유로 체류자격 변경허가를 거부할 수 있다. 이는 행정청이 신청에 대해 재심사하면서, 판결의 기속력이 미치지 않는 다른 적법한 거부 사유를 근거로 다시 거부하는 것이므로 적법하다. 만약 X가 기존 사유와 동일한 사유로 다시 거부하였다면 이는 기속력에 반하여 위법하게 되었을 것이다.

IV. 결론

- 위에서 검토한 바와 같이, 甲이 받은 취소판결의 기속력은 이전 거부처분의 위법 사유인 불법체류에 한정된다. 따라서 관할 행정청 X가 판결의 취지에 따라 다시 심사하면서 이전의 거부 사유와는 다른 '배우자가 국적을 취득한 후 3년 이상일 것'이라는 적법한 요건을 들어 체류자격 변경을 거부하는 것은 취소판결의 기속력에 위반되지 않으므로 적법하다.

<보충(부적법 의견) - 기속력에 반하진 않지만, 재량권 일탈·남용 법리 적용 후 위법 결론>

I. 문제의 제기

- 사안에서 X가 甲의 체류자격 변경허가 신청에 대하여 당초 거부사유와 다른 새로운 사유를 들어 다시 거부한 조치가 적법한지 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <선행 취소소송 확정판결의 기속력이 후행 재거부처분에 미치는지와 관련하여 당초 사유와 새로운 사유 간 기본적인 사실관계의 동일성이 인정되는지>, <새로운 처분사유인 지침상의 요건 미달을 근거로 한 처분이 재량권의 한계를 준수한 적법한 처분인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송의 기속력의 객관적 범위와 기본적인 사실관계의 동일성 법리를 검토하고, 체류자격 변경허가의 재량행위성 및 재량권 한계 일탈 여부를 판단하여 당해 거부처분의 적법성을 논하고자 한다.

II. 기속력과 재량권의 한계에 관한 법리

1. 취소판결의 기속력과 재거부처분의 한계

(1) 기속력의 의의 및 객관적 범위

- "행정소송법 제30조 제1항"에 규정된 기속력은 취소소송의 인용판결이 확정된 경우 피고 행정청과 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 구속하는 효력을 말한다. 거부처분 취소판결이 확정되면 행정청은 "제30조 제2항"에 따라 판결의 취지에 맞게 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 진다. 기속력의 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다.

(2) 기본적인 사실관계의 동일성 판단 기준

- 행정청이 거부처분 취소판결 확정 후 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 당초 사유와 기본적인 사실관계의 동일성이 없는 한 기속력에 위배되지 않는다. 기본적인 사실관계의 동일성 여부는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실관계에 착안하여 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해법익 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

2. 지침의 성격 및 재량권의 일탈·남용

(1) 지침의 법적 성질

- 출입국관리법령상 외국인의 체류자격 변경허가는 설권적 처분으로서 행정청의 광범위한 재량에 속한다. 행정청의 내부 심사기준인 지침 등은 대외적 구속력이 없는 행정규칙에 불과하므로, 법원은 이에 구속되지 않고 독자적으로 처분의 위법 여부를 심사한다.

(2) 재량권 일탈·남용의 한계와 이익형량

- 재량처분이라 하더라도 헌법상 비례의 원칙 등 법의 일반원칙을 준수해야 하며, 공익과 사익 간의 정당한 이익형량이 결여되거나 객관성을 결여한 경우 재량권의 일탈·남용으로서 위법하다.("행정소송법 제27조") 특히, "헌법 제36조 제1항"의 혼인과 가족생활의 보장 가치는 이익형량 시 중대하게 고려되어야 한다.

III. 사안의 적용

1. 절차적 측면에서의 기속력 위배 여부

- 당초 반려(거부)처분의 사유인 '7년의 불법체류'와 새로운 거부사유인 '배우자의 국적 취득 후 3년 미경과'는 처분의 기초가 되는 구체적 사실에 있어 아무런 연관성이 없어 기본적인 사실관계의 동일성이 부정된다. 따라서 X가 취소판결 확정 후 새로운 사유를 들어 다시 거부처분을 한 것은 이전 판결의 기속력에 위배되지 않는다.

2. 실체적 측면에서의 재량권 일탈·남용 여부

- X가 근거로 삼은 지침 등은 행정규칙에 불과하므로 해당 요건을 기계적으로 적용해서는 안 된다. 사안에서 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였으므로, 거부처분으로 인해 甲이 출국하게 될 경우 가정이 파탄에 이르고 아동의 복리가 심각하게 저해되는 사익의 침해가 발생한다. 반면 귀화 후 3년이라는 기준은 행정 편의적 기준에 불과하여 거부처분으로 달성하려는 공익보다 가정을 보호해야 할 사익이 훨씬 크다. 따라서 X의 거부처분은 이익형량의 정당성을 결여하여 재량권을 일탈·남용한 위법한 처분이다.

IV. 결론

- X가 새로운 처분사유를 들어 다시 거부처분을 한 것은 당초 사유와 기본적인 사실관계의 동일성이 없어 취소판결의 기속력에는 반하지 않는다. 그러나 해당 거부처분은 대외적 구속력이 없는 행정규칙을 기계적으로 적용하여 인도적 사정 및 가족 결합의 가치를 무시한 것으로서, 이익형량의 한계를 초과하여 재량권을 일탈·남용한 위법이 존재한다. 결론적으로 X의 재거부처분은 실체법상 위법하므로 법원은 이를 취소하여야 한다.

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2019-1-1]절차상 하자로 취소된 재심판정에 대한 확정판결 기속력의 내용과 중앙노동위원회의 법적 의무

《【문제1】 사용자인乙주식회사는 소속 근로자인甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한乙주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 감봉 3월의 징계처분을 하였다. 甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다. 甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에 甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다. 甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50점)

(물음1) 중앙노동위원회의 재심판정에 절차상 하자가 있음을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다. 중앙노동위원회가 이러한 확정판결에 기속되는 경우에 어떠한 의무를 부담하는지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 절차상 하자로 취소된 재심판정에 대한 확정판결 기속력의 내용과 중앙노동위원회의 법적 의무

I. 문제의 제기

- 사안에서 중앙노동위원회의 재심판정이 절차상 하자가 있음을 이유로 취소된 후 확정판결의 기속력에 따라 중앙노동위원회가 다시 재심판정을 하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 취소판결의 기속력에 의하여 행정청이 부담하는 재처분의무 및 그 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소판결 확정 후 중앙노동위원회가 부담하는 구체적인 법적 의무에 대해 논한다.

II. 기속력의 일반 법리

1. 기속력의 의의와 성질

(1) 기속력의 개념

- "행정소송법 제30조 제1항"에 규정된 기속력은 취소소송의 인용판결이 확정된 경우 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 법적으로 구속하는 효력을 말한다.

(2) 기속력의 성질 및 범위

- 기속력은 기판력과 구분되는 행정소송 특유의 실체법상 효력이다. 기속력의 주체적 범위는 당해 행정청과 관계 행정청에 미치며, 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다.

2. 기속력의 구체적 내용

(1) 반복금지의무

- 행정청은 판결에서 위법하다고 판단된 사유와 동일한 사실관계 아래에서 동일한 내용의 처분을 반복해서는 안 되는 소극적 의무를 진다.

(2) 재처분의무

- 당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 판결이 확정된 경우("제30조 제2항") 또는 처분의 절차나 형식이 위법하여 취소된 경우("제30조 제3항") 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 적극적 의무를 부담한다.

(3) 원상회복의무

- 명문의 규정은 없으나 기속력의 실효성 확보를 위하여 위법한 처분으로 발생한 가공의 행정상태를 제거하고 처분 전의 상태로 되돌려야 할 의무를 부담한다.

III. 사안의 적용

1. 중앙노동위원회의 재처분의무

(1) 재처분의무의 법적 근거

- 사안의 재심판정 기각 결정은 근로자의 재심신청이라는 신청을 거부하는 성격을 가지므로 "행정소송법 제30조 제2항"이 적용되고, 정족수 미달이라는 절차상 하자를 이유로 취소되었으므로 "동법 제30조 제3항"의 재처분의무가 모두 중첩적으로 적용된다.

(2) 개의 및 의결정족수의 보완

- 중앙노동위원회는 취소판결이 확정된 이상 무조치 상태로 있어서는 안 되며, 판결에서 지적된 정족수 미달의 절차상 위법을 보완하여 甲의 재심신청에 대해 다시 심리하고 의결을 거쳐 재처분을 내려야 한다.

2. 반복금지의무의 범위와 강제수단

(1) 동일 내용의 재심판정 허용 여부

- 기속력의 객관적 범위는 절차상 하자에 국한되므로, 중앙노동위원회가 적법한 정족수를 갖추어 실체적 사유(유인물 배포 등)를 재심리한 결과 동일하게 재심신청을 기각하더라도 이는 판결의 취지에 부합하며 반복금지의무에 저촉되지 않는다.

(2) 재처분의무 불이행 시 구제수단

- 만약 중앙노동위원회가 확정판결에도 불구하고 지체 없이 새로운 재처분을 하지 않는 경우, 甲은 "행정소송법 제34조 제1항"에 따라 법원에 간접강제를 신청하여 지연 기간에 따른 상당한 배상을 명하게 함으로써 재처분의 이행을 강제할 수 있다.

IV. 결론

- 중앙노동위원회는 확정판결의 기속력에 따라 개의 및 의결 정족수 미달이라는 절차상 하자를 완전히 보완하여 甲의 재심신청에 대해 다시 심리·의결해야 하는 재처분의무를 부담한다. 다만, 판결이 절차 위법만을 이유로 한 것이므로 적법한 정족수를 갖춘 상태에서 다시 기각 판결을 내리는 것은 허용된다. 만약 중앙노동위원회가 정당한 이유 없이 재처분의무를 이행하지 않는다면 甲은 법원에 간접강제를 신청하여 강제력을 확보할 수 있다.

《【문제1】 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50점)

<사례1>

근로자 甲은 A지방고용노동청장(이하 'A청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하였다. A청장은 '甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 <처분사유1>)'는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유1> 이외에 '甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 <처분사유2>)'라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유2>는 기존 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례2>

근로자 乙은 B지방고용노동청장(이하 'B청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음1) 甲의 취소소송에서 인용판결이 확정된 후 A청장은 <처분사유2>는 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사유임에 착안하여 이전의 甲의 지원금 신청에 대하여 <처분사유2>를 들어 다시 거부처분을 하였고, 이에 대하여 甲은 간접강제를 신청하였다. 甲의 간접강제 신청에 대한 법원의 인용 여부에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 최초 거부처분에서 추가한 사유를 다시 제기한 재거부처분에 대한 간접강제 신청의 인용 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 甲이 제기한 거부처분 취소소송에서 법원은 원고 동의 하에 당초 사유와 기본적 사실관계가 다른 <처분사유2>의 추가를 허용하여 종합 심리한 결과 청구를 인용하는 판결을 확정하였다. 이후 A청장이 판결에서 판단을 거친 <처분사유2>를 들어 다시 거부처분을 하자 甲이 이에 대하여 간접강제를 신청한 상황이다. 쟁점으로 <A청장의 재거부처분이 확정판결의 기속력에 반하여 무효인지 여부와 이에 따른 법원의 간접강제 신청 인용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분 취소판결 기속력의 객관적 범위와 소송 중 추가된 사유의 기속력의 범위, 간접강제의 요건을 고찰하고 이를 사안에 대입하여 법원의 인용 여부에 대해 논한다.

II. 취소판결의 기속력과 간접강제에 관한 법리

1. 취소판결의 기속력과 재처분의무의 범위

(1) 기속력의 의의 및 객관적 범위

- "행정소송법 제30조 제1항"에 따른 기속력은 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 효력이다. 기속력은 판결 주문 및 판결 이유에서 밝혀진 구체적인 위법사유에 대하여 미친다.

(2) 재처분의무와 새로운 거부사유의 허용성

- "동법 제30조 제2항"에 따라 거부처분이 취소된 경우 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다. 행정청이 판결에서 위법하다고 판단된 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 반하지 않는 적법한 재처분으로 인정된다.

2. 처분사유 추가·변경의 기속력에 대한 영향

(1) 처분사유 추가에 따른 심판 대상의 확장

- 소송 계속 중 행정청이 처분사유를 추가하고 법원이 이를 실질적으로 심리한 경우, 추가된 사유 역시 판결의 심판 대상이 된다. 비록 당초 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 사유라 하더라도 예외적으로 소송에서 적법하게 추가되어 실질적 판단을 거쳤다면 취소판결의 효력 범위에 포함된다.

(2) 판결에서 배척된 사유에 의한 재거부의 금지

- 취소소송에서 이미 주장되었다가 배척되었거나 심리 대상이 되어 위법함이 확정된 사유는 취소판결 기속력의 객관적 범위에 포섭된다. 따라서 소송에서 이미 판단을 거친 사유를 들어 다시 동일한 신청을 거부하는 것은 기속력의 반복금지의무에 정면으로 위배된다.

3. 간접강제의 요건과 재처분의무 불이행

(1) 간접강제의 의의 및 요건

- "행정소송법 제34조 제1항"은 행정청이 "제30조 제2항"에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 법원이 신청에 의하여 일정한 배상을 명할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 무효인 재처분과 간접강제 대상성

- 행정청이 재처분을 하였더라도 그것이 기속력에 위반되어 무효인 처분에 불과하다면, 이는 실질적으로 재처분의무를 이행하지 않은 것과 다를 없다. "판례" 역시 기속력에 위반되는 거부처분을 한 경우는 재처분의무를 이행하지 않은 것에 해당하므로 간접강제 신청의 대상이 된다고 판시하고 있다.

III. 사안의 적용

1. A청장의 재거부처분의 기속력 위배 여부

- 사안에서 관할 법원은 원고 甲의 동의를 얻어 기본적 사실관계가 다른 <처분사유2>의 추가를 허용하였고, 두 사유를 종합 심리하여 甲의 청구를 인용하는 판결이 확정되었다. 비록 <처분사유2>가 당초 사유와 다른 별개의 사유라 하더라도 소송 계속 중 추가되어 법원의 실질적 판단을 받았으므로, 확정판결의 기속력은 <처분사유2>의 위법성 판단에도 미친다. 따라서 A청장이 확정판결 후 다시 동일한 신청에 대하여 소송에서 이미 심리되어 위법한 것으로 확정된 <처분사유2>를 들어 거부처분을 한 것은 기속력에 위배되어 당연무효이다.

2. 甲의 간접강제 신청 인용 여부

- A청장의 재거부처분은 기속력에 위반되어 무효인 처분에 해당하므로, "행정소송법 제30조 제2항"에 따른 적법한 재처분의무를 이행하지 아니한 것과 같다. 따라서 甲이 제기한 간접강제 신청은 행정청의 재처분의무 불이행이라는 대상 요건을 적법하게 충족하였다.

IV 결론

- A청장이 취소판결 후 다시 동일한 신청에 대해 내린 거부처분은 소송 과정에서 이미 심리되어 판결 기속력의 객관적 범위에 포함된 <처분사유2>를 근거로 한 것으로서 당연무효에 해당한다. 무효인 재처분은 재처분의무의 불이행과 같으므로 법원은 甲의 간접강제 신청을 인용하여야 한다. 법원은 A청장에게 상당한 기간을 정하여 판결의 취지에 따른 적법한 재처분을 할 것을 명하고, 이를 이행하지 아니할 때에는 지연기간에 따른 일정한 배상을 할 것을 명하는 결정을 내려야 한다.

<제06장 취소소송의 종료.제03절 재심>

[기출][2016-2]할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

《[문제2] 甲회사는 대형할인점 건물을 신축하기 위한 건축허가 신청을 하였다가 행정청으로부터 거부처분을 받아 그 거부처분의 취소를 구하는 소송을 제기하여 승소하고 그 판결이 확정되었다. 그 이후 甲회사의 대형할인점 건물부지 인근에서 고등학교를 운영하는 학교법인 乙이 위 판결에 대하여 재심을 청구하였다. 이 청구는 적법한가? (25점)》

<문제2> 할인점 건축허가 거부처분 취소소송의 인용확정판결에 대한 인근 학교법인의 제3자 재심청구의 적법성 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲회사는 건축허가 거부처분 취소소송에서 승소판결을 받아 확정되었으나, 인근 학교를 운영하는 乙이 해당 확정판결에 대하여 재심을 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 재심청구의 당사자자격 및 재심의 요건을 충족하여 제3자인 乙이 확정판결에 대한 재심을 청구할 수 있는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 제3자의 확정판결에 대한 재심청구의 적법성에 대해 설명한다.

II. 제3자 재심청구의 의의와 요건

1. 제3자 재심청구의 의의

(1) 취소판결의 제3자효

- 취소소송에서 인용판결이 확정되면 그 처분은 소급적으로 효력을 상실한다. 따라서 행정행위의 상대방 외에도 제3자의 이해관계에 직접적 영향을 미칠 수 있다. 예컨대 건축허가 관련 취소판결은 주변 주민이나 학교 등 이해관계인에게 불이익을 줄 수 있다.

(2) 제3자 보호의 필요성

- 당사자가 아닌 제3자는 원칙적으로 소송에 참여하지 않으므로, 불리한 확정판결에 대해 항소나 상고로 다툴 수 없다. 그럼에도 해당 판결이 제3자의 권익을 침해할 수 있으므로 제3자에게 특별한 권리구제수단을 인정할 필요가 있다.

(3) 재심청구의 제도적 취지

- "행정소송법 제31조 제3항"은 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못하여 자기의 권리나 이익을 침해받은 경우 재심을 청구할 수 있도록 한다. 이는 당사자주의 절차 속에서 제3자의 권리보호를 보완하기 위한 장치이다.

2. 제3자 재심청구의 요건

(1) 대상 판결

- 재심은 취소소송의 확정판결을 대상으로 할 수 있다. 본 사안의 건축허가거부처분취소 확정판결은 이에 해당한다.

(2) 재심 청구인 (제3자)

- 재심청구인은 당해 소송의 당사자가 아닌 자로서, 확정판결로 권리나 법률상 이익에 직접적 침해를 받는 자이어야 한다. 단순한 사실적·경제적 불이익은 부족하다.

(3) 재심 사유

- 제3자가 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못한 경우여야 한다. 책임 없는 사유란 통상의 주의의무를 다하여도 소송 진행 사실을 알 수 없었던 경우 등을 의미한다.

(4) 제소기간

- 제3자는 판결의 존재를 안 날로부터 30일, 판결이 확정된 날로부터 1년 이내에 재심을 청구해야 한다. ("행정소송법 제31조 제4항")

III. 사안의 적용

1. 학교법인 乙의 주장

- 乙은 인근에서 고등학교를 운영하는 주체로서 대형할인점 건물 신축으로 인한 교육환경 침해를 주장할 수 있다. 따라서 甲의 건축허가 여부는 乙의 권리·이익과 밀접한 관련성이 있다.

2. 책임 없는 사유 판단

(1) 근접성

- 乙은 건축허가 대상 토지 인근에서 학교를 운영하고 있으므로, 관련 행정처분과 판결의 영향을 직접적으로 받을 수 있는 지위에 있다.

(2) 정보 접근 가능성

- 그러나 건축허가 거부처분과 그에 대한 소송은 공적 절차를 통해 진행되므로, 인근 학교법인이 이를 알 수 없었다고 단정하기 어렵다. 통상적인 주의를 기울였다면 소송의 진행 여부를 파악할 가능성이 인정된다.

(3) 판례 경향

- "대법원"은 제3자가 재심을 청구하려면 해당 소송에 참가하지 못한 것이 책임 없는 사유여야 함을 엄격하게 해석하고 있다. 즉, 단순히 소송 사실을 알지 못하였다는 사정만으로는 부족하다.

3. 제소기간

- 乙이 판결 확정 후 일정 기간이 경과하여 재심을 청구하는 경우, 행정소송법상 제소기간 요건을 충족하는지가 추가적으로 검토되어야 한다.

4. 검토

- 종합하면, 학교법인 乙이 건축허가취소소송 확정판결에 대한 재심청구를 하기 위해서는 판결로 인하여 법률상 이익이 침해되었음과 더불어 소송에 참가하지 못한 것이 책임 없는 사유 때문임을 입증해야 한다. 그러나 본 사안에서는 통상적인 주의로도 소송 진행을 알 수 있었을 가능성이 크므로, 책임 없는 사유 요건을 충족하기 어렵다. 따라서 乙의 재심청구는 부적법할 가능성이 높다.

IV. 결론

- 학교법인 乙이 제기한 재심청구는 행정소송법상 제3자 재심청구의 요건 중 책임 없는 사유에 해당하지 않아 적법하지 않다. 따라서 법원은 이를 각하할 것으로 보인다.

<제06장 취소소송의 종료.제04절 취소소송의 종료 사유>

[기출][2013-3]중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료 유형

《[문제3] 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료 유형

I. 문제 제기

- 행정소송법상 취소소송은 일반적으로 중국판결에 의해 종료되나, 현실적으로 당사자의 행위, 법원의 재판 또는 기타 사유에 의하여 중국판결을 거치지 않고 종료될 수 있는 경우가 존재한다. 이러한 경우 소송의 종료 시점과 효력, 판결의 기속력 여부 등이 문제가 되며, 특히 행정쟁송법적 특수성을 가진 취소소송에서는 소송종료의 법적 요건과 효과를 명확히 이해할 필요가 있다. 이하에서는 당사자의 행위, 법원의 재판, 기타 사유에 의한 종료 유형을 구체적으로 검토하여 설명한다.

II. 당사자의 행위에 의한 종료

1. 소의 취하

(1) 의의

- 원고가 소송을 계속할 필요성을 스스로 포기함으로써 소송절차를 종료시키는 의사표시이다.

(2) 요건

- ① 판결 확정 전에 이루어져야 한다는 시기 요건, ② 피고의 동의 필요(행정청 또는 당사자), ③ 법정 또는 서면에 의한 취하의 방식 준수.

(3) 효과

- 취하가 유효하면 소송은 중국판결 없이 종료되고, 원고는 동일한 소송을 다시 제기할 수 있으나, 이미 제출한 증거는 보존되지 않을 수 있다.

2. 청구의 포기 및 인낙 (제한적 인정)

(1) 의의

① 청구의 포기

- 원고가 청구권 자체를 포기하는 행위를 의미한다.

② 청구의 인낙

- 피고가 원고의 청구를 수용하는 행위를 의미한다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 취소소송은 공법적 권리구제를 위한 절차적 특수성이 있어, 청구권 자체를 포기하거나 피고의 인낙이 이루어지더라도 법원의 확정적 판단 없이 종료되는 경우는 제한적이며, 실무상 대부분 재결·판결이 있어야 중국적 종료로 인정된다.

3. 소송상 화해 및 조정 (제한적 인정)

(1) 의의

① 소송상 화해

- 당사자 간 합의를 법원이 확인하여 소송을 종료하는 것을 의미한다.

② 조정

- 법원이 당사자 사이의 합의에 기초해 조정권고를 하고 당사자가 수락하는 경우를 의미한다.

(2) 취소소송에서의 인정 여부

- 행정소송에서 피고가 공공기관인 경우, 소송상 화해 및 조정은 일반 민사소송과 달리 제한적으로 인정되며, 주로 행정청이 원고 청구를 수용하는 형태에서 가능하다.

III. 법원의 재판에 의한 종료 (중국판결 외)

1. 소장 각하 명령

(1) 의의

- 원고의 제소가 형식적 요건을 갖추지 못하거나 소송적격이 부정되는 경우, 법원이 소송을 심리하지 않고 종료시키는 결정이다.

(2) 효과

- 소송은 중국판결 없이 종료되며, 동일한 사건에 대해 다시 제기할 수 있으나, 제소기간 제한 등으로 일정한 제약을 받는다.

2. 소송종료선언 판결

(1) 의의

- 법원이 소송 요건이나 절차적 결함으로 소송을 더 이상 진행할 수 없다고 판단할 때 내리는 판결이다.

(2) 요건

- ① 소송적격 상실, ② 청구가 불가능함이 명백, ③ 절차적 하자가 치유 불가할 것

(3) 효과

- 판결 확정 시 소송은 중국적으로 종료되며, 기속력은 확정적이지만, 청구권 자체의 소멸은 아니므로 새로운 소송 제기는 가능하다.

IV. 기타 사유 : 당사자 대립구조의 소멸

1. 의의

- 소송 대상인 행정행위 자체가 소멸하거나, 원고와 피고 간 이해관계가 실질적으로 사라지는 경우를 의미한다.

2. 취소소송에서의 적용

- 예컨대, 행정청이 문제의 처분을 철회하거나, 행정행위 자체가 법적으로 무효화되는 경우, 소송은 실질적으로 종료될 수 있으며, 이는 중국판결 없이 효력이 발생하는 경우로 볼 수 있다.

V. 결론

- 중국판결에 의하지 않은 취소소송의 종료는 당사자의 행위, 법원의 재판, 기타 사유에 의해 이루어질 수 있다. 당사자 행위에 의한 종료는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해·조정이 있으며, 법원 재판에 의한 종료는 소장 각하 명령과 소송종료선언 판결이 대표적이다. 또한, 당사자 대립구조

의 소멸 등 기타 사유에 의해서도 소송은 종료될 수 있다. 다만, 취소소송의 특수성을 고려할 때, 이러한 종료는 일반 민사소송과 달리 제한적·엄격하게 해석되며, 법원의 개입과 공공기관의 수용 여부가 중요한 판단 기준이 된다. 이러한 제도적 장치는 행정쟁송의 효율성을 확보하고, 국민 권리구제의 실효성을 담보하는 중요한 역할을 수행한다.

《【문제2】「행정소송법」상 집행정지의 요건을 설명시오. (25점)》

<문제2> 행정소송법상 집행정지의 요건

I. 집행정지의 의미

- 집행정지란 행정소송에서 본안 판결의 확정 전에 당사자가 제기한 소송의 대상이 되는 처분이나 행위의 효력을 일시적으로 정지시키는 제도를 말한다. 즉, 본안 소송의 결과와 관계없이 현 상태에서 발생할 수 있는 회복하기 어려운 손해를 방지하고, 소송으로 인한 불이익을 최소화하기 위한 잠정적 권리구제 수단이다. 집행정지는 처분의 효력을 일시적으로 멈추게 하는 효과가 있으나, 본안 판결에 대한 기속력은 가지지 않는다.

II. 집행정지의 요건 [행정소송법 제23조]

1. 적법한 본안 소송의 계속 (적극적 요건)

- 집행정지는 본안 소송이 적법하게 제기되어 진행 중일 때 인정된다. 즉, 소송의 제기 자체가 적법하고 관할법원에서 계속 중이어야 하며, 본안 청구가 법적으로 심사 가능해야 한다. 본안 소송의 요건이 결여되어 있는 경우, 집행정지는 허용되지 않는다.

2. 처분 등의 존재 (적극적 요건)

- 집행정지는 대상 처분이나 행위가 현실적으로 존재하고 있어야 한다. 즉, 이미 존재하는 행정처분이나 집행이 가능한 상태이어야 하며, 아직 발생하지 않은 처분이나 가상의 처분을 대상으로는 집행정지를 청구할 수 없다.

3. 회복하기 어려운 손해 발생 우려 (적극적 요건)

(1) 의미

- 회복하기 어려운 손해란, 본안 소송에서 승소하더라도 원상회복이 곤란하거나 현실적 손실이 크고 금전적 보상만으로 해결하기 어려운 손해를 말한다.

(2) 판례상 인정 사례

- ❶ 사업허가 취소로 인한 영업상 피해. ❷ 건축허가 취소로 인한 이미 착공된 공사 비용 손실. ❸ 재산권 제한으로 인한 회복 곤란한 손해.

(3) 손해 발생의 우려

- 집행정지는 손해가 반드시 발생해야 하는 것이 아니라, 발생할 우려가 명백할 경우에도 인정된다. 법원은 현실적이고 상당한 위험을 검토하여 판단한다.

4. 긴급한 필요 (적극적 요건)

(1) 의미

- 긴급한 필요는 현 상태에서 즉시 조치를 취하지 않으면 손해 발생 가능성이 높거나, 본안 판결 전에 되돌리기 어려운 결과가 초래될 수 있는 상황을 의미한다.

(2) 판단 기준

- ❶ 손해 발생 시기와 정도. ❷ 본안 판결까지의 시간적 여유. ❸ 당사자 및 공공의 이익 고려

5. 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없을 것 (소극적 요건)

(1) 의미

- 집행정지로 인해 공공복리에 중대한 영향을 초래할 가능성이 없어야 한다. 즉, 개인의 권리 구제와 공공의 이익을 비교형량한다.

(2) 판단 기준

- ❶ 사회적·경제적 파급 효과. ❷ 안전, 환경, 공공행정에 미치는 영향. ❸ 다른 이해관계자의 권리 침해 여부

(3) 예시

- ❶ 대규모 건축 공사 중단 시 지역경제나 시민 불편. ❷ 환경보호 관련 조치 지연 시 환경적 피해.

6. 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것 (소극적 요건)

(1) 의미

- 본안 소송에서 청구가 명백히 이유 없을 경우 집행정지는 인정되지 않는다. 이는 본안에서 승소 가능성이 있어야 임시적 권리 구제의 필요성이 인정되기 때문이다.

(2) 판단 기준

- ❶ 법적 근거의 존재 여부. ❷ 판례와 학설에 의한 소송 가능성. ❸ 처분 사유의 명백한 정당성 여부

III. 결론

- 행정소송법상 집행정지는 본안 소송이 적법하게 계속 중이며, 대상 처분이 존재하고, 회복하기 어려운 손해 발생 우려와 긴급성이 인정되며, 공공복리에 중대한 영향을 미치지 않고, 본안 청구가 명백히 이유 없지 않은 경우에 한하여 허용된다. 이러한 요건을 충족하는 경우, 청구인은 본안 판결 전이라도 임시적 권리구제를 받아 처분으로 인한 불이익을 예방할 수 있다.

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 취소처분`을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 `가처분` 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음1) 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설의 대립과 대법원 판례의 입장을 기술하라.》

<문제7.2의 물음1> 항고소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부에 관한 학설 및 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 취소처분에 대한 취소소송 중 집행정지 신청이 기각되자 가처분을 통한 권리보호를 시도하고, 乙은 거부처분 취소소송 중 수익적 지위를 임시로 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <항고소송에서 행정소송법상 집행정지 제도 외에 민사소송법상 가처분 규정의 준용이 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항고소송에서 가처분 준용 가능성에 관한 학설과 판례의 입장을 기술한다.

II. 가처분의 의의 및 행정소송 가구제와의 관계

1. 가처분의 개념

- 가처분이란 금전채권 이외의 권리 또는 법률관계에 관한 확정판결의 강제집행을 보전하기 위하여 임시로 내려지는 명령을 말한다. 민사소송법상 가처분은 현상의 변경을 금지하는 다툼의 대상에 관한 가처분과 임시의 지위를 설정하는 임시처분으로 구분된다.

2. 집행정지와 차이

- 행 "행정소송법 제23조"가 규정하는 집행정지는 기존 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 소극적 가구제 수단이다. 반면 민사소송법상의 임시처분적 가처분은 신청인에게 임시의 지위를 부여하거나 적극적인 행위를 명하는 적극적 가구제 수단의 성격을 갖는다.

III. 가처분 규정 준용 여부에 관한 학설 및 판례

1. 학설의 대립

(1) 긍정설

- "행정소송법 제8조 제2항"에 의해 민사소송법 규정이 준용될 수 있고, 집행정지만으로는 거부처분이나 부작위와 같은 사안에서 실효적인 권리구제가 불가능하므로 가처분이 인정되어야 한다는 견해이다. 헌법상 재판받을 권리와 실질적 법치주의의 구현을 근거로 한다.

(2) 부정설

- "행정소송법 제23조"가 집행정지 제도를 별도로 두고 있는 것은 항고소송에서 가처분을 배제하려는 입법 취지로 해석한다. 또한, 가처분을 인정할 경우 행정권의 1차적 판단권을 침해하고 권력분립 원칙에 반할 우려가 있다는 점을 근거로 한다.

(3) 절충설

- 원칙적으로 부정하되, 집행정지만으로는 도저히 구제할 수 없는 예외적인 경우에 한하여 보충적으로 가처분을 허용하자는 견해이다.

2. 대법원 판례의 입장

(1) 항고소송에서의 부정

- "대법원"은 항고소송인 취소소송이나 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다. "판례"는 행정처분의 집행정지 사건에서 "행정소송법 제23조"의 집행정지 규정은 민사소송법상의 가처분에 대한 특칙이므로, 항고소송에서는 집행정지만이 허용될 뿐 가처분은 허용되지 않는다고 판시한다.

(2) 거부처분에 대한 판단

- 특히 거부처분에 대한 취소소송에서도 "대법원"은 가처분을 부정한다. 거부처분 취소소송에서 가처분을 통해 임시 지위를 설정하는 것은 행정청에게 특정 행위를 강제하는 결과를 초래하여 사법권의 한계를 넘어서는 것으로 본다.

(3) 당사자소송과의 비교

- 다만, "대법원"은 국가를 상대로 한 당사자소송에서는 "행정소송법 제44조 제1항"이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있으므로, 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 보아 항고소송과 결론을 달리하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 임시처분 신청에 대한 검토

- 甲이 신청하고자 하는 가처분은 취소소송 과정에서 공사 중지를 막아달라는 취지의 지위 설정이다. "대법원 판례"의 법리에 따르면, 취소소송에서는 "행정소송법 제23조"의 집행정지 규정이 우선 적용되며 민사소송법상의 가처분은 준용되지 않는다. 따라서 甲의 가처분 신청은 법원에 의해 부적법한 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 검토

- 乙은 거부처분 취소소송에서 수익적 지위 설정을 구하는 가처분을 신청하였다. 거부처분의 경우 집행정지를 하더라도 처분 전의 상태인 신청 시로 돌아갈 뿐이어서 실효성이 없다는 비판이 있으나, "판례"는 여전히 권력분립과 특칙 우선의 원칙을 이유로 항고소송에서의 가처분을 부정하므로 乙의 신청 역시 받아들여지기 어렵다.

V. 결론

- 현행법 체계와 "대법원 판례"의 확립된 태도에 의하면 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다. 이는 "행정소송법 제23조"가 집행정지를 특칙으로 규정하고 있기 때문이며, 사법권이 행정권의 영역에 적극적으로 개입하여 임시 지위를 설정하는 것을 경계하는 취지이다. 따라서 사안의 甲과 乙의 가처분 신청은 모두 허용되지 않는다는 것이 "판례"의 관점이다. 이러한 법리는 행정소송에서의 가구제 수단이 소극적인 집행정지에 국한되어 있다는 한계를 보여주며, 향후 입법적 개선을 통해 임시처분 제도의 도입 필요성이 논의되는 배경이 된다.

<제07장 취소소송의 가구제.제02절 가처분>

[예상][7.02-2]거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

《【문제7.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 취소처분`을 내렸다. 甲은 해당 취소처분에 대해 취소소송을 제기하면서, 소송이 진행되는 동안 해당 부지에 대한 공사를 계속 진행하기 위해 집행정지를 신청하였으나 법원에 의해 기각되었다. 이에 甲은 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법상의 `가처분` 규정을 준용하여 법원에 공사 중지를 막아달라는 취지의 임시처분을 신청하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 수익적 처분을 신청하였으나 거부당하자, 거부처분 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전까지 임시로 해당 수익적 지위를 설정해 달라는 가처분을 신청하였다.

(물음2) 특히 거부처분에 대한 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상 집행정지 제도로는 목적을 달성할 수 없는 이유와 가처분의 필요성 및 허용 여부에 대해 논하라.》

<문제7.2의 물음2> 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 결여와 가처분의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 수익적 처분을 신청하였으나 거부처분을 받아 이에 대한 취소소송을 제기하면서 판결 확정 전 임시로 수익적 지위를 확보하기 위한 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <거부처분 취소소송에서 현행 행정소송법상 집행정지 제도의 한계와 가처분에 의한 임시적 권리구제의 필요성 및 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 거부처분에 대한 취소소송에서 가처분 제도의 적용 가능성과 그 인정 여부를 검토한다.

II. 거부처분 취소소송에서 집행정지의 실효성 흠결

1. 집행정지의 소극적 성격

- 집행정지는 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 멈추는 소극적인 구제 수단이다. 이는 처분이 발해지기 전의 상태로 되돌려 놓는 것에 불과하며, 신청인에게 새로운 법적 지위를 부여하거나 적극적인 이행을 명하는 기능은 없다.

2. 거부처분 집행정지의 무용성

(1) 신청 시 상태로의 복귀

- 거부처분의 효력을 정지시키면 처분이 없었던 것과 같은 상태가 된다. 즉, 乙이 수익적 처분을 신청한 직후의 상태로 돌아갈 뿐이며, 행정청 B가 乙에게 수익적 처분을 내린 것과 같은 효과는 발생하지 않는다.

(2) 재처분의무의 불준용

- "행정소송법 제23조"는 본안판결의 기속력 중 재처분의무("제30조 제2항")를 준용하고 있지 않다. 따라서 거부처분의 집행이 정지된다고 하더라도 행정청에게 임시로라도 수익적 처분을 하도록 강제할 법적 근거가 없다. 결국 乙은 판결 확정 전까지 아무런 실질적 이득을 얻지 못하게 된다.

III. 항고소송에서 민사소송법상 가처분의 필요성 및 허용 여부

1. 가처분의 필요성

- 거부처분이나 부작위와 같이 집행정지만으로는 권리구제의 실효성을 확보할 수 없는 영역에서 적극적 가구제 수단인 가처분의 필요성이 제기된다. 乙의 경우처럼 판결 확정 전까지 임시로 수익적 지위를 설정받아야 할 긴급한 필요가 있는 경우 가처분은 유일한 대안이 될 수 있다.

2. 학설 및 판례의 입장

(1) 학설의 대립

- 긍정설은 헌법상 재판받을 권리와 국민의 실효적 권리구제를 위해 "행정소송법 제8조 제2항"에 따라 가처분을 인정해야 한다고 주장한다. 반면, 부정설은 행정소송법이 집행정지만을 명시한 것은 가처분을 배제하려는 취지이며, 가처분을 허용할 경우 사법부가 행정권의 영역을 침해하여 권력분립 원칙에 반한다고 본다.

(2) 대법원 판례의 입장

- "판례"는 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 명확히 하고 있다. "대법원"은 "행정소송법 제23조"가 집행정지라는 특칙을 두고 있으므로 민사소송법상의 가처분이 개입할 여지가 없다고 판시한다. 특히 거부처분에 대한 가처분은 행정청의 1차적 판단권을 침해하는 것으로 보아 허용하지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 집행정지 신청 시의 한계

- 乙이 거부처분 취소소송에서 집행정지를 신청하여 승인받더라도, 이는 행정청 B가 乙의 신청을 거부했다는 사실을 잠정적으로 지우는 것에 불과하다. 乙이 원했던 수익적 처분의 효과(예 : 영업 허가 등)는 발생하지 않으므로, 乙은 본안 판결이 확정될 때까지 경제적 손실 등 위험에 노출된다.

2. 乙의 가처분 신청에 대한 판단

- "판례"의 입장에 따를 때, 乙이 제기한 가처분 신청은 항고소송에서의 가처분 부정 법리에 따라 부적법 각하될 운명에 있다. 乙이 주장하는 적극적 가구제의 필요성은 인정되나, 현행법 해석상 사법부가 행정청을 대신하여 임시 지위를 창설해 주는 것은 권력분립의 한계를 넘는 것으로 간주되기 때문이다.

V. 결론

- 거부처분 취소소송을 제기한 乙의 경우, 현행 행정소송법상의 집행정지는 단순히 거부의 상태를 정지시킬 뿐 신청인에게 적극적인 권리 상태를 형성해 주지 못하므로 목적 달성에 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 적극적 가구제인 가처분이 필요하나, "대법원 판례"는 권력분립과 행정소송법의 특칙 우선을 이유로 항고소송에서의 가처분 준용을 부정하고 있다. 이러한 논의는 현행 가구제 제도의 불비로 인해 발생하는 거부처분 상대방의 권리구제 공백을 확인시켜 주며, 장차 행정소송법 개정 시 임시처분 제도의 명문화가 필요함을 시사한다.

《【문제3】 관련청구소송의 병합에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 관련청구소송의 병합의 의의 및 취지, 요건 및 유형, 관할 및 이송

I. 문제의 제기

- 관련청구소송의 병합 제도는 동일한 행정분쟁을 하나의 소송 절차에서 효율적이고 근본적으로 해결하기 위한 목적으로 인정된다. 이하에서는 행정소송법상 관련청구소송의 병합의 의의 및 취지, 병합의 요건 및 유형, 관할 및 이송에 관한 특례에 대해 설명한다.

II. 관련청구소송 병합의 의의 및 취지

1. 관련청구소송 병합의 의의

- 관련청구소송의 병합이란 항고소송(취소소송, 무효등 확인소송, 부작위위법확인소송)이 주된 청구로 제기된 경우, 그 항고소송과 법정된 관련성이 있는 다른 공법상 또는 사법상 청구를 동일한 절차에서 병합하여 심리하는 것을 말한다.

2. 병합 제도의 취지

(1) 분쟁의 일회적·근본적 해결

- 항고소송은 처분의 위법성만을 판단하여 효력을 소멸시키는 형성소송에 그치므로, 판결만으로는 국민의 손해배상이나 부당이득 반환 등 실질적인 권리 구제가 미흡하다. 관련청구의 병합은 항고소송의 판결을 선결 문제로 하는 다른 청구를 동일 절차에서 해결함으로써 판결의 모순을 방지하고 분쟁의 최종적인 종결을 가능하게 한다.

(2) 소송 경제의 실현

- 항고소송과 관련청구소송을 별도로 제기할 때 발생하는 시간적·경제적 낭비를 방지하고, 동일한 사실관계 및 증거조사를 일회적으로 집중 심리함으로써 사법 자원의 효율성을 도모한다.

III. 관련청구소송 병합의 요건 및 유형

1. 관련청구소송의 요건

- 관련청구소송의 병합이 적법하기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다.

(1) 항고소송의 계속

- 병합의 주된 청구인 항고소송이 법원에 적법하게 계속되어 있어야 한다. 관련청구소송은 항고소송에 종속되므로, 항고소송이 취하되거나 각하되면 관련청구소송은 원칙적으로 효력을 상실한다.

(2) 관련청구의 존재

- 항고소송과 법정된 관련성이 인정되는 다른 청구가 존재해야 한다. 그 청구는 사법상 청구일 수도 있고, 공법상 당사자소송 등일 수도 있다.

(3) 청구의 적법성

- 병합되는 관련청구 자체는 그 자체로 소송 요건(당사자적격, 제소기간 등)을 갖추어야 한다. 다만, 제소기간은 주된 항고소송의 기간이 아니라 관련청구소송의 본래 소송 유형이 정하는 기간을 따른다.

2. 관련청구소송의 유형 (관련성의 범위)

- 관련청구소송으로 병합이 가능한 소송은 "행정소송법 제10조 제2항"에 명확하게 규정된 경우에 한정된다.

(1) 손해배상·부당이득반환·원상회복 청구

- 항고소송의 대상인 처분 등(위법한 행정작용)을 원인으로 하는 손해배상, 부당이득반환, 또는 원상회복을 구하는 청구이다. 예를 들어, 위법한 영업정지 처분 취소소송과 그로 인한 손실에 대한 국가배상청구소송을 병합하는 경우가 이에 해당한다.

(2) 당해 처분과 관련되는 취소소송

- 당해 처분의 취소소송 등에 관련되는 처분(선행 처분, 후행 처분, 관련 처분)의 취소를 구하는 청구이다. 예를 들어, 선행 처분인 인가 처분 취소소송과 후행 처분인 그 인가에 따른 후속 처분 취소소송을 병합하는 경우 등 처분의 효력 상호 관련성이 있는 경우에 허용된다.

IV. 관련청구소송 병합의 특례 (관할 및 이송)

1. 관할의 집중 (특례)

- 관련청구소송은 원래 주된 항고소송이 제기된 법원의 관할에 속하지 않더라도, 주된 항고소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다. 이는 항고소송의 관할에 관련청구소송의 관할을 흡수시켜, 소송 주체의 주소지 등을 기준으로 관할이 분리되는 것을 막고 심리의 통일을 통해 효율성을 극대화하기 위함이다.

2. 이송

- 법원은 병합 제기된 관련청구소송에 대하여 필요하다고 인정할 때에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 관련청구소송을 원래 그 관할법원에 이송할 수 있다. 이는 법원의 재량적 조치로서, 관련청구소송을 분리 심리하는 것이 전문성 확보나 증거조사 등에 더 효율적이라고 판단되는 경우에 활용된다.

V. 결론

- 관련청구소송의 병합은 행정소송의 구제적 한계를 보완하고, 행정분쟁을 일회적이고 근본적으로 해결하며 소송 경제를 실현하는 데 핵심적인 역할을 하는 제도이다. 이는 처분 등을 원인으로 하는 손해배상·부당이득 등과 관련된 처분의 취소소송을 주된 항고소송과 병합하도록 허용하며, 관할의 집중에 인정하는 특례를 통해 그 실효성을 확보하고 있다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합 · 이송>

[기출][2018-3]영업정지처분 취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송의 병합 적법 여부

《[문제3] 사업자 甲은 위법을 이유로 행정청으로부터 2개월 영업정지처분을 받았다. 이에 대한 甲의 처분취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송이 병합될 수 있는지 설명하시오. (25점)》

<문제3> 영업정지처분 취소소송과 그 처분으로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송의 병합 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 사업자 甲은 위법한 영업정지처분에 대하여 처분취소소송을 제기함과 동시에 해당 처분으로 발생한 영업 손해에 대한 국가배상청구를 함께 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <항고소송과 국가배상청구소송이 관련 청구로서 행정소송 절차상 병합될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소소송과 국가배상청구소송의 병합 가능성과 그 요건을 검토한다.

II. 관련 청구소송 병합의 일반 법리

1. 관련청구소송 병합의 의의 및 범위

(1) 의의 및 취지

- "행정소송법 제10조 제1항"은 주된 처분등의 취소소송에 관련청구소송을 병합하여 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 하나의 처분에서 파생되는 다양한 법률적 분쟁을 동일한 법원 내에서 한꺼번에 해결함으로써 소송경제를 도모하고 판결의 모순 · 저축을 방지하기 위함이다.

(2) 관련청구의 범위

- "동법 제10조 제1항 제1호"는 당해 처분과 관련되는 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 청구소송을 관련청구소송의 하나로 규정하고 있다. 처분의 위법을 원인으로 하는 국가배상(손해배상)청구는 전형적인 관련청구에 해당한다.

2. 소의 병합 요건 및 관할 법원

(1) 주된 청구의 적법성 및 시기적 한계

- 소의 병합이 적법하기 위해서는 주된 송인 취소소송이 적법하게 제기되어 수소법원에 계속 중이어야 한다. 또한 추가적 병합의 경우 사실심 변론종결 전까지 이루어져야 하며, 주된 청구가 부적법하여 각하되는 경우에는 병합된 관련청구 역시 부적법 각하를 면할 수 없다.

(2) 수소법원의 관할권 확보

- "대법원"은 국가배상청구소송의 법적 성질을 공법상 당사자소송이 아닌 민사소송으로 파악한다. 그러나 "행정소송법 제10조"의 병합 규정은 특별한 관할 창설 규정이므로, 수소법원인 행정법원은 원래 민사소송인 국가배상청구소송에 대해서도 관련청구로서 적법하게 관할권을 행사하여 이를 심리 · 판단할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 국가배상청구의 관련청구 소속 여부

(1) 처분과의 관련성

- 사안에서 甲이 청구하고자 하는 국가배상청구는 행정청이 내린 2개월 영업정지처분의 위법성을 원인으로 하여 발생한 영업 손해의 전보를 구하는 소송이다. 이는 "행정소송법 제10조 제1항 제1호"에서 규정하는 당해 처분과 관련되는 손해배상청구소송에 정확히 부합한다.

(2) 민사소송과의 관계

- "판례"의 태도에 의하더라도 국가배상청구는 실체법상 민사소송에 불과하나, 영업정지처분 취소소송이라는 주된 항고소송에 흡수되어 병합될 수 있는 적격(관련청구소송의 지위)을 명백히 취득한다.

2. 병합의 구체적 적법성 검토

(1) 주된 송과의 연계성

- 甲이 영업정지처분의 위법을 주장하여 제기하는 취소소송이 제소기간 등 소송요건을 모두 충족하여 적법하게 계속 중인 상태라면, 사실심 변론종결 전에 영업 손해에 대한 국가배상청구소송을 병합하여 제기하는 소송 형태는 적법하다.

(2) 수소법원의 심리 가능성

- 수소법원인 행정법원은 주된 영업정지처분의 위법성 여부를 직접 심사하면서, 그와 연계된 국가배상법상 공무원의 고의 · 과실 및 인과관계 유무를 종합적으로 심리하여 본안판결을 내릴 수 있는 사법적 권한을 가진다.

IV. 결론

- 사안에서 사업자 甲이 행정청의 2개월 영업정지처분에 대하여 제기한 취소소송과 그로 인한 영업 손해에 대한 국가배상청구소송은 병합하여 제기될 수 있다. 국가배상청구는 "행정소송법 제10조 제1항 제1호"가 규정하는 당해 처분과 관련되는 손해배상청구로서 전형적인 관련청구소송에 해당하기 때문이다. "판례"가 국가배상소송을 민사소송으로 취급하더라도 행정소송법상 특별 관할 규정에 의해 행정법원이 관련청구로서 관할권을 가지므로, 주된 취소소송이 적법하게 계속 중이고 사실심 변론종결 전까지 병합이 이루어진다면 법원은 두 소송의 병합을 적법한 것으로 판단하여 실체적 심리를 진행하여야 한다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합·이송>

[기출][2021-1-2]무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송 추가 병합의 적법 여부

《【문제1】 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음2) 위 무효확인소송의 계속 중 甲은 추가적으로 급여지급결정 취소처분의 취소를 구하는 소를 병합하여 제기할 수 있는가? (20점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

❶ 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 '공무원'이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음2> 무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송 추가 병합의 적법 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기한 후, 동일한 처분에 대한 취소소송을 추가로 병합하여 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송 계속 중 처분의 취소를 구하는 청구를 추가하는 것이 소의 변경 또는 청구의 병합으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송과 취소소송의 병합 가능성 및 그 요건을 설명한다.

II. 무효확인소송과 취소소송의 병합에 관한 법리

1. 관련 청구소송 병합의 의의 및 요건

(1) 의의

- 「행정소송법 제10조 제1항」은 처분등의 취소청구소송에 관련청구소송을 병합하여 제기할 수 있도록 규정하고 있으며, 「동법 제38조 제1항」은 이를 무효등확인소송에도 준용한다. 이는 분쟁의 일회적 해결을 도모하고 판결의 모순·저착을 방지하기 위함이다.

(2) 요건

- 소의 병합이 인정되기 위해서는 주된 청구와 병합되는 청구 사이에 관련성이 존재해야 하며, 본안 심리를 담당하는 수소법원이 두 소송에 대해 모두 관할권을 가져야 한다. 동일한 처분의 무효확인 청구와 취소 청구는 전형적인 관련청구소송에 해당한다.

2. 병합의 형태적 한계

(1) 단순 병합 및 선택적 병합의 불허

- 동일한 처분에 대해 무효를 구하는 청구와 취소를 구하는 청구는 처분의 하자의 정도를 다르게 평가하는 것으로서 서로 양립할 수 없다. 따라서 법원이 두 청구를 모두 인용하거나 그중 하나를 임의로 선택하여 인용할 수 있는 단순 병합이나 선택적 병합의 형태는 허용되지 않는다.

(2) 주위적·예비적 병합의 허용

- 「판례」는 무효확인청구와 취소청구는 서로 양립할 수 없는 관계이므로 주위적·예비적 청구 형식으로만 병합이 가능하다고 본다. 사안의 경우 이미 제기된 무효확인소송을 주위적 청구로 삼고, 추가 병합하는 취소소송을 예비적 청구로 삼는 병합만이 적법하게 인정된다.

3. 병합된 취소소송의 제소기간 준수 여부

(1) 제소기간의 독립적 심사

- 추가적으로 병합되는 청구라 하더라도 제소기간과 같은 소송요건은 개별적·독립적으로 심사되어야 한다. 「행정소송법 제20조 제1항」에 따라 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기되어야 하는 불변기간의 제한을 받는다.

(2) 소 제기 시점의 기준

- 예비적 청구로 병합되는 취소소송의 제소기간 준수 여부는 주위적 청구인 무효확인소송이 제기된 시점이 아니라, 예비적 청구인 취소소송이 실제로 추가 병합되어 법원에 제출된 시점을 기준으로 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 병합의 형태적 적합성 검토

(1) 병합의 가능성

- 甲이 이미 제기하여 진행 중인 급여지급결정 취소처분 무효확인소송에 동일한 처분의 취소소송을 병합하는 것은 「행정소송법 제10조 및 제38조 제1항」에 따라 객관적 병합으로서 기본적으로 허용된다.

(2) 예비적 병합의 의무화

- 다만, 두 청구는 실제법상 하자의 정도를 달리하는 양립 불가능한 관계이므로, 甲은 기존의 무효확인소송을 주위적 청구로 유지하고 새로 추가하는 취소소송을 예비적 청구로 삼는 주위적·예비적 병합의 형태로 소를 제기하여야 한다.

2. 병합된 취소소송의 제소기간 도과 여부 판단

(1) 제소기간의 만료 시점

- 사안에서 甲은 급여지급결정 취소처분서를 2021. 1. 7. 수령하여 처분이 있음을 직접 알게 되었다. 따라서 「행정소송법 제20조 제1항」에 따른 취소소송의 제소기간은 초일불산입 원칙에 따라 2021. 1. 8.부터 기산하며, 90일이 경과하는 날인 2021. 4. 7.에 만료된다.

(2) 병합 제기 시점과 적법성

- 甲이 최초 무효확인소송을 제기한 시점은 2021. 5. 7.로서, 이 시점에 이미 취소소송의 제소기간인 2021. 4. 7.을 경과하였다. 취소소송의 추가 병합은 이보다 더 늦은 소송 계속 중에 행해지므로, 예비적으로 병합된 취소소송은 불변기간인 제소기간을 명백히 도과하여 제기된 소로서 소송요건을 결여하였다.

IV. 결론

- 사안에서 甲이 제기한 무효확인소송 계속 중 동일한 처분에 대한 취소소송을 예비적으로 병합하여 제기하는 것은 소의 병합 형식 자체로는 가능하다. 그러나 추가 병합되는 예비적 취소소송 역시 독립하여 제소기간을 준수하여야 하는바, 甲이 처분을 안 날인 2021. 1. 7.로부터 90일이 훨씬 경과한 시점에 소를 병합하였으므로 이는 제소기간 요건을 흠결하였다. 결론적으로 법원은 甲이 추가적으로 병합 제기한 취소청구에 대하여 제소기간 도과를 이유로 부적법 각하 판결을 내려야 한다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>

[예상][8.02-1]취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 거부처분`을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 `취소소송`을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 `부작위위법확인소송`으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 `영업정지 6개월 처분`을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 `영업정지 2개월`로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음1) 甲이 현재 진행 중인 `취소소송`을 `부작위위법확인소송`으로 변경하고자 할 때, 행정소송법 제21조에 따른 `소의 종류의 변경`의 요건과 허용 범위에 대하여 설명하라.》

<문제8.2의 물음1> 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위허가 거부처분 취소소송이 계속 중인 상태에서 부작위위법확인소송으로 소송의 종류를 변경하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법 제21조에 따른 소의 종류 변경이 인정되기 위한 요건과 취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 변경이 허용되는 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소의 종류 변경 제도의 의의와 요건 및 그 허용 범위에 대해 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 제기한 소송을 다른 종류의 항고소송이나 당사자소송으로 변경하는 것을 말한다. 이는 소의 제기 후에 발생한 사정변경에 대응하거나, 당초 소 제기가 잘못된 경우 원고의 권리구제를 도모하고 소송경제를 실현하기 위한 제도이다.

2. 법적 성질

- "행정소송법 제21조"에 의한 소의 변경은 구소(취소소송)를 취하하고 신소(부작위위법확인소송)를 제기하는 성격을 동시에 가진다. 이때 신소는 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 보아 제소기간 준수 여부를 판단하게 되는 소급효의 특징이 있다.

III. 소의 종류의 변경의 요건

1. 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 변경하고자 하는 구소가 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지 이루어져야 한다. 사안의 甲은 제1심 소송이 계속 중이므로 이 요건을 충족한다.

2. 청구의 기초의 동일성

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없는 범위 내에서 허용된다. 이는 구소와 신소가 동일한 행정작용이나 사실관계에 근거하고 있어 소송자료를 공통적으로 활용할 수 있는 경우를 의미한다. 甲의 경우 개발행위허가 신청에 대한 행정청의 반응(거부 또는 부작위)을 다투는 것이므로 청구의 기초가 동일하다고 볼 수 있다.

3. 신소의 적법성

- 변경되는 신소인 부작위위법확인소송은 그 자체로 소송요건을 갖추고 있어야 한다. 다만 제소기간의 경우 "행정소송법 제21조 제4항" 및 "제14조 제4항"에 따라 구소가 제기된 때에 제기된 것으로 간주되므로 구소의 제소기간 내 제기 여부가 중요하다.

4. 법원의 재량과 피고의 의견 청구

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 허가한다. 이때 법원은 피고의 의견을 들어야 한다. 피고가 소 변경에 반대하더라도 청구의 기초가 동일하고 변경의 필요성이 인정된다면 법원은 이를 허가할 수 있다.

IV. 소의 종류의 변경의 허용 범위와 사안의 특수성

1. 변경의 방향

- "행정소송법 제21조"는 항고소송 상호 간(취소소송 ↔ 무효확인소송 ↔ 부작위위법확인소송)의 변경뿐만 아니라 항고소송과 당사자소송 간의 변경도 허용한다.

2. 거부처분 취소소송과 부작위위법확인소송의 관계

(1) 처분의 존재 여부

- 사안에서 행정청 A는 이미 거부처분을 내린 상태이다. 부작위위법확인소송은 행정청이 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우에 제기하는 소송이다.

(2) 소 변경의 허용 범위에 관한 고찰

- 거부처분이 엄연히 존재하는 상황에서 이를 부작위로 보아 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 원칙적으로 대상적격의 흠결 문제를 발생시킬 수 있다. "판례"에 따르면 거부처분이 있는 경우에는 부작위위법확인소송을 제기할 수 없다. 따라서 甲이 소를 변경하려 할 때, 법원은 단순히 소 변경의 절차적 요건뿐만 아니라 변경된 신소가 부작위라는 요건을 실질적으로 충족하는지를 심사하게 된다. 만약 거부처분의 통지가 도달하지 않았거나 행정청의 반응이 부작위로 해석될 여지가 있다면 소 변경이 유효할 것이나, 명확한 거부처분이 있는 상황에서의 변경은 부적법한 신소로 귀결될 위험이 있다.

V. 결론

- 甲이 제기한 취소소송을 부작위위법확인소송으로 변경하는 것은 "행정소송법 제21조"에 따라 사실심 변론종결 전까지 청구의 기초가 동일하다면 신청할 수 있다. 소 변경이 허가되면 신소는 구소 제기 시에 제기된 것으로 간주되는 유리함이 있다. 다만, 사안에서 행정청 A의 명시적인 거부처분이 존재하는 상황이라면 변경된 부작위위법확인소송은 대상적격 흠결로 각하될 가능성이 높으므로, 甲은 법률 전문가의 조언에도 불구하고 실질적인 소송의 실익을 신중히 검토해야 한다. 이러한 법리는 원고의 주관적 권리구제를 넓게 보장하면서도, 소송 대상의 성질에 따른 소송 종류의 적정성을 유지하려는 행정소송법의 태도를 반영한다.

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제02절 소의 변경>

[예상][8.02-2]처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

《【문제8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 `개발행위허가 거부처분`을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 `취소소송`을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 `부작위위법확인소송`으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 `영업정지 6개월 처분`을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 `영업정지 2개월`로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 소송 계속 중 행정청이 처분을 변경한 경우, 乙이 기존의 소송을 유지하면서 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼기 위해 활용할 수 있는 `처분변경으로 인한 소의 변경`의 요건과 그 신청 기한에 대하여 기술하라.》

<문제8.2의 물음2> 처분변경으로 인한 소의 변경의 요건과 신청 기한

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지처분 취소소송을 제기하여 소송이 계속 중인 상태에서 행정청이 당초 처분을 감경하는 변경처분을 하자 변경된 처분을 소송의 대상으로 삼으려는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 처분변경으로 인한 소의 변경이 인정되기 위한 요건과 그 신청기간>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분변경으로 인한 소의 변경 제도의 의의와 요건 및 신청 기한에 대해 기술한다.

II. 처분변경으로 인한 소의 변경의 의의 및 성질

1. 의의

- 처분변경으로 인한 소의 변경이란 피고인 행정청이 소송의 대상인 처분을 소송 계속 중에 변경한 경우, 원고가 변경된 새로운 처분에 맞추어 소송의 대상을 바꾸거나 청구 내용을 변경하는 제도를 의미한다. 이는 행정청의 처분 변경으로 인해 기존 소송의 실익이 소멸하는 것을 방지하고 원고의 권리구제를 도모하기 위한 것이다.

2. 법적 성질

- "행정소송법 제21조"에 의한 소의 종류의 변경과 달리, "제22조"는 소송의 대상이 된 처분이 사후적으로 변경되었다는 특수한 사정을 고려한 제도이다. 소 변경이 허가되면 구소는 취하된 것으로 보고 신소가 제기된 것으로 간주하며, 제소기간의 준수 여부는 구소가 제기된 때를 기준으로 판단하는 소급효가 인정된다.

III. 처분변경으로 인한 소의 변경 요건

1. 항고소송의 계속과 처분의 변경

- 취소소송 등 항고소송이 법원에 적법하게 계속 중이어야 한다. 또한 소송의 대상이 된 당초 처분을 행정청이 소송 계속 중에 변경하였어야 한다. 사안의 경우 영업정지 6개월 처분이 2개월로 감경된 것은 처분의 실질적 내용이 바뀐 것이므로 처분의 변경에 해당한다.

2. 사실심 변론종결 전일 것

- 소의 변경 신청은 사실심(제1심 또는 제2심)의 변론종결 전까지만 가능하다. 상고심에서는 새로운 처분을 대상으로 하는 소의 변경이 허용되지 않는다.

3. 처분의 변경이 소송 대상에 영향을 미칠 것

- 행정청의 처분 변경으로 인하여 구소의 청구취지나 청구원인을 변경할 필요가 있어야 한다. 사안에서 乙은 영업정지 6개월의 취소를 구하고 있었으므로, 감경된 2개월 처분의 취소를 구하기 위해서는 소의 변경이 필수적이다.

4. 법원의 허가 결정

- 법원은 원고의 신청이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 소의 변경을 허가한다. 이때 법원은 피고 행정청의 의견을 들어야 한다.

IV. 신청 기한

1. 원칙적 기한

- "행정소송법 제22조 제2항"에 따라 처분변경으로 인한 소의 변경 신청은 처분의 변경이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 하여야 한다.

2. 기간의 성격

- 이 60일의 기간은 불변기간이다. 따라서 원고가 처분이 변경되었음을 알고도 60일이 경과한 후에 신청한다면 법원은 이를 부적법한 신청으로 보아 각하하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 가능성

- 사안에서 행정청 B가 소송 중에 영업정지 기간을 감경한 것은 乙에게 유리한 변경이지만, 乙이 2개월의 정지 처분 자체도 불복하고자 한다면 "행정소송법 제22조"에 따라 소를 변경해야 한다. 乙은 영업정지 2개월 처분이 있음을 안 날로부터 60일 이내에 법원에 소 변경 신청서를 제출해야 한다.

2. 감경처분의 특수성과 판례의 태도

- "대법원 판례"에 따르면, 사안과 같은 감경처분의 경우 변경된 내용의 당초 처분이 소송의 대상이 된다. 즉, 영업정지 6개월 중 4개월이 취소되고 남은 2개월 분의 영업정지가 소송의 대상이 되는 것이다. 乙은 소 변경을 통해 청구취지를 영업정지 6개월 처분 중 취소되지 않고 남은 2개월 처분을 취소한다는 형태로 수정하여 소송을 유지할 수 있다.

VI. 결론

- 乙은 행정청 B의 처분 변경에 대응하여 "행정소송법 제22조"에 따른 처분변경으로 인한 소의 변경을 신청할 수 있다. 이를 위해서는 사실심 변론종결 전까지 처분 변경을 안 날로부터 60일 이내에 신청서를 제출하여야 한다. 법원의 허가를 얻으면 乙은 기존 소송 절차에서 현출된 자료들을 활용하면서 변경된 영업정지 2개월 처분의 위법성을 계속해서 다룰 수 있게 된다. 이러한 법리는 소송 계속 중 행정청의 처분 변경으로 인해 원고가 불필요하게 새로운 소송을 처음부터 다시 제기해야 하는 번거로움을 덜어주고, 분쟁의 일회적 해결을 가능하게 하는 중요한 기능을 수행한다.

《【문제1】 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음1) 위 무효확인소송에서 급여지급결정 취소처분이 무효라는 점에 대한 입증책임은 누가 부담하는가? (10점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

❶ 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 '공무원'이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음1> 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송에서 처분의 무효 사유에 대한 입증책임의 귀속 주체

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 대하여 무효확인소송을 제기하고, 해당 처분의 무효를 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 처분의 무효를 주장하는 자와 처분청 중 누가 무효사유에 관한 입증책임을 부담하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정소송에서의 입증책임 분배와 무효확인소송에서 무효사유에 대한 입증책임의 귀속에 대해 설명한다.

II. 무효확인소송의 입증책임에 관한 법리

1. 입증책임 분배에 관한 학설

(1) 원고책임설

- 행정처분의 공정력이나 유효성 추정을 법적 근거로 삼는 견해이다. 행정처분은 권한 있는 기관에 의해 취소되거나 무효로 선언되기 전까지는 원칙적으로 유효한 처분으로 취급되므로, 이러한 기존의 법적 상태를 부인하고 당연무효를 주장하는 원고가 그 처분에 존재하는 하자가 중대하고 명백하다는 사실을 입증해야 한다는 입장이다.

(2) 법률요건분류설

- 「행정소송법 제8조 제2항」에 의해 민사소송법상의 입증책임 분배 원칙을 준용하는 견해이다. 각 당사자는 자신에게 유리한 법률적 효과를 규정한 법령의 요건 사실에 대하여 입증책임을 지게 된다. 이 견해에 의하면 처분의 성립 및 적법요건은 처분의 유효를 주장하는 행정청이 입증해야 하지만, 처분의 당연무효를 주장하여 그 효력을 소급적으로 배제하려는 경우에는 그 예외적 사유인 하자의 중대·명백성을 주장하는 원고가 입증책임을 부담한다고 파악한다.

2. 판례의 태도

(1) 원고책임설의 확고한 견지

- 「대법원」은 행정처분의 무효확인을 구하는 소송에서는 원고가 당해 처분에 존재하는 하자가 중대하고 명백하여 당연무효라는 사실을 입증할 책임이 있다고 판시하여 일관되게 원고책임설의 입장을 취하고 있다.

(2) 취소소송과의 법리적 차별성

- 「대법원」은 처분의 적법성 자체에 대한 입증책임을 피고 행정청이 지는 취소소송과 달리, 무효확인소송은 기득권의 완전한 박탈을 유도하는 중대한 소송이므로 예외적으로 처분의 당연무효를 구하는 원고가 엄격한 하자의 존부 및 정도를 입증해야 하며 소송 성질상 입증책임의 전환이 허용되지 않는다고 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 원고 甲의 입증책임 부담

- 「대법원」이 취하고 있는 원고책임설에 의할 때, 근로복지공단이 내린 급여지급결정 취소처분에 대하여 무효확인소송을 제기한 당사자인 원고 甲이 당해 처분의 무효 사유에 대한 입증책임을 전적으로 부담하게 된다.

2. 증명의 내용 및 한계

- 따라서 甲은 단순한 취소 사유에 불과한 위법성만을 규명하는 것으로는 부족하며, 근로복지공단의 취소처분에 존재하는 하자가 객관적으로 중대할 뿐만 아니라 외관상 일견 명백하여 당연무효에 이른다는 사실을 소송법상 실질적으로 증명하여야 한다. 만약 법원의 심리 결과 하자의 존부나 중대·명백성 여부가 불명명한 상태(진위불명)에 처하게 된다면, 입증책임을 지는 원고 甲이 패소의 불이익을 받게 된다.

IV. 결론

- 무효확인소송에서 처분의 당연무효를 주장하는 원고가 그 하자의 중대·명백성을 입증하여야 한다는 것이 「대법원」의 확고한 입장이다. 결론적으로 사안에서 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분이 무효라는 점에 대한 입증책임은 소를 제기한 당사자인 근로자 甲이 부담한다.

《【문제1】 증기계를 생산하는 제조회사에 근무하는 甲은 골절 등의 업무상 사고로 인하여 상해를 입었음을 이유로 근로복지공단으로부터 휴업급여와 장해급여 등의 지급결정을 받았다. 그 후 근로복지공단은 甲이 실제 상해를 입지 않았음에도 허위로 지급신청서를 작성하여 급여지급결정을 받은 사실을 들어 甲에 대한 급여지급결정을 취소하였고, 甲은 급여지급결정의 취소처분을 2021. 1. 7. 직접 수령하였다. 이와 함께 근로복지공단은 이미 甲에게 지급된 급여액에 해당하는 금액을 부당이득으로 징수하였다. 한편, 甲은 위 급여지급결정 취소처분이 위법함을 이유로 2021. 5. 7. 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 상호 관련성이 없는 별개의 문항임) (50점)

(물음3) 위 무효확인소송에서 기각판결이 확정된 후 甲이 급여지급결정 취소처분의 '법령 위반'을 이유로 국가배상청구소송을 제기한 경우, 무효확인소송의 기각판결의 효력과 관련하여 국가배상청구소송의 수소법원은 급여지급결정 취소처분의 '법령 위반'을 인정할 수 있는가? (20점)

「국가배상법 제2조(배상책임)」

① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 '공무원'이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 군인·군무원·경찰공무원 또는 예비군대원이 전투·훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사(戰死)·순직(殉職)하거나 공상(公傷)을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금·유족연금·상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 「민법」에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.》

<문제1의 물음3> 무효확인소송 기각판결 확정 후 후속 국가배상청구소송에서 수소법원의 법령 위반 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 급여지급결정 취소처분에 대한 무효확인소송에서 기각판결이 확정된 후, 동일 처분의 법령 위반을 이유로 국가배상청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <선행 무효확인소송의 기각판결이 후행 국가배상청구소송에서 처분의 법령 위반 여부에 관하여 기판력을 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송의 기판력과 국가배상청구소송에서 위법성 판단의 가능 여부에 대해 답한다.

II. 무효확인소송 기각판결의 기판력과 국가배상의 범위

1. 기판력의 의의 및 작용 요건

(1) 기판력의 개념

- 기판력이란 확정판결을 내린 법원 및 당사자가 후행 소송에서 선행 판결의 판단 내용과 모순·저촉되는 주장이나 판단을 할 수 없도록 구속하는 효력을 의미한다.

(2) 기판력의 작용 범위

- 선행 판결의 기판력이 후행 소송에 미치기 위해서는 선행 소송의 소송물과 후행 소송의 소송물이 동일하거나, 후행 소송의 소송물이 선행 소송의 소송물과 모순·저촉되는 관계 또는 선결문제 관계에 있어야 한다.

2. 무효확인소송 기각판결의 소송물적 범위

(1) 무효확인소송의 소송물

- 무효확인소송의 소송물은 당해 행정처분의 무효(효력 부존재) 여부이다. 따라서 무효확인소송에서 기각판결이 확정되었다는 것은 처분에 '무효사유에 해당하는 하자가 존재하지 않는다'는 점에 대해서만 기판력이 발생하는 것을 의미한다.

(2) 취소소송 기각판결과의 구별

- 취소소송의 기각판결은 처분이 '적법하다'는 점을 확정하므로 후행 국가배상청구소송에 기판력이 미쳐 위법을 주장할 수 없다는 것이 "판례"의 태도이다. 그러나 무효확인소송 기각판결은 처분이 '적법하다(단순취소 하자도 없다)'는 점까지 확정하는 것이 아니므로 기판력의 범위가 무효 여부에 한정된다.

3. 국가배상법상 법령 위반의 의미

(1) 법령 위반의 개념

- "국가배상법 제2조 제1항"의 법령 위반이란 엄격한 의미의 법률 위반뿐만 아니라 공무원의 직무 수행이 객관적 정당성을 결여한 경우까지 포함하는 광의의 개념이다.

(2) 행정소송법상 위법과의 관계

- 행정소송법상 취소사유에 해당하는 단순한 위법 역시 국가배상법상 법령 위반에 포섭된다. 따라서 무효확인소송 기각판결을 통해 처분이 무효가 아님이 확정되었다 하더라도, 당해 처분에 취소사유 수준의 하자가 존재한다면 이는 국가배상법상 법령 위반으로 인정될 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 선행 판결 기판력의 한계

- 사안에서 甲이 제기한 선행 급여지급결정 취소처분 무효확인소송의 기각판결이 확정됨으로써 발생한 기판력은 '해당 취소처분에 무효사유의 하자가 존재하지 않는다(유효하다)'는 사실에 국한된다. 이 기판력은 당해 취소처분에 '단순취소사유의 하자가 존재하는지 여부'나 국가배상법상 법령 위반이 존재하는지 여부에는 미치지 않는다.

2. 수소법원의 독자적 위법성 판단 가능성

- 후행 국가배상청구소송의 수소법원은 선행 무효확인소송 기각판결의 기판력에 구속되지 않는다. 따라서 수소법원은 독자적인 심리를 거쳐 근로복지공단의 급여지급결정 취소처분에 단순취소 수준의 하자(예 : 비례원칙 위반, 절차적 하자 등)가 존재함을 이유로 국가배상법상 법령 위반을 충분히 인정할 수 있다.

IV. 결론

- 선행 무효확인소송 기각판결의 기판력은 처분의 무효 여부에만 미칠 뿐 단순취소사유의 존재 여부까지 차단하는 것은 아니다. 따라서 후행 국가배상청구소송의 수소법원은 선행 판결의 기판력에 저촉됨이 없이, 독자적으로 급여지급결정 취소처분에 취소사유의 하자가 있음을 밝혀 "국가배상법 제2조 제1항"의 법령 위반을 유효하게 인정할 수 있다.

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[기출][2023-1-2]무효확인소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재처분의무 및 이행 강제를 위한 소송법상 수단

《[문제1]》 A시는 택지개발예정지구 지정 공람공고가 이루어진 P사업지구에서 택지개발사업을 시행하고 있으며, 甲은 P사업지구내 주택을 소유하고 있는 자이다. A시는 택지개발사업과 관련한 이주대책을 수립·공고하였는데, 이에 의하면 이주대책 대상자 요건을 '택지개발예정지구 지정 공람공고일 1년 이전부터 보상계약체결일 또는 수용재결일까지 계속하여 P사업지구 내 주택을 소유하고 계속 거주한 자로, A시로부터 그 주택에 대한 보상을 받고 이주하는 자'로 정하고 있다. 甲은 A시에 이주대책 대상자 선정 신청을 하였으나, A시는 '기준일 이후 주택 취득'을 이유로 甲을 이주대책 대상에서 제외하는 결정을 하였고, 이 결정은 2023. 6. 28. 甲에게 통보되었다(이하 '1차 결정'이라 함). 이에 甲은 A시에 이의신청을 하면서, 이의신청서에 이주대책 대상자 선정요건을 충족함을 증명할 수 있는 마을주민확인서, 수도개설 사용, 전력 개통사용자 확인 등 증빙서류를 새롭게 추가로 첨부하여 제출하였다. 그러나 A시는 추가된 증빙자료만으로 법적 소유관계를 확인할 수 없다는 이유로 甲의 이의신청을 기각하고 甲을 이주대책 대상에서 제외한다는 결정을 하였으며, 이 결정은 2023. 8. 31. 甲에게 통보되었다(이하 '2차 결정'이라 함). 다음 각 물음에 답하시오. (각 물음은 상호관련성이 없는 별개의 상황임) (50점)

(물음2) 甲이 1차 결정에 대해 무효확인소송을 제기하였고, 甲이 기준일 이전에 주택을 취득한 것이 인정되어 청구를 인용하는 법원의 판결이 확정되었다. A시는 甲을 이주대책 대상자로 선정하여야 하는지 여부 및 A시가 아무런 조치를 하지 않는 경우 「행정소송법」상 강제수단에 대하여 설명하시오. (25점)

<문제1의 물음2> 무효확인소송 인용판결 확정 후 피고 행정청의 재처분의무 및 이행 강제를 위한 소송법상 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 이주대책 대상자 제외 결정에 대한 무효확인소송에서 승소판결을 받아 확정되었고, A시가 그 판결에 따라 아무런 조치를 하지 않을 경우 강제수단을 검토해야 하는 상황이다. 쟁점으로 <취소·무효확인판결의 기속력에 따라 행정청이 부담하는 재처분의무와 이를 이행하지 않는 경우 활용할 수 있는 행정소송법상 강제수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인판결의 효력과 행정청의 불이행에 대한 강제수단에 대해 설명한다.

II. 무효확인판결의 기속력과 재처분의무

1. 기속력의 준용 여부

(1) 기속력의 의의

- 「행정소송법 제30조 제1항」에 따른 기속력은 당사자인 행정청을 구속하는 효력으로, 판결 주문 및 구체적인 위법사유에 대하여 미친다.

(2) 무효확인소송에서의 준용

- 「동법 제38조 제1항」은 무효확인소송에 "제30조"를 준용하므로 무효확인판결이 확정되면 피고 행정청은 당연히 기속력을 부담한다.

2. 거부처분 무효확인판결과 재처분의무

(1) 재처분의무의 법적 근거

- 「동법 제30조 제2항」은 거부처분 취소 시 재처분의무를 규정하며, "제30조 제1항"이 이를 준용하므로 무효확인판결 확정 시에도 행정청은 재처분의무를 부담한다.

(2) 이주대책 대상자 선정의무

- 법원이 甲의 요건 충족을 인정하여 처분을 무효로 판정했으므로, A시는 판결의 취지에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정하여야 하는 구체적 재처분의무를 진다.

III. 재처분의무 불이행 시 행정소송법상 강제수단

1. 간접강제의 준용 여부와 판례

(1) 학설의 대립

- 무효등 확인소송에 대한 규정을 준용하는 "행정소송법 제38조 제1항"이 간접강제 규정("제34조")을 준용하지 않아, 유추적용을 긍정하는 견해와 명문 규정의 배제를 중시하여 부정하는 견해가 대립한다.

(2) 판례의 태도

- "대법원"은 준용 규정이 없는 이상 무효확인판결에 대해서는 행정소송법 및 민사집행법상의 간접강제 신청이 허용되지 않는다고 판시하여 부정설을 확고히 한다.

2. 직접처분의 허용 여부

(1) 직접처분의 의의

- 재처분의무 불이행 시 법원 등이 직접 처분을 내리는 실효적 강제수단을 의미한다.

(2) 행정소송법상 한계

- 직접처분은 "행정심판법 제50조"에만 규정되어 있을 뿐, 현행 행정소송법에는 명문 규정이 없어 무효확인소송에서도 불가능하다.

IV. 사안의 적용

1. A시의 이주대책 대상자 선정 의무

- "제38조 제1항"에 의해 "제30조 제2항"의 재처분의무가 준용되므로, 판결을 통해 甲의 요건 구비가 밝혀진 이상 A시는 판결 취지에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정하는 재처분을 할 의무를 부담한다.

2. A시의 의무 불이행 시 강제수단의 한계

- A시가 불이행하는 경우, "제38조 제1항"이 "제34조"(간접강제)를 준용하지 않고 "판례" 역시 간접강제 신청을 불허하므로 간접강제 제도는 적용되지 않는다. 직접처분권도 인정되지 않으므로, 현행법상 A시의 의무 이행을 강제할 수 있는 소송법상 수단은 존재하지 않는다.

V. 결론

- A시는 판결의 기속력에 따라 甲을 이주대책 대상자로 선정할 재처분의무를 부담한다. 그러나 A시가 이를 불이행하는 경우, 행정소송법상 무효확인소송에 대해서는 간접강제 준용 규정이 없고 직접처분도 인정되지 않으므로 이행을 강제할 소송법상 수단은 전혀 존재하지 않는다. 이는 심각한 입법적 불비에 해당하므로, 향후 법 개정을 통해 무효확인소송에서도 간접강제 규정을 준용하도록 보완하여 국민의 실질적 권리구제를 보장하여야 한다.

<제09장 무효등 확인소송.제04절 무효등 확인소송의 종료>

[예상][9.04-1]무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 `당연무효`라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 `사정판결`을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제28조의 사정판결 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 학설 및 대법원 판례의 입장을 서술하고, 사안의 수용재결이 무효인 경우 법원이 사정판결을 내릴 수 있는지 답하라.》

<문제9.4의 물음1> 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 사안에 대한 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A의 수용재결에 대하여 甲이 중대하고 명백한 하자를 이유로 무효확인소송을 제기하였고, 법원은 해당 처분이 무효라고 판단하였으나 A는 공공복리에 중대한 지장이 초래된다는 이유로 사정판결을 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 취소소송의 특유한 제도인 사정판결 규정의 준용 가능 여부와 무효인 처분에 대한 사정판결의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 사정판결의 준용 여부 및 수용재결 무효에 대한 사정판결 가능 여부를 검토한다.

II. 사정판결의 의의 및 근거

1. 의의

- 사정판결이란 원고의 청구가 이유 있다고 인정되어 처분 등이 위법함에도 불구하고, 그 처분 등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에 법원이 원고의 청구를 기각하는 판결을 말한다. 이는 사법 국가 원칙에 대한 예외로서 공익과 사익의 조화를 도모하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- "행정소송법 제28조 제1항"은 취소소송에 관하여 사정판결을 명시하고 있다. 무효확인소송의 경우에는 "동법 제38조 제1항"에서 "제28조"를 준용하는 규정을 두고 있지 않아, 그 허용 여부가 해석상 논란이 된다.

III. 무효확인소송에서 사정판결 준용 여부에 관한 논의

1. 학설의 대립

(1) 준용 긍정설

- 무효인 처분이라 하더라도 이를 무효로 확정할 경우 공공복리에 중대한 지장을 초래할 수 있는 사정은 취소소송과 다를 바 없으므로, "행정소송법 제8조 제2항"에 의해 민사소송법이나 일반 원칙을 적용하거나 유추 준용하여 사정판결을 인정해야 한다는 견해이다.

(2) 준용 부정설(다수설)

- "행정소송법 제38조 제1항"이 준용 규정에서 "제28조"를 제외하고 있는 것은 입법자의 결단으로 보아야 한다. 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없는 것으로서 외형상 존재함으로 인한 공익적 사정보다 법치주의의 확립이 우선되어야 한다는 점을 근거로 한다.

2. 대법원 판례의 입장

- "대법원"은 일관되게 무효확인소송에서 사정판결을 부정하고 있다. "판례"는 "행정소송법 제38조 제1항"이 "제28조"를 준용하고 있지 아니함에 비추어 볼 때, 행정처분이 당연무효인 경우에는 사정판결을 할 수 없다고 명시적으로 판시하였다. 즉, 하자가 중대하고 명백하여 당연무효인 처분은 사정판결의 대상이 될 수 없다는 것이 확립된 태도이다.

IV. 사안의 적용

1. 수용재결의 성격과 하자의 정도

- 사안에서 법원은 수용재결에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 판단하였다. 당연무효인 처분은 법적 효력이 발생하지 않는 것이 원칙이므로, 그 처분에 기하여 진행된 공사 등의 외형적 결과가 존재하더라도 원칙적으로 법적 보호를 받기 어렵다.

2. 사정판결의 가능성 검토

- 행정청 A는 공사 진행률 90%, 예산 낭비, 교통 혼란 등의 공익적 사유를 들어 사정판결을 주장한다. 그러나 "대법원 판례"의 견해에 의하면 무효확인소송에서는 "행정소송법 제28조"가 준용되지 않으므로 법원은 사정판결을 내릴 수 없다. 하자가 무효 사유에 해당하는 이상, 설령 공익상 중대한 지장이 예상된다 하더라도 법원은 당해 수용재결이 무효임을 확인하는 판결을 내려야 한다.

V. 결론

- 무효확인소송에서 사정판결의 인정 여부에 대하여 학설은 대립하나, "대법원 판례"는 행정소송법상 준용 규정의 부재를 근거로 이를 엄격히 부정하고 있다. 사안의 경우 수용재결에 중대하고 명백한 하자가 있어 무효로 판단된 이상, 행정청 A가 주장하는 공공복리상의 사유가 존재하더라도 법원은 사정판결을 내릴 수 없으며 甲의 청구를 인용하여 무효를 확인하여야 한다. 이러한 법리는 무효인 행정행위에 대해서는 공익을 이유로 한 예외를 허용하지 않으므로써 국민의 기본권을 철저히 보호하고 행정의 적법성을 담보하려는 사법부의 의지를 반영한다. 다만, 이로 인해 발생하는 현실적인 공익 침해 문제는 수용재결의 재시행이나 손실보상 등 별도의 절차를 통해 해결되어야 할 과제로 남는다.

《【문제9.4】

<사례>

행정청 A는 관내 도로 확장 공사를 위해 甲 소유의 토지에 대하여 수용재결을 내렸고, 현재 공사는 90% 이상 진행되어 도로의 외형이 갖춰진 상태이다. 甲은 해당 수용재결의 절차상 중대한 하자가 존재하여 `당연무효`라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 심리 결과 법원은 수용재결에 실제로 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당한다고 판단하였다. 그러나 행정청 A는 공사가 거의 완료된 시점에서 수용재결이 무효로 확정될 경우 이미 투입된 막대한 예산이 낭비되고 교통 혼란이 야기되는 등 공공복리에 중대한 지장을 초래할 것이라며 `사정판결`을 내려달라고 주장한다. 한편, 甲은 소송에서 승소할 경우 해당 판결의 효력이 처분청인 A 외에 다른 국가기관에도 미치는지 궁금해하고 있다.

(물음2) 무효확인판결이 확정되었을 때 발생하는 판결의 효력 중 `제3자효`와 `기속력`의 의미를 설명하고, 특히 기속력의 내용 중 행정청의 `재처분의무`가 무효확인소송에서도 인정되는지 기술하라.》

<문제9.4의 물음2> 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 의미 및 재처분의무의 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 수용재결 무효확인소송에서 승소할 경우 판결의 효력이 처분청 A 외의 다른 국가기관에도 미치는지와 행정청의 후속 의무에 대해 궁금해하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인판결의 효력 중 제3자효와 기속력의 의미 및 무효확인소송에서도 기속력에 따른 행정청의 재처분의무가 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인판결의 제3자효와 기속력의 내용 및 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부를 기술한다.

II. 무효확인판결의 제3자효(대세효)

1. 의의

- 제3자효란 처분 등을 무효로 하는 판결의 효력이 소송 당사자인 원고와 피고 행정청뿐만 아니라 제3자에 대하여도 미치는 효력을 의미한다. "행정소송법 제38조 제1항"은 "제12조 제3항"(제3자효)을 무효확인소송에 준용하고 있다.

2. 내용 및 취지

- 제3자효가 인정됨에 따라 무효확인판결이 확정되면 누구든지 해당 처분이 무효임을 전제로 행동해야 하며, 다른 국가기관이나 법원도 그 처분의 무효를 전제로 판단해야 한다. 이는 행정법관계의 확실적 확정을 기하고 판결의 실효성을 높이기 위한 것이다. 甲의 경우 승소 판결이 확정되면 처분청 A 뿐만 아니라 다른 모든 국가기관에 대해서도 해당 수용재결이 무효임을 주장할 수 있다.

III. 무효확인판결의 기속력

1. 의의

- 기속력이란 처분 등을 무효로 하는 판결이 확정된 경우 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동해야 하는 구속력을 말한다. "행정소송법 제38조 제1항"은 "제30조"(기속력)를 준용하고 있다.

2. 기속력의 내용

(1) 반복금지의무

- 행정청은 판결에서 무효로 확인된 처분과 동일한 사유에 근거하여 동일한 내용의 처분을 반복해서는 안 되는 의무를 진다.

(2) 원상회복의무(결과제거의무)

- 행정청은 무효인 처분에 의하여 초래된 위법한 상태를 제거하고 처분 전의 상태로 되돌려 놓아야 할 의무를 진다. 사안에서 수용재결이 무효로 확인되면 행정청 A는 원칙적으로 토지 소유권을 甲에게 반환하는 등 위법한 결과를 제거해야 한다.

IV. 무효확인소송에서의 재처분의무 인정 여부

1. 문제의 소재

- "행정소송법 제30조 제2항"은 신청에 따른 처분이 절차상 하자 등을 이유로 취소된 경우 행정청에 재처분의무를 부과하고 있다. 무효확인소송의 준용 규정인 제38조 제1항이 제30조 제2항을 명시적으로 포함하고 있는지, 그리고 거부처분이 무효인 경우에도 재처분의무가 당연히 인정되는지가 쟁점이다.

2. 법적 근거의 검토

(1) 행정소송법 개정 전후의 상황

- 과거 "행정소송법 제38조 제1항"은 "제30조 제2항"(재처분의무)을 준용 규정에서 누락하고 있었다. 이로 인해 거부처분 무효확인판결이 확정되더라도 행정청에 재처분의무가 있는지에 대해 학설상의 다툼이 있었다.

(2) 현행법의 태도

- 2014년 행정소송법 개정을 통해 "제38조 제1항"에 "제30조 제2항"이 명시적으로 포함되었다. 따라서 현재는 거부처분이 무효로 확인된 경우에도 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 처분을 해야 할 법적 의무를 진다.

3. 수용재결 사안에의 적용

- 사안의 수용재결은 행정청이 일방적으로 내리는 형성적 행위이지만, 넓게 보면 도로 공사라는 공익사업을 위한 절차이다. 수용재결이 무효로 확정되면 행정청 A는 기속력에 따라 위법 사유를 보완하여 적법한 절차를 다시 밟거나(재처분의무의 준하는 행위), 무효인 재결에 기초한 점유를 해소해야 한다.

V. 사안의 적용

1. 제3자효의 적용

- 甲이 무효확인소송에서 승소하면 그 판결의 효력은 제3자효(대세효)에 의해 처분청 A 외에 토지 수용과 관련된 다른 행정기관이나 등기소 등 모든 국가기관에 미친다. 따라서 甲은 판결문을 근거로 수용재결의 효력이 없음을 누구에게나 주장할 수 있다.

2. 기속력과 재처분의무의 발동

- 판결이 확정되면 행정청 A는 기속력을 받는다. 사안의 수용재결이 무효로 확인된 이상 행정청 A는 해당 재결이 유효함을 전제로 공사를 계속하거나 토지를 점유할 수 없다. 또한 개정 행정소송법에 따라 재처분의무 규정이 준용되므로, 행정청 A가 공사를 계속 진행하고자 한다면 판결에서 지적된 중대·명백한 하자를 시정한 후 적법하게 다시 수용 절차를 밟아야 한다.

Ⅵ. 결론

- 무효확인판결은 취소판결과 마찬가지로 제3자효와 기속력이 인정된다. 따라서 甲은 판결의 효력을 다른 국가기관에도 주장할 수 있으며, 피고 행정청 A는 판결의 취지에 따라 행동해야 할 의무를 진다. 특히 현행 행정소송법은 무효확인소송에서도 재처분의무를 명시적으로 인정하고 있으므로, 행정청 A는 무효인 수용재결을 방지해서는 안 되며 판결에 따른 적법한 후속 조치를 취해야 한다. 이러한 법리는 행정처분이 무효인 경우 판결의 실효성을 확보하여 국민의 권익을 구체적으로 구제하고, 행정의 적법성을 회복하도록 강제하는 데 그 의의가 있다.

《[문제2] 건축사업자 甲은 X시장으로부터 건축허가를 받아 건물의 신축공사를 진행하던 중 건축법령상의 의무위반을 이유로 X시장으로부터 공사중지 명령을 받았다. 甲은 해당 법령의무위반을 하지 않았다고 판단하고, 공사중지명령처분의 위법하다고 주장하며 공사중지명령처분의 무효확인소송을 제기하였다. 법원은 사건의 심리결과 해당 처분에 `중대한` 위법이 있음이 인정되지만 `명백한` 위법은 아닌 것으로 판단하였다. 법원은 어떠한 판단을 내려야 하는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 공사중지명령의 무효확인을 구하는 소송에서 심리 결과 취소사유만 인정되는 경우 법원의 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 건축사업자 甲이 건축법령상 의무위반을 이유로 받은 공사중지명령처분에 대하여 무효확인소송을 제기하였고, 법원은 해당 처분에 중대한 위법은 있으나 명백한 위법은 없다고 판단하는 상황이다. 쟁점으로 <행정처분의 무효확인을 구하기 위한 중대성 및 명백성 요건 중 명백성 요건이 충족되지 않은 경우 법원이 어떠한 판단을 하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 처분의 무효 판단 기준과 중대·명백성 요건의 충족 여부에 따른 법원의 판단에 대해 설명한다.

II. 무효확인소송과 취소사유인 하자의 관계에 관한 법리

1. 하자의 정도와 처분의 효력

(1) 당연무효와 취소사유의 구별 기준 (중대·명백설)

- 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 처분에 존재하는 하자가 헌법이나 법률의 중요 규정을 위반한 것으로서 객관적으로 중대할 뿐만 아니라, 외관상 일견하여 누구나 명백하게 인식할 수 있어야 한다.

(2) 명백성 결여와 취소사유의 성격

- 하자가 객관적으로 중대하다고 하더라도 외관상 명백하지 않은 경우에는 처분은 당연무효가 되지 않고 단순한 취소사유에 그친다. 이러한 단순 취소사유인 처분은 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지는 공정력(구성요건적 효력)에 의하여 원칙적으로 유효한 처분으로 취급된다.

2. 무효확인소송에서 취소판결 선고의 가부

(1) 취소 청구 포함의 법리 (소의 포함 관계)

- 원고가 처분의 무효확인을 구하는 소송을 제기한 경우, 특별한 사정이 없는 한 처분의 무효확인을 구하는 청구 취지 중에는 처분이 당연무효가 아니라면 취소라도 해달라는 취소를 구하는 취지가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석하는 것이 합리적이다.

(2) 취소소송 소송요건 구비 여부에 따른 사법적 처리

- “대법원 판례”에 따르면 처분의 당연무효를 구하는 소에 취소소송의 소송요건(특히 제소기간 및 행정심판 전치주의 등)이 모두 구비되어 있다면, 법원은 무효 청구를 기각하는 대신 처분을 취소하는 취소판결을 내려야 한다. 반면, 제소기간 도과 등 취소소송의 소송요건을 갖추지 못하였다면 법원은 예외적으로 취소판결을 내릴 수 없으므로 무효 청구를 물리치는 기각판결을 내려야 한다.

III. 사안의 적용

1. 공사중지명령 하자의 법적 성격

(1) 하자의 중대성 인정과 명백성 흠결

- 사안의 공사중지명령은 심리 결과 중대한 위법은 존재하지만 명백한 위법은 존재하지 않는 상태이다. 따라서 하자의 중대·명백설에 의할 때, X시장의 처분은 당연무효에 해당하지 않는다.

(2) 단순 취소사유로의 확정

- 따라서 사안의 공사중지명령에 존재하는 하자는 단순 취소사유에 불과하므로, 처분 자체는 공정력을 가져 취소판결로 제거되기 전까지는 유효한 처분으로 유지된다.

2. 법원의 구체적 판결 방향

(1) 취소소송의 소송요건을 충족한 경우

- 만약 甲이 무효확인소송을 제기할 당시에 취소소송의 제소기간(처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있는 날부터 1년 이내)을 적법하게 준수하였고 기타 필요적 행정심판전치주의 등의 요건을 충족하였다면, 법원은 소의 포함 관계를 인정하여 공사중지명령을 취소하는 취소판결을 선고하여야 한다.

(2) 취소소송의 소송요건을 결여한 경우

- 만약 甲이 소를 제기한 시점이 이미 처분이 있음을 안 날부터 90일을 도과하는 등 취소소송의 제소요건을 흠결한 상태였다면 법원은 하자가 단순 취소사유에 불과하더라도 취소판결을 내릴 수 없다. 또한 처분이 당연무효도 아니므로 무효확인 청구의 이유가 없어 법원은 甲의 청구를 물리치는 기각판결을 선고하여야 한다.

IV. 결론

- X시장의 공사중지명령은 중대하나 명백하지 않은 하자가 존재하므로 당연무효가 아닌 단순 취소사유에 해당한다. 무효확인소송에는 특별한 사정이 없는 한 취소소송의 청구가 포함되어 있으므로, 수소법원은 소송요건의 구비 여부를 개별적·독립적으로 심사하여야 한다. 결론적으로 수소법원은 당해 무효확인소송이 취소소송의 제소기간 등 소송요건을 갖추었을 때에는 공사중지명령을 취소하는 취소판결을 선고하여야 하고, 만약 취소소송의 소송요건을 흠결하였을 때에는 당연무효가 인정되지 않으므로 기각판결을 선고하여야 한다.

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 `토양환경보전법` 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음1) 무효확인소송에서 행정소송법 제23조의 `집행정지` 규정이 준용되는지 여부를 밝히고, 무효확인소송에서의 집행정지 요건 중 `회복하기 어려운 손해`의 의미에 대하여 취소소송과 비교하여 서술하라.》

<문제9.6의 물음1> 무효확인소송에서 집행정지 규정의 준용 여부와 회복하기 어려운 손해의 의미

I 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲의 공장에 대하여 사용중지 명령을 하였고, 甲은 해당 처분의 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지시키기 위한 가구제 수단을 모색하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서도 취소소송과 마찬가지로 행정소송법상 집행정지 규정이 준용되는지 여부와 집행정지 요건인 회복하기 어려운 손해의 의미>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서의 집행정지 인정 여부와 회복하기 어려운 손해의 판단 기준을 취소소송과 비교하여 서술한다.

II 무효확인소송에서 집행정지의 준용 여부

1. 의의

- 집행정지는 처분의 집행이나 효력의 발생을 잠정적으로 멈추어 원고의 권리를 보호하는 가구제 수단이다. 무효확인소송은 처분의 효력이 존재하지 않음을 전제로 하지만, 외형상 처분이 존재하는 이상 그로 인한 집행을 위험을 차단할 필요가 있다.

2. 법적 근거 및 견해의 대립

(1) 긍정설 및 행정소송법의 태도

- 현행 "행정소송법 제38조 제1항"은 "제23조"를 명시적으로 준용하고 있다. 무효인 처분이라도 처분의 외형이 남아 있어 집행력이 행사될 가능성이 있으므로, 국민의 권리 보호를 위해 집행정지를 인정해야 한다는 취지이다.

(2) 부정설

- 무효인 처분은 처음부터 아무런 효력이 없으므로 정지할 효력 자체가 존재하지 않는다는 논리이다. 즉, 관념적으로 존재하지 않는 효력을 정지한다는 것은 논리적으로 모순이라는 견해이다.

(3) 판례의 입장

- "대법원"은 행정소송법의 준용 규정에 따라 무효확인소송에서도 집행정지가 허용된다는 점을 명확히 하고 있다. 다만, 무효확인소송에서의 집행정지는 취소소송과 비교하여 그 요건인 손해의 성격에 대하여 다소 엄격하게 해석될 여지가 있다.

III 집행정지 요건 중 회복하기 어려운 손해의 의미

1. 취소소송에서의 의미

(1) 개념의 확장

- 과거에는 금전 보상이 불가능한 손해만을 의미했으나, 현대적 "판례"는 금전 보상이 가능하더라도 사회통념상 원고가 참고 견디기 어렵거나 원상회복이 현저히 곤란한 경우를 포함하는 광의의 개념으로 해석한다.

(2) 구체적 판단 기준

- 사업의 중단으로 인한 막대한 경제적 손실, 기업 이미지의 실추, 파산의 위기 등 원고의 법적 지위에 심대한 타격을 줄 우려가 있는 경우 회복하기 어려운 손해로 인정된다.

2. 무효확인소송에서의 의미 및 비교

(1) 논리적 차이

- 무효인 처분은 처분 그 자체로 효력이 없으므로, 원고는 처분을 무시하고 행동할 수도 있다. 그러나 사실상의 강제집행이 예정되어 있거나 외형상 처분으로 인해 법률관계가 극도로 불안정해지는 경우 가구제의 필요성이 발생한다.

(2) 판례의 독특한 입장

- "대법원"은 무효확인청구의 소에는 처분의 효력 정지를 구할 법률상 이익이 있어야 한다고 판시하면서, 만약 처분의 효력을 정지하지 않더라도 처분이 당연무효임을 주장하여 민사소송 등 다른 방법으로 손해를 충분히 구제받을 수 있다면 집행정지의 필요성을 부정적으로 보는 경향이 있다.

(3) 비교 요약

- 취소소송에서는 처분의 공정력 때문에 일단 따라야 하는 의무가 발생하므로 손해의 범위를 넓게 보지만, 무효확인소송에서는 처분에 공정력이 없으므로 오직 실행력이 행사되어 실제로 권리가 침해될 긴급한 사정이 있는 경우에 한하여 보다 엄격하게 해석되는 측면이 있다.

IV 사안의 적용

1. 집행정지의 준용 및 신청

- 사안에서 행정청 A의 사용중지 명령은 무효확인소송의 대상이며, "행정소송법 제38조 제1항"에 따라 "제23조" 집행정지 규정이 준용된다. 따라서 甲은 공장 가동 중단이라는 위기에 대응하기 위해 집행정지를 신청할 수 있다.

2. 회복하기 어려운 손해의 존부

- 甲은 공장 가동 중단 시 거래처와의 계약 위반 및 막대한 손해 발생을 주장하고 있다. 이는 단순히 금전으로 보상될 수 있는 범위를 넘어 기업의 존립을 위협하거나 거래 질서를 파괴할 우려가 있는 경우에 해당한다. 비록 무효확인소송에서 손해의 요건을 비교적 엄격히 보더라도, 사용중지 명령이라는 직접적인 강제력이 수반되는 처분의 경우 회복하기 어려운 손해 및 긴급한 필요가 인정될 가능성이 높다.

V. 결론

- 무효확인소송에서도 행정소송법의 준용 규정에 따라 집행정지 제도가 인정된다. 이는 처분의 무효 여부와 상관없이 사실상의 집행력을 차단하여 국민을 보호하기 위함이다. 집행정지의 요건인 회복하기 어려운 손해는 취소소송과 마찬가지로 원상회복이나 금전 보상이 극도로 곤란한 경우를 의미하나, 무효인 처분은 원칙적으로 효력이 없다는 특수성 때문에 실제 집행 가능성이 구체적으로 증명되어야 한다는 점이 취소소송과의 실무적 차이점이다. 사안의 甲은 공장 중단으로 인한 파괴적 손해를 소명함으로써 가구제를 받을 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 법리는 무효인 행정행위의 외형이 가져오는 법적 혼란을 잠정적으로 해소하고, 본안 판결 전까지 신청인의 권익을 실효적으로 보전하는 데 기여한다.

《【문제9.6】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 공장에 대하여 `토양환경보전법` 위반을 사유로 사용중지 명령을 내렸다. 甲은 해당 처분이 처분 권한이 없는 자에 의해 행해진 것으로서 중대하고 명백한 하자가 있어 당연히무효라고 주장하며 무효확인소송을 제기하였다. 소송 계속 중 甲은 공장 가동이 중단될 경우 거래처와의 계약 위반으로 인해 회복하기 어려운 막대한 손해가 발생할 것을 우려하여, 판결 확정 시까지 처분의 효력을 멈춰달라는 가구제 수단을 강구하고 있다. 한편, 인근 주민 乙은 행정청 A가 甲에게 내린 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서, 행정청 A가 향후 해당 부지에 대하여 내릴지도 모를 다른 완화된 처분을 미리 금지해달라는 가처분을 신청하고자 한다.

(물음2) 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 관한 판례의 입장을 기술하고, 乙이 신청하려는 예방적 금지 성격의 가처분이 허용되는지 답하라.》

<문제9.6의 물음2> 무효확인소송에서 가처분의 준용 여부와 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 사용중지 명령처분에 대한 무효확인소송을 제기하면서 처분의 효력을 정지하기 위한 가구제 수단을 모색하고, 乙은 행정청 A의 장래 처분을 금지하기 위한 예방적 가처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 가능 여부와 행정청의 장래 처분을 사전에 금지하는 예방적 금지 가처분의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 가처분 준용에 관한 판례의 입장과 예방적 금지 가처분의 인정 여부에 대해 답한다.

II. 무효확인소송에서 민사소송법상 가처분 규정의 준용 여부

1. 판례의 일반적인 태도

(1) 항고소송에서의 부정

- “대법원”은 취소소송이나 무효확인소송과 같은 항고소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 없다는 입장을 확고히 하고 있다. “판례”는 “행정소송법 제23조”에서 규정하고 있는 집행정지 제도가 민사소송법상 가처분에 대한 특칙이라고 본다.

(2) 부정의 근거

- 항고소송은 행정청의 처분을 대상으로 하는 소송이므로, 사법부가 가처분을 통해 행정청의 행위를 미리 금지하거나 임시 지위를 설정하는 것은 권력분립의 원칙에 반하고 행정권의 1차적 판단권을 침해할 우려가 있다는 점을 주된 근거로 삼는다.

2. 당사자소송과의 비교

- “대법원”은 국가를 상대로 하는 당사자소송에서는 “행정소송법 제44조 제1항”이 집행정지 규정을 준용하지 않고 있다는 점을 근거로 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있다고 판시하여 항고소송과 구분하고 있다. 그러나 사안의 乙이 제기하는 소송은 항고소송인 무효확인소송이므로 위 부정설의 법리가 적용된다.

III. 예방적 금지 성격의 가처분 허용 여부

1. 예방적 금지소송과 가처분

- 예방적 금지소송이란 행정청이 특정한 처분을 하지 못하도록 미리 구하는 소송이다. 乙이 신청하려는 가처분은 본안소송으로서 예방적 금지소송이 인정됨을 전제로 그 가구제 수단으로서 기능을 한다.

2. 판례의 입장

(1) 본안소송의 부적법성

- “대법원”은 예방적 금지소송을 현행 행정소송법상 허용되지 않는 무명항고소송으로 본다. “판례”는 행정청이 장래에 내릴 처분을 미리 법원이 금지하는 것은 행정권에 대한 사법권의 지나친 간섭이라고 판단하여 이를 부적법 각하한다.

(2) 가처분의 불허

- 본안소송인 예방적 금지소송 자체가 허용되지 않으므로, 그에 부수하는 가구제 수단으로서의 예방적 금지 가처분 역시 허용될 수 없다. “판례”는 처분의 효력 발생 이후에 집행정지 등을 통해 다루는 것 외에, 장래의 처분을 미리 막는 가처분 형식의 권리구제는 인정하지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 무효확인소송과 가처분 신청

- 乙은 사용중지 명령에 대하여 무효확인소송을 제기하면서 가처분을 신청하였다. 그러나 앞서 살펴본 “판례”의 태도에 따르면 무효확인소송과 같은 항고소송에서는 민사소송법상의 가처분 규정이 준용되지 않는다.

2. 예방적 금지 가처분의 적법성 검토

- 乙이 구하는 향후 내릴지도 모를 완화된 처분을 미리 금지해달라는 신청은 전형적인 예방적 금지 성격의 가처분이다. 우리 “판례”는 예방적 금지소송 자체를 부정할 뿐만 아니라 항고소송에서의 가처분 준용도 부정하고 있으므로, 乙의 가처분 신청은 법적 근거가 없어 부적법 각하될 것이다. 乙은 실제 처분이 내려진 이후에 그 처분에 대하여 다시 무효확인소송이나 취소소송을 제기하고 집행정지를 신청하는 방식으로 대응해야 한다.

V. 결론

- 무효확인소송에서 민사소송법상의 가처분 규정이 준용될 수 있는지에 대하여 “대법원”은 “행정소송법 제23조”의 집행정지 규정이 특칙으로서 존재한다는 점과 권력분립 원칙을 근거로 이를 명백히 부정하고 있다. 특히 乙이 신청하고자 하는 예방적 금지 성격의 가처분은 본안소송인 예방적 금지소송의 허용 여부와 직결되는데, “판례”는 법문에 명시되지 않은 무명항고소송과 그에 따른 가처분을 일체 인정하지 않는다. 따라서 乙의 가처분 신청은 허용되지 않는다. 이러한 법리는 사법부가 행정청의 처분 권한을 사전에 제약하는 것을 극도로 경계하는 태도를 보여주며, 국민의 가구제 수단이 사후적 수단인 집행정지에 한정되어 있다는 현행 행정쟁송법 체계의 한계를 나타낸다.

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-1]무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 `압류처분`을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음1) 甲이 제기하려는 `무효확인청구와 취소청구의 병합`이 허용되는지 여부와 관련하여, 두 청구의 관계(주위적·예비적 병합 vs 단순 병합)에 따른 판례의 입장을 기술하라.》

<문제9.7의 물음1> 무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 압류처분의 하자가 무효사유인지 취소사유인지 불확실한 상황에서 무효확인청구와 취소청구를 함께 제기하려 하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인청구와 취소청구의 병합 가능 여부와 관련하여 주위적·예비적 병합 및 단순 병합의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인청구와 취소청구의 관계에 따른 병합 형태별 허용 여부를 기술한다.

II. 행정소송상 관련 청구의 병합

1. 병합의 의의 및 근거

- 병합이란 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 동시에 제기하거나 기존 소송에 다른 청구를 추가하는 것을 말한다. “행정소송법 제10조”는 소송의 효율성을 높이고 관련 분쟁을 일회적으로 해결하기 위해 관련 청구소송의 병합을 허용하고 있다.

2. 병합의 형태

(1) 단순 병합

- 여러 개의 청구를 병렬적으로 제기하여 법원이 모두에 대하여 심판을 하도록 하는 형태이다. 청구 상호 간에 양립이 가능한 경우에 주로 활용된다.

(2) 선택적 병합

- 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판할 필요가 없는 형태이다. 청구 상호 간에 양립할 수 없는 관계에 있을 때 사용된다.

(3) 주위적·예비적 병합

- 주위적 청구가 기각될 것을 대비하여 예비적 청구를 제기하는 형태이다. 법원은 주위적 청구가 이유 없을 때에만 비로소 예비적 청구를 심리한다.

III. 무효확인청구와 취소청구의 병합에 관한 판례의 입장

1. 주위적·예비적 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- “대법원”은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 주위적·예비적 병합의 형태로 제기하는 것을 명시적으로 허용하고 있다. “판례”는 무효확인소송과 취소소송은 소송물인 처분의 위법성이라는 기초는 동일하지만, 하자의 정도에 따라 양립할 수 없는 관계에 있다고 본다.

(2) 심리 방식

- 법원은 주위적 청구인 무효확인청구를 먼저 심리하여 그 하자가 중대하고 명백하여 무효라고 인정되면 예비적 청구인 취소청구에 대해서는 판단하지 않는다. 만약 하자가 존재하지만 무효 사유에는 이르지 않는 취소 사유에 불과하다고 판단될 때 비로소 예비적 청구를 심리하여 처분을 취소하게 된다.

2. 단순 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- “대법원”은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 단순 병합의 형태로 제기하는 것은 허용되지 않는다고 판시한다. “판례”는 양청구가 동일한 행정처분을 대상으로 하는 경우, 그 하자가 무효 사유이거나 취소 사유인 것 중 하나일 수밖에 없으므로 양립 불가능한 관계라고 판단하기 때문이다.

(2) 부적법 판정의 근거

- 만약 단순 병합으로 제기되었다 하더라도 법원은 이를 주위적·예비적 병합으로 보아 심리하거나, 병합의 형태를 명확히 하도록 설명권을 행사해야 한다. 무효와 취소를 동시에 선택적으로 청구하는 것은 청구의 취지가 모순되어 허용되지 않는다는 것이 “판례”의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 병합 신청의 적법성

- 사안의 甲은 주위적으로 무효확인을, 예비적으로 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이는 “판례”가 허용하는 전형적인 주위적·예비적 병합의 형태이다. 따라서 甲의 소 제기는 적법한 병합으로 인정될 수 있다.

2. 법원의 심리 방향

- 법원은 우선 압류처분의 하자가 중대하고 명백한지 심리한다. 만약 하자가 중대·명백하여 당연무효라면 무효확인판결을 내리고 소송을 종료한다. 그러나 하자가 중대·명백하지는 않으나 위법함이 인정된다면 예비적 청구인 취소소송의 요건(제소기간 등)을 검토한 후 취소판결을 내리게 된다.

V. 결론

- 동일한 처분에 대하여 무효확인을 구하는 청구와 취소를 구하는 청구는 성질상 양립할 수 없는 관계에 있다. “대법원”은 이러한 관계를 고려하여 두 청구의 단순 병합이나 선택적 병합은 허용하지 않으나, 주위적·예비적 병합의 형태는 국민의 권리구제 범위를 넓히기 위해 적법한 것으로 인정하고 있

다. 이러한 법리는 원고가 하자의 정도를 정확히 판단하기 어려운 실무적 상황을 배려하여 소송 경제와 실효적 권리구제를 동시에 달성하려는 행정쟁송 법상의 배려를 반영하고 있다.

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-2]무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 `압류처분`을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음2) 乙이 `무효확인소송`을 `취소소송`으로 변경하고자 할 때, 소 변경의 요건 중 하나인 `제소기간의 준수 여부`를 판단하는 기준 시점에 대하여 행정소송법 규정을 근거로 설명하라.》

<문제9.7의 물음2> 무효확인소송에서 취소소송으로의 변경 시 제소기간 준수의 기준 시점

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 영업정지 처분에 대한 무효확인소송을 제기한 후 해당 처분이 취소사유에 해당함을 이유로 취소소송으로 소를 변경하려 하나, 변경 시점에는 취소소송의 제소기간이 도과한 상황이다. 쟁점으로 <소의 종류 변경 시 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점이 최초 소 제기 시인지 변경 신청 시인지 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정소송법상 소의 변경 규정에 따른 제소기간 준수 여부의 판단 기준 시점을 설명한다.

II. 소의 종류의 변경의 의의 및 요건

1. 의의

- 소의 종류의 변경이란 원고가 청구의 기초에 변경이 없는 한 소송의 계속 중에 소의 종류를 항고소송 상호 간 또는 항고소송과 당사자소송 간에 변경하는 것을 말한다. 乙의 경우 무효확인소송이라는 항고소송을 취소소송이라는 다른 항고소송으로 변경하는 경우에 해당한다.

2. 일반적 요건

(1) 소의 계속과 사실심 변론종결 전

- 구소인 무효확인소송이 법원에 적법하게 계속되어 있어야 하며, 소의 변경 신청은 항소심을 포함한 사실심의 변론종결 전까지 이루어져야 한다.

(2) 청구의 기초의 동일성

- 구소와 신소의 청구 원인이 되는 기초적 사실관계가 동일해야 한다. 영업정지 처분이라는 동일한 행정작용을 대상으로 하므로 이 요건은 충족된다.

(3) 법원의 허가 및 피고의 의견 청취

- 법원은 소의 변경이 상당하다고 인정할 때 결정으로써 이를 허가하며, 이때 피고의 의견을 들어야 한다.

III. 제소기간의 준수 여부와 기준 시점

1. 행정소송법의 규정 근거

- "행정소송법 제21조 제4항"은 소의 종류의 변경이 있는 경우 "제14조 제4항" 및 "제5항"의 규정을 준용하도록 하고 있다. 준용되는 "제14조 제4항"은 피고경정 시의 제소기간에 관한 규정으로, 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 때에는 처음에 소를 제기한 때에 소가 제기된 것으로 본다"고 명시하고 있다.

2. 소급효의 인정

- 위 규정에 따라 乙이 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 신청을 하고 법원이 이를 허가한 경우, 신소인 취소소송은 소를 변경한 시점이 아니라 처음에 무효확인소송을 제기한 시점에 제기된 것으로 간주된다. 이를 소의 변경에 따른 소급효라고 한다.

3. 무효확인소송 제기 당시의 제소기간 준수 필요성

- 다만, 이러한 소급효가 인정되기 위해서는 구소인 무효확인소송 자체가 취소소송의 제소기간(처분이 있음을 안 날로부터 90일 등) 내에 제기되었어야 한다. 만약 처음부터 취소소송의 제소기간을 도과하여 무효확인소송을 제기했다가 나중에 취소소송으로 변경하는 경우에는 소급효를 인정하더라도 신소인 취소소송은 제소기간 도과로 부적법하게 된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소 변경 신청 기한

- 사안에서 乙은 소송 심리 중에 소를 변경하고자 하므로 사실심 변론종결 전이라는 시간적 요건을 갖추었다. 乙이 소 변경을 신청하면 법원은 청구의 기초가 동일한지를 판단하여 허가 여부를 결정하게 된다.

2. 제소기간 준수 여부의 판단

- 乙이 소를 변경하려는 현재 시점은 비록 취소소송의 제소기간이 지났으나, "행정소송법 제21조 제4항"에 의해 소급효가 인정된다. 따라서 乙이 처음에 무효확인소송을 접수했을 당시가 영업정지 처분에 대한 취소소송 제소기간 내였다면, 현재 변경된 취소소송은 적법하게 제소기간을 준수 것으로 인정된다.

V. 결론

- 무효확인소송을 취소소송으로 변경하는 경우, 신소의 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준 시점은 "행정소송법 제21조 제4항" 및 "제14조 제4항"에 의거하여 구소인 무효확인소송을 처음에 제기한 때이다. 乙이 무효확인소송을 취소소송의 제소기간 내에 제기했다면, 소 변경 시점에 이미 제소기간이 도과했더라도 소급효에 의해 신소인 취소소송은 적법하게 유지될 수 있다. 이러한 법리는 하자의 정도를 오인하여 소송의 종류를 잘못 선택한 원고에게 소급효를 부여함으로써 제소기간의 도과로 인한 불이익을 방지하고 실효적인 권리구제를 도모하는 데 그 취지가 있다.

《【문제1】 부작위 위법확인소송에 대해 논하시오. (50점)》

<문제1> 부작위위법확인소송의 의의, 특징, 소송요건, 판결의 효력

I. 문제 제기

- 부작위위법확인소송은 행정청의 위법한 부작위 상태를 확인하여 행정청에게 재처분 의무를 부과함으로써 국민의 권리 구제를 도모하는 것을 목적으로 하며, 그 법적 구조와 요건에 있어 다른 항고소송과 구별되는 특징을 가진다. 이하에서는 "행정소송법"상 항고소송 중 하나인 부작위위법확인소송에 대하여 그 의의, 특수한 법적 성격, 소송요건, 그리고 판결의 효력을 중심으로 상세히 논한다.

II. 부작위위법확인소송의 의의

- 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 부작위(不作爲)가 위법하다는 것을 확인하는 소송이다. ("행정소송법 제4조 제3호") 이는 행정청의 무응답 상태, 즉 침묵으로 인해 국민의 권리 침해가 발생하는 경우에 인정되는 구제 수단이다.

III. 부작위위법확인소송의 특징

- 부작위위법확인소송은 그 성격상 취소소송과는 다른 다음과 같은 특수성을 가진다.

1. 형식적 당사자소송성

- 이 소송은 외형상 행정청을 피고로 하는 항고소송에 해당하지만, 실질적으로는 행정청의 처분 의무 이행을 간접적으로 강제한다는 점에서 실질적인 당사자소송의 성격을 일부 가진다. 이는 행정청의 공법상 의무 이행을 다룬다는 점에서 당사자소송과 유사성을 띤다.

2. 간접적 권리 구제

- 이 소송은 부작위 상태에 대하여 위법성을 선언하는 확인소송의 성격을 가진다. 법원이 직접 처분을 하도록 명령하는 이행소송의 성격은 가지지 못하며, 단지 부작위의 위법성을 확인하여 행정청에 재처분 의무 ("행정소송법 제30조 준용")를 발생시켜 간접적으로 국민의 권리 구제를 도모한다.

3. 처분성을 요하지 않음

- 취소소송의 대상이 되는 것은 처분등이지만, 부작위위법확인소송의 대상은 행정청의 부작위(처분을 하지 아니한 상태) 그 자체이다. ("행정소송법 제2조 제1항 제2호") 따라서 대상적격 판단 시 부작위 자체에 처분성이 요구되지 않는다. 오히려 부작위는 처분이 부존재함을 전제로 한다.

IV. 부작위위법확인소송의 소송요건

- 부작위위법확인소송이 적법하게 제기되기 위해서는 다음과 같은 소송요건을 충족해야 한다.

1. 대상적격 (부작위의 존재)

(1) 의의

- 부작위위법확인소송의 대상적격은 행정청의 부작위가 법률상 정의된 요건을 충족하는 경우에 인정된다.

① 행정청의 처분 의무

- 부작위가 성립하기 위해서는 행정청이 당사자의 신청에 대하여 일정한 처분을 할 법률상 의무가 있어야 한다. 이 의무는 수익적 처분 의무뿐만 아니라, 침익적 처분 또는 확인적 처분을 할 의무까지 포함한다.

② 상당한 기간의 경과

- 신청에 대한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 발생한 후 상당한 기간이 경과했음에도 처분이 없어야 한다. 상당한 기간은 관련 법령의 처리 기간, 처분의 성질, 신청의 복잡성 등을 고려하여 사회 통념에 따라 개별적으로 판단된다.

③ 처분 부존재

- 신청에 대한 아무런 처분이 존재하지 않는 상태여야 한다. 만약 거부처분이 내려진 경우, 이는 부작위가 아닌 소극적 처분으로 간주되어 부작위 상태가 해소되고 취소소송의 대상이 된다.

(2) 판단 기준

① 법규상 신청권

- 처분 의무의 근거는 법규에서 도출되는 신청권이다. 관계 법령이 신청권자에게 처분을 요구할 수 있는 권리를 명시적으로 또는 묵시적으로 부여하고 있는 경우에 인정된다.

② 조리상 신청권

- 관계 법령에 명시적인 신청권 규정이 없더라도, 행정청의 처분이 국민의 법률상 지위에 불안정한 영향을 미치거나 공익상 필요한 경우 등 조리(條理)에 의해 신청권이 인정될 수 있다.

③ 재량행위의 부작위

- 재량행위의 경우에도 신청권이 인정될 수 있으며, 행정청이 재량을 행사하지 않고 무응답으로 일관하는 부작위는 위법확인 대상이 된다. 다만, 본안 심리 시에는 위법성 판단이 재량권 일탈·남용 여부가 아닌 재량권 행사의무 위반 여부에 초점을 맞춘다.

2. 원고적격

(1) 의의

- 부작위위법확인소송의 원고적격은 부작위로 인하여 법률상 이익을 침해당한 자에게 인정된다. ("행정소송법 제36조", "제12조" 준용)

(2) 판단 기준

- 원고적격이 인정되기 위해서는 부작위의 대상이 되는 신청된 처분에 대하여 신청인이 법률상 이익을 가지고 있어야 한다. 즉, 처분이 내려졌을 경우 그 처분으로 인해 법률상 이익을 얻거나 침해당할 가능성이 있는 자여야 하며, 단순한 사실상의 이익만으로는 부족하다.

3. 피고적격

- 부작위위법확인소송의 피고는 부작위의 주체인 행정청이다. ("행정소송법 제38조", "제13조" 준용) 이는 처분취소소송과 동일하게 대외적으로 처분 명의를 표시할 권한을 가진 행정기관의 장을 의미한다.

4. 협의의 소의 (권리보호의 필요)

(1) 의의

- 협의의 소익은 소송을 통해 부작위의 위법성을 확인받을 실질적인 이익이 있는지에 관한 요건이다. ("행정소송법 제36조", "제12조" 준용)

(2) 판단 기준

① 부작위 상태의 지속

- 소송 제기 이후에도 부작위 상태가 해소되지 않고 지속되어야 한다. 행정청이 소송 중 신청에 대한 거부처분이나 인용처분을 하는 경우 부작위 상태가 해소되므로 원칙적으로 소익이 소멸한다. 다만, 거부처분의 위법성을 다투기 위해서는 소의 종류를 취소소송으로 변경하여야 한다.

② 예외 (소의 이익 유지)

- 부작위 상태가 해소되어 처분이 내려진 경우에도, 그 처분이 위법하여 다시 부작위로 돌아가거나, 확인 판결을 통해 회복될 수 있는 법률상 이익이 남아 있는 경우에는 예외적으로 소익이 유지될 수 있다.

③ 처분을 할 수 있는 법률상 가능성

- 부작위위법확인소송은 행정청의 재처분 의무 이행을 목적으로 하므로, 소송 제기 시점 이후에도 행정청이 처분을 할 수 있는 법률상 가능성이 있어야 소익이 인정된다. 예를 들어, 신청의 대상이 되는 물건이 멸실된 경우 등은 소익이 부정될 수 있다.

5. 제소기간

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위가 계속되는 한 위법 상태가 지속되는 것으로 보아, 원칙적으로 취소소송과 같은 제소기간의 제한이 없다. ("행정소송법 제20조"는 부작위위법확인소송에 준용되지 않음)

(1) 행정심판을 거치지 아니한 경우

- 부작위는 계속되는 것이므로 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않는다고 보는 것이 타당하다.

(2) 행정심판을 거친 경우

- 행정심판을 거친 경우에는 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 제기해야 한다. ("행정소송법 제20조") 이는 불복 기간을 정함으로써 법적 안정성을 확보하기 위함이다.

6. 행정심판 전치주의

(1) 의의

- 부작위위법확인소송은 취소소송의 규정이 준용되지만, 그 대상이 부작위이므로 행정심판을 거치지 않고 소송을 제기하는 것이 원칙이다.

(2) 내용

- "행정소송법 제38조"에 따라 부작위위법확인소송에는 취소소송의 규정이 준용되지만, "제18조"(행정심판 전치)는 준용되지 않는다는 명시적인 규정은 없다. 그러나 부작위 상태에서는 행정심판의 의무적 전치주의가 적용되지 않는다는 것이 일반적인 견해이며, 법원의 태도이다. 다만, 개별 법률이 부작위에 대한 행정심판을 명시적으로 요구하는 경우에는 필요적 전치가 적용될 수 있다.

V. 부작위위법확인판결의 효력

1. 확인 효력

- 부작위위법확인판결은 행정청의 부작위 상태가 위법함을 확정하는 효력을 가진다. 이 효력은 부작위가 위법하다는 점에 대한 기판력을 발생시키며, 향후 동일한 부작위 상태에 대한 다툼을 차단한다.

2. 기속력

(1) 의의

- 부작위위법확인판결이 확정되면, 그 판결의 효력은 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다. ("행정소송법 제38조 제2항", "제30조 제1항" 준용) 이는 소송의 실효성을 담보하는 핵심적인 효력이다.

(2) 내용

- 행정청은 판결의 취지에 따라 재처분 의무를 부담하게 된다. 즉, 행정청은 지체 없이 판결의 취지에 따른 적법한 처분을 해야 한다. 이 재처분 의무는 행정청이 위법 사유를 제거하고 다시 처분을 해야 함을 의미하며, 반드시 신청을 인용해야 할 의무를 의미하는 것은 아니다.

(3) 실효성 확보

- 부작위위법확인판결의 실효성은 간접 강제 제도를 통해 확보된다. ("행정소송법 제34조") 행정청이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우, 법원은 당사자의 신청에 따라 배상금 지급을 명할 수 있으며, 이는 행정청의 처분을 간접적으로 강제하는 수단이 된다.

VI. 결론

- 부작위위법확인소송은 행정청의 부작위로 인한 국민의 권리 침해를 구제하기 위한 중요한 행정소송 유형이다. 그 소송요건으로는 행정청의 법률상 처분 의무와 상당한 기간 경과에도 불구하고 처분이 없는 부작위의 존재(대상적격), 법률상 이익 있는 자(원고적격), 부작위의 주체인 행정청(피고적격), 소의 이익, 그리고 필요적 행정심판 전치주의 준수 등이 있다. 부작위위법확인판결은 해당 부작위의 위법성을 확인하고 행정청에게 재처분 의무를 부과하며, 간접강제를 통해 그 실효성을 확보할 수 있다. 이는 적극적인 행정 작용을 이끌어내어 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 데 기여한다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[기출][2014-2]부작위위법확인소송에서의 부작위의 의의 및 성립요건

《[문제2] 부작위위법확인소송의 본안판단 요건으로서 부작위의 의의와 성립요건을 설명하시오. (25점)》

<문제2> 부작위위법확인소송에서의 부작위의 의의 및 성립요건

I. 문제 제기

- "행정소송법 제4조"는 항고소송의 유형으로서 취소소송, 무효등확인소송과 함께 부작위위법확인소송을 규정하고 있다. 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에도 불구하고 상당한 기간 내에 처분을 하지 않는 경우, 그 부작위가 위법함을 확인하는 소송이다. 이는 국민의 신청권을 실질적으로 보장하고, 행정의 소극적 태도로부터 권리를 보호하기 위한 중요한 제도이다. 그러나 부작위위법확인소송이 성립하기 위해서는 단순히 처분이 없다는 사실만으로는 부족하며, 법률상 일정한 요건을 충족해야 한다. 이하에서는 본 소송의 본안판단 요건으로서 부작위의 의의와 성립요건을 구체적으로 설명한다.

II. 부작위의 의의

- 부작위란 행정청이 국민의 신청에 대하여 응답해야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 상당한 기간 내에 아무런 처분을 하지 않는 상태를 의미한다. 이는 단순히 행정청의 소극적 태도와 구별된다. 즉, 법률상 응답의무가 없는 경우나, 사실상 준비단계에 불과한 미행위는 부작위에 해당하지 않는다. 따라서 부작위는 신청에 대한 응답의무가 존재함에도 이를 이행하지 않은 상태라는 점에서, 법률적·절차적 의미를 갖는다.

III. 부작위의 성립 요건

1. 행정청의 존재

- 부작위는 행정권 행사주체로서 권한 있는 행정청이 존재해야 한다. 권한 없는 기관의 불응이나 단순한 사실상 태만은 부작위의 대상이 될 수 없다.

2. 당사자의 신청 존재

- 부작위위법확인소송은 당사자의 신청을 전제로 한다. 이는 행정청이 법률상 또는 조리상 응답하여야 할 신청이어야 하며, 추상적 진정이나 단순 문의 등은 해당하지 않는다. 신청은 서면·구두를 불문하나, 법령에서 일정한 형식을 요구하는 경우 이를 갖추어야 한다.

3. 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무 존재

(1) 기속행위의 경우

- 법령에 따라 행정청이 일정한 요건을 충족하면 반드시 허가·인가 등 처분을 하여야 하는 경우, 신청에 대하여 행정청은 기속적으로 응답할 의무를 진다. 따라서 이 경우 응답하지 않는다면 곧바로 부작위가 성립한다.

(2) 재량행위의 경우

- 재량행위의 경우에도 일정한 범위 내에서 행정청은 신청에 응답해야 할 법률상 의무를 부담한다.

① 무하자재량행사청구권

- 신청인은 행정청이 재량을 행사함에 있어 하자 없는 판단을 할 것을 청구할 권리를 가진다. 따라서 재량행위라고 하여 행정청이 전혀 응답하지 않는 것은 허용되지 않는다.

② 재량권 0으로 수축

- 법령의 목적과 보호이익, 구체적 사정을 종합하여 행정청의 재량이 사실상 0으로 수축되는 경우에는 사실상 기속행위와 동일하게 응답의무가 발생한다.

(3) 판례의 경향

- "대법원"은 기속행위뿐 아니라 재량행위에 있어서도 응답의무를 인정하여 부작위 성립을 긍정하고 있다. 예컨대, 행정청이 일정한 요건을 충족한 건축허가 신청을 장기간 처리하지 않은 경우 부작위를 인정하였다. 이는 국민의 권리보호와 행정책임성을 강화하려는 입장이다.

4. 상당한 기간의 경과

- 부작위는 신청 후 상당한 기간이 경과하여야 성립한다. 여기서 상당한 기간이란 구체적 사안에 따라 판단되며, 법령에 처리기간이 정해진 경우 그 기간을 기준으로 한다. 별도의 규정이 없는 경우에도 사회통념상 행정청이 응답할 수 있는 합리적 기간이 도과해야 한다.

5. 처분 또는 부작위 상태의 지속

- 부작위가 성립하기 위해서는 신청 후 행정청의 불응 상태가 계속되어야 한다. 만일 소 제기 전에 행정청이 처분을 한 경우, 더 이상 부작위 상태가 아니므로 부작위위법확인소송은 부적법하게 된다.

IV. 결론

- 부작위위법확인소송의 본안판단 요건으로서 부작위가 성립하기 위해서는, ① 권한 있는 행정청이 존재하고, ② 당사자의 적법한 신청이 있으며, ③ 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재하고, ④ 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고, ⑤ 처분이 없는 상태가 계속되어야 한다. 특히 재량행위의 경우에도 무하자재량행사청구권 및 재량권 0으로의 수축 이론을 통해 응답의무가 인정됨을 "판례"는 명확히 하고 있다. 따라서 부작위위법확인소송은 단순히 행정청의 소극적 태만을 다루는 것이 아니라, 법률상 응답의무 위반을 전제로 하여 국민의 권익을 보호하는 제도라는 점에서 의의가 크다.

<재량권이 0으로 수축>

- 원칙적으로 재량행위인 경우에도, 특정 사안에서 위험이 중대하고 다른 수단이 없으면 행정청의 선택지가 사라져 특정 조치를 해야 할 의무로 바뀐다는 개념

《【문제3】 A시 시장 乙은 甲이 A시에서 진행하고 있는 공사가 관련 법령을 위반하였다는 이유로 해당 공사를 중지하는 명령을 하였다. 甲은 그 명령 이후에 그 원인이 사유가 소멸하였음을 들어 乙에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였다. 그러나 乙은 그 원인이 사유가 소멸되지 않았다고 판단하여 甲의 신청에 대하여 아무런 응답을 하지 않고 있다. 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A시 시장 乙은 甲에 대한 공사중지명령 후 원인이 사유가 소멸하였다는 이유로 제기된 철회신청에 대하여 이를 받아들이지 않고 아무런 응답을 하지 않는 상황이다. 쟁점으로 <행정청이 철회신청에 대하여 응답하지 않은 것이 항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대해 설명한다.

II. 부작위의 성립 조건과 신청권의 법리

1. 행정소송법상 부작위의 성립 요건

(1) 부작위의 정의 및 범위

- "행정소송법 제2조 제1항 제2호"는 부작위를 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것으로 규정하고 있다.

(2) 부작위의 4대 성립 요건

- 행정소송법상 처분의 부작위가 성립하여 사법심사의 대상이 되기 위해서는 ① 당사자로부터 구체적인 처분의 신청이 존재할 것, ② 행정청에게 일정한 처분을 행하여야 할 공법상 작위 의무가 존재할 것, ③ 처분을 내리기에 상당한 기간이 경과하였을 것, ④ 행정청의 처분 등 어떠한 공권력 행사도 부존재할 것이라는 요건을 누적적으로 충족하여야 한다.

2. 법률상 신청권의 요구와 도출 근거

(1) 법률상 신청권의 필요성

- "대법원"은 행정소송법상 부작위가 성립하기 위해서는 단순히 당사자가 처분을 신청한 사실만으로는 부족하며, 그 당사자에게 행정청의 공권력 발령을 요구할 수 있는 구체적인 법률상 신청권이 귀속되어 있어야 한다고 일관되게 판단한다. 법률상 신청권이 없는 제3자 등의 단순한 민원이나 진정에 대하여 행정청이 무응답으로 일관하더라도 이는 소송법상 부작위가 될 수 없다.

(2) 신청권의 구체적 도출 경로

- 처분을 요구할 수 있는 신청권은 성문법상 명시적으로 규정되어 있는 경우뿐만 아니라, 개별 법령의 합리적인 해석을 통해 도출되거나 행정법의 일반 원칙에 근거한 조리(條理)를 통해서도 예외적·보충적으로 인정될 수 있다.

3. 공사중지명령의 해소와 조리상 철회신청권

(1) 침익적 처분의 지속 요건과 실체법적 한계

- 공사중지명령과 같은 제재적·침익적 행정처분은 처분 당시는 물론이고 그 집행 및 효력이 유지되는 전 과정에 걸쳐 실체법상 적법 사유가 계속해서 존재하여야 한다. 만약 처분 발령 이후 사정변경으로 인하여 제재의 원인이 되었던 법령 위반 등 비위 상태가 완전히 해소되었다면, 해당 명령을 유지할 실체법적 근거는 상실된다.

(2) 조리상 철회신청권에 관한 판례의 태도

- "대법원"은 공사중지명령을 받은 처분의 상대방은 그 명령의 원인이 사유가 완전히 해소되었다면 처분청에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청할 수 있는 조리상 신청권을 가진다고 판시하여 조리상 권리의 존재를 명백히 긍정하고 있다. 행정청의 철회의무에 대응하는 신청인의 적극적 권리를 인정함으로써 사법적 구제의 기틀을 제공한 것이다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 조리상 철회신청권 취득 여부

(1) 철회신청의 구체성 확보

- 사안에서 공사중지명령의 상대방인 甲은 단순한 행정지도나 질의를 한 것이 아니라, 명령 발령의 원인이 사유가 소멸하였음을 직접 주장하며 乙에게 구체적으로 공사중지명령의 철회를 구하는 처분을 신청하였다.

(2) 판례에 따른 조리상 신청권의 성립

- 공사중지명령의 원인이 사유가 해소되었다면 甲에게는 처분의 효력을 거두어 줄 것을 청구할 수 있는 조리상 신청권이 귀속된다. 따라서 甲은 乙에 대하여 정당한 사법적 응답을 요구할 수 있는 소송법상 적격 있는 신청권자에 해당한다.

2. 乙의 무응답 행위의 위법 부작위 해당성

(1) 乙의 법적 작위 의무의 존재

- 甲의 정당한 조리상 신청권 행사에 대응하여, A시 시장 乙은 실제로 원인이 사유가 소멸하였는지를 충실히 심사하여 처분을 철회해 주거나, 여전히 소멸하지 않았다고 판단될 경우 신청을 거부하는 처분을 대외적으로 발령해야 할 공법상 답변 의무(작위 의무)를 부담하게 된다.

(2) 상당 기간의 도과 및 무조치 상태의 완성

- 그럼에도 불구하고 乙은 甲의 신청에 대하여 상당한 기간이 경과하기까지 철회처분도, 거부처분도 행하지 않은 채 어떠한 의사표시도 없이 무응답으로 방치하고 있다. 이는 법적 의무를 해태한 무조치 상태이므로 행정소송법상 부작위 성립 요건을 완벽히 충족한다.

IV. 결론

- A시 시장 乙이 甲의 공사중지명령 철회신청에 대하여 무조치 및 무응답으로 일관한 행위는 "행정소송법 제2조 제1항 제2호" 소정의 위법한 부작위에 해당한다. "대법원 판례"에 따라 제재적 처분의 상대방에게는 사정변경에 따른 조리상 철회신청권이 인정되고, 행정청에게는 그에 알맞은 응답을 해 줄 작위 의무가 발생하기 때문이다. 결론적으로 乙의 방치는 사법적 권리구제의 대상이 되는 위법한 부작위가 되므로, 甲은 乙을 피고로 삼아 관할 행정법원에 부작위위법확인소송을 적법하게 제기하여 권리구제를 도모할 수 있다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[예상][10.01-1]부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

《【문제10.1】

부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계에 대해서 논하시오.》

<문제10.1> 부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

I. 부작위위법확인소송의 의의와 절차적 특성

- 행정소송법상 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 부작위 상태가 위법함을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 부존재라는 특수한 상태를 다루므로 제소기간이나 전치절차의 적용에 있어 처분을 대상으로 하는 취소소송과는 다른 법리적 쟁점이 발생한다. 특히, "행정소송법 제38조 제2"항이 행정심판전치주의를 규정하는 "제18조"를 명시적으로 준용하지 않고 있음에도 불구하고, 실무와 이론상 전치주의의 적용이 긍정되는 배경과 그 구체적 실천 방안인 의무이행심판과의 연계성을 고찰할 필요가 있다. 이하에서는 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거와 절차적 요건에 대하여 논한다.

II. 행정소송법 제38조 제2항의 조문 해석과 쟁점

1. 조문상 준용 규정의 결여

- "행정소송법 제38조 제2항"은 부작위위법확인소송에 준용되는 조항들을 나열하고 있으나, 취소소송의 행정심판전치주의를 규정하고 있는 "제18조"를 포함하고 있지 않다. 이러한 조문 구조만 보면 문언상 부작위위법확인소송에서는 행정심판을 거칠 필요가 없는 것처럼 보일 수 있다.

2. 입법적 불비와 해석의 필요성

- 조문상 "제18조"가 누락된 이유에 대하여 입법상의 실수(입법 과오)라는 견해와 부작위의 특성상 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용하기 곤란하기 때문이라는 견해가 대립한다. 그러나 개별 법률에서 필요적 전치주의를 규정하고 있는 경우와의 충돌 문제, 그리고 "행정소송법 제20조 제2항"이 부작위위법확인소송에서 행정심판을 거친 경우의 제소기간을 규정하고 있는 점 등을 고려할 때 해석을 통한 보완이 요구된다.

III. 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거

1. 행정소송법 제20조 제2항의 존재

- "행정소송법 제20조 제2항"은 부작위위법확인소송에 대하여 제소기간을 적용하지 않으면서도, 다만 행정심판을 거친 경우에는 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 법 스스로 부작위위법확인소송에 행정심판 절차가 선행될 수 있음을 예정하고 있는 강력한 근거가 된다.

2. 행정심판법상 부작위에 대한 심판 청구권

- 행정심판법은 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 "행정소송법 제38조 제2항"의 준용 규정 누락에도 불구하고, 국민은 행정심판법에 의거하여 부작위 상태에 대해 행정심판을 청구할 권리를 가진다.

3. 필요적 전치주의 규정과의 조화

- 국세, 관세, 도로교통법상의 처분 등 개별 법률에서 "행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거쳐야 한다"고 규정하고 있는 경우, 해당 부작위 역시 그 법률의 적용을 받는 대상이 되므로 전치주의가 적용되는 것으로 해석함이 타당하다. 사법부는 이러한 개별법상의 필요적 전치 규정이 있는 경우 부작위위법확인소송에서도 이를 준수해야 한다고 판단한다.

IV. 의무이행심판과 부작위위법확인소송의 연계

1. 부작위에 대한 행정심판의 형태

- 부작위위법확인소송에 대응하는 행정심판은 부작위위법확인심판이 아니라 의무이행심판이다. 행정심판법은 부작위에 대해 위법 여부만을 확인하는 소극적 심판 대신 행정청에 직접 처분을 명하는 적극적 구제 수단인 의무이행심판을 제도화하고 있기 때문이다.

2. 의무이행심판의 제기 요건

- 당사자는 행정청의 부작위에 대하여 기간의 제한 없이 의무이행심판을 청구할 수 있다. 이때 심판위원회는 부작위가 위법하거나 부당하다고 판단되면 처분을 직접 하거나 처분을 할 것을 명하는 재결을 내리게 된다. 부작위위법확인소송에서 전치주의를 충족하기 위해서는 바로 이 의무이행심판을 거쳐야 한다.

3. 전치 절차로서의 기능

- 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 경우, 원고는 의무이행심판을 청구하여 기각 재결 등을 받은 후 그 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기함으로써 제소기간 요건과 전치 요건을 동시에 충족하게 된다. 만약 의무이행심판에서 인용 재결이 나왔음에도 행정청이 처분을 하지 않는다면, 이는 별도의 부작위 문제이므로 다시 다투어야 한다.

V. 판례 및 실무적 태도

1. 필요적 전치주의 사안에서의 태도

- "판례"는 개별 법률이 행정심판전치주의를 채택하고 있는 경우, 부작위위법확인소송이라 하더라도 행정심판을 거치지 않고 소를 제기하면 부작위 위법 판결을 내린다. 법 조문상의 준용 규정 미비보다 개별법상의 강행 규정과 국민의 권리 구제 체계를 우선시하는 입장이다.

2. 제소기간과의 상관관계

- 부작위위법확인소송은 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않으나, 행정심판을 거치게 되면 제소기간의 제한(90일)이 발생한다. 이는 행정심판을 거침으로써 부작위의 위법 여부에 대한 공적인 판단이 한 번 내려졌으므로, 그 이후의 소송 제기는 신속하게 확정되어야 한다는 법적 안정성의 논리가 반영된 것이다.

3. 실무상 유의사항

- 변호사나 당사자는 부작위 상태를 다룰 때 해당 사안이 필요적 전치주의 대상인지를 반드시 확인해야 한다. 만약 국세 사건처럼 전치주의가 필수적인 사안에서 의무이행심판을 거치지 않고 곧바로 부작위위법확인소송을 제기하면 승소 가능성과 상관없이 형식적 요건 미비로 소가 종료될 위험이 크다.

VI. 학설상의 쟁점 및 비판적 검토

1. 준용 규정 누락에 대한 입법론

- 다수설은 "행정소송법 제38조 제2항"에서 "제18조"를 누락한 것을 명백한 입법 과오로 본다. 부작위는 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용할 객체가 없다는 소수설도 있으나, 행정심판법이 의무이행심판을 통해 부작위를 심판 대상으로 삼고 있는 이상 논거가 부족하다는 평가를 받는다.

2. 전치주의 적용의 정당성

- 행정심판은 행정청 내부의 자율적 통제 기회를 부여하고 사법부의 부담을 경감하는 기능이 있다. 부작위 사안에서도 행정심판위원회가 행정청의 부작위 원인을 분석하여 신속한 처분을 유도할 수 있으므로 전치주의를 적용하는 것이 정책적으로도 타당하다.

3. 의무이행소송 도입과의 관계

- 향후 행정소송법 개정을 통해 의무이행소송이 도입된다면 부작위위법확인소송의 입지는 좁아질 것이다. 현재 부작위위법확인소송과 의무이행심판의 부조화(소송은 확인만, 심판은 이행까지)는 제도의 불균형을 초래하고 있으며, 전치주의 해석 역시 이러한 제도적 과도기에서 발생하는 혼란의 일부이다.

VI 결론

- "행정소송법 제38조 제2항"의 명문 규정에도 불구하고 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 것은 법체계의 통합적 해석과 국민의 실효적 권리 구제를 위한 결과이다. "행정소송법 제20조 제2항"이 전치 절차를 거친 경우의 제소기간을 명시하고 있고, 개별 법률이 필요적 전치주의를 요구하는 현실에서 조문상의 준용 규정 누락만을 근거로 전치주의를 부정하는 것은 타당하지 않다. 따라서 부작위 상태에 놓인 당사자는 행정심판법에 의한 의무이행심판을 청구하여 행정청의 응답을 촉구하거나 법적 판단을 받아야 하며, 이를 거친 후에는 엄격해지는 제소기간 내에 소송을 제기해야 한다. 이러한 법리는 행정청의 부작위로부터 국민을 보호하는 동시에 사법 절차의 객관성을 유지하는 균형점이 된다. 결국 부작위위법확인소송에서의 전치주의 문제는 단순한 조문 해석을 넘어 행정구제 제도 전체의 조화로운 운영이라는 관점에서 이해되어야 한다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

[기출][2017-2]무효인 보험료부과처분에 대해 이미 납부한 보험료를 반환받기 위한 소송유형과 피고적격

《【문제2】 국민건강보험공단은 甲에게 보험료부과처분을 하였고, 甲은 별도의 검토 없이 이를 납부하였다. 그러나 甲은 이후 당해 보험료부과처분이 무효임을 알게 되었다. 甲이 이미 납부한 보험료를 돌려받기 위하여 제기할 수 있는 소송의 종류에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 무효인 보험료부과처분에 대해 이미 납부한 보험료를 반환받기 위한 소송유형과 피고적격

I. 문제의 제기

- 사안에서 국민건강보험공단은 甲에게 보험료부과처분을 하였고, 甲은 이를 납부한 후 해당 처분이 무효임을 알게 되어 이미 납부한 보험료의 반환을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <무효인 행정처분에 따라 납부한 금원의 반환을 청구하기 위하여 어떠한 소송 형태를 제기하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효인 보험료부과처분으로 인한 금전 반환청구와 관련한 적절한 소송 종류에 대해 설명한다.

II. 공법상 부당이득반환과 무효확인소송의 법리

1. 공법상 부당이득반환청구소송의 성질 및 피고

(1) 소송유형에 관한 학설과 판례

① 학설의 대립

- 공법상 원인으로 발생한 부당이득반환청구권의 성질에 대하여, 이를 공법상의 독자적 권리로 평가하여 행정소송인 공법상 당사자소송으로 제기해야 한다는 공권설과, 실질이 민사상 채권과 다르지 않으므로 민사소송으로 제기해야 한다는 사권설이 대립한다.

② 판례의 태도

- “대법원”은 국세 및 지방세, 그리고 공법상 보험료의 과오납금 반환청구권을 원칙적으로 사법상 채권으로 평가하므로, 당사자소송이 아닌 민사소송의 방법으로 반환을 청구하여야 한다는 사권설의 입장을 일관되게 고수하고 있다.

(2) 선결문제와 피고 지정

① 선결문제와 인용 가능성

- 처분의 효력이 살아있다면 민사법원이 처분의 효력을 부인할 수 없으나, 사안처럼 처분이 당연무효인 경우에는 처분의 공정력(구성요건적 효력)이 발생하지 않는다. 따라서 수소법원인 민사법원은 스스로 부과처분이 무효임을 전제로 하여 곧바로 부당이득반환 판결을 내릴 수 있다.

② 적법한 피고의 확정

- 부당이득반환청구의 피고는 실제 법률상 원인 없이 이득을 영수하고 보유하는 실질적인 권리·의무의 귀속주체여야 한다. 사안의 보험료 징수 및 재정 주체는 국민건강보험공단이므로 반환청구소송의 피고적격은 권리주체인 국민건강보험공단에 귀속된다.

2. 무효등확인소송의 제기와 관련청구의 병합

(1) 무효등확인소송과 확인의 이익(보충성)

① 과거의 판례 및 학설

- “과거 판례”는 민사상 부당이득반환청구소송 등 직접적인 이행소송을 제기하여 구제받을 수 있는 경우에는 무효확인을 구할 소의 이익(확인의 이익)이 없다는 보충성설의 입장을 취하였다.

② 변경된 전원합의체 판례

- “대법원”은 전원합의체 판결을 통해 확인소송의 보충성 요건을 폐기하였다. 행정소송법은 당사자소송이나 무효등확인소송의 제기에 민사소송과 같은 보충성을 요구하는 규정이 없으므로, 직접적인 부당이득반환소송이 가능하더라도 별도로 처분의 무효확인을 구하는 소송을 제기할 수 있다.

(2) 행정소송법 제10조에 따른 관련청구의 병합

① 병합의 의의 및 요건

- “행정소송법 제10조 제1항 제1호” 및 “제38조 제1항”에 따라 처분의 무효확인을 구하는 취소소송이나 무효확인소송(주된 청구)에 당해 처분과 연계된 부당이득반환청구소송(관련청구)을 병합하여 행정법원에 제기할 수 있다.

② 이송 및 병합의 실익

- “판례”에 의해 부당이득반환청구소송이 민사소송으로 취급되더라도, 행정소송법상 관련청구 병합 규정은 행정법원에 특별한 관할권을 창설하므로 행정법원이 주된 무효확인과 함께 민사청구인 부당이득반환청구를 한꺼번에 심리·판단할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 부당이득반환 청구의 구체적 소송수단

(1) 민사소송의 제기 및 피고 지정

① 사권설에 따른 민사상 해결

- “대법원”의 확고한 사권설의 입장인 “판례”에 따라 때, 甲은 국민건강보험공단에 이미 납부한 보험료를 돌려받기 위해 민사소송 형태로 부당이득반환청구소송을 제기할 수 있다.

② 국민건강보험공단의 피고적격

- 이 소송의 피고는 보험재정의 관리주체이자 법적 권리의무의 종국적 귀속주체인 국민건강보험공단이 되므로 피고 지정은 적법하다.

(2) 선결문제 심리를 통한 직접 인용

① 공정력 배제와 민사법원의 무효 판단

- 부과처분이 당연무효이므로 민사법원은 처분의 공정력에 구속되지 않는다. 따라서 수소 민사법원은 처분의 무효 여부를 선결문제로 직접 판단할 수 있다.

② 실질적 구제 가능성

- 민사법원은 심리 결과 처분의 무효가 입증되는 경우 당연무효임을 확인하는 전제하에 국민건강보험공단에 대하여 이익금의 반환을 명하는 지급 판결을 내릴 수 있다.

2. 무효확인소송의 병합 활용

(1) 보충성 요건 완화에 따른 소구 가능성

① 무효확인 단독 청구의 적법성

- 甲은 보충성 불요설을 선언한 “전원합의체 판례”에 근거하여, 부당이득반환청구와 별개로 직접 국민건강보험공단을 피고로 삼아 처분의 무효등 확인소송을 단독으로 제기하는 것도 법리적으로 허용된다.

② 확인의 이익 충족

- 직접적인 이행소송(부당이득반환소송)이 가능하더라도 처분의 무효확인을 구하는 소의 이익은 명백히 충족된다.

(2) 행정법원에서의 병합 제기

① 무효확인과 부당이득반환의 병합

- 가장 실효적이고 바람직한 방법은 “행정소송법 제10조”를 활용하는 것이다. 甲은 국민건강보험공단을 피고로 관할 행정법원에 보험료부과처분 무효확인소송을 제기함과 동시에, 부당이득반환청구소송을 관련청구로서 병합하여 일괄 제기할 수 있다.

② 소송경제적 유용성

- 이 경우 수소 행정법원은 주된 처분의 무효 여부를 직접 판단하면서, 그에 수반되는 반환청구소송까지 일회적으로 심리하여 본안판결을 내릴 수 있으므로 甲에게 가장 완벽한 구제책이 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲이 이미 잘못 납부한 보험료를 돌려받기 위하여 취할 수 있는 구제 수단은 크게 두 가지이다. ❶ “대법원 판례”의 태도에 따라 국민건강 보험공단을 피고로 삼아 민사법원에 민사소송인 부당이득반환청구소송을 제기하는 방법이다. 당연무효 처분이므로 민사법원이 직접 무효를 선결문제로 판단하여 지급 판결을 내릴 수 있다. ❷ 보다 실효적이고 통일적인 권리구제를 도모하기 위해, 국민건강보험공단을 피고로 관할 행정법원에 무효등확인 소송을 제기하면서 이 소송에 부당이득반환청구소송을 관련청구로서 추가 병합하여 제기하는 방법이다. 보충성 요건이 불요되므로 병합 제기는 전적으로 적법하며, 행정법원의 일괄 심리를 통해 한 번에 완벽한 사법적 구제를 도모할 수 있다.

《[문제3] 甲은 부동산의 취득으로 인한 취득세 및 농어촌특별세의 납세의무부존재확인소송을 제기하려고 한다. 이러한 납세의무부존재확인소송의 법적 성질에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 납세의무부존재확인소송의 법적 성질 및 소송법상 특징

I. 문제의 제기

- 납세의무자 甲은 취득세 및 농어촌특별세의 납세의무부존재확인소송을 제기하려 한다. 이 소송이 행정소송법상 어떠한 범주에 속하는지 규명하는 것은 소송요건 및 적법 여부를 판단하는 선결 과제이다. 쟁점으로 <해당 소송이 항고소송인지 공법상 당사자소송인지, 소송물과 피고적격의 결정 기준은 무엇인지, 부과처분의 존재 여부에 따른 소송법상 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 납세의무부존재확인소송의 법적 성질, 피고적격 및 부과처분의 존재 여부에 따른 소송법상 한계를 설명한다.

II. 납세의무부존재확인소송의 법적 성질

1. 행정소송법상 소송 유형과 성격

(1) 공법상 당사자소송의 성격

① 공법상 법률관계의 직접 쟁송

- “대법원”은 납세의무부존재확인소의 소는 행정청의 처분을 전제로 하지 않고 공법상 법률관계 자체를 다투는 소송으로서 “행정소송법 제3조 제2호” 소정의 공법상 당사자소송에 해당한다고 판시한다.

② 실질적 당사자소송의 범주

- 처분 등이 아닌 법률관계 자체를 소송물로 삼아 존부를 다투는 소송이므로, 당사자소송 중 실질적 당사자소송에 해당한다.

(2) 확인소송 및 시심적 소송의 성질

① 확인소송의 특징

- 이행소송과 구별되며 당사자 간의 대등한 지위에서 공법상 권리의무의 존부를 법원으로부터 확정받는 확인소송이다.

② 시심적 소송의 특징

- 이미 형성된 행정작용의 위법을 사후적으로 심사·통제하는 복심적 소송(항고소송)과 달리 법률관계의 존부를 법원이 최초로 확정하는 시심적 소송에 해당한다.

2. 피고적격의 확정 범위

(1) 권리 의무 귀속주체의 피고 지정

① 귀속주체의 원칙

- “행정소송법 제39조”에 따라 당사자소송의 피고는 국가·공공단체 그 밖의 권리주체가 되어야 한다. 단순히 징수위탁을 받아 사무를 대행하는 수탁 행정청은 피고가 될 수 없다.

② 지방세와 국세의 피고 구별

- “대법원”은 지방세인 취득세의 귀속주체는 지방자치단체이며, 국세인 농어촌특별세의 귀속주체는 대한민국이 되므로 각각 실질적인 권리 귀속주체를 개별 피고로 지정해야 한다고 본다.

(2) 당사자소송의 보충성과 확인의 이익

① 보충성 불요설의 입장

- 행정소송법은 당사자소송 제기에 민사소송상의 보충성을 요구하는 명문 규정이 없으므로 이행소송 등 다른 구제수단이 있더라도 확인소송 형태의 당사자소송을 제기할 수 있다.

② 확인의 이익의 존재

- 과세관청과 당사자 사이에 세법상 의무의 존부에 대하여 분쟁이 존재하고 납세자의 법적 지위에 불안·위험이 현존하여 판결을 통한 법률관계 확정이 필요한 경우 인정된다.

3. 과세 부과처분과의 관계 및 한계

(1) 부과처분 미발령 시의 적법성

① 신고납세 조세와 부과처분 미발령

- 취득세 등 신고납세 조세에서 자진신고 행위가 당연무효이거나 과세관청의 부과처분이 아직 내려지지 않은 과세 공백 상태를 의미한다.

② 독립적 당사자소송의 허용

- 처분의 공정력이 작용하지 않는 무처분 상태이므로 납세의무자는 당사자소송으로 직접 납세의무부존재확인을 청구하는 것이 전적으로 허용된다.

(2) 부과처분이 이미 발령된 경우의 한계

① 처분의 공정력의 작용

- 부과처분이 이미 존재한다면 그것이 당연무효가 아닌 한 처분의 공정력에 의해 세액의 납부의무는 유효하게 존속하는 것으로 취급된다.

② 항고소송 제기의 의무화

- 처분의 효력이 유지되는 상황에서는 당사자소송을 제기할 소의 이익이 없다. 당사자는 반드시 부과처분을 소송물로 삼아 취소소송 등 항고소송을 제기해 처분의 효력을 제거해야 하며, 직접 당사자소송을 제기하는 것은 허용되지 않아 부적법 각하된다.

III. 사안의 적용

1. 소송 유형 및 피고의 지정

(1) 실질적 당사자소송의 해당성

- 甲이 제기하려는 취득세 및 농어촌특별세 납세의무부존재확인소송은 공법상 조세채무의 부존재 확정을 직접 청구하는 공법상 당사자소송(실질적 당사자소송)이자 확인소송에 해당한다.

(2) 개별 피고의 적법한 지정

- 피고적격 법리에 따라 취득세 부존재확인 부분은 세원의 최종 귀속주체인 지방자치단체를 피고로 삼아야 하며, 농어촌특별세 부존재확인 부분은 귀속주체인 대한민국을 피고로 삼아야 한다.

2. 과세처분 존부에 따른 적법 여부 판단

(1) 부과처분 이전의 경우

- 과세관청의 부과처분이 발령되기 전이거나 甲의 취득세 신고 행위가 당연무효에 해당하여 의무의 존부에 법적 불안이 현존하는 상황이라면, 당사자소송은 소의 이익이 인정되어 적법하다.

(2) 부과처분 이후의 경우

- 만약 이미 부과처분이 행해진 상태라면 처분의 공정력으로 인해 직접 조세채무의 부존재를 구할 수 없다. 따라서 甲은 부과처분취소소송 등 항고소송을 제기하여야 하며, 곧바로 제기한 당사자소송은 부적법 각하된다.

IV. 결론

- 납세의무부존재확인소송은 공법상 법률관계 존부를 법원이 최초로 확정하는 실질적 당사자소송이자 주관적 확인소송, 그리고 시심적 소송의 성질을 지닌다. 따라서 甲은 실질적 귀속주체인 지방자치단체(취득세) 및 대한민국(농어촌특별세)을 각각 피고로 지정하여 제기하여야 한다. 다만, 이 소송은 과세관청의 부과처분이 이미 발령되었는지 여부에 따라 소송법적인 한계를 지닌다. 이미 처분이 발령된 경우라면 처분의 공정력 및 항고소송 중심주의 원칙에 의해 당사자소송의 제기는 소의 이익을 상실하여 부적법 각하되므로, 반드시 부과처분을 소송물로 삼아 취소소송 등 항고소송을 제기하여 다투어야 한다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

[기출][2023-3]공사 전부 도급 시 고용·산재보험료 부존재확인 및 부당이득반환 청구의 적법한 피고와 소송유형

《[문제3] 甲은 자기 소유 토지에 전원주택을 신축하고자 건축업자인 乙과 전원주택신축공사에 관하여 도급계약을 체결하였고, 乙은 근로복지공단에 고용보험·산재보험관계성립신고를 하면서 신고서에 위 신축공사 사업장의 사업주를 甲으로 기재하여 제출하였다. 甲은 위 사업장에 관한 고용보험료와 산재보험료 중 일부만 납부하였고, 국민건강보험공단은 甲에게 체납된 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 것을 독촉하였다. 관련 법령상 보험료의 신고 또는 납부 등 산재보험 및 고용보험에 관한 사업의 주요 업무는 고용노동부장관으로부터 위탁받은 근로복지공단이 수행하고, 다만 보험료 체납관리 등 징수업무는 국민건강보험공단이 위탁받아 수행하고 있다. 甲은 건축주가 직접 공사를 하지 않고 공사 전부를 수급인에게 도급을 준 경우에는 근로자를 사용하여 공사를 수행하는 수급인이 원칙적으로 그 공사에 관한 사업주로서 고용보험 및 산재보험의 가입자가 되어 고용보험료 및 산재보험료를 납부할 의무를 부담한다는 것을 알게 되었다. 이에 甲은 국민건강보험공단이 납부를 독촉하는 보험료채무에 대해 그 부존재확인을 구하는 소송과 이미 근로복지공단에 납부한 보험료에 대해 부당이득으로서 반환을 구하는 소송을 제기하고자 한다. 甲은 누구를 상대로 어떤 유형의 소송을 제기하여야 하는지 설명하시오. (25점)》

<문제3> 공사 전부 도급 시 고용·산재보험료 부존재확인 및 부당이득반환 청구의 적법한 피고와 소송유형

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 전원주택 신축공사의 사업주로 잘못 기재되어 부과된 고용보험료 및 산재보험료와 관련하여 국민건강보험공단의 납부독촉에 대응하고, 이미 납부한 보험료의 반환을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <보험료채무의 부존재확인 및 납부한 보험료의 반환을 구하기 위하여 누구를 피고로 하여 어떠한 소송 유형을 제기하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 보험료 부과 및 징수와 관련한 항고소송과 당사자소송 등 적절한 소송 형태와 피고적격에 대해 설명한다.

II. 고용·산재보험료 관련 소송유형과 피고적격의 법리

1. 보험료채무 부존재확인소송의 성질과 피고적격

(1) 소송유형의 판단 (공법상 당사자소송)

- 보험료 납부의무는 공법상 법률관계에 직접 해당하는바, 이에 대한 존부를 다투는 확인소송은 "행정소송법 제3조 제2호"의 공법상 당사자소송의 형태로 제기되어야 한다. 행정청의 처분을 전제로 하지 않는 대등한 당사자 간의 공법상 권리의무 관계에 관한 소송이기 때문이다.

(2) 피고적격의 확정 (근로복지공단)

- "대법원"은 보험료 납부의무의 상대방이자 실질적인 공법상 권리의무의 귀속주체는 국민건강보험공단이 아니라 근로복지공단이라고 판시한다. 국민건강보험공단은 관련 법령에 의하여 단지 보험료의 징수업무만을 위탁받아 수행하는 징수 대행기관에 불과하므로, 채무 부존재확인소송의 적법한 피고는 근로복지공단이 된다.

2. 부당이득반환청구소송의 성질과 피고적격

(1) 소송유형에 관한 학설과 판례

① 학설의 대립

- 공법상 부당이득반환청구권의 성질에 대하여 공법상의 독자적 권리로 보아 행정소송인 공법상 당사자소송으로 제기해야 한다는 공권설과, 사법상의 채권과 다를 바 없어 민사소송으로 제기해야 한다는 사권설이 대립한다.

② 판례의 태도

- "대법원"은 공법상 부당이득반환청구권을 원칙적으로 사법상 채권으로 평가하므로, 당사자소송이 아닌 민사소송의 방법으로 반환을 청구하여야 한다는 사권설의 입장을 일관되게 고수하고 있다.

(2) 피고적격의 확정 (근로복지공단)

- 잘못 납부된 고용·산재보험료의 부당이득반환청구의 피고는 실제 기금의 관리·운용 주체이자 보험료의 실질적 귀속주체인 근로복지공단이 되어야 한다. 단순 징수 대행기관에 불과한 국민건강보험공단이나 국가를 상대로 청구할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 보험료채무 부존재확인의 소 제기 방향

(1) 소송유형

- 甲이 국민건강보험공단으로부터 독촉받고 있는 보험료채무는 공법상 보험료징수법령에 따른 공법상의 의무이므로, 그 의무의 존부를 다투는 소송은 공법상 당사자소송으로 제기하여야 한다.

(2) 피고의 지정

- 보험료의 부과권자이자 법적 납부의무의 귀속 주체는 근로복지공단이다. 국민건강보험공단은 단순 징수업무 수탁기관에 불과하므로, 甲은 근로복지공단을 피고로 삼아 소를 제기하여야 한다.

2. 부당이득반환청구소송의 제기 방향

(1) 소송유형

- "판례"의 사권설에 의할 때, 甲이 이미 잘못 납부한 고용·산재보험료에 대한 부당이득반환청구소송은 민사소송의 형태로 제기하여야 한다.

(2) 피고의 지정

- 과오납된 보험료의 귀속주체이자 관련 기금을 직접 관리·운용하는 권리주체는 근로복지공단이다. 따라서 부당이득반환청구의 적법한 피고 역시 근로복지공단이 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲은 국민건강보험공단이 독촉하는 고용·산재보험료채무의 부존재확인을 구하기 위해 근로복지공단을 피고로 삼아 공법상 당사자소송을 제기하여야 한다. 또한, 이미 납부한 보험료의 반환을 구하기 위해서도 마찬가지로 근로복지공단을 피고로 지정하여 민사소송을 제기하여야 한다. 이 두 소송은 "행정소송법 제10조" 및 "제44조"의 관련청구 병합 규정에 따라 관할 행정법원에 일괄하여 병합 제기함으로써 일회적이고 실효성 있는 권리구제를 도모할 수 있다.

<보충 - 피고 : 근로복지공단, 소송 유형 : 취소소송(무효확인소송)>

※ 국민건강보험공단이 단순히 위탁받아 체납관리 업무를 수행하는 기관일 뿐이고, 보험관계 성립의 주체는 근로복지공단이라는 점 때문에, 소송의 피고가 누구인가가 헷갈릴 수 있다. 이 부분은 판례와 행정소송법의 체계에서 정리해야 한다.

I. 보험료 부과·징수 권한의 구조

1. 근로복지공단

- "고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률(이하 '고용산재보험료징수법')"에 따르면, 보험관계 성립, 보험료 부과·고지, 보험료율 산정 등 보험관계의 실제적 처분권은 근로복지공단이 행사한다.

2. 국민건강보험공단

- 다만, "동법 제8조"에 따라 보험료 징수업무 중 일부, 특히 체납관리·강제징수 등 집행 단계는 국민건강보험공단에 위탁된다. 따라서 국민건강보험공단이 하는 독촉·압류 등은 근로복지공단의 부과처분을 전제로 하는 집행행위이다.

II. 피고적격 관련 판례 입장

1. 원칙 : 처분청이 피고

- "행정소송법 제13조 제1항"은 취소소송은 처분 등을 한 행정청을 피고로 한다고 규정한다. 따라서 보험료 부과·고지라는 처분의 주체는 근로복지공단이므로, 보험료 부과처분 자체를 다투는 소송의 피고는 근로복지공단이다.

2. 국민건강보험공단이 한 독촉·체납처분

- "대법원"은 일관되게, 국민건강보험공단이 독촉·압류 등 체납처분을 한 경우 그 처분의 피고적격은 국민건강보험공단에 있다고 보고 있다. 다만, 이때 쟁점은 <실체적으로 보험료 납부의무가 있느냐라기보다는 독촉 자체가 위법한가>의 문제로 귀결된다.

3. 실무적 구분

- 따라서 보험료 납부의무 자체(즉, 보험관계 성립 여부, 부과적법성)를 다투려면 근로복지공단을 피고로 삼아야 하고, 국민건강보험공단이 한 징수·독촉행위를 다투려면 국민건강보험공단을 피고로 삼아야 한다.

III. 사안의 적용

- 甲은 '나는 보험료 납부의무자가 아니다'라는 점을 다투고자 한다. 이는 곧 보험료 부과처분의 위법성(즉, 보험관계 성립 주체가 잘못되었다는 것)을 다투는 것이므로, 소송의 상대방은 근로복지공단이 되어야 한다. 국민건강보험공단의 독촉은 단순한 집행행위에 불과하여, 그 자체를 취소소송 대상으로 삼는 것은 부적절하다. 따라서 甲이 보험료 채무의 부존재를 주장하려면, 근로복지공단을 피고로 하여 보험료 부과처분 취소소송(또는 무효확인소송)을 제기하는 것이 타당하다.

IV. 결론

- 보험료 부과처분의 주체 : 근로복지공단
- 징수·독촉 등 체납관리 주체 : 국민건강보험공단
- 보험료 채무의 존부 자체를 다투려는 경우 : 근로복지공단을 상대로 취소소송/무효확인소송
- 단순히 독촉·압류의 위법을 다투려는 경우 : 국민건강보험공단을 상대로 취소소송
- 본 사안에서는 甲이 '나는 납부의무자가 아니다'라는 실체적 다툼을 제기하려는 것이므로, 피고는 근로복지공단이 되는 것이 타당하다.

《[문제1] 甲은 X주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y지방고용노동청 Z지청장(이하 'A'라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024. 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제70조 제2항에서 정한 '육아휴직이 끝난 날 이후 12개월'이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제15조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50점)

(물음1) 아래의 각 경우 법원의 판단에 관하여 설명하시오. (30점)

(1) 甲은 「고용보험법 시행령」 제94조 제3호에 해당하는 사유(직계비속의 질병)가 끝난 후 30일 이내 신청하였으므로 육아휴직급여 청구권이 있다고 주장하면서, 2024. 8. 1. 대한민국을 피고로 하여 금전의 지급을 구하는 민사소송의 소장을 서울지방법원에 제출하여 접수되었다. 국가소송수행자 B는 소송이 적법하지 않으므로 각하판결이 내려져야 한다고 항변한다. (15점)

- 지방공무원법 제20조의2 [행정소송과의 관계]
- 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 [시간외근무수당]
- 고용보험법 시행규칙 제105조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제119조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]

<문제1의 물음1-1> 거부처분에 대하여 대한민국을 피고로 지정한 민사상 금전지급 청구소송의 적법 여부 및 법원의 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 육아휴직급여 청구권이 있음을 주장하며 대한민국을 상대로 금전 지급을 구하는 민사소송을 제기하였고, 국가소송수행자는 해당 소송이 부적법하다고 항변하는 상황이다. 쟁점으로 <육아휴직급여 지급청구와 같이 행정청의 처분을 전제로 하는 공법상 금전청구를 어떠한 소송 형태로 제기하여야 하는지와 민사소송의 적법 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 국가소송수행자 B의 각하판결이 내려져야 한다는 항변에 대한 법원의 판단에 대해 설명한다.

II. 육아휴직급여 청구권의 성질과 구제소송의 요건

1. 육아휴직급여 청구권의 법적 성질과 처분의 선행 필요성

(1) 공법상 수급권의 성질

- 고용보험법에 따른 육아휴직급여는 국가가 헌법상 사회보장수급권의 이념을 실현하기 위하여 법령이 정한 요건을 갖춘 자에게 지급하는 공법상의 급여 청구권이다.

(2) 구체적 권리 발생의 시기 (판례의 태도)

- "대법원"은 고용보험법상의 육아휴직급여 청구권은 법령의 요건을 충족하는 것만으로 당연히 발생하는 권리가 아니라고 판단한다. 당사자의 신청에 대하여 관할 직업안정기관의 장이 급여를 지급하겠다는 구체적인 지급결정 처분을 내림으로써 비로소 구체적인 권리가 확정·발생한다. 따라서 행정청의 적법한 지급결정이 존재하지 않는 한, 직접 국가에 대하여 구체적인 급여의 지급을 청구하는 것은 실체법상 허용되지 않는다.

2. 거부처분에 대한 불복소송의 유형과 민사소송의 한계

(1) 거부처분 취소소송의 제기 의무

- 행정청이 육아휴직급여 지급을 거부한 행위는 신청인의 법적 지위에 직접 불이익을 초래하는 공권력의 행사 또는 그 거부로서 "행정소송법 제2조 제1항 제1호"의 처분에 해당한다. 따라서 이에 불복하여 권리를 획득하고자 하는 자는 관할 고용노동청 지청장을 피고로 삼아 거부처분 취소소송이라는 항고소송을 제기하여 거부처분의 위법성을 적극적으로 제거하여야 한다.

(2) 직접적인 민사소송 제기의 위법성

- 행정청의 거부처분이라는 선행 처분이 엄연히 존재함에도 불구하고, 이를 거부처분 취소소송을 통해 해결하지 아니한 채 직접 대한민국을 상대로 민사상 금전지급 청구소송을 제기하는 것은 소송물의 선택 및 소송 형태를 완전히 그르친 것으로서 소의 이익을 결여하여 매우 부적법하다.

3. 소송 유형의 잘못과 피고오지정에 대한 법원의 조치

(1) 행정소송법 제21조에 따른 소 변경의 유도

- 민사소송이 제기된 수소법원은 단순히 소송 형태가 잘못되었다는 이유로 즉시 각하해서는 안 된다. 실질적인 분쟁의 실체가 거부처분 취소소송에 해당한다면, 법원은 적극적으로 석명권을 행사하여 피고를 처분 행정청으로 경정("제14조")하고, 소송 유형을 거부처분 취소소송으로 변경("제21조")하도록 유도하여야 한다.

(2) 관할 행정법원으로서의 사건 이송

- 법원은 소 변경 절차와 함께 사건에 대한 관할권을 지닌 관할 행정법원으로 사건을 이송("행정소송법 제7조")함으로써 국민의 재판청구권을 보장하고 권리구제의 실효성을 높여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 소송 제기 방식의 위법성

(1) 소송 유형 및 청구의 부적법

- 甲이 구하는 육아휴직급여 청구권은 피고 A의 구체적인 지급결정 처분이 있어야 비로소 확정되는 공법상 권리이다. 따라서 甲은 거부처분 취소소송을 통해 구제를 도모해야 함에도 처분의 위법성을 거치지 않은 채 국가를 상대로 민사상 금전지급을 직접 청구하였으므로, 이는 소송의 형태를 오인한 것으로서 소의 이익을 결여하였다.

(2) 피고 지정 및 관할의 오류

- 항고소송의 피고는 처분을 행한 행정청인 Y지방고용노동청 Z지청장(A)이 되어야 한다. 그러나 甲은 권리의 의무의 귀속주체인 대한민국을 피고로 잘못 삼아 민사법원에 소를 제기하였으므로 피고적격과 관할권의 중대한 흠결이 존재한다.

2. 국가소송수행자 B의 항변과 수소법원의 최종 조치

(1) B의 각하 항변의 정당성

- 이 사건 소송은 구체적 급여 청구권이 발생하기 전에 제기된 직접적인 금전청구로서 소의 이익이 없으며 피고적격도 결여하였다. 따라서 적법하지 않은 소로서 각하되어야 한다는 국가소송수행자 B의 항변은 법리적으로 전적으로 타당하다.

(2) 법원의 구체적 심리 방향과 판단 형태

- 민사법원인 수소법원은 즉시 각하 판결을 선고할 것이 아니라, 구체적인 석명권을 발동하여 甲에게 피고를 Y지방고용노동청 Z지청장(A)로 경정하고 청구취지를 거부처분의 취소로 변경하도록 촉구해야 한다. 만약 甲이 법원의 석명에 응하여 소 변경을 신청하는 경우, 법원은 이를 허가하고 관할 행정법원으로 사건을 이송하는 결정을 내려야 한다. 그러나 법원의 유도와 석명에도 불구하고 甲이 민사소송 형태와 대한민국에 대한 금전청구를 끝내 고집한다면, 법원은 소송요건 흠결을 이유로 소 각하 판결을 선고하여야 한다.

IV. 결론

- 고용보험법상 육아휴직급여 청구권은 처분을 통하여 비로소 권리가 확정되므로 거부처분 취소소송을 제기하여야 한다. 이를 무시하고 직접 대한민국을 상대로 제기한 민사상 금전지급 청구소송은 부적법하므로 각하를 구하는 국가소송수행자 B의 항변은 타당하다. 결론적으로 수소법원은 석명권을 통하여 항고소송으로의 소 변경 및 피고경정을 유도한 후 관할 행정법원으로 사건을 이송하는 조치를 취해야 하며, 만약 원고 甲이 소 변경을 거부하는 경우에는 최종적으로 소 각하 판결을 내려야 한다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제04절 기관소송>

[기출][2009-2-2]기관소송

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 기관소송 (25점)》

<문제2의 물음2> 기관소송의 정의, 특징, 예시, 법적 한계

I. 문제 제기

- 기관소송은 행정기관 상호 간의 권한 다툼을 해결하기 위한 소송 형태로서, 일반적인 국민의 권리 구제와는 성격이 다르다. 이하에서는 기관소송의 정의, 특징, 예시, 법적 한계를 중심으로 관련 내용을 서술한다.

II. 기관소송의 정의

- 기관소송은 국가 또는 공공단체, 즉 행정기관 상호 간에 있어서 권한의 유무 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때, 이를 해결하기 위하여 제기하는 소송을 의미한다. ("행정소송법 제3조 제4호") 이는 공권력 주체 내부의 다툼을 법적으로 해결함으로써 행정조직의 질서를 유지하고 공익을 확보하는 데 그 목적이 있다. 기관소송은 행정주체와 사법(私法) 주체 간의 다툼인 당사자소송과 구별되며, 법이 정한 경우에 한하여 인정되는 법정(法定) 소송이다.

III. 기관소송의 특징

1. 주체

- 기관소송의 당사자는 국가 또는 공공단체의 기관이며, 사경제 주체인 사인(私人)은 기관소송의 주체가 될 수 없다. 소송의 주체는 공권력을 행사하는 행정기관 또는 그 기관의 구성원이다.

2. 소송 대상

- 소송의 대상은 행정기관 상호 간의 권한의 유무 또는 그 행사에 관한 다툼이다. 이는 구체적인 처분 자체의 위법성을 다투는 항고소송과는 달리, 기관 상호 간의 관계나 권한 범위의 적법성을 다투는 것이다.

3. 법정주의

- 기관소송은 오직 법률이 정한 경우에 한하여 제기할 수 있는 법정소송이다. ("행정소송법 제45조") 이는 법적 안정성 확보와 행정기관 상호 간의 자율성 존중을 위한 것이다. 일반 국민에게 무제한으로 허용되는 항고소송과는 본질적인 차이가 있다.

4. 형성소송

- 기관소송은 주로 기관 간의 권한 관계를 형성적으로 확정하는 소송의 성격을 가지며, 권한의 범위나 존재를 확인하거나 무효를 선언하는 경우가 많다. 이는 행정의 근본 질서에 관한 문제이기 때문이다.

5. 피고

- 기관소송은 기관 상호 간의 다툼이므로, 그 피고는 처분을 행한 행정청이 아닌 상대방 행정기관 자체가 된다. 이는 권한의 주체인 기관이 직접 소송 당사자가 되어야 함을 의미한다.

IV. 기관소송의 예시

- 기관소송은 행정소송법이 아닌 개별 법률에 근거가 있어야 제기 가능하다.

1. 지방자치법상 기관소송 [지방자치법 제192조]

- 지방자치법에는 기관소송의 대표적인 예가 규정되어 있다.

(1) 시·도의 교육감 또는 시장·군수·구청장의 처분에 대한 이의

- 지방자치단체의 장이 교육감이나 시장·군수·구청장의 처분이 위법하거나 부당하다고 인정할 때, 주무부장관에게 이의를 제기하고 이에 대한 재결에 불복할 경우 제기하는 소송이다.

(2) 지방의회 의결에 대한 제소

- 지방자치단체장이 지방의회의 의결이 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정하여 대법원에 제소하는 경우이다. 이 소송은 기관소송의 대표적인 형태 중 하나로, 기관 상호 간의 권한 다툼을 사법적으로 해결한다.

2. 교육감과 시·도 교육감

- 교육자치에 관한 법률 등에서 교육감과 시·도 교육감 간의 권한 다툼에 대한 소송을 규정하고 있는 경우에도 기관소송이 적용될 수 있다.

V. 기관소송의 한계

- 기관소송은 행정기관 내부의 권한 다툼을 규율하는 데 필수적이지만, 다음과 같은 한계를 지닌다.

1. 법정주의의 한계

- 기관소송은 법률에 규정된 경우에만 제기할 수 있으므로, 법률에 명시적인 근거가 없는 새로운 형태의 기관 간 다툼은 기관소송으로 해결하기 어렵다.

2. 국민 권리 구제 기능의 부재

- 기관소송은 행정기관의 권한 질서 유지가 주된 목적이므로, 소송 결과가 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않는다. 따라서 기관소송을 통해 국민의 직접적인 권리 구제를 도모할 수 없다.

3. 권한쟁의심판과의 관계

- 기관소송의 기능 중 상당 부분이 헌재판소법상 권한쟁의심판과 중복되는 문제가 있다. 기관소송은 지방자치단체와 국가기관 간, 또는 지방자치단체 상호 간의 다툼 중 법률이 정한 경우에만 적용되므로, 그 범위가 권한쟁의심판보다 좁다.

VI. 결론

- 기관소송은 행정기관 상호 간의 권한 다툼을 사법적으로 해결하여 행정 조직 질서의 합법성을 유지하기 위한 특수한 소송 형태이다. 이는 법정주의에 따라 법률에 명시적 근거가 있을 때에만 제기 가능하며, 주로 지방자치법 등의 개별 법률에서 그 예시를 찾을 수 있다. 기관소송은 국민의 권리 구제라는 행정소송의 일반적 목적과 달리, 행정기관 내부의 질서 유지에 중점을 둔다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

<제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>

[기출][2020-2]이의신청에 대한 행정청의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 여부

《【문제2】 甲은 태양광발전시설을 설치하기 위해 관할 군수 乙에게 개발행위허가를 신청하였으나 乙은 산림훼손 우려가 있다는 이유로 거부처분을 하였다. 甲은 「민원처리에 관한 법률」 제35조에 따라 乙에게 이의신청을 하였다. 乙은 甲의 이의신청을 검토한 후 종전과 동일한 이유로 이의신청을 기각하는 결정을 하였다. 乙의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 설명하시오. (25점)》

「민원처리에 관한 법률 제35조」

㉞ 민원인은 제1항에 따른 이의신청 여부와 관계없이 「행정심판법」에 따른 행정심판 또는 「행정소송법」에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.》

<문제2> 이의신청에 대한 행정청의 기각결정을 행정심판의 기각재결로 볼 수 있는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 태양광발전시설 설치를 위한 개발행위허가 거부처분에 대하여 민원 처리에 관한 법률(이하 `민원처리법`)상 이의신청을 하였고, 乙은 종전 처분과 동일한 사유로 이의신청을 기각하는 결정을 한 상황이다. 쟁점으로 <민원처리법상 이의신청에 따른 기각결정이 행정심판법상 행정심판의 기각재결에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이의신청 결정의 법적 성질과 행정심판 재결 해당 여부에 대해 설명한다.

II. 이의신청과 행정심판의 관계에 관한 법리

1. 양 제도의 법적 성격과 구별 기준

(1) 민원처리법상 이의신청의 성격

- 민원처리법상 이의신청은 처분을 행한 당해 행정청(처분청)으로 하여금 스스로의 판단을 재고하여 잘못이 있는 경우 자발적으로 처분을 시정하도록 유도하는 행정청 내부의 임의적 자가시정 절차에 불과하다.

(2) 행정심판법상 행정심판의 성격

- 행정심판은 처분청과 독립된 합의제 의결기관인 행정심판위원회가 행정처분의 위법·부당 여부를 제3자적 입장에서 엄격하게 사법(司法)에 준하는 절차를 거쳐 심리·판단하는 준사법적 행정구제 제도이다.

2. 대법원 판례의 입장

(1) 이의신청 기각결정의 처분성 부정

- “대법원”은 거부처분에 대하여 민원처리법에 따른 이의신청을 한 경우, 이의신청을 받아들이지 아니하는 기각결정은 당초의 거부처분을 그대로 유지하겠다는 의사를 다시 확인하여 통지한 것에 불과하다고 본다. 따라서 이는 신청인의 권리·의무에 새로운 법적 변동을 일으키는 공권력의 행사가 아니므로 독립된 행정처분에 해당하지 않는다.

(2) 행정심판 재결과의 차별성

- “대법원”은 민원처리법에 따른 이의신청은 행정심판법에 따른 행정심판과 법적 성질을 전혀 달리하는 독립된 간이 절차라고 본다. 따라서 이의신청에 대한 기각결정 내지 기각 통지는 행정심판법상 재결(기각재결)에 해당하지 않으며, 이의신청에 대한 통지를 받은 날부터 행정소송의 제소기간이 새롭게 기산되지 않는다고 엄격하게 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 이의신청과 행정심판의 실체법적 단절성

(1) 임의적 구제수단의 명문화

- “민원처리법 제35조 제3항”은 민원인은 이의신청 여부와 전혀 관계없이 행정심판 또는 행정소송을 독자적으로 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 이의신청 절차가 행정심판을 대체할 수 없음을 입법적으로 선언한 것이다.

(2) 乙의 기각결정의 법적 본질

- 군수 乙이 행한 기각결정은 자신의 기존 개발행위허가 거부처분이 적법함을 내부적으로 확인하고 재통지한 것에 불과하다. 준사법적 독립성을 지닌 행정심판위원회의 실질적 재결 절차를 거친 적이 없으므로, 이를 기각재결로 선택할 수 없다.

2. 소송법적 효과와 한계

(1) 재결정 자격의 결여

- 처분을 내린 군수 乙은 행정심판법상의 재결청 내지 행정심판위원회가 될 수 없으므로 乙의 독단적 기각 결정은 재결로서의 효력 자체가 발생할 수 없다.

(2) 제소기간 기산점의 고정

- 따라서 甲은 乙의 기각결정 통보일을 기준으로 소송을 제기해서는 안 되며, 당초의 개발행위허가 거부처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구하거나 취소소송을 제기하여야 소송요건을 준수하게 된다.

IV. 결론

- 결론적으로 관할 군수 乙이 甲의 이의신청에 대하여 내린 기각결정은 행정심판법상 행정심판의 기각재결로 볼 수 없다. 민원처리법상 이의신청은 행정청 내부의 임의적 자가시정 수단에 불과하여 준사법적 권리구제 수단인 행정심판과 본질적으로 구별되며, “대법원” 역시 이의신청 기각결정에 대하여 독자적 처분성 및 재결로서의 성격을 일관되게 부정하기 때문이다. 따라서 甲은 이의신청 기각 통지를 받은 날이 아닌, 당초의 거부처분을 안 날을 기준으로 90일의 불변기간 내에 독자적인 행정쟁송을 제기하여야 적법하게 권리를 구제받을 수 있다.

<제11장 행정심판의 일반론.제02절 행정심판의 종류>

[기출][2010-2]하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상 청구 및 재결의 실효성 확보수단

《【문제2】하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상의 권리구제수단에 관하여 설명시오(단, 집행정지 및 임시처분은 제외함). (25점)》

<문제2> 하자있는 거부처분에 대한 행정심판법상 청구 및 재결의 실효성 확보수단

I. 문제의 제기

- 행정청의 거부처분에 하자가 있는 경우 당사자는 이에 대하여 행정심판을 청구하여 구제를 도모할 수 있다. 행정심판법은 사법절차의 한계를 넘어 행정청에 적극적 행위를 명하거나 직접 처분을 할 수 있는 독자적인 구제수단을 마련해 두고 있다. 이하에서는 거부처분에 대항하는 행정심판의 청구유형과 재결의 실효성을 확보하기 위한 수단들을 중심으로 실질적 권리구제방안에 대하여 설명한다.

II. 하자있는 거부처분에 대한 행정심판의 청구

1. 취소심판 및 무효등 확인심판

(1) 취소심판의 의의 및 가능성

- 거부처분은 행정소송법 및 행정심판법상 처분에 해당하므로 이에 대한 취소심판 청구가 가능하다.

(2) 무효등확인심판의 의의 및 가능성

- 거부처분의 하자가 중대하고 명백한 경우 당사자는 무효등확인심판을 청구할 수 있으며, 이 경우에도 개정법에 따라 피청구인에게 재처분의무가 성립하여 실질적 권리구제가 도모된다.

2. 의무이행심판

(1) 의의 및 성격

- 의무이행심판은 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 명하거나 직접 처분을 하는 이행청구적 심판으로, 행정심판법이 인정하는 독자적 제도다.

(2) 거부처분 구제에서의 실효성

- 거부처분에 대한 의무이행재결은 행정청의 거부로 침해된 당사자의 신청권과 실질적 이익을 가장 확실하고 신속하게 실현하는 수단으로 기능한다.

III. 재결의 실효성 확보수단

1. 재처분의무

(1) 기속력으로서의 재처분의무

- 행정심판의 재결은 피청구인인 행정청을 구속하는 기속력을 가지며, 거부처분 취소재결이나 의무이행재결이 내려지면 피청구인은 재결의 취지에 따라 다시 처분을 해야 할 의무를 진다.

(2) 대상 재결의 범위

- "행정심판법 제49조"에 따르면 거부처분의 취소재결, 무효등확인재결, 의무이행재결(처분재결 및 처분명령재결) 모두에 대해 행정청의 재처분의무가 명문으로 인정된다.

2. 직접처분 및 간접강제

(1) 위원회의 직접처분

① 의의 및 요건

- 처분명령재결에도 불구하고 행정청이 처분을 하지 아니하는 경우, 위원회는 청구인의 신청에 따라 시정을 명하고 기한 내에 이행하지 않으면 직접 처분을 할 수 있다.

② 인정 한계

- 해당 제도는 의무이행재결에만 인정되며, 거부처분 취소재결에는 적용되지 않는다.

(2) 간접강제제도

① 의의 및 요건

- 행정청이 재처분의무를 이행하지 않는 경우 위원회는 청구인의 신청에 따라 지연기간에 따른 배상을 명하거나 즉시 배상할 것을 명할 수 있는 간접강제 결정을 내릴 수 있다.

② 적용 범위

- 직접처분과 달리 취소재결, 무효등확인재결, 의무이행재결 모두에 전면 적용되는 강력한 구제 수단이다.

IV. 사안의 적용

1. 취소심판 청구의 한계와 구제

- 당사자가 거부처분 취소심판을 청구하여 인용재결을 얻은 경우 행정청은 재처분의무를 부담하나, 이를 불이행할 시 직접처분은 불가능하고 간접강제를 통해서만 피청구인의 의무 이행을 강제할 수 있다.

2. 의무이행심판 청구의 실효성 극대화

- 당사자가 의무이행명령재결을 얻었음에도 행정청이 이를 불이행하는 경우, 청구인은 간접강제를 신청하여 경제적으로 압박할 수 있을 뿐만 아니라 위원회에 직접처분을 신청하여 직접 권리구제를 받을 수 있다.

V. 결론

- 행정심판법은 하자있는 거부처분에 대하여 취소심판뿐만 아니라 의무이행심판이라는 강력한 구제수단을 인정하고 있다. 아울러 행정청의 재처분의무 불이행 시 이를 실효적으로 강제하기 위하여 직접처분과 간접강제 제도를 유기적으로 병행 배치함으로써 행정소송에 비하여 신속하고 전향적인 국민의 권리구제를 실현하고 있다.

<제11장 행정심판의 일반론.제03절 고지제도>

[기출][2015-1-1]개발행위 불허가 처분 시 불고지한 경우의 취소심판 청구기간의 경과 여부

《【문제1】 甲은 2015. 1. 16. 주택신축을 위하여 개발행위허가를 신청하였다. 이에 관할 행정청 乙은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」의 규정에 의거하여 `해당 개발행위에 따른 기반시설의 설치나 그에 필요한 용지의 확보계획이 적절하지 않다`라는 사유로 2015. 1. 22. 개발행위 불허가 처분을 하였고, 그 다음날 甲은 그 사실을 알게 되었다.

그런데 乙은 위 불허가 처분을 하면서 甲에게 그 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 행정심판을 청구하는 경우의 심판청구 절차 및 심판청구기간을 알리지 아니하였다. 甲은 개발행위 불허가 처분에 불복하여 2015. 5. 7. 행정심판위원회에 취소심판을 청구하였다. 아울러 甲은 적법한 취소요건을 갖추어 취소소송도 제기하였다. (50점)

(물음1) 甲의 취소심판은 청구기간이 경과되었는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 개발행위 불허가 처분 시 불고지한 경우의 취소심판 청구기간의 경과 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 개발행위 불허가처분을 받은 후 행정청으로부터 행정심판에 관한 고지를 받지 못한 상태에서 일정 기간이 경과한 후 취소심판을 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정청이 행정심판의 청구절차 및 청구기간 등을 고지하지 않은 경우 甲의 취소심판이 행정심판 청구기간을 도과한 것으로 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판 청구기간의 진행 여부와 행정청의 불고지가 청구기간에 미치는 영향에 대해 설명한다.

II. 행정심판 청구기간 및 불고지의 법적 성격

1. 행정심판 청구기간의 원칙

(1) 주관적 청구기간

- "행정심판법 제27조 제1항"에 따르면 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 이는 처분의 존재를 현실적으로 안 날을 의미하며, "제27조 제4항"에 따라 이 기간은 행정청이나 위원회가 임의로 늘릴 수 없는 불변기간에 해당한다.

(2) 객관적 청구기간

- "동법 제27조 제3항"에 따르면 행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 청구하여야 한다. 주관적 청구기간과 객관적 청구기간 중 어느 하나라도 먼저 도과하면 해당 행정심판 청구는 부적법각하 처분을 면할 수 없다.

2. 피청구인의 불고지와 청구기간의 예외

(1) 고지의무의 의의

- "행정절차법 제26조" 및 "행정심판법 제58조 제1항"은 행정청이 처분을 하는 때에는 처분의 상대방에게 행정심판을 청구할 수 있는지 여부, 청구절차 및 청구기간을 알려야 할 의무를 명문으로 규정하고 있다.

(2) 불고지의 효과 및 예외적 청구기간

- 행정청이 고지의무를 이행하지 않아 처분 상대방에게 청구기간을 알리지 아니한 경우(불고지), "행정심판법 제27조 제6항"에 따라 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판청구를 제기할 수 있는 특례가 인정된다. 이 경우 주관적 청구기간인 90일의 제한은 적용되지 않고 객관적 청구기간만이 제척기간의 기준으로 작용한다.

III. 사안의 적용

1. 일반 청구기간 도과 여부 검토

(1) 주관적 청구기간의 기산 및 도과

- 사안에서 甲은 乙의 개발행위 불허가 처분이 있었던 다음 날인 2015년 1월 23일에 처분 사실을 알게 되었다. "행정기본법 제6조 제1항 제1호"에 따라 초일을 산입하지 않고 다음 날인 1월 24일부터 90일을 기산하면 만료일은 2015년 4월 23일이 된다. 甲의 심판청구일은 2015년 5월 7일이므로, 일반적인 주관적 청구기간(90일)은 이미 도과하였다.

(2) 객관적 청구기간의 기산 및 도과

- 처분이 있었던 날인 2015년 1월 22일의 다음 날인 1월 23일부터 객관적 청구기간인 180일을 기산하면 그 만료일은 2015년 7월 21일이 된다. 만약, 일반 원칙이 적용된다면 주관적 청구기간이 도과하였으므로 청구기간 경과로 부적법해진다.

2. 불고지에 따른 특례 적용 여부

(1) 乙의 불고지 사실 존부

- 관할 행정청 乙은 2015년 1월 22일 불허가 처분을 하면서 행정심판 청구 가능 여부, 절차, 기간을 전혀 알리지 않았다. 이는 "행정심판법 제58조"가 규정하는 고지의무를 직접적으로 위반한 명백한 불고지에 해당한다.

(2) 특례 적용에 따른 적법성 판단

- 불고지가 존재하므로 "행정심판법 제27조 제6항"에 따른 특례가 전면 적용된다. 따라서 甲의 청구기간은 처분이 안 날부터 90일이 아닌, 처분이 있었던 날인 2015년 1월 22일의 다음 날부터 기산하는 180일이 된다. 만료일인 2015년 7월 21일 이전에 해당하는 2015년 5월 7일에 취소심판을 청구하였으므로, 제척기간을 적법하게 준수한 청구이다.

IV. 결론

- 乙이 청구기간을 고지하지 아니한 불고지의 하자가 존재하므로, "행정심판법 제27조 제6항"의 불고지 특례가 적용되어 있었던 날부터 180일의 제척기간이 부여된다. 甲이 제기한 심판청구는 180일의 만료일인 2015년 7월 21일 이전인 2015년 5월 7일에 행해진 것으로서 적법하다. 결론적으로 甲의 취소심판은 청구기간이 경과하지 않았다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-1]처분의 개념과 행정청의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 `시정권고`를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음1) 행정심판법 제2조 제1호에서 규정하는 `처분`의 개념과 관련하여, 행정청 A의 `시정권고`가 행정심판의 대상인 처분에 해당하는지 여부를 판례의 입장에 근거하여 논하라.》

<문제12.1의 물음1> 처분의 개념과 행정청 A의 시정권고가 행정심판의 대상인지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A가 甲에게 관계 법령 위반을 이유로 시정권고를 통지하였고, 甲은 해당 권고가 영업 자유를 제한하는 행정심판 대상 처분에 해당한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판의 대상이 되는 처분의 개념과 비권력적 행정작용인 시정권고가 처분에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정청 A의 시정권고가 행정심판법상 처분에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 행정심판의 대상으로서의 처분

1. 처분의 개념

- "행정심판법 제2조 제1호"는 처분을 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라고 정의하고 있다. 이는 행정소송법상의 처분 개념과 동일하게 해석되는 것이 일반적이다.

2. 처분성의 판단 기준

- "판례"는 처분인지 여부를 판단함에 있어 그 행위의 성질·태양 및 목적, 응답의무의 존부, 주권자인 국민의 권리의무에 직접 관계되는 것인지 여부, 그리고 당해 행정작용의 실질적 영향력 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단한다. 특히, "최근 판례"는 국민의 권익구제의 폭을 넓히기 위하여 형식적인 법적 효력 유무에만 집착하지 않고 실질적인 불이익 여부를 중시하는 경향이 있다.

III. 시정권고의 행정지도적 성격과 처분성

1. 행정지도와 시정권고의 일반적 성격

- "행정절차법 제2조 제1호"에 따르면 행정지도는 행정기관이 그 직무 범위 안에서 일정한 행정 목적을 달성하기 위하여 특정인에게 일정한 작위 또는 부작위를 권고, 금지, 안내하는 등의 비권력적 사실행위를 말한다. 시정권고는 명칭상 권고의 형식을 띠고 있어 원칙적으로 상대방의 임의적인 협력을 전제로 하므로 법적 구속력이 없는 행정지도에 해당한다.

2. 처분성 인정 여부에 관한 판례의 입장

(1) 원칙적 부정

- "전통적 판례"는 행정지도가 상대방의 자발적 동의를 기초로 하는 것이며 그 자체만으로는 어떠한 법적 권리나 의무를 설정하지 않으므로 처분성이 없다고 보았다. 단순히 사실상의 강제력을 갖는 것만으로는 부족하다는 취지이다.

(2) 예외적 인정(실질적 판단)

- "최근 판례"는 행정지도가 형식상으로는 권고의 형태를 띠더라도 실질적으로 법령의 위반을 전제로 하고, 이를 따르지 않을 경우 후속적인 제재 처분(영업정지, 과태료 부과 등이 예정되어 있어 사실상 강제력을 행사하는 경우에는 처분성을 인정한다. 즉, 당해 행위가 상대방에게 법적 불이익을 수 인하도록 강요하는 효과가 있다면 행정쟁송의 대상으로 삼을 수 있다는 것이다.

(3) 구체적 사례(국가인권위원회 등의 권고)

- 국가인권위원회의 성희롱 결정 및 시정권고와 관련하여 "판례"는 비록 권고의 형식을 취하고 있으나, 당사자의 명예에 직접적인 타격을 가하고 향후 신분상 불이익을 초래할 가능성이 크다는 점을 근거로 처분성을 인정한 바 있다.

IV. 사안의 적용

1. 시정권고의 실질적 영향력 분석

- 사안에서 행정청 A의 시정권고는 관계 법령 위반을 이유로 하고 있다. 법령 위반을 이유로 한 권고는 통상적으로 이를 이행하지 않을 경우 행정청이 강제적인 제재 처분으로 나아갈 것임을 예고하는 전단계 행위로서의 성격을 갖는다.

2. 甲의 영업의 자유 제한 여부

- 甲은 해당 권고가 사실상의 강제력을 가져 영업의 자유를 제한한다고 주장한다. 만약 이 시정권고가 단순한 안내에 그치지 않고, 명단 공개나 후속 제재 처분의 직접적인 요건이 되는 등 甲에게 실질적인 법적 지위의 불안이나 불이익을 초래한다면 행정심판법상 처분으로 보아 다룰 수 있어야 한다.

3. 검토

- "판례"의 법리에 따라, 행정청 A의 시정권고가 단순히 권고의 수준을 넘어 상대방에게 법적 의무 이행을 강요하는 실질적 효과를 지닌다면 이는 행정심판의 대상인 처분에 해당한다고 보아야 한다.

V. 결론

- 행정심판의 대상인 처분은 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 공권력 행사를 의미한다. 행정청 A의 시정권고는 형식적으로는 비권력적 사실행위인 행정지도에 해당하여 원칙적으로 처분성이 부정되나, "판례"는 그 실질적인 영향력을 고려하여 예외적으로 처분성을 인정하고 있다. 따라서 사안의 시정권고가 법령 위반을 전제로 하여 甲에게 사실상의 복종을 강요하고 불이행 시 제재가 예정되어 있는 등 실질적인 불이익을 주는 작용이라면, 甲은 이에 대하여 행정심판을 청구하여 그 적법성을 다툴 수 있다. 이러한 법리는 행정 작용의 형식이 점차 다양해짐에 따라 국민의 권익이 사각지대에 놓이지 않도록 처분의 개념을 유연하게 해석하려는 현대 행정쟁송법의 흐름과 궤를 같이한다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제01절 행정심판의 대상적격>

[예상][12.01-2]부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

《【문제12.1】

<사례>

행정청 A는 관내에서 영업하는 甲이 관계 법령을 위반하였다는 이유로 `시정권고`를 통지하였다. 甲은 이 권고가 사실상의 강제력을 가져 자신의 영업 자유를 제한한다고 주장하며 행정심판을 청구하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B에게 특정 인허가를 신청하였으나, 행정청 B는 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고 허가나 거부 중 어떠한 처분도 하지 않고 있다. 乙은 이러한 행정청 B의 무반응에 대하여 행정심판을 통해 구제받고자 한다. 또한, 丙은 소속 공무원이었던 자로서 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판법에 따른 행정심판을 제기하려고 한다.

(물음2) 乙이 행정청 B의 무반응에 대하여 제기할 수 있는 행정심판의 종류를 제시하고, 행정심판법상 `부작위`가 성립하기 위한 요건을 설명하라. 또한, 丙이 행정심판법에 따른 행정심판을 청구할 수 없는 예외적인 사유가 존재하는지 행정심판법 제3조를 중심으로 서술하라.》

<문제12.1의 물음2> 부작위에 대한 행정심판의 종류, 부작위 성립 요건 및 행정심판 제기의 예외 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B가 인허가 신청에 대하여 상당한 기간 동안 아무런 처분을 하지 않는 부작위 상태에 있고, 丙은 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분에 대하여 행정심판 청구 가능 여부가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 부작위에 대한 의무이행심판의 요건과 행정심판법 제3조에 따른 행정심판 청구 제한 사유의 존재 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기할 수 있는 부작위에 대한 행정심판의 종류와 성립요건 및 丙이 행정심판을 청구할 수 없는 사유가 존재하는지 서술한다.

II. 부작위에 대한 행정심판의 종류 및 성립 요건

1. 행정심판의 종류

- 행정청의 부작위에 대하여 乙이 제기할 수 있는 행정심판은 크게 의무이행심판이다. "행정심판법 제5조 제3호"에 따르면 의무이행심판은 행정청의 부당하거나 위법한 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다. 현행 행정심판법은 부작위위법확인심판을 별도로 두지 않고 의무이행심판으로 통합하여 운영하고 있다.

2. 부작위의 성립 요건

(1) 당사자의 신청

- 부작위가 성립하기 위해서는 먼저 법령에 근거하여 행정청에 대하여 특정한 처분을 구하는 당사자의 적법한 신청이 있어야 한다. 사안에서 乙이 행정청 B에게 인허가를 신청한 사실이 이에 해당한다.

(2) 행정청의 처분 의무

- 행정청에게 신청에 대하여 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재해야 한다. 이는 법령상 명시적인 의무뿐만 아니라 해석상 응답 의무가 인정되는 경우도 포함한다.

(3) 상당한 기간의 경과

- 행정청이 신청을 수리한 후 사회통념상 해당 처분을 하기에 충분한 상당한 기간이 경과하였어야 한다. 사안에서도 상당한 기간이 경과하였음이 명시되어 있다.

(4) 행정청의 무반응

- 행정청이 인가·허가 등의 긍정적 처분뿐만 아니라 거부처분과 같은 부정적 처분조차 하지 않은 상태여야 한다. 만약 거부처분을 하였다면 이는 부작위가 아니라 거부처분 취소심판이나 의무이행심판의 대상이 된다.

III. 행정심판 청구의 예외적 사유

1. 행정심판법 제3조의 취지

- "행정심판법 제3조 제1항"은 모든 처분과 부작위에 대하여 행정심판을 제기할 수 있음을 원칙으로 하되, 사안의 성질상 행정심판법에 따른 심판 절차를 거치는 것이 부적절하거나 특별한 불복 절차가 마련되어 있는 경우에는 예외를 인정하고 있다.

2. 행정심판법 적용 제외 대상

- "행정심판법 제3조 제2항"은 대통령의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판을 제기할 수 없다고 규정한다. 그러나 丙의 사례는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분이므로 이에 해당하지 않는다.

3. 다른 법률에 따른 특별한 불복 절차

- 특정 기관의 행위에 대하여는 헌법적 지위나 절차의 특수성을 고려하여 행정심판법에 따른 행정심판 대신 별도의 특별행정심판이나 소송 절차만을 허용하는 경우가 있다.

(1) 선거관리위원회 처분의 특수성

- 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 그 기관의 독립성과 전문성을 고려할 때 일반 행정심판위원회의 심리 대상으로 삼기에 부적절할 수 있다.

(2) 丙의 사례에 대한 적용

- 중앙선거관리위원회 위원장의 파면 처분과 같은 인사에 관한 사항은 국가공무원법 등에 따라 소청심사라는 특별한 행정심판 절차를 거쳐야 하거나, 기관의 특성상 행정심판법의 일반적 절차가 배제될 수 있다. 특히, "행정심판법 제3조 제1항"은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 예외로 두고 있는데, 선거관리위원회 위원장의 행위 등 헌법기관의 처분에 대해서는 해당 기관 내부에 설치된 위원회나 특별법에 따른 절차를 따르도록 규정된 경우가 많으므로 丙은 행정심판법상의 일반 행정심판을 청구할 수 없는 예외적 상황에 처할 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 구제 수단

- 乙은 행정청 B의 인허가 신청에 대한 무반응에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있다. 사안은 乙의 신청이 있었고, 상당한 기간이 지났으며, 행정청 B가 아무런 응답을 하지 않고 있으므로 행정심판법상 부작위 요건을 모두 충족한다. 따라서 乙은 행정심판위원회에 처분을 이행할 것을 구하는 심판을 청구할 수 있다.

2. 丙의 행정심판 청구 가능성 검토

- 丙이 다투고자 하는 중앙선거관리위원회 위원장의 처분은 "행정심판법 제3조 제1항"의 예외 사유에 해당할 가능성이 매우 높다. 헌법기관인 선거관리위원회의 처분은 그 독립성을 존중하여 일반 행정심판위원회의 감독을 받지 않으며, 소청심사와 같은 별도의 행정심판 절차가 마련되어 있거나 직접 행정소송으로 다투어야 할 사안에 해당하므로 丙이 행정심판법에 따른 일반 행정심판을 청구하는 것은 부적법할 것으로 판단된다.

V. 결론

- 乙은 행정청 B의 부작위에 대하여 의무이행심판을 통해 구제받을 수 있으며, 이는 행정청의 처분 의무와 상당 기간의 무응답이라는 부작위 요건을 충족하였기 때문이다. 반면 丙의 경우 처분청이 중앙선거관리위원회 위원장이라는 점과 파면이라는 인사 처분의 특성상, "행정심판법 제3조 제1항"이 규정하는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 등에 해당하여 일반 행정심판법에 따른 심판 청구는 허용되지 않을 것이다. 이러한 법리는 행정청의 무분응에 대한 실효적 구제 수단을 제공함과 동시에, 헌법상 독립기관이나 대통령의 처분 등에 대해서는 일반적 심판 절차의 예외를 설정함으로써 권력분립과 행정의 특수성을 조화시키려는 취지를 담고 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제02절 행정심판의 당사자자격>

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제04절 행정심판기관>

[기출][2024-2]중앙노동위원회 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판 청구 시 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격

《[문제2] 甲은 인터넷설치서비스업을 행하는 법인이다. 甲이 2024. 1. 22. 고객민원 및 직원 간의 불협화음 등을 이유로 甲 소속 근로자 A에게 정직 7개월의 징계처분을 하자, A는 2024. 1. 26. 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 2024. 2. 27. 징계사유가 인정되고 징계양정이 과하다고 볼 수 없다는 이유로 A의 구제신청을 기각하였다. A는 2024. 3. 4. 관할 지방노동위원회의 판정에 불복하여 중앙노동위원회에게 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2024. 4. 30. 관할 지방노동위원회의 판정을 취소하고 A에게 행한 정직은 부당정직임을 인정하면서 甲에게 판정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 A에 대한 정직을 취소하고 정직기간 중 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라고 구제명령(이하 '이 사건 구제명령'이라 한다)을 하였다. 한편, 중앙노동위원회는 2024. 6. 26. 甲이 이행기한까지 이 사건 구제명령을 이행하지 않았다는 이유로 이행강제금을 부과할 것임을 예고하였다. 이후 중앙노동위원회는 2024. 8. 7. 甲에게 '구제명령 완전 불이행'의 이유로 250만원의 이행강제금 부과처분(이하 '이 사건 부과처분'이라 한다)을 하였다. 한편, 甲은 2024. 8. 5. 인사위원회를 개최하여 A에 대한 정직 취소를 의결한 바 있다. 이 사건 부과처분의 위법을 이유로 취소심판을 청구하려고 한다. 이 경우 행정심판기관의 관할과 피청구인 적격에 관하여 검토하시오. (25점)》

<문제2> 중앙노동위원회 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판 청구 시 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격

I. 문제의 제기

- 사안은 중앙노동위원회가 단행한 이행강제금 부과처분에 대하여 甲 법인이 취소심판을 제기하려는 경우이다. 쟁점으로 <부당정직 구제명령 불이행에 따른 이행강제금 부과처분이 행정심판의 대상이 되는지>, <행정심판을 제기할 때 관할 행정심판기관이 어디인지>, <피청구인 적격을 갖는 자가 누구인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이 사건 부과처분의 행정심판 대상성을 규명하고, 이에 따른 관할 행정심판위원회 및 피청구인 적격에 관한 법리를 검토한다.

II. 관할 행정심판기관 및 피청구인 적격의 법리

1. 이행강제금 부과처분의 행정심판 대상성

(1) 일반 행정처분성

- "행정심판법 제3조 제1항"에 따라 행정심판은 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여 제기할 수 있다. "근로기준법 제33조 제1항"에 따른 이행강제금 부과처분은 사용자에 대하여 구체적인 금전 부과 의무를 지우는 처분이므로 행정심판의 대상이 된다.

(2) 재심판정과의 구별

- "노동위원회법 제27조 제1항"에 따른 중앙노동위원회의 재심판정은 행정소송의 대상만 될 뿐 행정심판을 제기할 수 없다. 반면 이 사건 이행강제금 부과처분은 재심판정이 아닌 근로기준법상 구제명령의 실효성 확보를 위해 행하는 일반 행정처분이므로 행정심판에 의한 취소가 허용된다.

2. 관할 행정심판기관의 법리

(1) 관할 지정의 일반원칙

- "행정심판법 제6조 제2항 제1호"에 따르면 중앙행정기관 또는 그 소속 행정청의 처분이나 부작위에 대한 행정심판 청구는 국민권익위원회에 설치된 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다.

(2) 중앙노동위원회의 지위

- 중앙노동위원회는 고용노동부장관 소속으로 설치된 합의제 행정기관이나, 노동위원회법에 의해 독립적인 권한을 행사하는 중앙행정기관의 지위를 가진다. 따라서 중앙노동위원회가 행한 처분의 취소를 구하는 행정심판은 중앙행정심판위원회가 관할한다.

3. 피청구인 적격의 법리

(1) 피청구인 지정의 원칙

- "행정심판법 제17조 제1항"에 따라 행정심판은 처분을 한 행정청을 피청구인으로 하여야 한다. 처분을 한 행정청이란 외부적으로 자기 명의로 의사결정하여 표시하는 기관을 뜻하며, 합의제 행정청도 포함된다.

(2) 노동위원회법 제27조 제1항의 특칙 배제

- "노동위원회법 제27조 제1항"은 재심판정에 대한 소송의 피고를 중앙노동위원회 위원장으로 규정하는 특칙을 두고 있으나, 이는 재심판정에 한하여 적용된다. 이행강제금 부과처분은 재심판정이 아니므로 일반 원칙에 따라 처분청인 합의제 행정기관 중앙노동위원회 자체가 피청구인이 된다.

III. 사안의 적용

1. 이 사건 행정심판의 관할 행정심판기관

- 이 사건 부과처분은 중앙노동위원회가 2024. 8. 7. 甲에게 행한 250만 원의 이행강제금 부과처분이다. 중앙노동위원회는 중앙행정기관의 지위를 가지므로, "행정심판법 제6조 제2항 제1호"에 의거하여 취소심판의 관할 기관은 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회가 된다.

2. 이 사건 취소심판의 피청구인 적격

- 이 사건 부과처분은 외부적으로 합의제 행정청인 중앙노동위원회의 명의로 발령되었다. 또한 이 사건 부과처분은 재심판정이 아니므로 노동위원회법상 피고 특칙이 적용되지 않는다. 따라서 "행정심판법 제17조 제1항"에 따라 처분청인 중앙노동위원회가 피청구인 적격을 가진다.

IV. 결론

- 이 사건 이행강제금 부과처분에 대한 취소심판의 관할 행정심판기관은 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회이며, 피청구인 적격을 가지는 처분청은 중앙노동위원회가 된다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-1]불고지에 따른 행정심판의 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 `영업정지 1개월 처분`을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다 (불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음1) 甲이 2025년 9월 10일에 행정심판을 청구하는 경우, 행정심판법 제27조에 규정된 `행정심판 청구기간`의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 특례를 중심으로 해당 청구가 적법한지 여부를 논하라.》

<문제12.3의 물음1> 불고지에 따른 행정심판 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 甲에게 영업정지 1개월 처분을 하면서 행정심판 청구기간 등에 관한 사항을 고지하지 않았고, 甲은 처분이 있는 날로부터 4개월이 경과한 후 행정심판을 청구하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 청구기간의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례가 적용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 행정심판 청구가 청구기간을 준수하여 적법한지 논한다.

II. 행정심판 청구기간의 원칙

1. 주관적 청구기간

- "행정심판법 제27조 제1항"에 따라 행정심판은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내에 청구하여야 한다. 여기서 처분이 있음을 알게 된 날이란 통지나 공고 등 처분이 있음을 현실적으로 안 날을 의미한다.

2. 객관적 청구기간

- "동법 제27조 제3항"에 따라 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 이는 처분이 있음을 알지 못한 경우에도 적용되는 절대적인 기간이다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 예외적으로 인정될 수 있다.

3. 기간의 성격

- 행정심판 청구기간은 불변기간이 아니나(심판법상 명시적 규정 없음), 기간이 경과하면 해당 처분을 더 이상 다룰 수 없는 확정력(불가쟁력)이 발생하므로 소송요건의 하나로서 엄격히 준수되어야 한다.

III. 행정청의 불고지에 따른 청구기간의 특례

1. 고지제도의 의의 [행정심판법 제58조]

- 행정청은 처분을 할 때 상대방에게 행정심판 청구 가능 여부, 청구 절차 및 기간 등을 알려야 할 의무가 있다. 이는 국민의 알 권리를 보장하고 행정쟁송의 기회를 실효적으로 제공하기 위함이다.

2. 불고지의 효과 [행정심판법 제27조 제6항]

- 행정청이 처분을 하면서 심판 청구 기간을 알리지 아니한 경우(불고지)에는 "동법 제27조 제3항"에 따른 기간, 즉 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판 청구를 할 수 있다.

3. 특례의 취지

- 행정청의 고지 의무 위반으로 인해 청구인이 90일이라는 단기적인 주관적 청구기간을 지키지 못한 책임을 청구인에게 전가하지 않기 위한 것이다. 따라서 불고지의 경우에는 주관적 청구기간(90일)은 적용되지 않고 오직 객관적 청구기간(180일)만이 적용된다.

IV. 사안의 적용

1. 주관적 청구기간 준수 여부 검토

- 甲은 2025년 5월 1일에 처분서를 수령하였으므로 처분이 있음을 안 날은 2025년 5월 1일이다. 원칙적인 청구기간인 90일을 적용하면 2025년 7월 말경에 기간이 만료되므로, 90일이 지난 2025년 9월 10일의 청구는 원칙적으로 부적법하다.

2. 불고지 특례의 적용

- 그러나 행정청 A는 처분 시 청구 기간을 전혀 기재하지 않았다. "행정심판법 제27조 제6항"에 따라 甲에게는 90일의 기간이 적용되지 않고 처분이 있었던 날부터 180일의 기간이 적용된다.

3. 구체적인 기간 계산

- 처분이 있었던 날인 2025년 5월 1일부터 180일을 계산하면 2025년 10월 하순경까지 청구가 가능하다. 甲이 행정심판을 청구한 날은 2025년 9월 10일이므로, 이는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 해당한다.

V. 결론

- 행정심판법은 행정청의 고지 의무 이행을 담보하고 국민의 쟁송권을 보호하기 위하여 불고지 시 청구기간의 특례를 두고 있다. 사안에서 행정청 A의 불고지로 인해 甲에게는 처분이 있었던 날부터 180일의 청구기간이 보장된다. 甲이 2025년 9월 10일에 제기한 행정심판 청구는 처분이 있음을 안 날부터 90일은 경과하였으나, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 제기된 것이므로 청구기간을 준수한 적법한 청구에 해당한다. 이러한 법리는 행정청의 절차적 의무 위반이 국민의 실질적인 권리 구제 기회를 박탈하지 않도록 차단하는 장치로서, 행정의 투명성과 책임성을 강조하는 행정심판법의 기본 정신을 반영하고 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

[예상][12.03-2]피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

《【문제12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 `영업정지 1개월 처분`을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음2) 乙의 사례와 같이 피청구인을 잘못 지정하여 행정심판을 청구한 경우, 행정심판법상 어떠한 구제 절차가 마련되어 있는지 `피청구인의 경정` 제도를 중심으로 설명하라.》

<문제12.3의 물음2> 피청구인을 잘못 지정한 경우의 구제 절차와 피청구인의 경정 제도

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 행정청 B의 인허가 거부처분에 대하여 행정심판을 청구하면서 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 지정하여 청구한 상황이다. 쟁점으로 <행정심판 청구 시 피청구인을 잘못 지정한 경우 이를 보정할 수 있는 행정심판법상 피청구인의 경정 제도의 요건과 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙의 잘못된 피청구인 지정에 대한 구제 절차로서 피청구인의 경정 제도에 대해 설명한다.

II. 피청구인의 경정 제도 일반론

1. 의의

- 피청구인의 경정이란 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 원래의 피청구인을 물러나게 하고 정당한 피청구인으로 교체하는 것을 말한다. 이는 청구인의 단순한 실수로 인하여 본안 심리도 받지 못하고 권리구제 기회를 박탈당하는 불합리한 결과를 방지하기 위한 제도이다.

2. 법적 근거

- "행정심판법 제17조"는 피청구인의 경정에 관하여 규정하고 있다. 특히 "제1항"은 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우 위원회가 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 피청구인을 경정할 수 있음을 명시하고 있다.

III. 피청구인 경정의 요건 및 절차

1. 경정 요건

(1) 피청구인의 오지정

- 청구인이 피청구인을 잘못 지정한 것이 명백해야 한다. 사안의 乙과 같이 처분청인 B 대신 행정심판위원회를 피청구인으로 기재한 경우는 전형적인 오지정에 해당한다.

(2) 심판청구의 계속

- 해당 행정심판이 위원회에 계속 중이어야 한다. 즉, 아직 심결이 내려지기 전이라면 사실심 단계에서 언제든지 가능하다.

2. 경정 절차

(1) 신청 또는 직권에 의한 경정

- 청구인이 스스로 잘못을 깨닫고 경정을 신청할 수 있을 뿐만 아니라, 행정심판위원회 역시 오지정이 명백하다고 판단되면 청구인의 신청이 없더라도 직권으로 경정을 결정할 수 있다.

(2) 위원회의 결정

-위원회는 경정 사유가 인정되면 경정 결정을 내린다. 이때 위원회는 종전의 피청구인과 새로운 피청구인 및 청구인에게 그 사실을 통지해야 한다.

IV. 경정의 효과 및 제소기간과의 관계

1. 소급효의 인정

- "행정심판법 제17조 제3항"에 따라 피청구인의 경정 결정이 있으면 새로운 피청구인에 대한 심판청구는 처음에 심판청구를 한 때에 제기된 것으로 본다. 즉, 피청구인을 잘못 지정했다라도 처음에 청구서를 제출한 시점을 기준으로 청구 기간의 준수 여부를 판단하므로 乙에게 매우 유리한 규정이다.

2. 종전 피청구인에 대한 소의 종료

- 새로운 피청구인으로서의 경정이 확정되면 종전의 잘못 지정된 피청구인에 대한 심판청구는 취하된 것으로 간주되어 소송 절차에서 탈퇴하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제 가능성

- 乙은 비록 피청구인을 행정심판위원회로 잘못 기재하였으나, 이는 "행정심판법 제17조"에 따른 경정 사유에 해당한다. 따라서 乙은 스스로 피청구인 경정 신청을 하거나, 위원회가 직권으로 행정청 B를 피청구인으로 변경하는 결정을 내림으로써 구제받을 수 있다.

2. 청구기간 준수 여부의 확정

- 乙이 처음에 행정심판위원회에 청구서를 제출한 시점이 거부처분에 대한 행정심판 청구기간 내였다면, 추후 피청구인이 행정청 B로 경정되더라도 처음에 제출한 날짜를 기준으로 기간 준수 여부를 판단하므로 제소기간 도과 문제는 발생하지 않는다.

VI. 결론

- 행정심판법상 피청구인의 경정 제도는 청구인의 절차적 실수를 교정해 주는 핵심적인 구제 수단이다. 乙의 사례와 같이 피청구인을 오인하여 청구한 경우, 위원회의 직권 또는 乙의 신청에 의한 경정 결정을 통해 정당한 처분청인 B를 상대로 심판 절차를 계속 진행할 수 있다. 이러한 제도는 행정심판이 단순한 법적 쟁송을 넘어 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 간이·신속한 구제 절차로서 기능하게 하는 밑거름이 된다. 이러한 법리는 형식주의를 탈피하여 실질적 법치주의를 실현하고자 하는 행정쟁송법의 기본 원리를 잘 보여주는 사례라 할 수 있다.

《【문제2】 취소심판의 재결이 내려지기 전에 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상의 잠정적인 권리구제수단에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 취소심판의 재결이 내려지기 전 청구인이 제기할 수 있는 행정심판법상 잠정적 권리구제수단

I. 문제 제기

- 행정심판은 원칙적으로 본안재결을 통하여 권리구제가 이루어진다. 그러나 본안재결이 있기까지 상당한 기간이 소요되며, 그 사이 처분의 집행으로 인해 청구인에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 수 있다. 따라서 행정심판법은 청구인의 권리를 잠정적으로 보호하기 위하여 집행정지와 임시처분이라는 제도를 두고 있다. 이하에서는 이들 제도의 의의와 요건 및 한계에 대하여 설명한다.

II. 집행정지

1. 의의

- 집행정지란 행정심판의 계속 중 처분 또는 그 집행이나 절차의 효력을 일시적으로 정지시켜, 본안재결 전까지 청구인의 권리를 잠정적으로 보호하는 제도를 말한다. 이는 소극적 권리구제수단으로서 처분의 효력 자체를 정지시키는 기능을 가진다.

2. 요건

(1) 본안 청구의 적법성

- 본안인 취소심판 청구가 적법하게 제기되어 있어야 한다.

(2) 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 처분의 집행으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 가능성이 있어야 한다. 단순한 불편이나 경미한 손해는 부족하다.

(3) 긴급한 필요성

- 손해 발생이 급박하여 본안재결까지 기다릴 수 없는 필요성이 인정되어야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향 없음

- 집행정지를 허용할 경우 공익에 중대한 해가 발생하지 않아야 한다.

(5) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것

- 본안에서 전혀 인용 가능성이 없는 경우에는 집행정지가 허용되지 않는다.

3. 한계

- 집행정지는 처분의 효력을 정지시키는 데 그치므로 적극적으로 청구인의 권리를 실현시키는 데에는 한계가 있다. 또한 공익적 고려가 우선되는 경우에는 인용되지 않는다.

III. 임시처분

1. 의의

- 임시처분은 집행정지로는 충분한 구제가 불가능한 경우에, 청구인의 권리 또는 법률상 이익을 실효적으로 보전하기 위하여 행정심판위원회가 잠정적으로 일정한 행위를 명하거나 금지하는 적극적 권리구제수단이다.

2. 요건

(1) 본안 청구의 적법성

- 본안심판 청구가 적법하여야 한다.

(2) 중대한 불이익 또는 급박한 위험 발생 우려

- 임시처분을 하지 않으면 청구인에게 중대한 불이익이나 급박한 위험이 발생할 우려가 있어야 한다.

(3) 집행정지로는 목적 달성 곤란

- 단순한 효력정지만으로는 권리보호가 충분하지 않은 경우여야 한다.

(4) 공공복리에 중대한 영향 없음

- 공익을 심각하게 해하지 않아야 한다.

(5) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것

- 본안에서 인용 가능성이 전혀 없는 경우에는 임시처분을 허용하지 않는다.

3. 특징

(1) 적극적 구제 가능

- 집행정지가 소극적 권리구제라면, 임시처분은 행위의 정지, 행위의 명령 등 적극적인 조치를 명할 수 있다.

(2) 보충성

- 집행정지로는 목적을 달성할 수 없는 경우에 한해 보충적으로 인정된다.

IV. 결론

- 행정심판법은 청구인의 권리보호를 위하여 본안재결 전에도 잠정적인 권리구제수단을 인정한다. 집행정지는 처분의 효력이나 집행을 정지시켜 본안재결 전 회복하기 어려운 손해를 예방하는 소극적 권리구제수단이다. 임시처분은 집행정지로는 부족한 경우 청구인의 권리 실현을 위하여 적극적인 행위를 명할 수 있는 보충적 권리구제수단이다. 따라서 본안재결 전에도 청구인은 이들 제도를 통하여 권리 보호를 잠정적으로 확보할 수 있다.

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제05절 가구제>

[기출][2018-1-1]거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성

《[문제1] 甲은 A국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009년 4월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010년 4월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015년 12월 귀화하였으나, 2016년 10월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017년 7월 乙과 혼인신고를 하고, 2017년 8월 관할행정청인 X에게 대한민국 국민의 배우자(F-6-1)자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7년여의 `불법체류`를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 `지침 등`이라 함)상 허가요건 중 하나인 `국내합법체류자`요건을 결여하게 되어 X는 2017년 8월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50점)

(물음1) 만일, 甲이 X의 반려처분에 불복하여 행정심판을 제기함과 동시에 임시처분을 신청하는 경우, 임시처분의 인용가능성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 대한민국 국민의 배우자 자격으로 체류자격 변경허가를 신청하였으나 X가 국내합법체류자 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 반려처분을 하였고, 甲은 이에 불복하여 행정심판과 함께 임시처분을 신청하려는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 임시처분의 요건과 체류자격 변경허가 반려처분에 대한 임시처분의 인용 가능성>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 임시처분 신청이 행정심판법상 요건을 충족하여 인용될 수 있는지 논한다.

II. 행정심판법상 임시처분의 일반 법리

1. 임시처분의 의의 및 집행정지와의 보충성 관계

(1) 임시처분의 의의

- 임시처분은 "행정심판법 제31조"에 근거한 가구제 수단으로, 처분이나 부작위로 인하여 발생하는 중대한 손해를 예방하거나 급박한 위험을 막기 위하여 당사자에게 임시의 지위를 설정해 주는 적극적 효력의 예외적 구제 제도이다.

(2) 집행정지와의 보충성 관계

- "행정심판법 제31조 제2항"은 임시처분이 집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 않는다고 규정하여 집행정지에 대한 보충성을 명시하고 있다. 따라서 소극적 가구제 수단인 집행정지가 가능한 영역에서는 임시처분을 청구할 수 없다.

2. 임시처분의 성립 요건

(1) 적극적 요건

- 임시처분이 인용되기 위해서는 ① 본안 심판청구가 적법하게 제기되어 계속 중이어야 한다. ② 처분이나 부작위가 위법·부당하다고 의심할 만한 상당한 이유가 있어야 한다. ③ 처분이나 부작위로 인하여 당사자가 중대한 손해를 입거나 급박한 위험에 처할 우려가 있어 임시의 지위를 정할 긴급한 필요성이 존재해야 한다.

(2) 소극적 요건

- ① 임시처분의 인용이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한다. ② 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에는 가구제의 필요성 자체가 조각되므로 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 집행정지에 대한 보충성 요건 충족 여부

(1) 거부처분과 집행정지의 한계

- X가 내린 반려행위는 신청을 거절하는 성격의 거부처분이다. 거부처분에 대하여 단순히 효력을 멈추는 집행정지 결정을 내리더라도, 처분 전의 상태인 무처분 상태로 소급할 뿐 행정청에게 가처분적 성격의 수리의무나 임시 허가 의무를 부과하는 적극적인 법적 효력은 발생하지 않는다.

(2) 임시처분의 허용성

- 따라서 거부처분은 집행정지 신청만으로는 신청인의 구제 목적을 실질적으로 달성할 수 없는 공백 영역에 해당한다. 이에 따라 "행정심판법 제31조 제2항"의 보충성 요건을 적법하게 충족하므로 임시처분의 신청 대상이 된다.

2. 긴급한 필요성 및 소극적 요건의 충족 여부

(1) 중대한 손해와 긴급한 필요성

- 甲은 체류자격 변경이 불허되는 경우 강제 출국을 당하여 귀화 후 이혼한 배우자 乙 및 최근 출산한 자녀와 즉시 격리되는 상황에 놓인다. 이는 신생아의 보호권과 가정을 유지할 헌법적 가치를 정면으로 위협하여 회복하기 어려운 중대한 손해와 급박한 위험에 해당하므로, 임시 체류 지위를 정해야 할 긴급한 필요성이 매우 명백하게 인정된다.

(2) 공공복리 영향 및 본안의 인용가능성

- 불법체류 경력이 존재하나 임시적인 체류 지위를 결정해 주는 것이 대한민국의 국가 안보나 공공복리에 직접적이고 중대한 위해를 끼친다고 보기 어렵다. 또한 본안 심판청구는 인도적 사정 및 아동의 복리라는 혼인과 가족생활 보장의 헌법적 가치를 간과하여 재량권을 일탈·남용한 실체법적 위법 사유가 상당하므로, 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에도 해당하지 않는다.

IV. 결론

- 결론적으로 甲이 거부처분에 대하여 제기한 임시처분 신청은 법원에 의해 인용될 가능성이 매우 높다. 반려처분(거부처분)은 집행정지만으로 구제 수단을 강구할 수 없어 보충성 요건을 완벽히 갖추었으며, 본안 심판청구의 위법성이 소명되고 강제 퇴거 시 발생할 가족 결핍권 침해 및 영유아 양육 곤란의 긴급성이 충분히 인정되기 때문이다. 따라서 행정심판위원회는 甲에게 본안 심판의 재결이 내려지기 전까지 대한민국에 임시로 체류할 수 있는 지위를 보장하는 임시처분 인용 결정을 내려야 한다.

<제13장 행정심판의 심리·재결.제01절 행정심판의 심리>

[예상][13.01-1]직권심리주의의 의미와 범위 및 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 한계

《【문제13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다는 행정심판위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 행정심판위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음1) 행정심판법 제39조에서 규정하는 `직권심리주의`의 의미와 범위에 비추어 볼 때, 행정심판위원회가 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여 심리할 수 있는지 여부와 그 한계에 대하여 서술하라.》

<문제13.1의 물음1> 직권심리주의의 의미와 범위 및 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 한계

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정심판위원회는 청구인 甲이 제출한 자료만으로 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다는 이유로 甲이 주장하지 않은 사실관계에 대하여 직권으로 조사하고 관련 증거를 수집한 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 직권심리주의의 의미와 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 가능 여부 및 그 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 행정심판위원회의 직권심리가 허용되는 범위와 한계에 대해 서술한다.

II. 행정심판의 심리 원칙과 직권심리주의

1. 심리 원칙의 구조

- 행정심판의 심리는 당사자의 주장과 증거제출을 기초로 하는 당사자주의를 원칙으로 하되, 행정의 적법성 확보와 공익 실현이라는 목적을 위해 직권주의적 요소를 가미하고 있다. 이를 직권탐지주의가 가미된 변론주의라고 한다.

2. 직권심리주의의 의미

- "행정심판법 제39조"는 행정심판위원회로 하여금 사건의 진상을 파악하여 객관적이고 공정한 재결을 내릴 수 있도록 심리의 능동성을 부여한다. 이는 법률 지식이 부족한 청구인을 보호하고 처분의 적법성을 실질적으로 심사하기 위한 장치이다.

III. 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 가능성

1. 심리의 범위

- 직권심리는 당사자가 제기한 심판청구의 대상이 되는 처분의 위법·부당성 여부를 판단하기 위한 범위 내에서 이루어진다. "판례"는 행정소송과 마찬가지로 행정심판에서도 처분의 동일성이 유지되는 범위 내에서는 당사자가 명시적으로 주장하지 않은 사유라도 기록에 나타난 자료를 바탕으로 심리할 수 있다는 입장이다.

2. 심리 가능한 사실의 성격

- 행정심판위원회가 심리할 수 있는 주장하지 않은 사실은 처분의 적법성을 판단하는 데 기초가 되는 사실관계나 증거를 의미한다. 즉, 청구인이 주장하는 위법 사유를 뒷받침하거나 반박하기 위해 필요한 객관적 정황들을 행정심판위원회가 직접 탐지할 수 있다.

IV. 직권심리주의의 한계

1. 처분의 동일성 유지

- 직권심리는 청구의 대상이 된 당해 처분의 범위를 벗어날 수 없다. 즉, 처분의 기초가 되는 기본적 사실관계의 동일성이 없는 전혀 새로운 처분 사유를 행정심판위원회가 임의로 찾아내어 재결의 근거로 삼는 것은 허용되지 않는다.

2. 불이익변경금지의 원칙

- 직권심리의 결과 처분이 위법함을 발견하더라도, 재결은 심판청구의 대상이 된 처분보다 청구인에게 불리한 내용으로 결정될 수 없다. ("행정심판법 제47조 제2항") 직권심리가 청구인의 지위를 악화시키는 도구로 사용되어서는 안 된다는 취지이다.

3. 당사자의 방어권 보장과 석명권

- 행정심판위원회가 직권으로 사실을 조사한 경우, 그 결과에 대하여 당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. 당사자가 전혀 예상하지 못한 사실을 근거로 재결하는 것은 방어권을 침해하는 기습적 판단이 될 수 있으므로, 행정심판위원회는 관련 사항에 대해 석명권을 행사하여 당사자의 의견을 들어야 한다.

V. 사안의 적용

1. 행정심판위원회의 조사 행위의 적정성

- 사안에서 행정심판위원회가 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계 파악이 어려워 직접 조사를 실시한 것은 "행정심판법 제39조"에 따른 정당한 직권심리 범위 내에 있다. 특히 성매매 알선이라는 중대한 사유에 대한 처분의 적법성을 따지기 위해 실체적 진실을 규명하는 것은 행정심판위원회의 의무이기도 하다.

2. 심리 범위의 한계 준수 여부

- 다만, 행정심판위원회는 조사한 새로운 사실관계가 영업허가 취소처분이라는 기존 처분의 기본적 사실관계 동일성 내에 있는지 확인해야 한다. 또한 조사된 사실이 甲에게 불리한 증거로 사용될 경우, 반드시 甲에게 그에 대한 반박이나 의견 진술의 기회를 부여함으로써 절차적 정당성을 확보해야 한다.

VI. 결론

- 행정심판법상 직권심리주의는 행정청의 처분에 대한 실체적 적법성을 확보하기 위해 인정되는 원칙이다. 따라서 행정심판위원회는 사안의 진상을 명확히 하기 위해 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여도 심리하고 조사할 수 있다. 그러나 이러한 권한은 처분의 동일성을 유지하는 범위 내로 제한되며, 당사자의 방어권을 보장하기 위해 고지 및 의견 진술의 기회를 부여해야 한다는 절차적 한계를 가진다. 사안의 행정심판위원회는 조사한 사실을 토대로 재결하되, 甲에게 해당 조사 결과에 대한 의견을 묻는 석명 절차를 거침으로써 직권심리의 한계를 준수해야 한다.

《【문제13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다는 행정심판위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 행정심판위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음2) 행정심판법 제40조에 따른 `구술심리`와 `서면심리`의 관계를 설명하고, 甲이 구술심리를 신청하였음에도 불구하고 위원회가 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적인 사유에 대하여 기술하라.》

<문제13.1의 물음2> 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청 거절의 예외적 사유

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 자신의 주장을 직접 진술하기 위하여 행정심판위원회에 구술심리를 신청하였으나, 행정심판위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만으로 재결하려는 상황이다. 정점으로 <행정심판법상 구술심리와 서면심리의 관계 및 구술심리 신청에도 불구하고 서면심리만으로 재결할 수 있는 예외 사유>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 구술심리 신청에 대한 행정심판위원회의 서면심리 가능 여부를 중심으로 기술한다.

II. 구술심리와 서면심리의 관계

1. 심리 방식의 의의

(1) 서면심리

- 당사자가 제출한 심판청구서, 답변서, 증거서류 등 서면 자료만을 바탕으로 사건을 파악하고 판단하는 방식이다. 신속한 처리가 가능하고 비용이 적게 든다는 장점이 있다.

(2) 구술심리

- 당사자나 대리인이 행정심판위원회에 직접 출석하여 말로 주장하고 진술하는 방식이다. 심판위원들이 당사자의 목소리를 직접 듣고 의문점을 즉석에서 확인할 수 있어 실체적 진실 규명과 당사자의 절차적 만족도 제고에 유리하다.

2. 행정심판법의 원칙(병행주의와 구술심리 신청권)

- 행정소송이 구술심리를 원칙으로 하는 것과 달리, "행정심판법 제40조 제1항"은 행정심판의 심리는 구술심리나 서면심리로 한다고 규정하여 양자를 선택적으로 병용할 수 있음을 밝히고 있다. 다만, "동조 제2항"은 당사자가 구술심리를 신청하면 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다고 규정함으로써, 당사자가 원하는 경우 구술심리를 원칙적인 심리 방식으로 보장하고 있다.

III. 서면심리만으로 결정할 수 있는 예외적 사유

- 행정심판위원회는 당사자의 구술심리 신청이 있더라도 다음의 경우에는 예외적으로 서면심리만으로 재결할 수 있다.

1. 서면심리만으로 충분하다고 인정되는 경우

- 사건의 쟁점이 법률적 해석에 국한되거나, 이미 제출된 서면 자료와 증거만으로도 처분의 위법·부당 여부가 객관적이고 명백하게 드러나는 경우이다. 굳이 당사자를 출석시켜 진술을 듣지 않더라도 실체적 진실을 파악하는 데 지장이 없다고 행정심판위원회가 판단할 때 해당한다.

2. 신청이 부적절하거나 지연 목적이 명백한 경우

- 당사자의 신청이 오로지 재결을 지연시키기 위한 목적이거나, 이미 충분한 진술 기회가 주어졌음에도 반복적인 주장을 위해 출석을 요구하는 등 심리의 효율성을 저해한다고 판단되는 경우 행정심판위원회는 이를 거부할 수 있다.

3. 절차적 경제와 효율성 고려

- 행정심판은 소송에 비해 간이하고 신속한 구제를 목적으로 하므로, 사안의 경중이나 복잡성에 비추어 구술심리에 소요되는 행정적 비용과 시간이 과다하다고 인정될 때 서면심리를 선택할 수 있는 재량이 행정심판위원회에 부여된다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 구술심리 신청권의 성격

- 甲은 자신의 억울함을 풀기 위해 구술심리를 명시적으로 신청하였다. "행정심판법 제40조 제2항"의 취지상 행정심판위원회는 특별한 사정이 없는 한 甲에게 출석하여 진술할 기회를 부여해야 한다.

2. 행정심판위원회의 서면심리 결정의 정당성 검토

- 행정심판위원회가 사건이 명백하다는 이유로 서면심리만 하려는 것은 법에서 정한 예외 사유 중 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우에 해당한다고 주장하는 것이다. 그러나 영업허가 취소라는 중의적 처분이고, 甲이 전혀 몰랐던 사실이라며 주관적 사정을 강력히 주장하고 있는 점을 고려할 때, 단순히 경찰 통보 내용만으로 사건이 명백하다고 단정하여 구술심리를 거부하는 것은 甲의 절차적 권리를 과도하게 제한할 우려가 있다.

3. 행정심판위원회의 재량과 한계

- 행정심판위원회가 서면심리를 강행할 수는 있으나, 이는 객관적으로 보아 서면만으로 충분하다는 판단이 합리적이어야 한다. 만약 甲의 주장에 대한 사실관계 확인이 더 필요하거나 감정적 억울함에 대한 소명이 처분의 부당성 판단(재량권 남용 등)에 영향을 미칠 수 있다면, 행정심판위원회는 구술심리 신청을 받아들이는 것이 타당하다.

V. 결론

- 행정심판법상 구술심리와 서면심리는 병행될 수 있으나, 당사자의 신청이 있는 경우에는 구술심리를 하는 것이 원칙이다. 다만, 행정심판위원회는 서면만으로도 처분의 적법성을 판단하기에 충분하다고 인정되는 예외적인 경우에 한하여 이를 거부하고 서면심리만으로 재결할 수 있다. 사안에서 행정심판위원회가 甲의 신청을 거절하고 서면심리만으로 결정하고자 한다면, 그것이 단순한 편의주의가 아니라 제출된 자료만으로도 충분히 객관적인 판단이

가능하다는 합리적 근거가 뒷받침되어야 한다. 이러한 판단은 행정심판의 신속성과 당사자의 절차적 권리 보장이라는 두 가치를 조화시키려는 노력의 일환이며, 특히 침익적 처분의 경우 당사자의 진술권을 폭넓게 보장하는 것이 실질적 법치주의에 부합한다.

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 행정심판 재결의 종류 (25점)》

<문제2의 물음1> 행정심판 재결의 종류

I. 문제 제기

- 행정심판은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대해 국민이 제기하는 쟁송 절차이며, 재결은 행정심판위원회(이하 `위원회`)가 심판 청구에 대한 심리를 거쳐 내리는 최종적인 판단이다. 이하에서는 행정심판법에서 규정하고 있는 재결에 대해 논한다.

II. 행정심판 재결의 종류

1. 각하재결

- 심판청구가 요건을 갖추지 못한 경우에 본안 심리 없이 청구를 배척하는 재결이다. 심판 요건은 청구 기간 준수, 청구인 적격, 피청구인 적격, 대상 적격 등을 포함한다. 예를 들어, 청구 기간을 넘겨 심판을 청구했거나, 심판 대상이 될 수 없는 사항에 대해 청구한 경우에 각하재결이 내려진다. 각하재결은 청구인의 권리 구제를 받을 자격 자체가 없다고 판단하는 것이므로, 본안 판단에 들어가지 않는다.

2. 기각재결

- 심판청구가 요건은 갖추었으나, 본안 심리 결과 청구인의 주장이 이유 없다고 판단될 때 청구를 배척하는 재결이다. 즉, 행정청의 처분이나 부작위가 위법하거나 부당하지 않다고 판단한 경우에 내려진다. 예를 들어, 행정처분이 법령에 따라 적법하게 이루어졌거나, 재량권의 범위를 벗어나지 않았다고 판단되는 경우이다. 기각재결은 본안 판단을 통해 청구인의 청구를 받아들이지 않는다는 점에서 각하재결과 구별된다.

3. 인용재결

- 심판청구가 이유 있다고 인정되어 청구인의 주장을 받아들이는 재결이다. 인용재결은 다시 취소재결, 무효확인재결, 의무이행재결로 나뉜다.

(1) 취소재결 [행정심판법 제43조 제3항]

① 의의

- 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 재결이다.

② 내용

- 위원회는 처분의 전부 또는 일부를 취소하거나, 처분을 다른 내용으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 과도한 영업정지 처분을 감경하여 정지 기간을 단축하는 변경재결도 가능하다.

③ 효과

- 취소재결이 확정되면 그 처분은 소급하여 효력을 상실하고, 행정청은 재결의 취지에 따라 재처분 의무를 진다. ("행정심판법 제49조 제2항")

(2) 무효확인재결 [행정심판법 제43조 제4항]

① 의의

- 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 재결이다.

② 내용

- 위원회는 처분이 무효임을 확인하거나, 유효임을 확인하는 재결을 내릴 수 있다.

③ 효과

- 처분이 무효임을 확인하는 재결은 해당 처분이 처음부터 효력이 없었음을 확인하는 것이므로, 별도의 처분 취소를 요하지 않는다.

(3) 의무이행재결 [행정심판법 제43조 제5항]

① 의의

- 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대해 일정한 처분을 하도록 명하는 재결이다. 이는 거부처분이나 부작위에 대한 가장 적극적인 구제 수단이다.

② 처분재결

- 위원회가 직접 신청에 따른 처분을 하는 재결이다. 이는 주로 기속행위나 재량권이 0으로 수축되는 경우에 예외적으로 인정된다.

③ 처분명령재결

- 피청구인인 행정청에게 신청에 따른 처분을 할 것을 명하는 재결이다.

④ 효과

- 의무이행재결이 내려지면 행정청은 재결의 취지에 따라 처분을 해야 할 의무를 진다. ("행정심판법 제49조 제3항") 만약 행정청이 이를 이행하지 않으면 위원회는 직접 처분이나 간접강제를 통해 재결의 실효성을 확보할 수 있다. ("행정심판법 제50조, 제50조의2")

4. 사정재결 [행정심판법 제44조]

(1) 의의

- 심판청구가 이유 있다고 인정(즉, 처분이 위법하거나 부당하다고 판단)되지만, 그 처분을 취소하거나 변경하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정할 때 심판청구를 기각하는 재결이다.

(2) 내용

- 처분의 위법·부당성을 인정하면서도 공익을 위하여 청구인의 권리 구제를 제한하는 재결이므로, 이때는 청구인에게 상당한 구제방법(예 : 손실 보상)을 취할 수 있다.

(3) 특징

- 사정재결은 본질적으로 인용재결의 성격을 가지지만, 공익을 위해 예외적으로 기각하는 것이므로, 청구인에게 불이익이 발생할 수 있다.

III. 결론

- 행정심판 재결은 각하재결, 기각재결, 인용재결, 사정재결로 구분된다. 각 재결은 고유의 제도적 장치로 기능한다. 따라서 행정심판 재결의 다양한 유형과 그 효과를 정확히 이해하는 것은 실무적 대응 및 권리구제 전략 수립에 있어 필수적이다.

《【문제3】이행재결의 기속력 확보수단으로서의 직접처분을 설명하시오. (25점)》

<문제3> 이행재결의 기속력 확보수단으로서의 직접처분의 의의, 취지, 요건, 효과

I. 문제의 제기

- 본 문제는 이행재결의 기속력을 확보하기 위한 수단으로서의 직접처분에 대해 설명하는 데 있다. 이는 행정심판의 실효성을 담보하기 위해 행정심판법이 마련한 중요한 제도적 장치이며, 불이행에 대한 강제수단으로서의 법적 의의, 제도적 취지, 요건 및 효과 등을 중심으로 검토하여야 한다.

II. 직접처분의 의의

- 직접처분이란 행정심판위원회가 인용재결(취소재결 또는 의무이행재결)에도 불구하고 피청구인인 행정청이 재결의 취지에 따른 처분을 하지 않을 때, 행정심판위원회가 직접 처분을 하는 것을 의미한다. 이는 행정심판의 재결에 실효성을 부여하기 위한 강력한 강제수단으로, "행정심판법 제50조"에 규정되어 있다.

III. 직접처분의 제도적 취지

- 직접처분 제도는 행정청의 불이행으로 인해 행정심판의 재결이 무력화되는 것을 방지하고, 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하기 위해 도입되었다. 특히 처분청이 거부처분에 대한 취소재결 또는 의무이행재결의 취지에 따른 처분을 하지 않는 경우, 당사자는 재결을 받았음에도 불구하고 원하는 결과를 얻지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 직접처분은 이러한 상황에서 행정심판위원회가 직접 나서서 처분을 함으로써 재결의 효력을 관철하고, 국민의 권리구제 제도를 완성하는 역할을 한다.

IV. 직접처분의 요건

- "행정심판법 제50조"에 따른 직접처분은 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

1. 인용재결의 존재

- 직접처분은 재결이 있어야 가능하며, 특히 피청구인에게 재처분 의무를 발생시키는 취소재결 또는 의무이행재결이 존재해야 한다.

2. 피청구인의 재결 취지 불이행

- 직접처분은 피청구인인 행정청이 재결의 취지에 따른 처분을 하지 아니하는 경우에 한하여 인정된다. 즉, 재결 이후 행정청이 상당한 기간 동안 아무런 조치를 취하지 않거나, 재결의 취지에 어긋나는 처분을 한 경우에 해당된다.

3. 직접처분이 가능한 처분

- 직접처분은 인용재결의 내용이 일정한 처분을 하도록 하는 것일 경우에만 가능하다. 이는 위원회가 직접 그 내용을 특정하여 처분할 수 있어야 한다는 의미이다.

4. 위원회의 결정

- 직접처분은 행정심판위원회의 직권 또는 당사자의 신청에 의해 결정된다. 위원회는 직접처분을 하기 전에 기간을 정하여 서면으로 시정을 명해야 하며, 이 시정명령에도 불구하고 행정청이 불이행하는 경우에 비로소 직접처분 결정을 내릴 수 있다.

V. 직접처분의 효과

- 직접처분은 다음과 같은 효과를 발생시킨다.

1. 처분의 효력

- "행정심판법 제50조 제2항"은 위원회가 한 직접 처분은 피청구인인 행정청이 한 처분으로 본다고 규정하고 있다. 이는 직접처분이 법적으로 피청구인인 행정청이 직접 한 처분과 동일한 효력을 가진다는 의미이다. 따라서 행정심판위원회가 직접 처분한 내용은 행정청의 행위로 간주되어 관련 법적 효과를 발생시킨다.

2. 재처분 의무의 소멸

- 직접처분이 이루어지면 피청구인에게 부과되었던 재결의 취지에 따른 재처분 의무는 소멸한다.

3. 간접강제와의 관계

- 직접처분은 행정청의 불이행에 대한 강력한 구제수단인 반면, 간접강제("행정심판법 제50조의2")는 지연기간에 따른 배상금 부과를 통해 이행을 심리적, 경제적으로 압박하는 수단이다. 두 제도는 상호 보완적인 관계에 있으며, 위원회는 사안의 특성과 불이행의 정도를 고려하여 적절한 수단을 선택하여 재결의 실효성을 확보할 수 있다.

VI. 결론

- 직접처분은 행정청이 행정심판 재결의 취지를 이행하지 않을 때, 행정심판위원회가 직접 처분을 하여 재결의 효력을 강제로 실현하는 제도이다. 이는 국민의 권리구제 실효성을 보장하고 행정심판 제도의 권위를 확립하기 위한 중요한 수단으로, 피청구인의 재결 불이행이라는 요건 아래 위원회의 직권 또는 당사자의 신청에 의해 이루어지며, 그 효과는 피청구인이 직접 처분한 것으로 간주된다.

《【문제2】 A국립대학교 법학전문대학원에 지원한 甲은 A국립대학교총장(이하 'A대학총장'이라 함)에게 자신의 최종입학점수를 공개해 줄 것을 청구하였으나, A대학총장은 영업비밀임을 이유로 공개거부결정을 하였다. 甲이 위 결정에 대하여 행정심판을 청구하였고 B행정심판위원회는 이를 취소하는 재결을 내렸다. 그럼에도 불구하고 A대학총장은 위 행정심판위원회의 재결을 따르지 아니하고 甲의 최종입학점수를 공개하지 아니하고 있다. 이에 甲이 행정심판법상 취할 수 있는 실효성 확보 수단을 설명하시오. (25점)》

<문제2> 입학점수 공개거부취소재결의 실효성 확보를 위한 행정심판법상 구제 수단

I. 문제의 제기

- 사안에서 A대학총장은 甲의 최종입학점수 공개거부결정에 대한 B행정심판위원회의 취소재결에도 불구하고 이를 이행하지 않고 공개하지 아니하는 상황이다. 쟁점으로 <행정심판법상 재결의 기속력과 행정청이 재결에 따른 의무를 이행하지 않는 경우 활용할 수 있는 실효성 확보 수단>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A대학총장의 재결 불이행에 대하여 甲이 취할 수 있는 행정심판법상 실효성 확보 수단에 대해 설명한다.

II. 재결의 기속력과 재처분의무의 법리

1. 재결의 기속력의 의의 및 성격

(1) 기속력의 의의

- "행정심판법 제49조 제1항"에 규정된 기속력은 심판청구를 인용하는 재결이 확정되었을 때 피청구인인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 실체법상의 효력이다.

(2) 기속력의 성격

- 기속력은 재결의 실효성을 담보하기 위한 행정심판법 고유의 실체법적 효력으로서, 재결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에 대하여 미치며 당연무효를 수반한다.

2. 거부처분 취소재결과 재처분의무

(1) 재처분의무의 성격

- 당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 재결이 있는 경우, 행정청은 지체 없이 이전의 신청에 대하여 재결의 취지에 따라 처분을 하여야 하는 적극적 의무를 부담한다.

(2) 행정심판법 제49조의 규정

- "행정심판법 제49조 제4항"은 신청을 거부하는 처분을 취소하거나 변경하는 재결이 있는 경우 동조 제2항의 재처분의무를 준용하도록 명시하여 법적 근거를 명확히 하고 있다.

III. 행정심판법상 실효성 확보 수단의 인정 범위

1. 위원회의 직접처분 [행정심판법 제50조]

(1) 직접처분의 의의

- 피청구인이 인용재결에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 청구인의 신청에 따라 위원회가 직접 처분을 할 수 있는 제도이다.

(2) 거부처분 취소재결의 직접처분 불허 (소극)

- "행정심판법 제50조 제1항"은 피청구인이 "제49조제2항"(의무이행재결에 따른 재처분의무)을 이행하지 않는 경우에만 직접처분을 할 수 있도록 규정하고 있다. 거부처분 취소재결에 따른 재처분의무를 규정한 "제49조제4항"은 직접처분의 대상에서 제외되어 있으므로, 거부처분 취소재결의 불이행에 대해서는 직접처분을 청구할 수 없다.

2. 위원회의 간접강제 [행정심판법 제50조의2]

(1) 간접강제의 의의

- 행정청이 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 위원회가 결정으로 상당한 기간을 정하고 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명함으로써 의무 이행을 간접적으로 강제하는 수단이다.

(2) 거부처분 취소재결의 간접강제 허용 (적극)

- "행정심판법 제50조의2 제1항"은 피청구인이 "제49조제2항"(제49조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 처분을 하지 아니하면 청구인의 신청에 따라 간접강제 결정을 내릴 수 있도록 명시하고 있다. 따라서 거부처분 취소재결 불이행 시 간접강제 청구는 당연히 허용된다.

IV. 사안의 적용

1. 직접처분의 불가능성

(1) 구체적 판단

- B행정심판위원회가 내린 재결은 A대학총장의 정보공개 거부결정을 취소하는 거부처분 취소재결에 해당한다.

(2) 소송법상 한계

- 앞서 고찰한 바와 같이 "행정심판법 제50조 제1항"은 의무이행재결의 불이행에 한하여 직접처분을 인정하므로, 거부처분 취소재결의 불이행 상태에 처한 甲은 B위원회에 직접처분을 신청할 수 없다.

2. 간접강제의 신청 가능성

(1) 구체적 판단

- A대학총장은 재결의 기속력 및 "행정심판법 제49조 제4항"에 따라 甲의 최종입학점수를 공개하여야 할 실체법상 재처분의무를 지고 있으나 이를 이행하지 않고 있다.

(2) 소송법상 효과

- 甲은 "행정심판법 제50조의2"에 근거하여 B행정심판위원회에 간접강제를 신청할 수 있다. 위원회는 상당한 기간을 정해 이행을 명하고, 미이행 시 지연기간에 따른 배상 결정을 통하여 A대학총장의 점수 공개를 강제할 수 있다.

V. 결론

- B행정심판위원회의 정보공개 거부처분 취소재결이 확정됨으로써 피청구인 A대학총장은 甲의 입학점수를 공개하여야 할 재처분의무를 부담한다. A대학총장이 이를 이행하지 않는 경우, 해당 재결은 거부처분 취소재결이므로 "행정심판법 제50조"의 직접처분 대상에는 해당하지 않아 직접처분을 청구할 수는 없다. 그러나 "행정심판법 제50조의2"에 따른 간접강제 요건은 완벽히 충족하므로, 甲은 B위원회에 간접강제 신청서를 제출하여 지연배상 결정을 유도함으로써 A대학총장으로 하여금 최종입학점수를 공개하도록 하는 실효성 있는 사법적 구제를 도모할 수 있다.